

مقرر الدراسة النصية للفرقة الرابعة  
من كتاب

شرح الإمام جلال الدين المحلي  
على متن

منهاج الطالبين للشيخ محي الدين  
النووي

في فقه مذهب الإمام الشافعي

تعليق:

- ١- أ.د. رمضان عبد الله الصاوي أستاذ الفقه ونائب رئيس الجامعة للوجه البحري .
- ٢ - أ.د. فتحية الحنفي أستاذ الفقه المتفرغ بكلية الدراسات الإسلامية للبنات بالقاهرة.
- ٣ - أ.د. نجوى عبد المحسن شتا أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية للبنات بالإسكندرية.
- ٤- أ.د. جهاد محمود الأشقر أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بتفهننا الأشراف.
- ٥- أم د. حسن عبد الفتاح أستاذ الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون بتفهننا الأشراف.
- ٦- د. عيد أحمد الهادي عثمان مدرس الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة.

## كِتَابُ الْبَغَاةِ (١)

جَمْعُ بَاغٍ (هُم مَخَالِفُو الْإِمَامِ (٢) بِخُرُوجٍ عَلَيْهِ وَتَرْكِ الْإِنْفِيَادِ) لَهُ (أَوْ) مَنْعٌ حَقٌّ تَوَجَّهَ عَلَيْهِمْ) كَالزَّكَاةِ (٣) (بِشَرْطِ شَوْكَةِ لَهُمْ (٤) وَتَأْوِيلِ (٥))

(١) جَمْعُ بَاغٍ، وَالبَغْيُ الظُّلْمُ وَمَجَاوِزَةُ الْحَدِّ، سُمُوا بِذَلِكَ؛ لِظُلْمِهِمْ وَعُدُولِهِمْ عَنِ الْحَقِّ، وَافْتَتَحَهُ فِي الْمَحَرَّرِ بِقَوْلِهِ Y: [وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا]، وَلَيْسَ فِيهَا ذِكْرُ الْخُرُوجِ عَلَى الْإِمَامِ، لَكِنَّهَا تَشْمَلُهُ لِعُمُومِهَا أَوْ تَقْتَضِيهِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا طَلَبَ الْقِتَالَ لِبَغْيِ طَائِفَةٍ عَلَى طَائِفَةٍ، فَلِلْبَغْيِ عَلَى الْإِمَامِ أَوْلَى، وَالْإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَى قِتَالِهِمْ، قَالَ الشَّافِعِيُّ r: أَخَذْتُ السَّيْرَةَ فِي قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ مِنَ النَّبِيِّ p، وَفِي قِتَالِ الْمُزْتَدِينَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ r، وَفِي قِتَالِ الْبَغَاةِ مِنْ عَلِيٍّ r.

(٢) وَلَوْ جَائِزًا وَهُمْ عَادِلُونَ، كَمَا قَالَهُ الْقَفَّالُ، وَحَكَاهُ ابْنُ الْقَشِيرِيِّ عَنْ مُعْظَمِ الْأَصْحَابِ، وَمَا فِي الشَّرْحِ وَالرُّوضَةِ مِنَ التَّقْيِيدِ بِالْإِمَامِ الْعَادِلِ، وَكَذَا هُوَ فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ، مُرَادُهُمْ: إِمَامٌ أَهْلُ الْعَدْلِ فَلَا يُنَافِي ذَلِكَ، وَيَذُلُّ لِذَلِكَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: إِنَّ الْخُرُوجَ عَلَى الْأَئِمَّةِ وَقِتَالَهُمْ حَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ كَانُوا فَسَقَةً ظَالِمِينَ، لَكِنْ نُوزِعَ فِي الْإِجْمَاعِ بِخُرُوجِ الْحُسَيْنِ عَلَى يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، وَمَعَ كُلِّ مِنْهُمَا خَلْقٌ كَثِيرٌ مِنَ السَّلَفِ، وَقَدْ يُقَالُ: إِنَّ مُرَادَهُ الْإِجْمَاعُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَفَرَّقَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ مَنْ تَغَلَّبَ عَلَى الْإِمَامَةِ فَيَجُوزُ الْخُرُوجُ عَلَيْهِ إِذَا جَارَ وَبَغَى، وَبَيْنَ مَنْ عَقِدَتْ لَهُ الْإِمَامَةُ فَلَا يَجُوزُ.

(٣) لِأَنَّ أَبَا بَكْرَ الصِّدِّيقَ r قَاتَلَ مَانِعِي الزَّكَاةِ لِمَنْعِهِمُ الزَّكَاةَ، وَلَمْ يَخْرُجُوا عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا مَنْعُوا الْحَقَّ الْمُتَوَجَّهَ عَلَيْهِمْ.

(٤) أَيُّ: بِكَثْرَةٍ، أَوْ قُوَّةٍ، وَلَوْ بِحِصْنٍ يُمَكِّنُ مَعَهَا مَقَاوِمَةَ الْإِمَامِ، فَيَحْتَاجُ فِي رَدِّهِمْ إِلَى الطَّاعَةِ لِكُلْفَةٍ مِنْ بَذْلِ مَالٍ، وَتَحْصِيلِ رِجَالٍ.

(٥) يَعْتَقِدُونَ بِهِ جَوَازَ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ، أَوْ مَنْعَ الْحَقِّ الْمُتَوَجَّهَ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّ مَنْ خَالَفَ مَنْ غَيْرَ تَأْوِيلٍ كَانَ مُعَانِدًا لِلْحَقِّ، وَيُشْتَرَطُ فِي التَّأْوِيلِ أَنْ يَكُونَ قَاسِدًا لَا يَقْطَعُ بِفَسَادِهِ، بَلْ

لِخُرُوجِهِمْ عَلَى الْإِمَامِ، أَوْ مَنَعِهِمُ الْحَقَّ (وَمُطَاعٌ فِيهِمْ) <sup>(١)</sup> تَحْصُلُ بِهِ قُوَّةٌ  
لِلشُّوْكَةِ، (قِيلَ: وَإِمَامٌ مَنْصُوبٌ) لَهُمْ؛ حَتَّى لَا تَتَعَطَّلَ الْأَحْكَامُ بَيْنَهُمْ،  
وَالْأَصَحُّ: عَدَمُ اشْتِرَاطِهِ وَلَا تَعَطُّلَ لَهَا. (وَلَوْ أَظْهَرَ قَوْمٌ رَأْيَ الْخَوَارِجِ) <sup>(٢)</sup>  
كَتَرِكَ الْجَمَاعَاتِ، وَتَكْفِيرِ ذِي كَبِيرَةٍ، وَلَمْ يُقَاتِلُوا <sup>(٣)</sup> تَرَكُوا <sup>(٤)</sup> فَلَا

يَعْتَقِدُونَ بِهِ جَوَازَ الْخُرُوجِ كَتَاوِيلِ الْخَارِجِينَ مِنْ أَهْلِ الْجَمَلِ وَصَفَيْنِ عَلَى عَلِيٍّ بِأَنَّهُ  
يَعْرِفُ قَتْلَةَ عُمَانَ، وَيَقْدِرُ عَلَيْهِمْ، وَلَا يَقْتَصُّ مِنْهُمْ لِمَوَاطَأَتِهِ إِيَّاهُمْ، وَتَأْوِيلُ بَعْضِ  
مَانِعِي الزَّكَاةِ مِنْ أَبِي بَكْرٍ بِأَنَّهُمْ لَا يَدْفَعُونَ الزَّكَاةَ إِلَّا لِمَنْ صَلَاتُهُ سَكَنَ لَهُمْ، وَهُوَ  
النَّبِيُّ P.

(١) أَي: مُتَّبِعٌ يَحْصُلُ بِهِ قُوَّةٌ لِشُوكَتِهِمْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِمَامًا مَنْصُوبًا فِيهِمْ يَصُدُّونَ عَنْ  
رَأْيِهِ، إِذْ لَا قُوَّةَ لِمَنْ لَا يَجْمَعُ كَلِمَتَهُمْ مُطَاعٌ.

(٢) الْخَوَارِجُ: هُمْ قَوْمٌ مِنَ الْمُبْتَدِعَةِ يُكْفَرُونَ مَنْ ارْتَكَبَ كَبِيرَةً، وَيَطْعَنُونَ بِذَلِكَ فِي  
الْأَئِمَّةِ، لَا يَحْضُرُونَ مَعَهُمُ الْجُمُعَةَ وَالْجَمَاعَاتِ.

(٣) وَهُمْ فِي قَبْضَتِنَا، كَمَا فِي الْمَحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالرُّوْضَةِ.

(٤) فَلَا نَتَعَرَّضُ لَهُمْ، سَوَاءً أَكَانُوا بَيْنَنَا، أَمْ امْتَأَرُوا بِمَوْضِعٍ عَنَّا، لَكِنْ لَمْ يَخْرُجُوا عَنْ  
طَاعَةِ الْإِمَامِ، وَلَمْ يَفْسُقُوا بِذَلِكَ مَا لَمْ يُقَاتِلُوا؛ لِأَنَّهُمْ اعْتَقَادُهُمْ أَنَّ مَنْ أَتَى كَبِيرَةً كَفَرَ،  
وَحَبَطَ عَمَلُهُ، وَخَلَدَ فِي النَّارِ، وَأَنَّ دَارَ الْإِمَامِ صَارَتْ بِظُهُورِ الْكِبَائِرِ فِيهَا دَارُ كُفْرٍ  
وَإِبَاحَةٍ، فَلِذَلِكَ طَعَنُوا فِي الْأَئِمَّةِ، وَلَمْ يُصَلُّوا خَلْفَهُمْ، وَتَجَنَّبُوا الْجُمُعَةَ وَالْجَمَاعَةَ، وَلَوْ  
صَرَّحُوا بِسَبِّ الْإِمَامِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ عَزَرُوا، لَا إِنْ عَرَّضُوا فِي الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ  
عَلِيًّا سَمِعَ رَجُلًا مِنَ الْخَوَارِجِ، يَقُولُ: لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، وَعَرَّضَ بِتَخْطِئَتِهِ فِي  
الْحُكْمِ، فَقَالَ: كَلِمَةٌ حَقٌّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ، لَكُمْ عَلَيْنَا ثَلَاثٌ: لَا تَمْنَعُكُمْ مَسَاجِدُ اللَّهِ أَنْ  
تَذْكُرُوا فِيهَا اسْمَ اللَّهِ، وَلَا تَمْنَعُكُمْ الْفِيءُ مَا دَامَتْ أَيْدِيكُمْ مَعَنَا، وَلَا تَبْذُوكُمْ بِقِتَالٍ، فَجَعَلَ  
حُكْمَهُمْ حُكْمَ أَهْلِ الْعَدْلِ، وَمَحَلُّ عَدَمِ النَّعْضِ لَهُمْ: إِذَا لَمْ تَنْصَرَرْ بِهِمْ، فَإِنْ تَصَرَّرْنَا  
بِهِمْ تَعَرَّضْنَا لَهُمْ حَتَّى يَزُولَ الضَّرَرُ.

يَتَعَرَّضُ لَهُمْ. (وَالَا) أَي: وَإِنْ قَاتَلُوا <sup>(١)</sup> (فَقُطِّعَ طَرِيقُ) أَي: فَحُكِّمَهُمْ حُكْمُهُمْ، كَذَا فِي الرُّوضَةِ كَأَصْلِهَا عَنِ الْبَغَوِيِّ بَعْدَ قَوْلِهِمَا عَنْ الْجُمْهُورِ. وَلَوْ بَعَثَ الْإِمَامُ إِلَيْهِمْ وَالِيًّا فَقَتَلُوهُ فَعَلَيْنِهِم الْقِصَاصُ <sup>(٢)</sup>، وَهَلْ يَتَحَتَّمُ قَتْلُ قَاتِلِهِ كَقَاطِعِ الطَّرِيقِ؛ لِأَنَّهُ شَهْرُ السِّلَاحِ أَمْ لَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ إِخَافَةَ الطَّرِيقِ، وَجِهَانِ، زَادَ الْمُصَنِّفُ أَصْحُهُمَا لَا يَتَحَتَّمُ <sup>(٣)</sup>.

(وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْبُعَاةِ) لِتَأْوِيلِهِمْ <sup>(٤)</sup> (وَقَضَاءُ قَاضِيهِمْ) <sup>(٥)</sup> فِيمَا يُقْبَلُ فِيهِ (قَضَاءُ قَاضِينَا) <sup>(٦)</sup>، إِلَّا أَنْ يَسْتَحِلَّ دِمَاءَنَا، فَلَا يُقْبَلُ قَضَاؤُهُ لِانْتِقَاءِ الْعَدَالَةِ الْمُشْتَرِطَةِ فِي الْقَاضِي، وَكَذَلِكَ الشَّاهِدُ إِذَا كَانَ يَسْتَحِلُّ دِمَاءَنَا لَا نَقْبَلُ شَهَادَتَهُ، وَالْمَالُ كَالدَّمِ فِي ذَلِكَ. (وَيُنْفَذُ) بِالتَّشْدِيدِ (كِتَابُهُ بِالْحُكْمِ) جَوَازًا <sup>(٧)</sup> (وَيُحْكَمُ بِكِتَابِهِ بِسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ فِي الْأَصَحِّ) كَتَنَفِيزِ كِتَابِهِ بِالْحُكْمِ،

(١) أَي: بِأَنْ قَاتَلُونَا، أَوْ لَمْ يَكُونُوا فِي قَبْضَتِنَا.

(٢) أَي: أَقْنَصَ مِنْهُمْ كَغَيْرِهِمْ، لَا أَنَّهُمْ قُطِّعَ طَرِيقُ.

(٣) لِأَنَّهُمْ لَمْ يَقْصِدُوا إِخَافَةَ الطَّرِيقِ.

(٤) لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا بِفَسَقَةٍ؛ لِتَأْوِيلِهِمْ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: "إِلَّا أَنْ يَكُونُوا مِمَّنْ يَشْهَدُونَ لِمُؤَافِقِهِمْ بِتَضَدِّيقِهِ كَالْخَطَّابِيَّةِ، وَهُمْ صِنْفٌ مِنَ الرَّافِضَةِ يَشْهَدُونَ بِالرُّورِ، وَيَقْضُونَ بِهِ لِمُؤَافِقِهِمْ بِتَضَدِّيقِهِمْ، فَلَا نَقْبَلُ شَهَادَتَهُمْ، وَلَا يَنْفَذُ حُكْمُ قَاضِيهِمْ، وَلَا يَخْتَصُّ هَذَا بِالْبُعَاةِ"

(٥) أَي: بَعْدَ اعْتِبَارِ صِفَاتِ الْقَاضِي فِيهِ.

(٦) لِأَنَّ لَهُمْ تَأْوِيلًا يَسُوعُ فِيهِ الْإِجْتِهَادُ.

(٧) فَإِذَا كَتَبَ بِمَا حَكَمَ بِهِ إِلَى قَاضِينَا جَارَ لَهُ قَبُولُهُ وَتَنْفِيزُهُ، وَلَكِنْ يُسَنُّ لَهُ عَدَمُ تَنْفِيزِهِ تَنْفِيزُهُ اسْتِخْفَافًا بِهِمْ.

وَالثَّانِي: لَا، لِمَا فِيهِ مِنْ إِقَامَةِ مَنْصِبِهِ، وَفِي الرُّوضَةِ كَأَصْلِهَا حِكَايَةُ  
الْخِلَافِ قَوْلَيْنِ.

(١) أَقَامُوا حَدًّا، وَأَخَذُوا زَكَاةً، وَجَزِيَةً (٢)، وَخَرَجًا (٣) وَفَرَّقُوا سَهْمَ  
الْمُرْتَزِقَةِ (٤) عَلَى جُنْدِهِمْ صَحَّ) مَا فَعَلُوهُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي اسْتَوْلَوْا عَلَيْهِ (٥)،  
(٥)، فَإِذَا عَادَ إِلَيْنَا لَا يُلْعَى فِعْلُهُمْ (وَفِي الْأَخِيرِ (٦) وَجْهٌ: أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ  
الْمَوْقِعُ؛ لِأَنَّهُ تَمْهِيدٌ لِسَبَبِ الْخُرُوجِ عَلَى الْإِمَامِ.

(وَمَا أَتَّفَقَ بَاغٍ عَلَى عَادِلٍ وَعَكْسُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي قِتَالٍ ضَمِنَ) أَيُّ:  
ضَمِنَ كُلُّ مِنْهُمَا مُتَّفَعٌ مِنْ نَفْسٍ وَمَالٍ (٧)، (وَالْأَيُّ (٨) أَيُّ وَإِنْ كَانَ فِي  
قِتَالٍ بِسَبَبِهِ (فَلَا) ضَمَانَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا (٩)، (وَفِي قَوْلٍ: يَضْمَنُ

---

(١) أي: اسْتَوْلَى الْبُعَاةُ عَلَى بَلَدٍ.

(٢) من أهلها.

(٣) من أرض خراجية.

(٤) من الفيء.

(٥) تَأْسِيًا بِعَلِيٍّؓ، وَلَئِنْ فِي إِعَادَةِ الْمُطَالَبَةِ إِضْرَارًا بِأَهْلِ الْبَلَدِ، أَمَا إِذَا أَقَامَ الْحَدَّ غَيْرُ  
وُلَاتِهِمْ فَإِنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِهِ، وَمَحَلُّ الْإِعْتِدَادِ بِهِ فِي الزَّكَاةِ: إِذَا كَانَتْ غَيْرَ مُعْجَلَةٍ، أَوْ كَانَتْ  
مُعْجَلَةً لَكِنْ اسْتَمَرَّتْ شَوْكَتُهُمْ حَتَّى وَجَبَتْ، فَلَوْ زَالَتْ شَوْكَتُهُمْ قَبْلَ الْوُجُوبِ لَمْ يَقَعْ مَا  
عَجَّلُوهُ مَوْقِعَهُ؛ لِأَنَّ وَقْتَ الْوُجُوبِ لَمْ يَكُونُوا أَهْلًا لِلْأَخْذِ.

(٦) وَهُوَ تَفْرِقَةُ سَهْمِ الْمُرْتَزِقَةِ عَلَى جُنْدِهِمْ.

(٧) جَزِيًّا عَلَى الْأَصْلِ فِي الْإِتْلَافَاتِ.

(٨) بِأَنَّ كَانَ الْإِتْلَافُ فِي قِتَالٍ لِضَرُورَتِهِ.

(٩) اقْتِدَاءً بِالسَّلَفِ؛ لِأَنَّ الْوَقَائِعَ الَّتِي جَرَتْ فِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ ۱۷ كَوُقُوعَةِ الْجَمَلِ  
وَصِفَيْنَ لَمْ يُطَالَبَ بَعْضُهُمْ بِضَمَانِ نَفْسٍ وَلَا مَالٍ، وَتَرْغِيْبًا فِي الطَّاعَةِ لِنَلَّا

الْبَاغِي) مَا أَتْلَفَهُ عَلَى الْعَادِلِ لِأَنَّهُ مُبْطَلٌ وَدُفِعَ بِشُبْهَةِ تَأْوِيلِهِ، <sup>(١)</sup> وَلَوْ كَانَ الْإِتْلَافُ لَا بِسَبَبِ الْقِتَالِ وَجَبَ ضَمَانُهُ قَطْعًا.

(وَالْمُتَأَوَّلُ بِلَا شَوْكَةٍ يَضْمَنُ) مَا أَتْلَفَهُ مِنْ نَفْسٍ وَمَالٍ <sup>(٢)</sup>، وَإِنْ كَانَ فِي قِتَالٍ، (وَعَكْسُهُ <sup>(٣)</sup> كَبَاغٍ) فَلَا يَضْمَنُ مَا أَتْلَفَهُ فِي قِتَالٍ عَلَى الْقَوْلِ الرَّاجِحِ.

### [ضوابط قتال أهل البغي]

(وَلَا يُقَاتِلُ) الْإِمَامُ (الْبَغَاةَ حَتَّى يَبْعَثَ إِلَيْهِمْ أَمِينًا فَطِنًا نَاصِحًا، يَسْأَلُهُمْ مَا يَنْقِمُونَ، فَإِنْ ذَكَرُوا مَظْلَمَةً <sup>(٤)</sup> يَكْسِرُ اللَّامَ (أَوْ شُبْهَةً أَزَالَهَا <sup>(٥)</sup>، فَإِنْ أَصْرُوا) بَعْدَ الْإِزَالَةِ <sup>(٦)</sup> (نَصَحَهُمْ) بِأَنْ يَعِظَهُمْ، وَيَأْمُرُهُمْ بِالْعُودِ إِلَى

---

يَنْفِرُوا عَنْهَا وَيَتِمَادُوا عَلَى مَا هُمْ فِيهِ، وَلِهَذَا سَقَطَتِ النَّبْعَةُ عَنِ الْحَزْبِيِّ إِذَا أَسْلَمَ، وَلَئِنَّا مَأْمُورُونَ بِالْقِتَالِ فَلَا يَضْمَنُ مَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ، وَهُمْ إِنَّمَا أَتْلَفُوا بِتَأْوِيلٍ.

<sup>(١)</sup> لِأَنَّهُمَا فِرْقَتَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مُحِقَّةٌ وَمُبْطِلَةٌ، فَلَا يَسْتَوِيَانِ فِي سُقُوطِ الْغَرَمِ كَقُطَاعِ الطَّرِيقِ؛ لِشُبْهَةِ تَأْوِيلِهَا.

<sup>(٢)</sup> لِأَنَّا لَوْ أَسْقَطْنَا الضَّمَانَ عَنْهُ لَمْ تَعْجَزْ كُلُّ شِرْذِمَةٍ تُرِيدُ إِتْلَافَ نَفْسٍ وَمَالٍ أَنْ تُبْدِيَ تَأْوِيلًا، وَتَفْعَلَ مِنَ الْفَسَادِ مَا تَشَاءُ، وَفِي ذَلِكَ بُطْلَانُ السِّيَاسَاتِ.

<sup>(٣)</sup> وَهُوَ مَنْ لَهُ شَوْكَةٌ بِلَا تَأْوِيلٍ حُكْمُهُ.

<sup>(٤)</sup> اقْتِدَاءً بِعَلِيِّ  $\tau$  فَإِنَّهُ بَعَثَ ابْنَ عَبَّاسٍ  $\tau$  إِلَى أَهْلِ النَّهْرَوَانِ، فَرَجَعَ بَعْضُهُمْ وَأَبَى بَعْضُهُمْ.

<sup>(٥)</sup> لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِقِتَالِهِمْ رَدُّهُمْ إِلَى الطَّاعَةِ، وَدَفْعُ شَرِّهِمْ كَدْفَعِ الصَّائِلِ دُونَ قَتْلِهِمْ لِقَوْلِهِ Y: [فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ] [الحجرات: ٩]، أَي: تَرْجِعْ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ Y وَسُنَّةِ رَسُولِهِ  $\rho$ .

<sup>(٦)</sup> أَوْ لَمْ يَذْكُرُوا شَيْئًا.

الطَّاعَةِ، (ثُمَّ) <sup>(١)</sup> أَي: إِنْ لَمْ يَرْجِعُوا (أَذْنَهُمْ) بِالْمَدِّ، أَي: أَعْلَمَهُمْ (بِالْقِتَالِ) <sup>(٢)</sup>، فَإِنْ اسْتَمْهَلُوا <sup>(٣)</sup> فِيهِ (اجْتَهَدَ) فِي الْإِمْهَالِ وَعَدَمِهِ (وَفَعَلَ مَا رَأَى صَوَابًا) مِنْهُمَا، فَإِنْ ظَهَرَ لَهُ أَنَّ اسْتِمْهَالَهُمْ لِلتَّأْمُلِ فِي إِزَالَةِ الشُّبْهَةِ أَمْلَهُمْ، أَوْ لاسْتِلْحَاقِ مَدَدٍ لَهُمْ لَمْ يُمْلَهُمْ.

(وَلَا يُقَاتِلُ) إِذَا وَقَعَ قِتَالٌ (مُذِيرُهُمْ، وَلَا يَقْتُلُ) (مُتَحَنِّنُهُمْ) مِنْ أَثَنَتِهِ الْجِرَاحَةَ أَوْ ضَعْفَتُهُ (وَأَسِيرُهُمْ، وَلَا يُطْلَقُ) <sup>(٤)</sup> وَإِنْ كَانَ صَبِيًّا وَامْرَأَةً حَتَّى تَنْقُضِيَ الْحَرْبُ، وَيَتَفَرَّقَ جَمْعُهُمْ، إِلَّا أَنْ يُطِيعَ بِاخْتِيَارِهِ) فَيُطْلَقَ قَبْلَ ذَلِكَ، وَهَذَا فِي الرَّجُلِ، وَأَمَّا الصَّبِيُّ وَالْمَرْأَةُ فَيُطْلَقَانِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ، وَذِكْرُ الْمُحَرَّرِ لِهَمَّا بَعْدَ الرَّجُلِ ظَاهِرٌ فِي ذَلِكَ.

(وَيُرَدُّ سِلَاحُهُمْ وَخَيْلُهُمْ إِلَيْهِمْ إِذَا انْقَضَتْ الْحَرْبُ، وَأَمِنَتْ غَائِلَتُهُمْ) <sup>(٥)</sup> بَعُودَهُمْ إِلَى الطَّاعَةِ، أَوْ تَفَرُّقِهِمْ، كَمَا يَرُدُّ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، (وَلَا يَسْتَعْمِلُ) سِلَاحَهُمْ وَخَيْلَهُمْ (فِي قِتَالٍ إِلَّا لِحَرُورَةٍ) بِأَنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدًا مَا يَدْفَعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ إِلَّا سِلَاحَهُمْ، أَوْ مَا يَرْكَبُهُ وَقَدْ وَقَعَتْ هَزِيمَةٌ إِلَّا خَيْلَهُمْ.

(١) إِنْ أَصْرُوا دَعَاهُمْ إِلَى الْمُنَاطَرَةِ، فَإِنْ لَمْ يُجِيبُوا أَوْ أَجَابُوا، وَغَلِبُوا فِي الْمُنَاطَرَةِ وَأَصْرُوا.

(٢) لِأَنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ أَوَّلًا بِالْإِصْلَاحِ ثُمَّ بِالْقِتَالِ، فَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ مَا أَخَّرَهُ اللَّهُ. وَإِنَّمَا يُعْلِمُهُمْ بِالْقِتَالِ إِذَا عَلِمَ أَنَّ فِي عَسْكَرِهِ قُوَّةً وَقُدْرَةً عَلَيْهِمْ، وَإِلَّا أَخَّرَهُ إِلَى أَنْ تُمْكِنَهُ الْقُوَّةُ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّهُ الْإِحْتِيَاظُ فِي ذَلِكَ.

(٣) أَي: طَلَبُوا الْإِمْهَالَ مِنَ الْإِمَامِ.

(٤) أَي: أَسِيرُهُمْ، بَلْ يُحْبَسُ؛ إِذْ بِحَبْسِهِ تَضَعُفُ الْبُعَاةُ.

(٥) أَي: شَرُّهُمْ بِتَفَرُّقِهِمْ، أَوْ رَدِّهِمْ لِلطَّاعَةِ؛ لِزَوَالِ الْمُخْذُورِ حِينَئِذٍ.

(وَلَا يُقَاتِلُونَ بِعَظِيمٍ كَنَارٍ وَمَنْجَنِيْقٍ<sup>(١)</sup>) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالْجِيمِ آلَهُ رَمِي الْحِجَارَةِ (إِلَّا لِحَرُورَةٍ، بَأَنْ قَاتَلُوا بِهِ) فَاحْتِيجَ إِلَى الْمُقَاتَلَةِ بِمِثْلِهِ دَفْعًا، كَمَا أَفْصَحَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، (أَوْ أَحَاطُوا بِنَا) وَاحْتَجْنَا فِي دَفْعِهِمْ إِلَى ذَلِكَ، كَمَا فِي الرُّوضَةِ وَأَصْلِهَا.

(وَلَا يُسْتَعَانُ عَلَيْهِمْ بِكَافِرٍ<sup>(٢)</sup>) لِأَنَّهُ يَحْرُمُ تَسْلِيْطُهُ عَلَى الْمُسْلِمِ، (وَلَا يَمَنْ يَرَى قَتْلَهُمْ مُدْبِرِينَ) كَالْحَنْفِيِّ إِبْقَاءَ عَلَيْهِمْ<sup>(٣)</sup>، (وَلَوْ اسْتَعَانُوا عَلَيْنَا بِأَهْلِ حَرْبٍ وَآمَنُوهُمْ) بِالْمَدِّ، أَي: عَقَدُوا لَهُمْ أَمَانًا<sup>(٤)</sup>، لِيُقَاتِلُوا مَعَهُمْ كَمَا فِي الرُّوضَةِ وَأَصْلِهَا (لَمْ يُنْعَذْ) بِالْمُعْجَمَةِ (أَمَانُهُمْ عَلَيْنَا، وَنَعَذَ عَلَيْهِمْ فِي الْأَصَحِّ)، وَالثَّانِي: الْمَنْعُ؛ لِأَنَّهُ أَمَانٌ عَلَى قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَلَى الثَّانِي:

(١) لِأَنَّ الْمُقْصُودَ مِنْ خَالِهِمْ رُدُّهُمْ إِلَى الطَّاعَةِ، وَقَدْ يَرْجِعُونَ فَلَا يَجِدُونَ لِلنَّجَاةِ سَبِيلًا.  
(٢) ذِمِّيٌّ أَوْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ تَسْلِيْطُهُ عَلَى الْمُسْلِمِ، وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ لِمُسْتَحَقِّ الْقِصَاصِ مِنْ مُسْلِمٍ أَنْ يُوَكِّلَ كَافِرًا فِي اسْتِيفَائِهِ، وَلَا لِلْإِمَامِ أَنْ يَتَّخِذَ جَلَادًا كَافِرًا لِإِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.

(٣) وَيُسْتَنْتَنَى مَا إِذَا دَعَتْ الْحَاجَةُ إِلَى الْإِسْتِعَانَةِ بِهِمْ، قَالَ الشَّيْخَانِ (الرافعي، والنووي): فَيَجُوزُ بِشَرْطَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ حُسْنُ إِقْدَامٍ وَجَرَاءَةٍ. الثَّانِي: أَنْ يُمَكِّنَ دَفْعُهُمْ عَنْهُمْ لَوْ اتَّبَعُوهُمْ بَعْدَ انْهَرَامِهِمْ، زَادَ الْمَاوَرِدِيُّ شَرْطًا ثَالِثًا وَهُوَ: أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَنْتَبِعُوا مُدْبِرًا، وَلَا يَقْتُلُوا جَرِيحًا، وَأَنْ يَثِقَ بِوَفَائِهِمْ بِذَلِكَ.

(٤) لِأَنَّ الْأَمَانَ لِتَرْكِ قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ، فَلَا يَنْعَقِدُ عَلَى شَرْطِ قِتَالِهِمْ، وَحِينَئِذٍ فَلَنَا عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ، وَاسْتَرْقَاقُهُمْ، وَقَتْلُ أَسِيرِهِمْ، وَقَتْلُهُمْ مُدْبِرِينَ، وَتَذْفِيفُ جَرِيحِهِمْ، نَعَمْ لَوْ قَالُوا: ظَنَّنَا أَنَّهُ يَجُوزُ لَنَا إِعَانَتُهُ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، أَوْ أَنَّهُمْ الْمُحِقُّونَ، وَلَنَا إِعَانَةُ الْمُحِقِّ، أَوْ أَنَّهُمْ اسْتَعَانُوا بِنَا عَلَى كُفَارٍ وَأَمَكَّنَ صِدْقُهُمْ بَلَّغَانَهُمُ الْمَأْمَنَ، وَأَجْرَيْنَا عَلَيْهِمْ حُكْمَ الْبُعَاةِ، فَلَا نَسْتَبِيحُهُمْ لِلْأَمَانِ مَعَ غَدْرِهِمْ.



قَالَ الْبَغَوِيُّ: لَهُمْ أَنْ يَكُرُّوا عَلَيْهِمْ بِالْقَتْلِ وَالْإِسْتِرْقَاقِ، وَقَالَ الْإِمَامُ: لَيْسَ لَهُمْ اغْتِيَالُهُمْ، بَلْ يُبَلِّغُونَهُم الْمَأْمَنَ. (وَلَوْ أَعَانَهُمْ أَهْلُ الذِّمَّةِ عَالِمِينَ بِتَحْرِيمِ قِتَالِنَا) مُخْتَارِينَ فِيهِ (انْتَقَضَ عَهْدُهُمْ<sup>(١)</sup>، أَوْ مُكْرَهِينَ فَلَا) يُنْتَقِضُ<sup>(٢)</sup>، (وَكَذَا إِنْ قَالُوا: ظَنَّنَا جَوَازَهُ) أَيُّ: الْقِتَالِ إِعَانَةً، (أَوْ أَنََّّهُمْ مُحِقُّونَ<sup>(٣)</sup>) فَلَا يُنْتَقِضُ (عَلَى الْمَذْهَبِ<sup>(٤)</sup>)، وَفِي قَوْلٍ مِنْ طَرِيقٍ: يُنْتَقِضُ؛ لِفَسَادِ ظَنِّهِمْ، (وَيُقَاتَلُونَ) أَيُّ: مَنْ قُلْنَا لَا يُنْتَقِضُ عَهْدُهُمْ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ (كِبُغَاةٍ)<sup>(٥)</sup> لِانْضِمَامِهِمْ إِلَيْهِمْ.

(١) كَمَا لَوْ انْفَرَدُوا بِالْقِتَالِ فَصَارَ حُكْمُهُمْ حُكْمَ أَهْلِ الْحَرْبِ، فَيُقَاتَلُونَ مُقْبِلِينَ وَمُذْبِرِينَ.

(٢) لِشُبْهَةِ الْإِكْرَاهِ.

(٣) أَيُّ: إِنَّهُ يَجُوزُ لَنَا إِعَانَةُ بَعْضِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى بَعْضٍ، أَوْ ظَنَّنَا أَنَّهُمْ يَسْتَعِينُونَ بِنَا عَلَى قِتَالِ كُفَّارٍ، وَأَمَكَنَ صِدْقُهُمْ، فَلَا يُنْتَقِضُ عَهْدُهُمْ بِالظَّنِّ الْمَذْكُورِ.

(٤) لِمُوَافَقَتِهِمْ طَائِفَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَعَ غُذْرِهِمْ، وَلَا بُدَّ فِي دَعْوَاهُمْ الْجَهْلُ مِنْ إِمْكَانِ صِدْقِهِمْ، كَمَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ وَالْعَزَالِيُّ، وَإِلَّا فَلَا تُقْبَلُ.

(٥) لِأَنَّ الْأَمَانَ حَقٌّ دِمَاءَهُمْ، كَمَا أَنَّ الْإِسْلَامَ حَقٌّ دِمَاءُ الْبُغَاةِ.

## (١) السَّرِقَةُ (٢)

يَفْتَحِ السَّيْنِ وَكَسِرِ الرَّاءِ (يُشْتَرَطُ لَوْجُوبُهُ فِي الْمَسْرُوقِ أُمُورٌ):  
الْأَوَّلُ: (كَوْنُهُ رُبْعَ دِينَارٍ (٣) خَالِصًا (٤) أَوْ قِيَمَتُهُ) أَيْ مُقَوِّمًا

(١) لَوْ قَالَ كِتَابُ السَّرِقَةِ كَمَا فَعَلَ فِي الزَّيْنِ لَكَانَ أَخْصَرَ وَأَعَمَّ ؛ لِتَنَاقُلِهِ أَحْكَامَ نَفْسِ السَّرِقَةِ، وَالْجَوَابُ: أَنَّ الْقَطْعَ هُنَا وَاحِدٌ لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْفَاعِلِ، فَكَانَ هُوَ الْمَقْصُودُ بِالذَّاتِ، وَمَا عَدَاهُ بِطَرِيقِ التَّبَعِ لَهُ، فَذَكَرَ لِذَلِكَ، وَالْحَدُّ نَمَّ مُتَعَدِّدٌ بِتَعَدُّدِ فَاعِلِهِ، وَمُخْتَلِفٌ فِي بَعْضِ أَجْزَائِهِ، فَإِنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاعْتِبَارِ كَوْنِ الزَّانِي بِكَرًا أَوْ مُحَصَّنًا، وَبَيَّنَ كَوْنَهُ حُرًّا أَوْ رَقِيقًا، فَلَمْ يَذْكُرِ الْحَدَّ فِي الزَّيْنِ لِاخْتِلَافِهِ بِاخْتِلَافِ الزَّانَةِ، وَذَكَرَ الْقَطْعَ فِي السَّرِقَةِ لِعَدَمِ اخْتِلَافِهِ، فَحَذَفَ لِنَلَا يُتَوَهَّمُ التَّخْصِيصُ بِبَعْضِهَا، فَهَمَّا صَنِيعَانِ لِكُلِّ مَلَحَظٍ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: ذَكَرَهُ لِصِحَّةِ عَوْدِ ضَمِيرِ وَجُوبِهِ عَلَيْهِ.

وَأَرْكَانُ الْقَطْعِ ثَلَاثَةٌ: مَسْرُوقٌ، وَسَرَقَةٌ، وَسَارِقٌ، وَبَدَأَ الْمَصْنِفُ بِشُرُوطِ الرُّكْنِ الْأَوَّلِ.  
(٢) السَّرِقَةُ لُغَةً: أَخَذُ الْمَالِ خُفْيَةً. وَشَرْعًا: أَخَذُ الْمَالِ خُفْيَةً ظُلْمًا مِنْ جِزْرِ مِثْلِهِ بِشُرُوطٍ. وَالْأَصْلُ فِي الْقَطْعِ بِهَا قَوْلُ اللَّهِ: [وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا]، وَهِيَ مِنْ الْكِبَائِرِ؛ لِأَنَّهَا نَوْعٌ مِنَ الْعَصَبِ، وَشَرَعَ الْقَطْعَ فِيهَا لِحِفْظِ الْمَالِ لِأَنَّهَا أَخَذُ الْخَمْسِ، وَلِذَلِكَ ذَكَرَتْ آخِرَهَا، وَكَانَ الْحَدُّ فِيهَا يَقْطَعُ أَلْتَهَا لِأَنَّهَا الْأَصْلُ، وَلِعَدَمِ تَعْطِيلِ الْمَنْفَعَةِ عَلَيْهِ مِنْ أَصْلِهَا.

(٣) رُبْعَ دِينَارٍ فَأَكْثَرُ، وَلَوْ كَانَ الرُّبْعُ لِمَجَاعَةٍ، وَقَالَ ابْنُ بَنِي الشَّافِعِيِّ: يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ الْقَلِيلِ، وَلَا يُشْتَرَطُ النَّصَابُ لِعُمُومِ الْآيَةِ، وَفِي الصَّحِيحِ: "لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ". وَأُجِيبَ عَنِ الْآيَةِ: بِأَنَّهَا مَخْصُوصَةٌ بِالْحَدِيثِ مُسَلِّمٌ: "لَا تَقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا" وَبَحْدِيثِ الْبُخَارِيِّ: "تُقَطَّعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا أَوْ فِيمَا قِيَمَتُهُ رُبْعُ دِينَارٍ فَصَاعِدًا".

(٤) وَصَفَ رُبْعَ الدِّينَارِ بِكَوْنِهِ خَالِصًا؛ لِأَنَّ الرُّبْعَ الْمَغْشُوشَ لَيْسَ بِرُبْعِ دِينَارٍ حَقِيقَةً، فَإِنْ كَانَ فِي الْمَغْشُوشِ رُبْعٌ خَالِصٌ وَجَبَ الْقَطْعُ.

به <sup>(١)</sup>، وَالْدَيْنَارُ وَزُنْ مِثْقَالٍ <sup>(٢)</sup>، رَوَى مُسْلِمٌ حَدِيثًا: "لَا تُقَطَّعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا" <sup>(٣)</sup>، وَالْبَخَارِيُّ حَدِيثًا: "تُقَطَّعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا أَوْ فِيمَا قِيمَتُهُ رُبْعُ دِينَارٍ فَصَاعِدًا" <sup>(٤)</sup>، وَاحْتَرَزَ بِالْخَالِصِ عَنِ الْمَعْشُوشِ، فَإِنْ بَلَغَ خَالِصُ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ رُبْعُ دِينَارٍ قُطِعَ بِهِ، وَكَذَا خَالِصُ التَّبَرِ <sup>(٥)</sup>، وَيُقَطَّعُ بِرُبْعِ دِينَارٍ قِرَاضَةً <sup>(٦)</sup>، وَالتَّقْوِيمُ يُعْتَبَرُ بِالْمَضْرُوبِ <sup>(٧)</sup> فَلَوْ سَرَقَ شَيْئًا يُسَاوِي رُبْعَ مِثْقَالٍ <sup>(٨)</sup> مِنْ غَيْرِ الْمَضْرُوبِ، كَالسَّبِيكَةِ، وَالْحَلِيِّ، وَلَا يَبْلُغُ رُبْعًا مَضْرُوبًا فَلَا قُطْعَ بِهِ.

(١) نَبَّهَ بِقَوْلِهِ: (أَوْ قِيمَتُهُ) عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ فِي التَّقْوِيمِ هُوَ الذَّهَبُ الْخَالِصُ، حَتَّى لَوْ سَرَقَ دِرَاهِمَ أَوْ غَيْرَهَا قُومَتْ بِهِ، وَيُعْتَبَرُ النَّصَابُ وَقَدْ إِخْرَاجِهِ مِنَ الْجِزْرِ، فَلَوْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَسْقُطَ الْقُطْعُ.

(٢) الدينار: اسم لقطعة من الذهب مضروبة مقدرة بمِثْقَالٍ، وهو نوع من النقد كانوا يتعاملون به، وهو يساوي اليوم: (٤.٢٥) أربعة جرامات وربع الجرام من الذهب، فهذا المقدار، أو ما يساويه من عملة كل بلد، وهو المعيار في استخراج الحقوق الشرعية من زكاة، ودية، وتحديد صداق، ونصاب سرقة، وغير ذلك.

(٣) صحيح مسلم.

(٤) صحيح البخاري.

(٥) التبر: سبائك الذهب أو الفضة قبل ضربها نقودًا.

(٦) القراضة: بضم القاف، ما سقط بالقطع (القرض)، ومنه قراضة الذهب والفضة، أي ما قطع منهما.

(٧) الذهب والفضة إذا صارا نقدًا، والتبر ما كان من الذهب والفضة غير مصوغ، فإن ضربت صارت دنائير ودرهم، فهي عين.

(٨) حكم القطع إذا نقصت قيمة المسروق عن النصاب.

(وَلَوْ سَرَقَ رُبْعًا سَبِيكَةً) أَوْ حُلِيًّا (لَا يُسَاوِي رُبْعًا مَضْرُوبًا فَلَا قَطْعَ) بِهِ (فِي الْأَصَحِّ) <sup>(١)</sup> نَظَرًا إِلَى الْقِيَمَةِ فِيمَا هُوَ كَالسِّلْعَةِ <sup>(٢)</sup>، الثَّانِي: يُنْظَرُ إِلَى الْوَزْنِ. <sup>(٣)</sup> وَلَوْ سَرَقَ خَاتَمًا وَزَنُّهُ دُونَ رُبْعٍ، وَقِيَمَتُهُ بِالصَّنْعَةِ رُبْعٌ، فَلَا قَطْعَ بِهِ عَلَى الصَّحِيحِ <sup>(٤)</sup>؛ نَظَرًا إِلَى الْوَزْنِ، وَالثَّانِي: يُنْظَرُ إِلَى الْقِيَمَةِ. (وَلَوْ سَرَقَ دَنَانِيرَ ظَنَّنَهَا <sup>(٥)</sup> فُلُوسًا لَا تُسَاوِي رُبْعًا قُطْعَ) <sup>(٦)</sup>، وَلَا أَثَرَ لِظَنِّهِ، (وَكَذَا ثَوْبٌ رَثٌّ) <sup>(٧)</sup> بِالْمُثَلَّثَةِ فِيهِمَا (فِي جَنْبِهِ تَمَامُ رُبْعٍ جَهْلُهُ) السَّارِقُ، فَإِنَّهُ يُقَطَّعُ بِهِ (فِي الْأَصَحِّ) <sup>(٨)</sup> وَلَا نَظَرَ إِلَى جَهْلِهِ، وَالثَّانِي: يُنْظَرُ إِلَيْهِ <sup>(٩)</sup> وَلَوْ أَخْرَجَ نِصَابًا مِنْ حِرْزٍ مَرَّتَيْنِ (بِأَنْ تَمَّ بِالثَّانِيَةِ <sup>(١٠)</sup> (فَإِنْ تَخَلَّلَ) بَيْنَهُمَا (عِلْمُ الْمَالِكِ، وَإِعَادَةُ الْحِرْزِ) بِإِضْلَاحِ النَّقْبِ، أَوْ

(١) الأصح: وجه راجح يقابله وجه مرجوح، دليل المرجوح فيه قوة.

(٢) لِأَنَّ الْمَذْكُورَ فِي حَدِيثِ الرَّسُولِ  $p$  لَفْظُ الدِّينَارِ، وَهُوَ اسْمٌ لِلْمَضْرُوبِ.

(٣) فَيُقَطَّعُ، وَلَا حَاجَةَ لِتَقْوِيمِهِ؛ لِئُلُوغِ عَيْنِ الذَّهَبِ قَدْرَ النَّصَابِ، كَمَا فِي الرَّكَاعَةِ.

(٤) الصحيح: وجه راجح يقابله وجه مرجوح، دليل المرجوح فيه ضعف.

(٥) أثر الظن في السرقة، أي: لَا تَبْلُغُ قِيَمَتُهَا.

(٦) لِأَنَّهُ قَصْدُ سَرِقَةٍ عَيْنِهَا، وَهِيَ تُسَاوِي رُبْعًا، وَلَوْجُودِ الْإِسْمِ، وَلَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيْنِ خَطْوُهُ.

(٧) أي: بِالْيَا، مُتَّسِحًا، مُمَرَّقًا.

(٨) لِأَنَّهُ أَخْرَجَ نِصَابًا مِنْ حِرْزٍ عَلَى قَصْدِ السَّرِقَةِ، وَالْجَهْلُ بِجَنْسِ الْمَسْرُوقِ لَا يُؤْتَرُ كَالْجَهْلُ بِصِفَتِهِ.

(٩) نَظَرًا إِلَى الْجَهْلِ.

(١٠) بِأَنْ أَخْرَجَ مَرَّةً بَعْضَهُ وَمَرَّةً بَاقِيَهُ.

إِغْلَاقِ الْبَابِ مَثَلًا (فَالْإِخْرَاجُ الثَّانِي سَرِقَةً أُخْرَى) فَلَا قَطْعَ فِي ذَلِكَ، <sup>(١)</sup> وَفِي أَصْلِ الرُّوْضَةِ وَإِعَادَتِهِ الْحِرْزَ، (وَالْأَلَا) أَيُّ: وَإِنْ لَمْ يَتَخَلَّلْ عِلْمُ الْمَالِكِ، أَوْ تَخَلَّلَ وَلَمْ يُعَذِّدِ الْحِرْزَ (قُطِعَ فِي الْأَصَحِّ)؛ إِبْقَاءُ لِلْحِرْزِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ <sup>(٢)</sup>، وَالثَّانِي: <sup>(٣)</sup> مَا يُبْقِيهِ، وَرَأَى الْإِمَامُ <sup>(٤)</sup>، وَالْغَزَالِيُّ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ الْقَطْعَ بَعْدَ الْقَطْعِ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ مُضَيِّعٌ، وَأَسْقَطَ ذَلِكَ مِنَ الرُّوْضَةِ، وَفِي وَجْهِ: إِنْ اشْتَهَرَ خَرَابُ الْحِرْزِ بَيْنَ الْمَرَّتَيْنِ لَمْ يُقَطَّعْ، وَالْأَلَا قُطِعَ، وَفِي رَابِعٍ: إِنْ كَانَتْ الثَّانِيَةُ فِي لَيْلَةٍ الْأُولَى قُطِعَ، أَوْ فِي لَيْلَةٍ أُخْرَى فَلَا.

(وَلَوْ نَقَبَ وَعَاءَ حِنْطَةٍ <sup>(٥)</sup> وَنَحَوَهَا <sup>(٦)</sup> فَانْصَبَ نِصَابٌ) <sup>(٧)</sup> أَيُّ مُقَوِّمٌ بِهِ، بِهِ، وَهُوَ رُبْعٌ مِثْقَالٍ كَمَا تَقَدَّمَ (قُطِعَ) بِذَلِكَ (فِي الْأَصَحِّ)؛ لِهَتْكَهِ الْحِرْزُ الْخَارِجَ بِهِ نِصَابٌ، وَالثَّانِي: يُنْظَرُ إِلَى عَدَمِ إِخْرَاجِهِ <sup>(٨)</sup>.

(١) لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مُتَفَصِّلَةٌ عَنِ الْأُخْرَى، وَلَمْ تَبْلُغْ نِصَابًا.

(٢) إِبْقَاءُ لِلْحِرْزِ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَخِيذِ؛ لِأَنَّهُ أَخْرَجَ نِصَابًا كَامِلًا مِنْ حِرْزٍ مِثْلِهِ، فَأَشْبَهَ مَا إِذَا أَخْرَجَهُ دَفْعَةً وَاحِدَةً؛ لِأَنَّ فِعْلَ الشَّخْصِ يَنْبَنِي عَلَى فِعْلِهِ.

(٣) لَا قَطْعَ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَ النِّصَابَ مِنْ حِرْزٍ مَهْشُوكٍ.

(٤) الْإِمَامُ: الْمُرَادُ بِهِ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ أَبُو الْمَعَالِي الْجَوِينِي.

(٥) الْحِنْطَةُ: الْقَمْحُ وَالْبُرُّ، وَهُوَ جَنْسٌ مِنَ النَّبَاتَاتِ ذَوَاتِ الْحَبِّ تُزْرَعُ، وَهِيَ مِنْ فَصِيلَةِ فَصِيلَةِ النَّجِيلِيَّاتِ وَتَشْتَمِلُ عَلَى أَهَمِّ الْأَنْوَاعِ النَّبَاتِيَّةِ الْغَذَائِيَّةِ.

(٦) كَوْعَاءُ زَيْتٍ.

(٧) أَيُّ: شَيْءٌ مُقَوِّمٌ بِرُبْعٍ دِينَارٍ.

(٨) أَيُّ: لَا قَطْعَ؛ لِأَنَّهُ خَرَجَ بِسَبَبِهِ، وَالسَّبَبُ ضَعِيفٌ لَا يَقْطَعُ بِهِ.

(وَلَوْ اشْتَرَكَا <sup>(١)</sup> فِي إِخْرَاجِ نِصَابَيْنِ) مِنْ حِرْزٍ (قُطِعَا <sup>(٢)</sup>)، وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ الْمُخْرَجُ أَقَلَّ مِنْ نِصَابَيْنِ (فَلَا) يُقْطَعُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا؛ تَوْزِيْعًا لِلْمَسْرُوقِ عَلَيْهِمَا بِالسَّوِيَّةِ فِي الشَّقَيْنِ.

[حكم سرقة المال غير المحترم]

(وَلَوْ سَرَقَ حَمْرًا، وَخِنْزِيرًا، وَكَلْبًا، وَجِلْدَ مَيْتَةٍ بِلَا دَبْغٍ فَلَا قُطْعَ) بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ، وَسَوَاءٌ سَرَقَهُ مُسْلِمٌ أَمْ ذِمِّيٌّ. (فَإِنْ بَلَغَ إِثْمُ الْخَمْرِ نِصَابًا قُطِعَ) بِهِ (عَلَى الصَّحِيحِ)؛ نَظَرًا إِلَى أَخْذِهِ مِنْ حِرْزِهِ <sup>(٣)</sup>، وَالثَّانِي: نَظَرًا إِلَى أَنَّ مَا فِيهِ مُسْتَحَقُّ الْإِرَاقَةِ، فَجَعَلَهُ شُبْهَةً فِي دَفْعِ الْقُطْعِ. (وَلَا قُطْعَ فِي) سَرِقَةِ <sup>(٤)</sup> (طُنْبُورٍ <sup>(٥)</sup> وَنَحْوِهِ <sup>(٦)</sup>)؛ لِأَنَّهُ مِنَ الْمَلَاهِي <sup>(٧)</sup>، كَالْخَمْرِ (وَقِيلَ: إِنْ بَلَغَ مَكْسَرُهُ نِصَابًا قُطِعَ <sup>(٨)</sup>)، قُلْتُ: الثَّانِي أَصَحُّ) وَفِي الرُّوضَةِ الرُّوضَةِ كَأَصْلِهَا عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ، (وَاللَّهُ أَعْلَمُ) وَاخْتَارَ الْأَوَّلَ الْإِمَامُ.

(الثَّانِي) مِنَ الشُّرُوطِ (كَوْنُهُ) أَيْ الْمَسْرُوقِ (مِلْكًا لِعَیْرِهِ) أَيْ السَّارِقِ، فَلَا قُطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مَالَ نَفْسِهِ مِنْ يَدِ غَيْرِهِ، كَالْمُرْتَهَنِ وَالْمُسْتَأْجِرِ. (فَلَوْ

---

(١) حكم الاشتراك في السرقة أي: سارقان مكلّفان.

(٢) لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا سَرَقَ نِصَابًا.

(٣) لِأَنَّهُ سَرَقَ نِصَابًا مِنْ حِرْزٍ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ، كَمَا إِذَا سَرَقَ إِثْمًا فِيهِ بَوْلٌ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ يُقْطَعُ بِاتِّفَاقٍ، كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرِدِيُّ وَغَيْرُهُ.

(٤) حكم سرقة آلات الملاهي.

(٥) الطُنْبُورُ: آلة من آلات اللعب واللَّهْوِ والطَّرَبِ، ذَاتُ عُنُقٍ وَأُوتَارٍ.

(٦) كَمِرْمَارٍ، وَصَنَمٍ، وَصَلِيبٍ.

(٧) وَلِأَنَّ التَّوَصُّلَ إِلَى إِزَالَةِ الْمَعْصِيَةِ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ، فَصَارَ شُبْهَةً كَارِاقَةِ الْخَمْرِ.

(٨) لِأَنَّهُ سَرَقَ نِصَابًا مِنْ حِرْزِهِ.

مَلَكُهُ <sup>(١)</sup> بِإِثْرٍ بِالْمُتَلَثَّةِ (وَعِيره) كَشِرَاءٍ (قَبْلَ إِخْرَاجِهِ مِنَ الْحِرْزِ، أَوْ نَقْصٍ فِيهِ عَنْ نِصَابٍ بِأَكْلِ وَغِيره) كَاِحْزَاقٍ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ (لَمْ يُقْطَعْ) بِالْمُخْرَجِ الْمَذْكُورِ؛ لِمَلِكِهِ، أَوْ نَقْصِهِ. <sup>(٢)</sup> (وَكَذَا <sup>(٣)</sup> إِنْ ادَّعَى) السَّارِقُ (مَلَكُهُ) أَيُّ: الْمَسْرُوقِ لَمْ يُقْطَعْ (عَلَى النَّصِّ <sup>(٤)</sup>) لِأَنَّ مَا ادَّعَاهُ مُحْتَمَلٌ، فَيَكُونُ شُبْهَةً فِي دَفْعِ الْقَطْعِ، وَفِي وَجْهِهِ، أَوْ قَوْلٍ مُخَرَّجٍ: <sup>(٥)</sup> يُقْطَعُ <sup>(٦)</sup>، وَحَمْلُ النَّصِّ عَلَى إِقَامَتِهِ بَيِّنَةٌ بِمَا ادَّعَاهُ.

(وَلَوْ سَرَقًا <sup>(٧)</sup> وَادَّعَاهُ) أَيُّ: الْمَسْرُوقِ (أَحَدُهُمَا لَهُ، أَوْ لَهُمَا، فَكَذَّبَهُ الْآخَرُ، لَمْ يُقْطَعْ الْمُدَّعِي) لِمَا تَقَدَّمَ (وَقُطِعَ الْآخَرُ فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّهُ مُقَرَّرٌ

(١) حكم القطع إذا ملك السارق ما سرق.

(٢) أَمَا فِي الْأُولَى: فَلِأَنَّهُ مَا أَخْرَجَ إِلَّا مَلَكُهُ، وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ: فَلِأَنَّهُ لَمْ يُخْرَجْ مِنَ الْحِرْزِ نِصَابًا.

(٣) لو ادعى السارق ملكية ما سرقه فلا قطع في هذه الحالة.

(٤) النص: يستخدمه علماء الشافعية في كتبهم ويراد به كلام الشافعي (رحمه الله)، وقد سموا ما قاله نصًا لأنه مرفوع القدر؛ لتتصيص الشافعي (رحمه الله) عليه، أو لأنه مرفوع إليه.

(٥) المراد بمصطلح التخريج: هو إذا لم يكن للشافعي (رحمه الله) نصٌّ في مسألة بعينها، فيبحث الأصحاب عن مسألة متشابهة لها، نص على حكمها الشافعي (رحمه الله) نفسه، فينقلون هذا الحكم المنصوص إلى المسألة غير المنصوص عليها، وهذا يشبه القياس بالنسبة إلى نصوص الشارع نفسه، وقد يخرجون حكم المسألة من أصول الشافعي (رحمه الله) وقواعد مذهبه، لا من الفروع المنصوص عليها.

(٦) لِيَأْخُذَ النَّاسُ ذَلِكَ ذَرْيَةً لِدَفْعِ الْحَدِّ.

(٧) أَيُّ: اثْنَانِ مَا لَا نِصَابَيْنِ فَأَكْثَرُ.

(١)، وَالثَّانِي: لَا يُقْطَعُ الْمَكْذَبُ؛ لِدَعْوَى رَفِيقِهِ الْمَلِكَ لَهُ، كَمَا لَوْ قَالَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ: إِنَّهُ مَلِكُهُ يَسْقُطُ الْقَطْعُ.

(وَأِنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزِ شَرِيكِهِ مُشْتَرَكًا) (٢) بَيْنَهُمَا (فَلَا قَطْعَ) عَلَيْهِ (فِي الْأَظْهَرِ) (٣)، وَإِنْ قَلَّ نَصِيبُهُ مِنْهُ؛ لِأَنَّ لَهُ فِي كُلِّ جُزْءٍ حَقًّا، وَذَلِكَ شُبْهَةٌ، وَالثَّانِي: قَالَ لَا حَقَّ لَهُ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ، فَإِذَا سَرَقَ نِصْفَ دِينَارٍ مِنَ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ كَانَ سَارِقًا لِنِصَابٍ مِنْ مَالِ شَرِيكِهِ، فَيُقْطَعُ بِهِ عَلَى الثَّانِي. (الثَّالِثُ) (٤) مِنَ الشُّرُوطِ: (عَدَمُ شُبْهَتِهِ فِيهِ، فَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ مَالٍ أَصْلٍ وَفَرْعٍ) لِلْسَّارِقِ؛ لِمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْإِتِّحَادِ (و) مَالٍ (سَيِّدٍ) لِلْسَّارِقِ؛ لِشُبْهَةِ اسْتِحْقَاقِ لِلنَّفَقَةِ عَلَيْهِ.

[حكم سرقة أحد الزوجين مال الآخر]

(وَالْأَظْهَرُ: قَطْعُ أَحَدِ زَوْجَيْنِ بِالْآخِرِ) أَيِ بِسَرِقَةِ مَالِهِ فِيمَا هُوَ مُحَرَّرٌ عَنْهُ؛ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ (٥)، وَالثَّانِي: الْمَنْعُ؛ لِشُبْهَةِ، فَإِنَّهَا تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ عَلَيْهِ، وَهُوَ يَمْلِكُ الْحَجَرَ عَلَيْهَا.

(وَمَنْ سَرَقَ مَالَ بَيْتِ الْمَالِ إِنْ فُرِزَ) بِالْفَاءِ وَالزَّايِ آخِرُهُ (لِطَائِفَةٍ لَيْسَ هُوَ مِنْهُمْ قُطِعَ)؛ إِذْ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِي ذَلِكَ، (وَالْأَيُّ) أَيِ وَإِنْ لَمْ يُفَرَزْ لِطَائِفَةٍ

---

(١) أَيُّ: أَنَّهُ أَقَرَّ بِسَرِقَةِ نِصَابٍ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ.

(٢) حُكْمُ إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ مِنْ حِرْزِ شَرِيكِهِ شَيْئًا مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا.

(٣) الْأَظْهَرُ: هُوَ قَوْلُ رَاجِحٍ، يَقَابِلُهُ قَوْلُ مَرْجُوحٍ، دَلِيلُ الْمَرْجُوحِ فِيهِ قُوَّةٌ.

(٤) الشَّرْطُ الثَّلَاثُ مِنْ شُرُوطِ الْمَسْرُوقِ: عَدَمُ وَجُودِ شُبْهَةِ مَلِكٍ فِي الْمَالِ الْمَسْرُوقِ.

(٥) وَلِأَنَّ النِّكَاحَ عُقْدَ عَلَى مَنَفْعَةٍ فَلَا يُؤَثِّرُ فِي دَرَجَةِ الْحَدِّ، كَالْإِجَارَةِ لَا يَسْقُطُ بِهَا الْحَدُّ عَنْ الْأَجِيرِ أَوْ الْمُسْتَأْجِرِ إِذَا سَرَقَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ.



(فَالْأَصَحُّ: أَنَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ حَقٌّ فِي الْمَسْرُوقِ كَمَالِ مَصَالِحٍ، وَكَصَدَقَةٍ، وَهُوَ فَقِيرٌ فَلَا يُقَطَّعُ؛ لِلشُّبْهَةِ، (وَالَّا) أَيُّ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ حَقٌّ (قُطِّعَ)؛ لِانْتِفَاءِ الشُّبْهَةِ.

(وَالْمَذْهَبُ <sup>(١)</sup>) قَطَّعَهُ بِبَابِ مَسْجِدٍ وَجَدَّعَهُ بِإِعْجَامِ الذَّالِ (لَا حُصْرَ، وَقَنَادِيلَ تُسْرَجُ <sup>(٢)</sup>) فِيهِ؛ لِأَنَّ لِلْمُسْلِمِ الْإِنْتِفَاعَ بِهَا بِالْفُرْشِ وَالِاسْتِصَاةَ، بِخِلَافِ بَابِهِ، وَجَدَّعَهُ فِي سَفْفٍ مَثَلًا، فَإِنَّهُمَا لِتَحْصِينِهِ وَعِمَارَتِهِ، وَرَأَى الْإِمَامُ تَخْرِيجَ وَجْهِ فِيهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ أَجْزَاءِ الْمَسْجِدِ وَالْمَسْجِدُ مُشْتَرَكٌ، وَذَكَرَ فِي الْحُصْرِ وَالْقَنَادِيلِ وَجْهَيْنِ، وَثَالِثًا فِي الْقَنَادِيلِ الْفَرْقُ بَيْنَ مَا يُقْصَدُ لِلِاسْتِصَاةِ وَمَا يُقْصَدُ لِلزَّيْنَةِ، أَيُّ: فَيُقَطَّعُ فِي الثَّانِي كَمَا يُقَطَّعُ فِيهِ عَلَى الطَّرِيقَةِ الْأُولَى الْجَازِمَةُ الْمُقَابِلَ لَهَا مَا رَأَى الْإِمَامُ تَخْرِيجَهُ، وَمَا ذَكَرَهُ مِنَ الْخِلَافِ، وَالذِّمِّيُّ يُقَطَّعُ فِي الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ بِلَا خِلَافٍ. (وَالْأَصَحُّ قَطَّعَهُ بِمَوْفُوفٍ سَرَقَهُ)، لِأَنَّهُ مَالٌ مُحَرَّرٌ <sup>(٣)</sup> (وَأُمُّ وَلَدٍ سَرَقَهَا نَائِمَةً، أَوْ مَجْنُونَةً)؛ لِأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ مَضْمُونَةٌ بِالْقِيَمَةِ، وَالثَّانِي: قَالَ: الْمَلِكُ فِيهَا ضَعِيفٌ، وَكَذَا فِي الْمَوْفُوفِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَلِكَ فِيهِ لِلْوَاقِفِ، أَوْ لِلْمَوْفُوفِ عَلَيْهِ، وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْمَلِكَ فِيهِ لِلَّهِ Y فَهُوَ كَالْمُبَاحَاتِ.

(١) المذهب هو: بيان المعتمد من أحد القولين، أو الوجهين المحكيين.

(٢) هل يجب القطع على من سرق من المسجد الحصر والقناديل التي تسرج.

(٣) سِوَاءَ أَقْلُنَا: الْمَلِكُ فِيهِ لِلَّهِ Y، أَمْ لِلْمَوْفُوفِ عَلَيْهِ، أَوْ لِلْوَاقِفِ.

(الرَّابِعُ) مِنَ الشُّرُوطِ: (كَوْنُهُ مُحَرَّرًا <sup>(١)</sup>) بِمِلَاحَظَةٍ، أَوْ حَصَانَةٍ مَوْضِعِهِ، فَإِنْ كَانَ بِصَحْرَاءَ، أَوْ مَسْجِدٍ أَوْ شَارِعٍ، وَكُلُّ مِنْهَا لَا حَصَانَةَ لَهُ (أَشْتَرِطَ) فِي كَوْنِهِ مُحَرَّرًا (دَوَامُ لِحَاطٍ) بِكُسْرِ اللَّامِ لَهُ، (وَإِنْ كَانَ بِحِصْنٍ) كَدَارٍ، وَحَانُوتٍ (كَفَى لِحَاطُ مُعْتَادٍ)، وَلَمْ يُشْتَرِطْ دَوَامُهُ. وَمِنْ الْحِصْنِ حِرْزٌ لِمَالٍ دُونَ مَالٍ، كَمَا فِي قَوْلِهِ: (وَإِضْطَبَلُ) بِكُسْرِ الهمزة (حِرْزٌ دَوَابٌّ) أَيُّ: (وَإِنْ كَانَتْ نَفِيسَةً (لَا آنِيَّةً وَثِيَابٍ) (وَإِنْ كَانَتْ حَسِيسَةً، (وَعَرَصَةً <sup>(٢)</sup>) دَارٍ وَصَفَتْهَا <sup>(٣)</sup>) حِرْزٌ آنِيَّةً، وَثِيَابٍ بِذَلَّةٍ <sup>(٤)</sup>) (بِالْمُعْجَمَةِ (لَا حُلِيِّ وَنَقْدٍ) وَثِيَابٍ نَفِيسَةٍ. <sup>(٥)</sup>

(وَلَوْ نَامَ بِصَحْرَاءَ، أَوْ مَسْجِدٍ) أَوْ شَارِعٍ (عَلَى ثَوْبٍ، أَوْ تَوَسَّدَ مَتَاعًا فَمُحَرَّرٌ، فَلَوْ انْقَلَبَ <sup>(٦)</sup>) فَزَالَ عَنْهُ <sup>(٧)</sup>) فَلَا) أَيُّ: فَلَيْسَ حِينَئِذٍ مُحَرَّرًا.

---

(١) الحرز في السرقة هو: ما نصب عادة لحفظ أموال الناس، فيما يعسر أخذها، بحيث لا يعد صاحب المال مضيقاً له بوضعه فيه.

ولم يحدد الشرع الحرز، والضابط فيه: هو العرف والعادة، فكل ما كان حرزاً في العرف والعادة كان حرزاً في الشرع. وَلَا شَكَّ أَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَمْوَالِ وَالْأَحْوَالِ وَالْأَوْقَاتِ، فَقَدْ يَكُونُ الشَّيْءُ حِرْزًا فِي وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ، بِحَسَبِ صَلَاحِ أَحْوَالِ النَّاسِ وَفَسَادِهَا، وَقُوَّةِ السُّلْطَانِ وَضَعْفِهِ، وَضَبْطِ الْعَزَالِيِّ: بِمَا لَا يُعَدُّ صَاحِبُهُ مُضَيِّعًا. (٢) أَيُّ: صَحْنُ.

(٣) صَقَّةُ الْبَيْتِ: مَقْعِدٌ بِالْقَرَبِ مِنْهُ مُظَلَّلٌ.

(٤) الْبِذْلَةُ مِنَ الثِّيَابِ: مَا يُلْبَسُ فِي الْمِهْنَةِ وَالْعَمَلِ وَلَا يُصَانُ، وَالْجَمْعُ: بِذَلٌّ.

(٥) أَمَّا النَّفِيسَةُ: فَحِرْزُهَا الْبُيُوتُ، وَالْخَانَاتُ وَنَحْوُهَا، كَالْأَسْوَاقِ الْمُعَيَّنَةِ.

(٦) أَيُّ: فِي نَوْمِهِ.

(٧) أَيُّ: الثَّوْبِ.

(وَتُوبٍ وَمَتَاعٍ وَضَعَهُ بِقُرْبِهِ بِصَحْرَاءَ) أَوْ مَسْجِدٍ (إِنْ لَاحَظَهُ <sup>(١)</sup>) كَمَا تَقَدَّمَ (مُحَرَّرٌ <sup>(٢)</sup>)، وَإِلَّا فَلَا) وَلَوْ كَثُرَ الطَّارِقُونَ مَعَ اللَّحَاطِ خَرَجَ بِرَحْمَتِهِمْ عَنْ كَوْنِهِ مُحَرَّرًا فِي الْأَصَحِّ.

(وَشَرَطُ الْمُلَاحِظِ <sup>(٣)</sup>) قُدْرَتُهُ عَلَى مَنَعِ سَارِقٍ بِقُوَّةٍ، أَوْ اسْتِعَاثَةٍ (فَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا لَا يُبَالِي بِهِ السَّارِقُ، وَالْمَوْضِعُ بَعِيدٌ عَنِ الْعَوْتِ فَلَيْسَ بِحِرْزٍ. (وَدَارٌ مُنْفَصِلَةٌ عَنِ الْعِمَارَةِ <sup>(٤)</sup>) إِنْ كَانَ بِهَا قَوِيٌّ يَقْطُنُ حِرْزٌ مَعَ فَتْحِ الْبَابِ وَإِغْلَاقِهِ، وَإِلَّا) أَيُّ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهَا أَحَدٌ، أَوْ كَانَ بِهَا ضَعِيفٌ وَهِيَ بَعِيدَةٌ عَنِ الْعَوْتِ كَمَا تَقَدَّمَ، أَوْ قَوِيٌّ نَائِمٌ (فَلَا) أَيُّ: فَلَيْسَتْ حِرْزًا مَعَ فَتْحِ الْبَابِ وَإِغْلَاقِهِ، وَفِي وَجْهِ: أَنَّهَا فِي إِغْلَاقِهِ مَعَ النَّوْمِ حِرْزٌ، قَالَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَهُوَ الْأَقْرَبُ، وَفِي الرُّوضَةِ وَهُوَ أَقْوَى، وَجَزَمَ الرَّافِعِيُّ فِي الْمُحَرَّرِ بِمُقَابِلِهِ انْتَهَى، وَلَا تَرْجِيحَ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ.

---

(١) أي: بنظره، وَيُشْتَرَطُ مَعَ الْمُلَاحَظَةِ أَمْرَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ لَا يَكُونَ فِي الْمَوْضِعِ اِزْدِحَامٌ لِلطَّارِقِينَ، نَعَمْ إِنْ كَثُرَ الْمُلَاحِظُونَ عَادَلَ كَثَرَةُ الطَّارِقِينَ كَمَا نَقَلَاهُ عَنِ الْإِمَامِ وَأَقْرَأَهُ.

الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمُلَاحِظُ فِي مَوْضِعٍ بَحِيثٌ يَرَاهُ السَّارِقُ حَتَّى يَمْتَنِعَ مِنَ السَّرِقَةِ إِلَّا بَتَعْفُلِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَرَاهُ فَلَا قَطْعَ، إِذْ لَا حِرْزَ يَظْهَرُ لِلْسَّارِقِ حَتَّى يَمْتَنِعَ مِنَ السَّرِقَةِ.

(٢) لقضاء العرف بذلك.

(٣) شرط الملاحظ الذي يثبت به الحرز.

(٤) ضابط حرز الدار البعيدة عن العمران.

(وَمُتَّصِلَةً) <sup>(١)</sup> بِالْعِمَارَةِ أَيِ بِدُورِ أَهْلِهَا (حِرْزٌ مَعَ إِغْلَاقِهِ) أَيِ: الْبَابِ، (وَحَافِظٌ وَلَوْ) هُوَ (نَائِمٌ) لَيْلًا وَنَهَارًا (وَمَعَ فَتْحِهِ وَتَوَمُّهِ غَيْرِ حِرْزٍ لَيْلًا، وَكَذَا نَهَارًا فِي الْأَصَحِّ) وَالثَّانِي: هِيَ حِرْزٌ فِي زَمَنِ الْأَمْنِ؛ اعْتِمَادًا عَلَى نَظَرِ الْجِيرَانِ وَمُرَاقَبَتِهِمْ.

(وَكَذَا يَقْطُنُ تَغْلَهُ سَارِقٌ) فَإِنَّهَا فِي ذَلِكَ غَيْرُ حِرْزٍ (فِي الْأَصَحِّ)؛ لِنَقْصِيرِهِ فِي الْمُرَاقَبَةِ مَعَ فَتْحِ الْبَابِ، وَالثَّانِي: <sup>(٢)</sup> يَنْفِي التَّقْصِيرَ عَنْهُ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ دَوَامِ الْمُرَاقَبَةِ، وَلَوْ بَالِغٍ فِيهَا فَانْتَهَزَ السَّارِقُ فُرْصَتَهُ قُطِعَ بِهَا خِلَافٌ.

(فَإِنْ خَلَتْ) <sup>(٣)</sup> أَيِ: الدَّارُ الْمُتَّصِلَةُ مِنْ حَافِظٍ فِيهَا (فَالْمَذْهَبُ: أَنَّهَا حِرْزٌ نَهَارًا زَمَنِ أَمْنٍ وَإِغْلَاقِهِ) أَيِ: الْبَابِ (فَإِنْ فَقَدَ شَرْطُ) مِمَّا ذُكِرَ، بِأَنْ كَانَ الْبَابُ مَفْتُوحًا، أَوْ الزَّمَنُ زَمَنَ خَوْفٍ، أَوْ الْوَقْتُ لَيْلًا (فَلَا) أَيِ: فَلَيْسَتْ حِرْزًا، وَعَبَّرَ فِي الرُّوْضَةِ بِالْمَذْهَبِ أَيْضًا، وَفِي الشَّرْحِ وَالْمَحَرَّرِ بِالظَّاهِرِ، وَلَمْ يُذَكَّرْ لَهُ مُقَابِلٌ.

(وَخِيْمَةٌ بِصَحْرَاءَ) <sup>(٤)</sup> إِنْ لَمْ تُشَدَّ أَطْنَابُهَا <sup>(٥)</sup> وَتُرْخَى أَذْيَالُهَا (بِالْمُعْجَمَةِ) (فَهِيَ وَمَا فِيهَا كَمَتَاعِ بِصَحْرَاءَ) فَيُشْتَرَطُ فِي كَوْنِ ذَلِكَ مُحَرَّرًا دَوَامٌ لِحَافِظِهِ، (وَالْأَيُّ) بِأَنْ شُدَّتْ أَطْنَابُهَا وَأُرْخِيَتْ أَذْيَالُهَا (فَحِرْزٌ بِشَرْطِ حَافِظٍ

(١) ضابط حِرْز الدار المتصلة بالعمارة.

(٢) أنها حِرْز؛ لعسر المراقبة دائمًا.

(٣) حكم خلو الدار المتصلة من حافظ لها.

(٤) ضابط حِرْز الخيمة التي في الصحراء.

(٥) شُدَّ أَطْنَابُ الْخِيْمَةِ: الْجِبَالُ الَّتِي تُشَدُّهَا.

قَوِيَّ فِيهَا، وَلَوْ) هُوَ (نَائِمٌ)، وَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: أَوْ نَامَ بِقُرْبِهَا، وَقَوْلُهُ:  
وَتُرْخَى بِالرَّفْعِ مِنْ عَطْفِ جُمْلَةٍ عَلَى جُمْلَةٍ فِي حَيِّزِ النَّفْيِ، أَيْ إِنْ انْتَقَى  
الشَّدُّ وَالْإِزْخَاءُ، وَلَوْ صَرَّحَ بِالنَّافِي فِي الْمَعْطُوفِ كَالْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ كَانَ  
وَاضِحًا.

(وَمَاشِيَةً <sup>(١)</sup> بِأَبْنِيَّةٍ مُغْلَقَةٍ) أَبْوَابُهَا (مُتَّصِلَةٌ بِالْعِمَارَةِ مُحَرَّرَةٌ بِلَا حَافِظٍ،  
وَبِزِيَّةٍ يُشْتَرَطُ) فِي إِحْرَازِهَا (حَافِظٌ وَلَوْ) هُوَ (نَائِمٌ)، وَلَوْ كَانَتْ الْأَبْوَابُ  
مَفْتُوحَةً أُشْتَرِطَ حَافِظٌ مُسْتَتِيقٌ.

(وَأَيْلٌ بِصَحْرَاءَ) <sup>(٢)</sup> تَرَعَى مَثَلًا (مُحَرَّرَةٌ بِحَافِظٍ يَرَاهَا) فَإِنْ لَمْ يَرِ بَعْضُهَا؛  
لِكَوْنِهِ فِي وَهْدَةٍ <sup>(٣)</sup> مَثَلًا فَذَلِكَ الْبَعْضُ غَيْرُ مُحَرَّرٍ، وَلَوْ نَامَ عَنْهَا، أَوْ  
تَشَاغَلَ لَمْ تَكُنْ مُحَرَّرَةً لَهُ، وَلَوْ لَمْ يَبْلُغْ صَوْتُهُ بَعْضَهَا إِذَا زَجَرَهَا فَفِي  
الْمُهَذَّبِ وَغَيْرِهِ: أَنَّ ذَلِكَ الْبَعْضَ غَيْرُ مُحَرَّرٍ، وَسَكَتَ آخَرُونَ عَنْ اعْتِبَارِ  
بُلُوغِ الصَّوْتِ؛ لِإِمْكَانِ الْعُدُوِّ إِلَى مَا لَمْ يَبْلُغْهُ، وَلَا تَرْجِيحِ فِي الرَّوْضَةِ  
كَأَصْلِهَا.

(وَمَقْطُورَةٌ) سَائِرَةٌ تُقَادُ (يُشْتَرَطُ) فِي إِحْرَازِهَا (التَّفَاتُ قَائِدُهَا إِلَيْهَا كُلِّ  
سَاعَةٍ، بِحَيْثُ يَرَاهَا) وَرَاكِبٌ أَوَّلُهَا كَقَائِدِهَا، فَإِنْ لَمْ يَرِ بَعْضُهَا لِحَائِلٍ فَهُوَ  
غَيْرُ مُحَرَّرٍ.

(وَأَنْ لَا يَزِيدَ قِطَارٌ عَلَى تِسْعَةٍ) لِلْعَادَةِ الْغَالِبَةِ، فَإِنْ زَادَ فَكَغَيْرِ الْمَقْطُورَةِ،  
أَيْ: فَالزَّائِدُ غَيْرُ مُحَرَّرٍ.

---

(١) ضابط حرز الماشية.

(٢) ضابط حرز الإبل التي تكون بالصحراء.

(٣) الوهدة: الأرض المنخفضة.

(وَعَبْرٍ مَقْطُورَةٍ) بِأَنْ تُسَاقَ (لَيْسَتْ مُحَرَّرَةً فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ الْإِبِلَ لَا تَسِيرُ هَكَذَا غَالِبًا، وَالثَّانِي: مُحَرَّرَةٌ بِسَائِقِهَا الْمُنتَهِي نَظَرُهُ إِلَيْهَا كَالْمَقْطُورَةِ الْمَسُوقَةِ، وَهُوَ أَوَّلَى الْوُجْهِينِ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ، وَعَبَّرَ فِي الْأَوَّلِ فِي الْمُحَرَّرِ بِالشَّبهِ (١) وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُقَيِّدِ الْمَقْطُورَةَ بِعَدَدٍ، وَتَوَسَّطَ أَبُو الْفَرَجِ السَّرْحَسِيُّ فَقَالَ فِي الصَّحَرَاءِ: لَا يَتَقَيَّدُ الْقِطَارُ بِعَدَدٍ، وَفِي الْعُمَرَانِ يُعْتَبَرُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِيهِ، وَهُوَ مَا بَيْنَ سَبْعَةٍ إِلَى عَشْرَةٍ، فَإِنْ زَادَ لَمْ تَكُنْ الرِّيَادَةُ مُحَرَّرَةً، قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَهُوَ الْأَحْسَنُ وَعَبَّرَ عَنْهُ فِي أَصْلِ الرِّوَضَةِ بِالْأَصَحِّ.

(وَكَفَنٍ) (٢) فِي قَبْرِ بَيْتٍ مُحَرَّرٍ ذَلِكَ الْبَيْتِ (مُحَرَّرٌ) ذَلِكَ الْكَفَنُ (وَكَذَا) كَفَنٌ فِي قَبْرِ (بِمَقْبَرَةٍ بِطَرَفِ الْعِمَارَةِ) أَيِ: مُحَرَّرٌ (فِي الْأَصَحِّ) لِلْعَادَةِ، وَالثَّانِي: إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ حَارِسٌ فَهُوَ غَيْرُ مُحَرَّرٍ، كَمَتَاعٍ وَضِعَ فِيهِ، (لَا بِمَضِيعَةٍ) بِكُسْرِ الضَّادِ وَسُكُونِهَا وَفَتْحِ الْيَاءِ، أَيِ: بُقْعَةٍ ضَائِعَةٍ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ، فَإِنَّهُ غَيْرُ مُحَرَّرٍ (فِي الْأَصَحِّ)؛ إِذْ لَا خَطَرَ وَلَا انْتِهَازَ فُرْصَةٍ فِي أَخْذِهِ، وَالثَّانِي: قَالَ: الْقَبْرُ حَرَزٌ لِلْكَفَنِ حَيْثُ كَانَ؛ لِأَنَّ النُّفُوسَ تَهَابُ الْمَوْتَى، وَلَوْ كَانَ بِمَقْبَرَةٍ مَحْفُوفَةٍ بِالْعِمَارَةِ يَنْدُرُ تَخَلُّفُ الطَّارِقِينَ عَنْهَا فِي زَمَنِ يَتَأَتَّى فِيهِ النَّبْشُ، أَوْ كَانَ عَلَيْهَا حُرَّاسٌ مُرْتَبُونَ فَهُوَ مُحَرَّرٌ جَزْمًا.

(١) الأشبه: يستعمل هذا المصطلح فيما لو كان في المسألة حكمان مبنيان على قياسين، لكن علة أحدهما أقوى، فيكون الحكم المبني عليها أقوى شبهًا من العلة.

(٢) ضابط حرز الكفن.

فَصَلَ: <sup>(١)</sup> (يُقْطَعُ مُؤَجَّرُ الْحِرْزِ) <sup>(٢)</sup> الْمَالِكُ لَهُ بِسَرِقَتِهِ مِنْهُ مَالُ الْمُسْتَأْجِرِ <sup>(٣)</sup> أَنَّهُ مُسْتَحَقٌّ لِمَنَافِعِهِ، وَمِنْهَا الْإِحْرَازُ، فَخَرَجَ بِهَذَا التَّوْجِيهِ مَنْ اسْتَأْجَرَ مَحُوطًا لِلزَّرَاعَةِ، فَأَوَى فِيهِ مَا شِئِنَهُ مَثَلًا، فَلَا يُقْطَعُ مُؤَجَّرُهُ بِسَرِقَتِهَا.

(وَكَذَا مُعِيرُهُ) <sup>(٤)</sup> أَي: الْحِرْزِ، يُقْطَعُ بِسَرِقَتِهِ مِنْهُ مَالُ الْمُسْتَعِيرِ (فِي الْأَصَحِّ) لِاسْتِحْقَاقِهِ مَنَفَعَتَهُ، وَالثَّانِي: لَا يُقْطَعُ لِأَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ عَنِ الْعَارِيَةِ مَتَى شَاءَ، وَالثَّلَاثُ: إِنْ دَخَلَ بِقَصْدِ الرُّجُوعِ عَنِ الْعَارِيَةِ لَمْ يُقْطَعْ، أَوْ بِقَصْدِ السَّرِقَةِ قُطِعَ.

(وَلَوْ غَصَبَ) <sup>(٥)</sup> حِرْزًا لَمْ يُقْطَعْ مَالِكُهُ بِسَرِقَتِهِ مِنْهُ؛ لِأَنَّ لَهُ الدُّخُولَ فِيهِ، (وَكَذَا أَجْنَبِيٍّ) أَي: لَا يُقْطَعُ بِسَرِقَتِهِ مِنْهُ (فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ حِرْزًا لِلْغَاصِبِ، وَالثَّانِي: قَالَ: لَيْسَ لِلْأَجْنَبِيِّ الدُّخُولُ فِيهِ.

(وَلَوْ غَصَبَ) <sup>(٦)</sup> مَالًا وَأَحْرَزَهُ بِحِرْزِهِ، فَسَرَقَ الْمَالِكُ مِنْهُ مَالَ الْغَصْبِ، أَوْ سَرَقَ (أَجْنَبِيٍّ) مِنْهُ الْمَالُ (الْمَغْصُوبَ فَلَا قَطْعَ) عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا (فِي الْأَصَحِّ)؛ أَمَّا الْمَالِكُ: فَلِأَنَّ لَهُ دُخُولَ الْحِرْزِ لِأَخْذِ مَالِهِ، وَالثَّانِي <sup>(٧)</sup>:

(١) حكم لو سرق مؤجر الحرز مال المستأجر منه.

(٢) أي: فيما لا يمتنع القطع وما يمتنع، وما يكون حِرْزًا لِشَخْصٍ دُونَ آخَرَ.

(٣) إِذْ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ مُسْتَحَقَّةٌ لِلْمُسْتَأْجِرِ، وَالْإِحْرَازُ مِنَ الْمَنَافِعِ.

(٤) حكم لو سرق معير الحرز مال المستعير منه.

(٥) حكم لو سرق صاحب الحرز المغصوب أو الأجنبى منه.

(٦) حكم لو سرق المالك ماله المغصوب من الحرز.

(٧) أي: يقطع.

نَظَرًا إِلَى أَنَّهُ أَخَذَ غَيْرَ مَالِهِ، وَأَمَّا الْأَجْنَبِيُّ: فَلِأَنَّ الْحِرْزَ لَيْسَ بِرِضَا الْمَالِكِ، وَالثَّانِي: فِيهِ نَظَرٌ إِلَى أَنَّهُ حِرْزٌ فِي نَفْسِهِ، وَالْخَصْمُ عَلَيْهِ الْمَالِكُ وَمِثْلُ غَضَبِ الْمَالِ فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ سَرَقَتُهُ.

(وَلَا يُقْطَعُ <sup>(١)</sup> مُخْتَلَسٌ <sup>(٢)</sup>، وَمُنْتَهَبٌ <sup>(٣)</sup>، وَجَاذٌ <sup>(٤)</sup> وَدِيعَةٌ) وَفُهُمَ حَدِيثُ: حَدِيثُ: (لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلَسِ وَالْمُنْتَهَبِ وَالْخَائِنِ قَطْعٌ) <sup>(٥)</sup> صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْأَوَّلَانِ يَأْخُذَانِ الْمَالَ عَيْنًا، وَيَعْتَمِدُ الْأَوَّلُ عَلَى الْهَرَبِ، وَالثَّانِي عَلَى الْقُوَّةِ وَالْعَلَبَةِ، وَيَدْفَعَانِ بِالْأَسْلَاطَانِ غَيْرَهُ، بِخِلَافِ السَّارِقِ لِأَخْذِهِ خُفْيَةً فَشُرْعَ قَطْعُهُ رَجْرًا.

(وَلَوْ نَقَبَ) <sup>(٦)</sup> فِي لَيْلَةٍ (وَعَادَ فِي لَيْلَةٍ أُخْرَى فَسَرَقَ قُطِعَ فِي الْأَصَحِّ، قُلْتُ: أَخْذًا مِنَ الرَّافِعِيِّ فِي الشَّرْحِ (هَذَا إِذَا لَمْ يَعْلَمْ الْمَالِكُ النَّقَبَ، وَلَمْ يَظْهَرْ لِلطَّارِقِينَ، وَإِلَّا) أَيُّ: بِأَنْ عِلْمَهُ الْمَالِكُ، أَوْ ظَهَرَ لِلطَّارِقِينَ (فَلَا يُقْطَعُ قَطْعًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ)؛ لِإِنْتِهَاكِ الْحِرْزِ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ: <sup>(٧)</sup> وَجَّهَ بِأَنَّهُ عَادَ بَعْدَ إِنْتِهَاكِ الْحِرْزِ، وَالْأَصَحُّ أَبْقَى الْحِرْزَ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ.

---

(١) حكم سرقة المختلس والمنتهب والجاذ للوديعة.

(٢) المختلس: هُوَ مَنْ يَعْتَمِدُ الْهَرَبَ مِنْ غَيْرِ غَلَبَةٍ مَعَ مُعَايَنَةِ الْمَالِكِ.

(٣) المنتهب: هُوَ مَنْ يَأْخُذُ عَيْنًا وَيَعْتَمِدُ عَلَى الْقُوَّةِ وَالْعَلَبَةِ.

(٤) أي: منكر الوديعة.

(٥) أخرجه ابن ماجه، والنسائي.

(٦) حكم لو نقب السارق في ليلة، وسرق في ليلة أخرى.

(٧) أي: لا قطع.



وَلَوْ نَقَبَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَأَخَذَ فِي آخِرِهِ قُطْعَ أَيضًا، وَيَأْتِي فِيهِ خِلَافٌ  
مِمَّا تَقَدَّمَ فِي إِخْرَاجِ النَّصَابِ فِي مَرَّتَيْنِ بِطَرِيقِ الْأُولَى، فَإِنَّهُ هُنَاكَ تَمَمَ  
السَّرِقَةُ وَهُنَا ابْتَدَأَهَا.

(وَلَوْ نَقَبَ) <sup>(١)</sup> وَاحِدٌ (وَأَخْرَجَ غَيْرُهُ فَلَا قُطْعَ) عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ  
لَمْ يَسْرِقْ، وَالثَّانِي أَخَذَ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ. <sup>(٢)</sup>

(وَلَوْ تَعَاوَنَا فِي النَّقَبِ) <sup>(٣)</sup>، وَانْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِالْإِخْرَاجِ، أَوْ وَضَعَهُ نَاقِبٌ  
بِقُرْبِ النَّقَبِ فَأَخْرَجَهُ آخَرُ قُطْعَ الْمُخْرِجِ) وَهُوَ فِي الثَّانِيَةِ شَرِيكَ فِي النَّقَبِ  
كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا.

(وَلَوْ وَضَعَهُ) <sup>(٤)</sup> بَوَسَطَ نَقْبِهِ فَأَخَذَهُ خَارِجٌ، وَهُوَ يُسَاوِي نَصَابَيْنِ لَمْ يُقْطَعَا  
يُقْطَعَا فِي الْأَظْهَرِ)؛ لِأَنَّهُمَا لَمْ يُخْرِجَاهُ مِنْ تَمَامِ الْحِرْزِ، وَالثَّانِي: يُقْطَعَانِ  
لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي النَّقَبِ وَالْإِخْرَاجِ، كَذَا وَجَّهَهُ الرَّافِعِيُّ، وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ  
الْخِلَافَ فِي الْمُشْتَرَكَيْنِ فِي النَّقَبِ.

(وَلَوْ رَمَاهُ) <sup>(٥)</sup> إِلَى خَارِجِ حِرْزٍ، أَوْ وَضَعَهُ بِمَاءٍ جَارٍ) فَخَرَجَ بِهِ مِنْ  
الْحِرْزِ (أَوْ ظَهَرَ دَابَّةٌ سَائِرَةٌ) فَخَرَجَتْ بِهِ مِنَ الْحِرْزِ (أَوْ عَرَّضَهُ لِرِيحٍ

---

(١) الحكم لو نقب واحد، وسرق غيره.

(٢) وَيَجِبُ عَلَى الْأَوَّلِ ضَمَانُ الْجِدَارِ، وَعَلَى الثَّانِي ضَمَانُ الْمَأْخُذِ.

(٣) الحكم لو تعاون اثنان في النقب، وانفرد أحدهما بالإخراج.

(٤) الحكم لو وضع المسروق بوسط نقبه فأخذه خارج، وهو يساوي نصابين.

(٥) الحكم لو رمي الشخص المال المحرز إلى خارج حرزه، أو وضعه بماء جار، أو

ظهر دابة سائرة.

هَابَّةٍ فَأَخْرَجَتْهُ) مِنَ الْحِرْزِ (قُطِعَ) لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ مِنَ الْحِرْزِ بِمَا فُعِلَ مِمَّا ذُكِرَ <sup>(١)</sup>.

(أَوْ) <sup>(٢)</sup> وَضَعَهُ بِظَهْرِ دَابَّةٍ (وَاقِفَةٍ فَمَشَتْ بِوَضْعِهِ) حَتَّى خَرَجَتْ بِهِ مِنَ الْحِرْزِ (فَلَا) يُقْطَعُ (فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّ لَهَا اخْتِيَارًا فِي السَّيْرِ، وَالثَّانِي: يُقْطَعُ؛ لِأَنَّ الْخُرُوجَ حَصَلَ بِفِعْلِهِ، وَلَا يَتَأْتَى الْخُرُوجُ فِي الْمَاءِ الرَّائِدِ إِلَّا بِتَخْرِيكِهِ، فَإِنْ حَرَكَهُ فَخَرَجَ قُطِعَ.

(وَلَا يَضْمَنُ حُرٌّ بِيَدٍ، وَلَا يُقْطَعُ سَارِقُهُ)؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ، (وَلَوْ سَرَقَ صَغِيرًا بِقِلَادَةٍ) نَصَابٍ (فَكَذَا) أَيُّ: لَا يُقْطَعُ (فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّهَا فِي يَدِ الصَّبِيِّ مُحَرَّرَةٌ بِهِ، وَالثَّانِي: جَعَلَ سَرِقَتَهُ سَرِقَةً لَهَا.

(وَلَوْ نَامَ عَبْدٌ عَلَى بَعِيرٍ فَقَادَهُ وَأَخْرَجَهُ عَنِ الْقَافِلَةِ قُطِعَ)؛ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ مِنَ الْحِرْزِ، (أَوْ حُرٌّ) <sup>(٣)</sup> فَلَا يُقْطَعُ (فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّ الْبَعِيرَ فِي يَدِ الْحُرِّ مُحَرَّرٌ، وَالثَّانِي: <sup>(٤)</sup> قَالَ أَخْرَجَهُ مِنَ الْحِرْزِ.

(وَلَوْ نَقَلَ) <sup>(٥)</sup> مِنْ بَيْتٍ مُغْلَقٍ إِلَى صَحْنٍ دَارٍ بِأُفْهَامِهَا مَفْتُوحٌ قُطِعَ)؛ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ مِنْ حِرْزِهِ إِلَى مَحَلِّ الضِّيَاعِ، (وَالْأَوَّلُ) بِأَنَّ كَانَ الْأَوَّلُ مَفْتُوحًا

---

(١) وَلِأَنَّ الْإِخْرَاجَ فِي الْجَمِيعِ مَنْسُوبٌ إِلَيْهِ، وَسَوَاءَ رَمَاهُ مِنَ النَّقْبِ، أَمْ مِنَ الْبَابِ، أَمْ مِنْ فَوْقِ الْجِدَارِ، وَسَوَاءَ أَخَذَهُ بَعْدَ الرَّمْيِ أَمْ لَا، أَخَذَهُ غَيْرُهُ أَمْ لَا، تَلَفَ كَأَن رَمَاهُ فِي نَارٍ، أَمْ لَا.

(٢) الْحُكْمُ لَوْ وَضَعَ الْمَالُ الْمَحْرُوزَ بِظَهْرِ دَابَّةٍ وَاقِفَةٍ، فَمَشَتْ بِوَضْعِهِ حَتَّى خَرَجَتْ بِهِ مِنَ الْحِرْزِ.

(٣) أَيُّ: نَامَ حُرٌّ عَلَى بَعِيرٍ فَقَادَهُ وَأَخْرَجَهُ عَنِ الْقَافِلَةِ.

(٤) أَيُّ: يَقْطَعُ.

(٥) أَيُّ: الْمَالُ مِنْ بَعْضِ زَوَايَا الْبَيْتِ لِبَعْضِ آخَرٍ مِنْهُ.

وَالثَّانِي مُغْلَقًا، أَوْ كَانَا مُفْتُوحَيْنِ، أَوْ مُغْلَقَيْنِ (فَلَا) يُقْطَعُ، وَوَجْهُهُ فِي الْمَفْتُوحِ: أَنَّهُ غَيْرُ حِرْزٍ، (وَقِيلَ: إِنْ كَانَا <sup>(١)</sup> مُغْلَقَيْنِ قُطِعَ)؛ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ مِنْ حِرْزِهِ، وَالْأَوَّلُ قَالَ مِنْ بَعْضِ حِرْزِهِ، فَإِنَّ النَّبَابَ الثَّانِي مِنْهُ.

(وَبَيَّنْتَ خَانَ <sup>(٢)</sup> وَصَحْنَهُ <sup>(٣)</sup> كَبَيْتٍ، وَ) صَحْنٍ (دَارٍ فِي الْأَصَحِّ) فَيُقْطَعُ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ دُونَ الْبَاقِي عَلَى خِلَافٍ فِي الرَّابِعِ، وَالثَّانِي يُقْطَعُ فِيهِ قِطْعًا؛ لِأَنَّ صَحْنَ الْخَانِ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ السُّكَّانِ. <sup>(٤)</sup>

فَصَلَ <sup>(٥)</sup> (لَا يُقْطَعُ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ)؛ لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِمَا (وَمُكْرَهٍ) بِفَتْحِ الرَّاءِ؛ لِشُبْهَةِ الْإِكْرَاهِ الدَّافِعَةِ لِلْحَدِّ، وَقُطِعَ السُّكَّرَانِ عَلَى الْخِلَافِ فِيهِ مِنْ قَبِيلِ رَبْطِ الْأَحْكَامِ بِالْأَسْبَابِ.

(وَيُقْطَعُ مُسْلِمٌ وَذِمِّيٌّ بِمَالٍ مُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ) أَيُّ كُلِّ مِنْهُمَا لِاتِّزَامِ الذِّمِّيِّ الْأَحْكَامَ كَالْمُسْلِمِ <sup>(٦)</sup>.

---

(١) أي: باب البيت والدار.

(٢) أي: الفُنْدُقُ، أو الحانوت، أو المتجر.

(٣) صحن الدار: هي الساحة وسطها.

(٤) مَحَلُّ الْخِلَافِ إِذَا كَانَ السَّارِقُ مِنْ غَيْرِ سُكَّانِهِ، فَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ وَسَرَقَ مِنَ الْبَيْتِ وَالْحِجْرَةِ الْمُغْلَقَيْنِ قُطِعَ، وَإِنْ سَرَقَ مِنَ الْعُرْصَةِ لَمْ يُقْطَعْ.

(٥) في شروط السارق، وَفِيمَا تَثَبُّتُ بِهِ السَّرِقَةُ، وَمَا يُقْطَعُ بِهَا.

(٦) أَمَّا قُطْعُ الْمُسْلِمِ بِمَالِ الْمُسْلِمِ فَبِإِجْمَاعٍ، وَأَمَّا قُطْعُهُ بِمَالِ الذِّمِّيِّ فَعَلَى الْمَشْهُورِ لِأَنَّهُ مَعْصُومٌ بِذِمَّتِهِ، وَقِيلَ: لَا يُقْطَعُ كَمَا لَا يُقْتَلُ بِهِ، وَأَمَّا قُطْعُ الذِّمِّيِّ بِمَالِ الْمُسْلِمِ أَوْ الذِّمِّيِّ فَلِاتِّزَامِهِ الْأَحْكَامَ، سَوَاءً أَرْضِي بِحُكْمِنَا أَمْ لَا.

(وفي معاهد<sup>(١)</sup> أقوال: أحسنها: إن شرط<sup>(٢)</sup> قطعه بسرقة قطع، وإلا فلا) يقطع، والأول يقطع مطلقاً، والثاني: عكسه،<sup>(٣)</sup> (قلت) كما قال الرافعي في الشرح: (الأظهر عند الجمهور لا قطع) مطلقاً (والله أعلم) قال فيه: والتفصيل حسن، وفي المحرر أحسنها.<sup>(٤)</sup>

(وتثبت السرقة بيمين المدعي المزدودة<sup>(٥)</sup> في الأصح) فيقطع بها؛ لأنها لأنها كالبينة، أو كإقرار المدعى عليه، وكل منهما يقطع به، والثاني: لا يقطع بها؛ لأن القطع حق لله<sup>(٦)</sup>، كذا في الروضة كأصلها، وفيهما في الدعاوى الجزم بالثاني، (وبإقرار السارق)<sup>(٦)</sup> ولا يشترط تكريره.

---

(١) المعاهد: هو الرجل من أهل الحرب يدخل دار الإسلام بأمان، فيحرم على المسلمين قتله.

(٢) أي: إن شرط عليه في عهده.

(٣) أي: إن لم يشرط عليه في عهده فلا يقطع؛ لعدم التزامه.

(٤) والثالث: يقطع مطلقاً كالذمي، وخص المأوردي الخلاف بمال المسلم أو الذمي، فإن سرق مال معاهد فلا يقطع قطعاً، وأما المال المسروق فيجب استرداده منه جزماً إن بقي، وبذلك إن تلف.

(٥) اليمين المردودة: اليمين العائدة على المدعي عند نكول المدعى عليه.

(٦) أطلق المصنف الإقرار، وله شرطان:

أحدهما: أن يكون بعد الدعوى عليه، فإن أقر قبلها لم يثبت القطع في المال، بل يوقف على حضور المالك وطلبه.

(وَالْمَذْهَبُ: قَبُولُ رُجُوعِهِ) <sup>(١)</sup> كَالزَّيِّ، وَفِي قَوْلٍ: لَا، كَالْمَالِ، <sup>(٢)</sup> وَالطَّرِيقُ  
 الثَّانِي: الْقَطْعُ بِقَبُولِ رُجُوعِهِ، فَلَا يُقْطَعُ، وَفِي الْغُرْمِ قَوْلَانِ: أَظْهَرُهُمَا:  
 وَجُوبُهُ، وَفِي طَرِيقٍ ثَالِثٍ: الْقَطْعُ بِوُجُوبِ الْغُرْمِ أَيْضًا.  
 (وَمَنْ أَقَرَّ بِعُقُوبَةِ اللَّهِ Y) أَيُّ: بِمُوجِبِهَا بِكَسْرِ الْجِيمِ، كَالسَّرِقَةِ، وَالزَّيِّ  
 ابْتِدَاءً، أَوْ بَعْدَ دَعْوَى (فَالصَّحِيحُ أَنَّ لِلْقَاضِي أَنْ يُعَرِّضَ لَهُ بِالرُّجُوعِ)  
 عَنْ الْإِقْرَارِ <sup>(٣)</sup>، (وَلَا يَقُولُ) لَهُ (ارْجِعْ) عَنْهُ، وَالثَّانِي: لَا يُعَرِّضُ لَهُ  
 بِالرُّجُوعِ، وَالثَّلَاثُ: يُعَرِّضُ لَهُ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ، وَإِنْ عَلِمَ فَلَا،  
 وَيَدُلُّ لِلأَوَّلِ قَوْلُهُ لِمَاعِزِ الْمُقَرَّرِ بِالزَّيِّ: "لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ" رَوَاهُ  
 النَّبَخَارِيُّ، وَلِمَنْ أَقَرَّ عِنْدَهُ بِالسَّرِقَةِ: "مَا إِخَالُكَ" <sup>(٤)</sup> سَرَقْتَ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ  
 وَغَيْرُهُ. (وَلَوْ أَقَرَّ بِلَا دَعْوَى أَنَّهُ سَرَقَ مَالَ زَيْدٍ الْغَائِبِ لَمْ يُقْطَعُ فِي الْحَالِ،  
 بَلْ يَنْتَظَرُ حُضُورَهُ فِي الْأَصَحِّ)؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُقَرَّرَ أَنَّهُ كَانَ أَبَاحَهُ لَهُ،

---

ثَانِيَهُمَا: أَنْ يُفْصَلَ الْإِقْرَارُ كَالشَّهَادَةِ، فَيُبَيِّنُ السَّرِقَةَ، وَالْمُسْرُوقَ مِنْهُ، وَقَدَّرَ الْمُسْرُوقَ،  
 وَالْحَرْزَ بِتَعْيِينٍ أَوْ وَصْفٍ، بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَظُنُّ غَيْرَ السَّرِقَةِ  
 الْمَوْجِبَةَ لِلْقَطْعِ سَرِقَةً مُوجِبَةً لَهُ.

(١) أَيُّ: الرُّجُوعُ عَنِ الْإِقْرَارِ بِالسَّرِقَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْقَطْعِ.  
 وَلَوْ بَقِيَ مِنَ الْقَطْعِ بَعْدَ الرُّجُوعِ مَا يَضُرُّ إِبْقَاؤُهُ قِطْعَهُ هُوَ لِنَفْسِهِ، وَلَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ  
 قِطْعُهُ، أَمَّا الْغُرْمُ فَلَا؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ أَدْمِي.

(٢) أَيُّ: لَا يَقْبَلُ الرُّجُوعُ عَنِ الْإِقْرَارِ بِالسَّرِقَةِ فِي الْمَالِ.  
 (٣) كَأَنْ يَقُولَ لَهُ فِي السَّرِقَةِ: لَعَلَّكَ أَخَذْتَ مِنْ غَيْرِ حَرْزٍ، وَفِي الزَّنَا: لَعَلَّكَ فَاحَذَتْ،  
 أَوْ لَمَسَتْ، وَفِي الشُّرْبِ: لَعَلَّكَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ مَا شَرِبْتَهُ مُسْكِرٌ.

(٤) مَا إِخَالُكَ بِكَسْرِ الهمزة هُوَ الشَّائِعُ الْمَشْهُورُ بَيْنَ الْجُمْهُورِ، وَالْفَتْحُ لَعْنَةُ بَعْضٍ، وَإِنْ  
 كَانَ الْقِيَاسُ لِكُونِهِ صِغَةً الْمُتَكَلِّمِ مِنْ خَالٍ بِمَعْنَى ظَنٍّ.

وَالثَّانِي يُقْطَعُ فِي الْحَالِ لِظُهُورِ مُوجِبِهِ. (أَوْ) أَقَرَّ (أَنَّهُ أَكْرَهَ أَمَةً غَائِبٍ عَلَى زَنَى حُدٍّ فِي الْحَالِ فِي الْأَصَحِّ) <sup>(١)</sup>، وَالثَّانِي: يُنْتَظَرُ حُضُورُهُ؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُقَرَّرَ أَنَّهُ كَانَ وَقَفَهَا عَلَيْهِ. (وَتَثْبُتُ) السَّرِقَةُ الْمُرْتَبِّ عَلَيْهَا الْقَطْعُ (بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ، فَلَوْ شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ) بِسَرِقَةٍ (ثَبَّتَ الْمَالُ وَلَا قَطْعُ)، وَكَذَا شَاهِدٌ وَيَمِينُ الْمُدَّعِي بِهَا. <sup>(٢)</sup> (وَيُسْتَرْتَضَى ذِكْرُ الشَّاهِدِ شُرُوطَ السَّرِقَةِ) الْمُوجِبَةِ لِلْقَطْعِ، بَبَيَانِ السَّارِقِ <sup>(٣)</sup>، وَالْمَسْرُوقِ مِنْهُ، وَالْمَسْرُوقِ، وَكَوْنِهِ مِنْ حِرْزٍ بِتَعْيِينِهِ أَوْ صِفَتِهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ كَاتِفَاقِ الشَّاهِدَيْنِ بِهَا <sup>(٤)</sup>. (وَلَوْ اخْتَلَفَ شَاهِدَانِ) <sup>(٥)</sup> (كَقَوْلِهِ) أَيَّ أَحَدِهِمَا: (سَرَقَ بُكْرَةً، وَالْآخَرُ

---

(١) لِأَنَّ حُدَّ الزِّنَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الطَّلَبِ، وَلَوْ حَضَرَ وَقَالَ: كُنْتُ أَبْحَثُهَا لَهُ، لَمْ يَنْقُطِ الْحُدُّ، لِأَنَّ إِبَاحَةَ النُّبُحِ مُلْغَاءٌ.

(٢) مَحَلُّ ثُبُوتِ الْمَالِ: مَا إِذَا شَهِدُوا بَعْدَ دَعْوَى الْمَالِكِ أَوْ وَكِيلِهِ، فَلَوْ شَهِدُوا حِسْبَةً لَمْ يَثْبُتْ بِشَهَادَتِهِمُ الْمَالُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ شَهَادَتَهُمْ مُنْصَبَّةٌ إِلَى الْمَالِ، وَشَهَادَةُ الْحِسْبَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَالِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ.

(٣) وَذَلِكَ بِالْإِشَارَةِ إِلَى عَيْنِهِ إِنْ كَانَ حَاضِرًا، وَبِذِكْرِ اسْمِهِ وَنَسَبِهِ بِحَيْثُ يَحْصُلُ التَّمْيِيزُ إِنْ كَانَ غَائِبًا، وَاسْتَشْكَلَ بَأَنَّ النِّيَّةَ لَا تُشْمَعُ عَلَى غَائِبٍ فِي حُدُودِ اللَّهِ. Y. وَقَدْ يُجَابُ: بِأَنَّهَا إِنَّمَا سُمِعَتْ تَغْلِيْبًا لِجَانِبِ الْمَالِ، وَلِهَذَا لَا قَطْعُ عَلَى السَّارِقِ حَتَّى يَحْضُرَ الْمَالِكُ وَيَدَّعِي بِمَالِهِ.

(٤) فَلَا يَكْفِي الْإِطْلَاقُ؛ إِذْ قَدْ يُظَنُّ مَا لَيْسَ بِسَرِقَةٍ سَرِقَةً؛ لِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِيْمَا يُوجِبُ الْقَطْعَ.

(٥) أَي: وَقْتُ الشَّهَادَةِ.

عَشِيَّةً، فَبَاطِلَةٌ) <sup>(١)</sup> أَي: لَا يَنْتَرِيبُ عَلَيْهَا قَطْعٌ وَلَا غُرْمٌ، <sup>(٢)</sup> وَلِلْمَشْهُودِ لَهُ أَنْ يَخْلِفَ مَعَ أَحَدِهِمَا فَيَغْرُمُهُ. (وَعَلَى السَّارِقِ رَدُّ مَا سَرَقَ، فَإِنْ تَلَفَ ضَمِنَهُ) قَالَ p: "عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتُ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ <sup>(٣)</sup>.

---

(١) أَي: النِّسْبَةُ إِلَى الْقَطْعِ، أَمَّا الْمَالُ: فَإِنْ خَلَفَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ مَعَ الشَّاهِدِ أَخَذَ الْغُرْمَ مِنْهُ، وَإِلَّا فَلَا.

(٢) لِأَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى فِعْلٍ لَمْ يَتَّفَقَا عَلَيْهِ.

(٣) قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ قُطِعَ لَمْ يَغْرَمْ، وَإِنْ غَرِمَ لَهُ لَمْ يَقُطَعْ، وَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ كَانَ غَنِيًّا ضَمِنَ، وَإِلَّا فَلَا.

لَنَا: أَنَّ الْقَطْعَ لِلَّهِ Y، وَالضَّمَانُ لِأَدَمِيٍّ؛ فَلَا يَمْنَعُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، وَلَا يَمْنَعُ الْفَقْرُ إِسْقَاطَ مَالِ الْغَيْرِ.

وَلَوْ كَانَ لِلْمَسْرُوقِ مَنَفَعَةٌ اسْتَوْفَاهَا السَّارِقُ أَوْ عَطَّلَهَا وَجَبَتْ أَجْرُهَا كَالْمَغْصُوبِ، وَلَوْ أَعَادَ الْمَالُ الْمَسْرُوقَ إِلَى الْحِرْزِ لَمْ يَسْقُطِ الْقَطْعُ وَلَا الضَّمَانُ عَنْهُ.

## (باب قاطع الطريق<sup>(١)</sup>)

(هُوَ مُسْلِمٌ مُكَلَّفٌ لَهُ شَوْكَةٌ) بِجَمَاعَةٍ يَتَرَصَّدُونَ فِي الْمَكَامِنِ لِلرِّفْقَةِ، فَإِذَا رَأَوْهُمْ بَرَزُوا قَاصِدِينَ لِلْأَمْوَالِ مُعْتَمِدِينَ فِي ذَلِكَ عَلَى قُوَّةٍ وَقُدْرَةٍ يَتَغَلَّبُونَ بِهَا حَيْثُ لَا غَوْثٌ<sup>(٢)</sup> كَمَا سَيَأْتِي (لَا مُخْتَلِسُونَ<sup>(٣)</sup>) يَتَعَرَّضُونَ لِأَخْرِ قَافِلَةٍ) يَسْلُبُونَ شَيْئًا (يُعْتَمِدُونَ الْهَرَبَ) بِرَكْضِ الْخَيْلِ أَوْ الْعَدْوِ عَلَى الْأَقْدَامِ فَلْيَسُوا قُطَّاعًا؛ لِإِنْتِفَاءِ الشَّوْكَةِ (وَالَّذِينَ يَغْلِبُونَ شِرْذِمَةً) بِإِعْجَامِ الدَّالِ (بِقُوَّتِهِمْ قُطَّاعٌ فِي حَقِّهِمْ لَا) قُطَّاع (لِقَافِلَةٍ عَظِيمَةٍ) سَلَبُوا مِنْهُمْ شَيْئًا بَلْ مُخْتَلِسُونَ (وَحَيْثُ يَلْحَقُ غَوْثٌ) بِالْمُتَلَثِّثَةِ (لَيْسُوا) ذَوُو الشَّوْكَةِ بِمَا ذَكَرَ (بِقُطَّاعٍ) بَلْ مُنْتَهَبُونَ (وَقَدْ أَلْغَوْثُ يَكُونُ لِلْبُعْدِ) عَنِ الْعِمَارَةِ (أَوْ لِضَعْفٍ) فِي أَهْلِهَا مَعَ الْقُرْبِ عَنِ الْإِغَاثَةِ (وَقَدْ يَغْلِبُونَ) أَيُّ: ذَوُو الشَّوْكَةِ (وَالْحَالَةُ هَذِهِ) أَيُّ الضَّعْفِ (فِي بَلَدٍ فَهُمْ قُطَّاعٌ) وَعِبَارَةُ الْمُحَرَّرِ: فَلَهُمْ حُكْمُ الْقُطَّاعِ، وَلَا تُشْتَرَطُ فِيهِمُ الذُّكُورَةُ، فَالنِّسْوَةُ قَاطِعَاتُ طَرِيقٍ، وَالْوَاحِدُ إِذَا كَانَ لَهُ فَضْلٌ قُوَّةٌ يَغْلِبُ بِهَا الْجَمَاعَةَ وَتَعَرَّضَ لِلنَّفُوسِ وَالْأَمْوَالِ مُجَاهِرًا فَهُوَ قَاطِعُ طَرِيقٍ.

## [عقوبة قاطع الطريق]

(١) هذا الباب يسمى باب الحراة؛ لأن الله تعالى قال فيه: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا....) (الآية).

(٢) شرطهم: عدم وجود الغوث.

(٣) جمع مختلس وهو النشال، مثل من يركب دراجة نارية ويأخذ المال ثم يلوذ بالفرار.



(وَلَوْ عَلِمَ الْإِمَامُ قَوْمًا يُخَيَّفُونَ الطَّرِيقَ وَلَمْ يَأْخُذُوا مَالًا وَلَا) قَتَلُوا (نَفْسًا) عَزَّرَهُمْ بِحَبْسٍ وَغَيْرِهِ) وَالْحَبْسُ فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهِمْ أُولَى.

(وَإِذَا أَخَذَ الْقَاطِعُ نَصَابَ السَّرِقَةِ قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى وَرِجْلُهُ الْيُسْرَى، فَإِنْ عَادَ فَيُسْرَاهُ وَيُمْنَاهُ، وَإِنْ قَتَلَ قُتِلَ حَتْمًا) لَا يَسْقُطُ بِوَجْهِهِ<sup>(١)</sup>، (وَإِنْ قَتَلَ وَأَخَذَ مَالًا) رُبْعَ دِينَارٍ (قُتِلَ ثُمَّ صُلِبَ) بَعْدَ غَسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ وَالصَّلَاةَ عَلَيْهِ (ثَلَاثًا)<sup>(٢)</sup> ثُمَّ يَنْزَلُ، وَقِيلَ: يَبْقَى حَتَّى يَسِيلَ صَدِيدُهُ، وَفِي قَوْلٍ: يُصَلَّبُ<sup>(٣)</sup> قَلِيلًا، ثُمَّ يَنْزَلُ فَيُقْتَلُ) وَيُغْسَلُ وَيُكْفَنُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ<sup>(٤)</sup>، (وَمَنْ أَعَانَهُمْ وَكَثَّرَ جَمْعَهُمْ)<sup>(٥)</sup> (وَلَمْ يَأْخُذْ مَالًا وَلَا قَتَلَ نَفْسًا،) (عُزِّرَ بِحَبْسٍ وَتَغْرِيبٍ وَغَيْرِهِمَا) أَيِ بَوَاحِدٍ مِمَّا ذُكِرَ بِرَأْيِ الْإِمَامِ، (وَقِيلَ: يَتَّعَيْنُ التَّغْرِيبُ إِلَى حَيْثُ يَرَاهُ)<sup>(٦)</sup> (وَإِذَا عَيَّنَ صَوْبًا)<sup>(٧)</sup> مَنَعَهُ الْعُدُولُ إِلَى غَيْرِهِ، وَهَلْ يُعَزَّرُ فِي الْبَلَدِ الْمُنْفَى إِلَيْهِ بِضَرْبٍ وَحَبْسٍ وَغَيْرِهِمَا؟ وَجَهَانٍ، قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: الْأَصَحُّ: أَنَّهُ إِلَى رَأْيِ الْإِمَامِ وَمَا اقْتَضَتْهُ الْمَصْلَحَةُ (وَقَتْلُ الْقَاطِعِ يَغْلِبُ فِيهِ مَعْنَى الْقِصَاصِ، وَفِي قَوْلٍ) مَعْنَى (الْحَذِّ) حَيْثُ لَا يَصِحُّ الْعَفْوُ عَنْهُ وَيَسْتَوْفِيهِ السُّلْطَانُ (فَعَلَى الْأَوَّلِ: لَا يُقْتَلُ بِوَلَدِهِ وَذِمِّيٍّ) وَعَبْدٌ (لَوْ مَاتَ)

(١) أي: لا يسقط هذا الحد بشفاعة أو غيرها.

(٢) ثلاثة أيام فأقل لمدة يقدرها أهل الخبرة حسب الصيف والشتاء؛ للعبارة.

(٣) حيًّا.

(٤) والعمل على الأول، والمدة يقدرها أهل الخبرة حتى لا يتعفن الجسد، إنما الصلب ليتعظ غيره.

(٥) كالمراقبين مثلاً من أجلهم.

(٦) أي: الإمام.

(٧) أي: إذا عين الحاكم مكاناً.

مِنْ غَيْرِ قَتْلِ (فَدِيَّةٍ) فِي الْحُرِّ وَقِيَمَةً فِي الْعَبْدِ مِنْ تَرْكِتِهِ، (وَلَوْ قَتَلَ جَمْعًا قُتِلَ بِوَاحِدٍ وَلِلْبَاقِيْنَ دِيَاتٌ) فَإِنْ قَتَلَهُمْ مُرْتَبًا قُتِلَ بِالْأَوَّلِ، وَلَوْ عَفَا وَلِيُّهُ لَمْ يَسْقُطْ قَتْلُهُ لِتَحْتَمِهِ (وَلَوْ عَفَا وَلِيُّهُ) أَيُّ الْمَقْتُولِ (بِمَالٍ وَجَبَ) الْمَالُ (وَسَقَطَ الْقِصَاصُ وَيُقْتَلُ حَدًّا) لِتَحْتَمِ قَتْلِهِ (وَلَوْ قَتَلَ بِمُتَقِلٍّ أَوْ بِقَطْعِ عِضْوٍ فَعِلَ بِهِ مِثْلُهُ) وَعَلَى الثَّانِي: يُقْتَلُ بِالسَّيْفِ فِي هَذِهِ الْخَامِسَةِ، وَلَعَا الْعَفْوُ فِي الرَّابِعَةِ، وَلَا دِيَّةٌ فِي الثَّالِثَةِ وَالثَّانِيَةِ، وَلَا قِيَمَةٌ فِيهَا، وَيُقْتَلُ فِي الْأَوَّلِ.

(وَلَوْ جَرَحَ فَاَنْدَمَلَ لَمْ يَتَحْتَمِ قِصَاصٌ فِي الْأَظْهَرِ) فَالْقَاطِعُ فِيهِ كَغَيْرِهِ، وَالثَّانِي: يَتَحْتَمِ كَالْقَتْلِ، وَالثَّالِثُ: يَتَحْتَمِ فِي الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ، وَالْمَشْرُوعُ فِيهِمَا الْقَطْعُ حَدًّا دُونَ غَيْرِهِمَا كَالْأَنْفِ وَالْأُذُنِ وَالْعَيْنِ، وَالْقِصَاصُ عَلَى الْأَقْوَالِ الْمُقَابَلَةِ بِالْمِثْلِ وَمَا لَا قِصَاصَ فِيهِ كَالْجَائِفَةِ وَاجِبَةُ الْمَالِ وَالسَّارِي قُتِلَ وَقَدْ تَقَدَّمَ حُكْمُهُ.

[توبة قاطع الطريق قبل القدرة عليه<sup>(١)</sup>]

(وَتَسْقُطُ عُقُوبَاتُ تَخْصُ الْقَاطِعَ بِتَوْبَتِهِ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، لَا بَعْدَهَا عَلَى الْمَذْهَبِ) فِي الشَّقِيِّينَ، وَقِيلَ: فِي كُلِّ مِنْهُمَا قَوْلَانِ، وَدَلِيلُ السَّقُوطِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ نَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ) [المائدة: ٣٤] الْآيَةُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا يَخُصُّهُ مِنْ قَطْعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَتَحْتَمِ الْقَتْلِ وَالصَّلْبِ (وَلَا يُسْقِطُهُ سَائِرُ الْحُدُودِ) أَيُّ بَاقِيهَا وَهُوَ حُدُودُ الزَّرْنَى وَالسَّرِقَةِ وَالشَّرْبِ

(١) إذا سلم قاطع الطريق نفسه سقط عنه حكم قاطع الطريق وأقيم عليه مسألة الحدود، فإن أخاف يعذره السلطان أو يعفو عنه، وإن سرق قطعت فقط يمينه، وإن قتل قُتِلَ حَدًّا.

وَالْقَذْفِ (بِهَا) أَيِ بِالتَّوْبَةِ (فِي الْأَظْهَرِ) فِي حَقِّ قَاطِعِ الطَّرِيقِ وَغَيْرِهِ،  
وَالثَّانِي يَسْقُطُ بِهَا قِيَاسًا عَلَى حَدِّ قَاطِعِ الطَّرِيقِ.

[اجتماع عقوبات على شخص واحد]

(فَصْلٌ) فِي اجْتِمَاعِ عُقُوبَاتٍ عَلَى غَيْرِ قَاطِعِ الطَّرِيقِ<sup>(١)</sup>، (مَنْ لَزِمَهُ)  
لَا دَمِيَّينَ (قِصَاصٌ) فِي النَّفْسِ (وَقَطْعٌ) لِطَرْفٍ (وَحَدٌّ) قَذْفٍ وَطَالِبُوهُ جُلْدٌ  
ثُمَّ قُطِعَ ثُمَّ قُتِلَ وَيُبَادَرُ بِقَتْلِهِ بَعْدَ قَطْعِهِ لَا قَطْعُهُ بَعْدَ جُلْدِهِ إِنْ غَابَ  
مُسْتَحِقُّ قَتْلِهِ لِأَنَّهُ قَدْ يَهْلِكُ بِالمُؤَالَاةِ فَيَقُوتُ قِصَاصُ النَّفْسِ (وَكَذَا إِنْ  
حَضَرَ وَقَالَ عَجَلُوا الْقَطْعَ) فَإِنَّا لَا نُعَجِّلُهُ (فِي الْأَصَحِّ) خَوْفًا مِنَ الْهَلَاكِ  
بِالمُؤَالَاةِ، وَالثَّانِي قَالَ: التَّأخِيرُ كَانَ لِحَقِّهِ وَقَدْ رَضِيَ بِالتَّقْدِيمِ.

(وَإِذَا أَخَّرَ مُسْتَحِقُّ النَّفْسِ حَقَّهُ جُلْدًا، فَإِنْ بَرَأَ) يَفْتَحِ الرَّاءِ (قَطْعٌ) وَلَا  
يُقْطَعُ قَبْلَ الْبُرْءِ خَوْفَ الْهَلَاكِ بِهِ (وَلَوْ أَخَّرَ مُسْتَحِقُّ طَرْفٍ) حَقَّهُ (جُلْدٌ  
وَعَلَى مُسْتَحِقِّ النَّفْسِ الصَّبْرُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الطَّرْفَ) حَذَرًا مِنْ فَوَاتِهِ (فَإِنْ  
بَادَرَ فَقَتَلَ فَلِمُسْتَحِقِّ الطَّرْفِ دِيَّتُهُ) لِقَوَاتِ اسْتِيفَائِهِ (وَلَوْ أَخَّرَ مُسْتَحِقُّ  
الْجُلْدِ) حَقَّهُ (فَالْقِيَاسُ) مِمَّا سَبَقَ (صَبْرُ الْآخَرِينَ)، فَلَا يُقْتَلُ وَلَا يُقْطَعُ  
قَبْلَ الْجُلْدِ.

(وَلَوْ اجْتَمَعَ حُدُودُ اللَّهِ تَعَالَى) عَلَى وَاحِدٍ، بِأَنْ شَرِبَ وَزَنَى بِكُرًا وَسَرَقَ  
وَارْتَدَّ (قُدِّمَ الْأَخْفُ) مِنْهَا (فَالْأَخْفُ) وَجُوبًا وَأَخْفُهَا حَدُّ الشُّرْبِ، فَيَقَامُ ثُمَّ

---

(١) هذا فصل في اجتماع عقوبات على شخص واحد، وهي أما أن تكون كلها لأدمي  
أو لله أو لهما، فهي أقسام ثلاثة سواء في قاطع الطريق وغيره، وقد ذكرها على هذا  
الترتيب، فلو كانت لواحد لم يجب الترتيب شرعا، بل بإرادته.

يُمَهِّلُ وَجُوبًا حَتَّى يَبْرَأَ ثُمَّ يُجْلَدُ لِلزَّنى وَيُمَهِّلُ ثُمَّ يُقَطَّعُ ثُمَّ يُقَتَّلُ (أَوْ)  
اجْتَمَعَ (عُقُوبَاتُ اللَّهِ تَعَالَى وَلِأَدْمِيَّيْنِ) بِأَنْ انْضَمَّ إِلَى مَا ذُكِرَ قَذْفُ (قُدِّمَ  
حَدُّ قَذْفٍ عَلَى) حَدِّ (زِنَا) لِأَنَّهُ حَقُّ أَدْمِيٍّ وَقِيلَ لِأَنَّهُ أَحَفُّ (وَالْأَصْحُ  
تَقْدِيمُهُ عَلَى حَدِّ الشُّرْبِ وَأَنَّ الْقِصَاصَ قِتْلًا وَقَطْعًا يُقَدَّمُ عَلَى) حَدِّ  
(الزَّنى) تَقْدِيمًا لِحَقِّ الْأَدْمِيِّ وَالثَّانِي الْعَكْسُ تَقْدِيمًا لِلْأَخَفِّ.

### (كتاب الْإِيمَان) <sup>(١)</sup>

---

(١) الْإِيمَان: جمع يمين، وهي مؤنثة وتذكر، وتجمع أيضا على ( أَيْمَن ) ومن معاني  
اليمين لغة: القوة والقسم، والبركة ، واليد اليمنى ، والجهة اليمنى، ويقابلها: اليسار ،  
بمعنى: اليد اليسرى ، والجهة اليسرى، أما في الشرع ، فقد عرفها صاحب غاية  
المنتهى من الحنابلة بأنها: تأكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص.

جَمْعُ يَمِينٍ (لَا تَتَعَقَّدُ) الْيَمِينُ (إِلَّا بِذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ صِفَةٍ لَهُ <sup>(١)</sup>) بِأَنْ يَخْلِفَ بِمَا مَفْهُومُهُ الذَّاتُ أَوْ الصِّفَةُ وَالذَّاتُ. (كَقَوْلِهِ وَاللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ) أَيْ مَالِكِ الْمَخْلُوقَاتِ (وَالْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَمَنْ نَفْسِي بِيَدِهِ) أَيْ قُدْرَتِهِ يُصَرِّفُهَا كَيْفَ يَشَاءُ، (وَكُلِّ اسْمٍ لَهُ مُخْتَصٌّ بِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) غَيْرَ مَا ذَكَرَ؛ كَالْإِلَهِ وَالرَّحْمَنِ وَخَالِقِ الْخَلْقِ، (وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ) فِي هَذَا الْقِسْمِ (لَمْ أُرِدْ بِهِ الْيَمِينِ) لَا فِي الظَّاهِرِ وَلَا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى.

(وَمَا انْصَرَفَ) مِنْ هَذَا الْقِسْمِ (إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ كَالرَّحِيمِ وَالْخَالِقِ وَالرَّزَّاقِ وَالرَّبِّ) وَالْحَقِّ، (تَتَعَقَّدُ بِهِ الْيَمِينُ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ غَيْرَهُ) تَعَالَى، فَإِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِهِ مُقَيَّدًا كَرَحِيمِ الْقَلْبِ وَخَالِقِ الْإِفْكِ وَرَازِقِ الْجَيْشِ وَرَبِّ الْإِبْلِ. (وَمَا أُسْتَعْمَلُ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ) تَعَالَى (سَوَاءً كَالشَّيْءِ وَالْمَوْجُودِ وَالْعَالِمِ) بِكُسْرِ اللَّامِ (وَالْحَيِّ) وَالْغَنِيِّ (لَيْسَ بِيَمِينٍ إِلَّا بِنِيَّةٍ) لَهُ تَعَالَى فَهُوَ بِهَا يَمِينٌ وَفِي وَجْهِ صَحْحِهِ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ أَنَّهُ لَيْسَ بِيَمِينٍ وَصَحَّحَ فِي الرَّوْضَةِ الْأَوَّلِ.

(وَالصِّفَةُ: كَوْعَظْمَةِ اللَّهِ وَعِزَّتِهِ وَكِبْرِيَائِهِ وَكَلَامِهِ وَعِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ وَمَشِيئَتِهِ يَمِينٌ)، بِأَنْ يَأْتِيَ بِالظَّاهِرِ بَدَلُ الضَّمِيرِ فِي السِّتَةِ (إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ) أَيْ

---

(١) أما اليمين بمخلوق فلا تتعقد: كنبى وملك؛ للنهي الصحيح عن الحلف بالآباء، وللأمر بالحلف بالله، وروى الحاكم خبر: "من حلف بغير الله فقد كفر"، وفي رواية: "فقد أشرك" وحملوه على ما إذا قصد تعظيمه كتعظيم الله تعالى، فإن لم يقصد ذلك أثم عند أكثر أصحابنا أي: تبعنا لنص الشافعي الصريح فيه.

يُرِيدُ. (بِالْعِلْمِ الْمَعْلُومِ وَبِالْقُدْرَةِ الْمُقْدُورِ) فَإِنَّهُ يُقْبَلُ فِيهِ وَلَا يَكُونُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا يَمِينًا لِأَنَّ اللَّفْظَ مُحْتَمِلٌ لَهُ.

(وَلَوْ قَالَ: وَحَقَّ اللَّهُ فَيَمِينٌ) لَغَلَبَتْ اسْتِعْمَالُهُ فِيهَا بِمَعْنَى اسْتِحْقَاقِ اللَّهِ الْإِلَهِيَّةَ. (إِلَّا أَنْ يُرِيدَ الْعِبَادَاتِ) الَّتِي أَمَرَ بِهَا فَلَيْسَ بِيَمِينٍ لِاحْتِمَالِ اللَّفْظِ لَهَا <sup>(١)</sup>.

(وَحُرُوفُ الْقَسَمِ) عِنْدَ أَهْلِ اللِّسَانِ ثَلَاثَةٌ (بَاءٌ) مُوَحَّدَةٌ (وَوَاوٌ وَتَاءٌ) فَوْقَانِيَّةٌ (كَبِاللَّهِ وَوَاللَّهِ وَتَاللَّهِ) لِأَفْعَلَنَّ كَذَا (وَتَخْتَصُّ التَّاءُ) الْفَوْقَانِيَّةُ (بِاللَّهِ) وَالْوَاوُ بِالْمُظْهَرِ وَتَدْخُلُ الْمُوَحَّدَةُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمُضْمَرِ فَهِيَ الْأَصْلُ، وَتَلِيهَا الْوَاوُ.

(وَلَوْ قَالَ: "اللَّهُ" وَرَفَعَ أَوْ نَصَبَ أَوْ جَرَّ) لِأَفْعَلَنَّ كَذَا (فَلَيْسَ بِيَمِينٍ إِلَّا بِنِيَّةٍ) لَهَا، وَاللَّحْنُ بِالرَّفْعِ لَا يَمْنَعُ انْعِقَادَ الْيَمِينِ وَالنَّصْبُ بِنَزْعِ الْجَارِ.

(وَلَوْ قَالَ: أَقْسَمْتُ أَوْ أَقْسِمُ أَوْ حَلَفْتُ أَوْ أَخْلَفْتُ بِاللَّهِ لِأَفْعَلَنَّ) كَذَا (فَيَمِينٌ) إِنْ نَوَاهَا أَوْ أَطْلَقَ، وَإِنْ قَالَ: قَصَدْتُ خَبْرًا مَاضِيًا) فِي صِيغَةِ الْمَاضِي (أَوْ مُسْتَقْبَلًا) فِي الْمُضَارِعِ (صَدَّقَ بَاطِنًا، وَكَذَا ظَاهِرًا عَلَى الْمَذْهَبِ) وَفِي قَوْلٍ: لَا وَبِهِ قَطَعَ بَعْضُهُمْ؛ لِظُهُورِ اللَّفْظِ فِي الْإِنْشَاءِ، فَإِنْ عُرِفَ لَهُ يَمِينٌ مَاضِيَّةٌ قَبْلَ قَوْلِهِ فِي إِرَادَتِهَا قُطْعًا، (وَلَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ: أَقْسِمُ عَلَيْكَ

---

(١) لأن العبادات حق لله تعالى علينا وليست صفة له تعالى فإن رفع الحق أو نصبه فكناية لتردده بين استحقاق الطاعة والإلهية فليس يمين إلا بنية ولو حلف المسلم بأية منسوخة من القرآن أو بالتوراة أو الإنجيل انعقدت يمينه وتنعقد اليمين بقوله وكتاب الله أو قرآن الله كما نقلاه عن البغوي وأقراه.

بِاللَّهِ، أَوْ أَسْأَلُكَ بِاللَّهِ لَتَفْعَلَنَّ) كَذَا (وَأَرَادَ يَمِينَ نَفْسِهِ فَيَمِينٌ) يُسْتَحَبُّ  
لِلْمُخَاطَبِ إِبْرَارُهُ فِيهَا<sup>(١)</sup>. (وَالَا<sup>(٢)</sup> فَلَا) وَيُحْمَلُ عَلَى الشَّفَاعَةِ فِي فِعْلِهِ.  
(وَلَوْ قَالَ: إِنْ فَعَلْتَ كَذَا فَأَنَا يَهُودِيٌّ أَوْ بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ فَلَيْسَ  
بِيَمِينٍ<sup>(٣)</sup>) وَلَا يَكْفُرُ بِهِ إِنْ قَصَدَ تَبَعِيدَ نَفْسِهِ عَنِ الْفِعْلِ، قَالَ فِي الرَّوْضَةِ  
وَلْيُقْل: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهُ. وَإِنْ قَصَدَ الرِّضَا  
بِذَلِكَ إِذَا فَعَلَهُ فَهُوَ كَافِرٌ فِي الْحَالِ، (وَمَنْ سَبَقَ لِسَانُهُ إِلَى لَفْظِهَا) أَيُّ:  
الْيَمِينِ (بِلَا قَصْدٍ) كَقَوْلِهِ فِي حَالِ غَضَبٍ أَوْ لَجَاجٍ أَوْ صِلَةٍ كَلَامٍ: لَا  
وَاللَّهِ تَارَةً، وَبَلَى وَاللَّهِ أُخْرَى. (لَمْ تَنْعَقِدْ) يَمِينُهُ وَيُسَمَّى ذَلِكَ لَعْوُ الْيَمِينِ  
الْمُفَسَّرَ بِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّعْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ) فِي  
حَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ وَالتَّبِيهَةِ.

(وَتَصِحُّ) الْيَمِينُ (عَلَى مَاضٍ وَمُسْتَقْبَلٍ) نَحْوُ وَاللَّهِ مَا فَعَلْتَ كَذَا أَوْ  
فَعَلْتَهُ، وَاللَّهِ لَا فَعَلْتَ كَذَا أَوْ لَا أَفْعَلُهُ. (وَهِيَ مَكْرُوهَةٌ) قَالَ تَعَالَى: (وَلَا

---

(١) إِبْرَارُ الْقِسْمِ: مِنَ الْبَرِّ وَهُوَ خِلَافُ الْحَنْثِ، وَالْمَعْنَى: تَصْدِيقٌ مِنْ أَقْسَمَ عَلَيْكَ بِفِعْلِ  
مَا طَلَبَهُ مِنْكَ. عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "أَمَرْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ  
وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، أَمَرْنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ  
وَإِبْرَارِ الْقِسْمِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ. وَنَهَانَا عَنْ آتِيَةِ الْفُضَّةِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ  
وَالْحَرِيرِ وَالدِّيْبَاجِ وَالْقَسِيِّ وَالْإِسْتَبْرَقِ".

(٢) بِأَنْ أَرَادَ يَمِينُ الْمَخَاطَبِ أَوْ لَمْ يَرِدْ يَمِينًا، بَلِ التَّشْفَعُ إِلَيْهِ أَوْ أَطْلُقَ، فَلَا يَكُونُ يَمِينًا  
فِي الصُّورِ الثَّلَاثِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْلِفْ هُوَ وَلَا الْمَخَاطَبُ.

(٣) لَخْلُوهُ عَنْ ذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى وَصِفَتِهِ، وَالْحَلْفُ بِذَلِكَ مَعْصِيَةٌ وَالتَّلَفُّظُ بِهِ حَرَامٌ كَمَا  
قَالَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْأَذْكَارِ.

تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ) (إِلَّا فِي طَاعَةٍ) كَفَعِلِ وَاجِبٍ أَوْ مَنْدُوبٍ  
وَتَرْكِ حَرَامٍ أَوْ مَكْرُوهٍ فَطَاعَةٌ، (فَإِنْ حَلَفَ عَلَى تَرْكِ وَاجِبٍ<sup>(١)</sup>) أَوْ فَعَلِ  
حَرَامٍ<sup>(٢)</sup> عَصَى بِحِلْفِهِ وَلَزِمَهُ الْحِنْثُ) بِالْمُثَلَّثَةِ. (وَكَفَّارَةٌ<sup>(٣)</sup>) أَوْ) عَلَى (تَرْكِ  
مَنْدُوبٍ<sup>(٤)</sup>) أَوْ فَعَلِ مَكْرُوهٍ) كَالْأَلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ (سُنَّ حِنْثُهُ وَعَلَيْهِ  
كَفَّارَةٌ<sup>(٥)</sup>) أَوْ) عَلَى (تَرْكِ مُبَاحٍ أَوْ (فَعَلِهِ) كَدُخُولِ دَارٍ وَأَكْلِ طَعَامٍ وَلُبْسِ  
ثَوْبٍ. (فَالْأَفْضَلُ: تَرْكُ الْحِنْثِ<sup>(٦)</sup>) وَقِيلَ) الْأَفْضَلُ (الْحِنْثُ) لِيَنْتَفِعَ  
الْمَسَاكِينُ بِالْكَفَّارَةِ.

### [حكم الأيمان الصادقة والمؤكدّة]

فَرَعٌ: الْأَيْمَانُ الْوَاقِعَةُ فِي الدَّعَاوَى إِذَا كَانَتْ صَادِقَةً لَا تُكْرَهُ وَلَا يُكْرَهُ  
الْيَمِينُ لِتَوْكِيدِ كَلَامٍ، (وَلَهُ تَقْدِيمُ كَفَّارَةٍ بَغَيْرِ صَوْمٍ عَلَى حِنْثٍ جَائِزٍ)

(١) كترك الصبح.

(٢) كالسرقة.

(٣) لأن الإقامة على هذه الحالة معصية لخبر الصحيحين من حلف يميناً فرأى  
غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه.

(٤) كسنة الضحى.

(٥) لأن اليمين والإقامة عليها مكروهان لقوله تعالى: ( وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ  
وَالسَّعَةِ ) الآية.

(٦) بل يسن؛ لما فيه من تعظيم الله تعالى، وقد قال تعالى: ( وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ  
تَوْكِيدِهَا ).



كَالْحِنْثِ فِي الْمُبَاحِ (قِيلَ: وَ) حِنْثٌ (حَرَامٌ) كَالْحِنْثِ بِتَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ فِعْلٍ حَرَامٍ كَالزَّنا.

(قُلْتُ: هَذَا) الْوَجْهُ (أَصَحُّ) مِنْ مُقَابِلِهِ وَهُوَ الْمَنْعُ (وَاللَّهُ أَعْلَمُ) وَصَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرُّوضَةِ أَخْذًا مِنْ قُوَّةِ كَلَامِ الشَّرْحِ، وَوَجْهُ الْمَنْعِ بِالْحَذَرِ مِنَ التَّطَرُّقِ إِلَى ارْتِكَابِ حَرَامٍ، وَالصَّوْمُ لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْحِنْثِ، (وَ) لَهُ تَقْدِيمٌ (كَفَّارَةِ ظَهَارٍ<sup>(١)</sup> عَلَى الْعَوْدِ وَ) كَفَّارَةُ (قَتْلِ عَلَى الْمَوْتِ، وَ) تَقْدِيمٌ (مَنْذُورٍ مَالِيٍّ) عَلَى الْمُعْلَقِ عَلَيْهِ، كَشِفَاءِ الْمَرِيضِ فِي قَوْلِهِ: إِنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُعْتِقَ عَبْدًا، وَالْمُرَادُ فِي الْجَمِيعِ: التَّقْدِيمُ بَعْدَ الْحَلْفِ وَالظَّهَارِ وَالْجَرْحِ وَالنَّذْرِ الْأَسْبَابُ الْأُولَى، وَالْحِنْثُ وَمَا بَعْدَهُ الْأَسْبَابُ الثَّوَانِي، فَلَا يَجُوزُ التَّقْدِيمُ عَلَى السَّبَبَيْنِ، وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ الصَّوْمِ عَلَى الْمَوْتِ، وَصَوِّرُوا التَّقْدِيمَ عَلَى الْعَوْدِ بِمَا إِذَا ظَاهَرَ مِنْ رَجْعِيَّةٍ ثُمَّ كَفَّرَ ثُمَّ رَاجَعَهَا، وَبِمَا إِذَا طَلَّقَ بَعْدَ الظَّهَارِ رَجْعِيًّا ثُمَّ كَفَّرَ ثُمَّ رَاجَعَ أَمَّا إِذَا أُعْتِقَ عَقِبَ الظَّهَارِ عَنْهُ فَهُوَ تَكْفِيرُهُ مَعَ الْعَوْدِ لَا قَبْلَهُ لِأَنَّ اشْتِغَالَهُ بِالْإِعْتَاقِ عَوْدٌ.

---

(١) الظهار لغة: مأخوذ من الظهر، ولفظ ظهر يطلق لغة على معان منها: مقابلة الظهر للظهر حقيقة: يقال: ظاهرته، إذا قابلت ظهره حقيقة. والبروز بعد الخفاء: يقال: ظهر لي رأي، إذا علمت ما لم تكن علمته.

والظهار شرعاً: أن يُشَبَّه الرجل زوجته في الحرمة بإحدى محارمه، بنسب، أو رضاع أو مصاهرة، أو ببعضها، فيقول الرجل إذا أراد الامتناع عن الاستمتاع بزوجه: أنت علي كظهر أمي، أو أختي أو غيرهما، فمتى فعل ذلك فقد ظاهر من امرأته.

## [صفة كفارة اليمين<sup>(١)</sup>]

(فصل: يَتَخَيَّرُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ بَيْنَ عَتَقِ كَالظَّهَارِ) أَيِ كَعْتَقِ كَفَّارَتِهِ وَهُوَ عَتَقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ بِلَا عَيْبٍ يُخْلُ بِالْعَمَلِ وَالْكَسْبِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي مَحَلِّهِ. (وَإِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ كُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّ حَبٍّ مِنْ غَالِبِ قُوْتِ بَلَدِهِ أَوْ كِسْوَتُهُمْ بِمَا يُسَمَّى كِسْوَةً كَقَمِيصٍ أَوْ عِمَامَةٍ أَوْ إِزَارٍ) أَوْ رِدَاءٍ (لَا خُفٍّ وَقُقَّازِينَ وَمِنْطَقَةٍ) بِكُسْرِ الْمِيمِ وَتَقَدَّمَ تَفْسِيرُ الثَّلَاثَةِ فِي بَابِي رِكَاهِ النَّقْدِ وَمَحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ، (وَلَا تُشْتَرِطُ صِلَاحِيَّتُهُ) أَيِ مَا يُكْسَى (لِلْمَدْفُوعِ إِلَيْهِ فَيَجُوزُ سَرَاوِيلُ صَغِيرٍ لِكَبِيرٍ لَا يَصْلُحُ لَهُ وَ) يَجُوزُ. (قُطْنٌ وَكَتَّانٌ وَحَرِيرٌ لِامْرَأَةٍ وَرَجُلٍ وَلَبِيسٌ<sup>(٢)</sup>) لَمْ تَذْهَبْ قُوَّتُهُ<sup>(٣)</sup> فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الثَّلَاثَةِ أَيِ كُلِّ مِنْهَا<sup>(٤)</sup> (لَزِمَهُ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) لِلْآيَةِ<sup>(٥)</sup>. (وَلَا يَجِبُ تَتَابُعُهَا فِي الْأَظْهَرِ)؛ لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ، وَالثَّانِي: يَجِبُ احْتِيَاطٌ<sup>(٦)</sup>، (وَإِنْ غَابَ مَالُهُ انْتَهَرَهُ وَلَمْ يَصُمْ) لِأَنَّهُ وَاجِدٌ<sup>(١)</sup>.

---

(١) واختصت من بين الكفارات بكونها مخيرة في الابتداء مرتبة في الانتهاء، والصحيح في سبب وجوبها عند الجمهور: الحنث واليمين معا.

(٢) بفتح اللام بعدها موحدة مكسورة بمعنى ملبوس.

(٣) فَإِنْ ذَهَبَتْ بَحِيْثٌ صَارَ مَسْحَقًا لَمْ يَجْزِ وَلَا بَدَّ مَعَ بَقَاءِ قُوْتِهِ مِنْ كَوْنِهِ غَيْرَ مَنْخَرَقٍ.

(٤) المراد بالعجز ألا يقدر على المال الذي يصرفه في الكفارة كمن يجد كفايته وكفاية من تلزمه مؤنته فقط ولا يجد ما يفضل عن ذلك.

(٥) وهي قوله تعالى: (كفارته إطعام عشرة مساكين ..... ) الآية.

(٦) ولأن ابن مسعود قرأ: "ثلاثة أيام متتابعات"، والقراءة الشاذة كخبر الواحد في وجوب العمل كما أوجبنا قطع يد السارق بالقراءة الشاذة في قوله تعالى: (والسارق

### [الحلف على السكنى]

(فصل: حَلَفَ لَا يَسْكُنُهَا) أَيِ هَذِهِ الدَّارِ (أَوْ لَا يُقِيمُ فِيهَا) وَهُوَ فِيهَا (فَلْيَخْرُجْ فِي الْحَالِ) لِيَخْلُصَ مِنَ الْحَلِفِ، وَلَا يَحْنُثُ لَوْ خَرَجَ وَتَرَكَ فِيهَا أَهْلَهُ وَمَتَاعَهُ (فَإِنْ مَكَثَ بِهَا عُدْرٍ حَنِثَ، وَإِنْ بَعَثَ مَتَاعَهُ) وَأَهْلَهُ كَمَا لَوْ لَمْ يَبْعَثْهُمَا؛ لِأَنَّ حَلْفَهُ عَلَى سُكْنَى نَفْسِهِ، وَإِنْ مَكَثَ لِعُدْرٍ كَأَنْ أَغْلَقَ عَلَيْهِ الْبَابَ، أَوْ مُنِعَ مِنَ الْخُرُوجِ أَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ لَوْ خَرَجَ لَمْ يَحْنُثْ (وَإِنْ اشْتَغَلَ بِأَسْبَابِ الْخُرُوجِ، كَجَمْعِ مَتَاعٍ وَإِخْرَاجِ أَهْلِ وَلُبْسِ ثَوْبٍ) لِلْخُرُوجِ (لَمْ يَحْنُثْ) بِمُكْتَنِهِ لِمَا ذُكِرَ كَمَا لَوْ عَادَ لَهُ بَعْدَ الْخُرُوجِ فِي الْحَالِ.

(وَلَوْ حَلَفَ لَا يُسَاكِنُهُ فِي هَذِهِ الدَّارِ فَخَرَجَ أَحَدُهُمَا فِي الْحَالِ لَمْ يَحْنُثْ، وَكَذَا لَوْ بَنَى بَيْنَهُمَا جِدَارًا وَلِكُلِّ جَانِبٍ مَدْخَلٌ) لَا يَحْنُثُ (فِي الْأَصَحِّ) لِاشْتِغَالِهِ بِرَفْعِ الْمَسَاكِنَةِ، وَالثَّانِي: يَحْنُثُ؛ لِحُصُولِهَا إِلَى تَمَامِ الْبِنَاءِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، وَفِي الرُّوْضَةِ كَأَصْلِهَا نِسْبَةً تَصَحِّحُهُ إِلَى الْجُمُهورِ وَتَرْجِيحُ الْأَوَّلِ إِلَى الْبَغْوِيِّ.

---

والسارقة فاقطعوا أيديهما )، ولأن من قاعدة الشافعي رضي الله تعالى عنه حمل المطلق على المقيد من جنسه وهو الظهار والقتل.

(<sup>١</sup>) وإنما أبيح له الصوم إذا لم يجد.

(وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُهَا وَهُوَ فِيهَا أَوْ لَا يَخْرُجُ وَهُوَ خَارِجٌ فَلَا حِنْثَ بِهَذَا)  
الْمَذْكُورِ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى دُخُولًا وَلَا خُرُوجًا<sup>(١)</sup>.

(أَوْ لَا يَتَزَوَّجُ<sup>(٢)</sup> أَوْ لَا يَتَطَهَّرُ<sup>(٣)</sup> أَوْ لَا يَلْبَسُ أَوْ لَا يَرْكَبُ أَوْ لَا يَقُومُ أَوْ لَا يَقْعُدُ فَاسْتَدَامَ هَذِهِ الْأَحْوَالَ) الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا مِنَ التَّزَوُّجِ إِلَى آخِرِهَا (حِنْثٌ، قُلْتُ: تَحْنِثُهُ بِاسْتِدَامَةِ التَّزَوُّجِ وَالتَّطَهُّرِ) الْمُخَالِفُ لِمَا فِي الشَّرْحِ مِنْ عَدَمِ الْحِنْثِ (غَلَطَ؛ لِذُهُولِ<sup>(٤)</sup>) فَإِنَّ الْإِسْتِدَامَةَ فِيهِمَا لَا تَسْمَى تَزَوُّجًا وَتَطَهُّرًا بِخِلَافِهَا فِي بَاقِي الْأَحْوَالِ فَتُسَمَّى لُبْسًا وَرُكُوبًا إِلَى آخِرِهَا، (وَاسْتِدَامَةُ طَيْبٍ لَيْسَتْ تَطْيِبًا فِي الْأَصَحِّ) فَلَا يَحْنُثُ بِهَا الْحَالِفُ لَا يَتَطَيَّبُ (وَكَذًا وَطءٌ وَصَوْمٌ وَصَلَاةٌ<sup>(٥)</sup>) وَاللَّهُ أَعْلَمُ) أَيُّ اسْتِدَامَتِهَا لَيْسَتْ نَفْسُهَا فِي الْأَصَحِّ فَلَا يَحْنُثُ بِاسْتِدَامَتِهَا الْحَالِفُ لَا يَفْعَلُهَا وَيَتَصَوَّرُ فِي الصَّلَاةِ بِنِسْيَانِهَا، وَالْمَسَائِلُ الْأَرْبَعُ ذَكَرَهَا الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ.

---

(١) لأن الدخول الانفصال من خارج إلى داخل والخروج عكسه ولم يوجد ذلك في الاستدامة؛ فلهذا لا يسمى دخولا ولا خروجًا.

(٢) وهو متزوج.

(٣) وهو متطهر.

(٤) بزال معجمة وهو نسيان الشيء والغفلة عنه إذ لا يقال تزوجت شهرا بل من شهر لأن التزوج قبول العقد.

(٥) بأن يحلف في الصلاة ناسيا أنه فيها أو كان أخرس وحلف بالإشارة فلا يحنث باستدامتها على الأصح.

(وَمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارًا حَنْثَ بِدُخُولِ دِهْلِيْزٍ) بِكَسْرِ الدَّالِ (دَاخِلَ  
 الْبَابِ) لَا ثَانِي لَهُ (أَوْ بَيْنَ بَابَيْنِ لَا بِدُخُولِ طَاقٍ) مَعْقُودٍ (قُدَّامَ الْبَابِ<sup>(١)</sup>)  
 وَقِيلَ: يَحْنَثُ بِهِ؛ لِدُخُولِهِ فِي النِّبْعِ (وَلَا بِصُعُودِ سَطْحٍ) مِنْ خَارِجِهَا  
 (غَيْرَ مَحُوطٍ<sup>(٢)</sup>)، وَكَذَا مَحُوطٌ) مِنْ الْجَوَانِبِ الْأَرْبَعَةِ<sup>(٣)</sup> (فِي الْأَصَحِّ)  
 وَالثَّانِي: يَحْنَثُ لِإِخَاطَةِ حَيْطَانِ الدَّارِ بِهِ.

(وَلَوْ أَدْخَلَ يَدَهُ أَوْ رَأْسَهُ أَوْ رِجْلَهُ) فِيهَا (لَمْ يَحْنَثْ) لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ (فَإِنْ  
 وَضَعَ رِجْلَيْهِ فِيهَا مُعْتَمِدًا عَلَيْهِمَا حَنْثٌ) لِأَنَّهُ نَوَّعَ مِنَ الدُّخُولِ، فَإِنْ  
 مَدَّهُمَا فِيهَا وَهُوَ قَاعِدٌ خَارِجُهَا لَمْ يَحْنَثْ (وَلَوْ انْهَدَمَتْ فَدَخَلَ وَقَدْ بَقِيَ  
 أَسَاسُ الْحَيْطَانِ حَنْثٌ) لِبَقَاءِ اسْمِ الدَّارِ (وَإِنْ صَارَتْ فَضَاءً أَوْ جُعِلَتْ  
 مَسْجِدًا أَوْ حَمَامًا أَوْ بُسْتَانًا فَلَا) يَحْنَثُ؛ لِزَوَالِ اسْمِ الدَّارِ.

(وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ زَيْدٍ حَنْثَ بِدُخُولِ مَا يَسْكُنُهَا بِمِلْكٍ لَا بِإِعَارَةٍ  
 وَإِجَارَةٍ وَغَضَبٍ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ) بِدَارِهِ (مَسْكَنُهُ) فَيَحْنَثُ بِالْمِلْكِ وَغَيْرِهِ  
 (وَيَحْنَثُ بِمَا يَمْلِكُهُ وَلَا يَسْكُنُهُ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ) بِدَارِهِ (مَسْكَنُهُ) فَلَا يَحْنَثُ بِمَا  
 لَا يَسْكُنُهُ، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْإِضَافَةَ إِلَى مَنْ يَمْلِكُ تَقْتَضِي الْمِلْكِ.

(١) لأنه وإن كان منها ويدخل في بيعها لا يقال لمن دخله أنه دخلها وفسر الراجعي  
 الطاق بالمقعود خارج الباب وهو ما يعمل لبعض أبواب الأكاير.

(٢) لأنه لا يسمى داخل الدار لغة ولا عرفاً لأنه حاجز يقي الدار الحر والبرد فهو  
 كحيطانها.

(٣) بخشب أو قصب أو نحو ذلك.

(وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ زَيْدٍ أَوْ لَا يُكَلِّمُ عَبْدَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ فَبَاعَهُمَا<sup>(١)</sup>)، أَوْ طَلَّقَهَا<sup>(٢)</sup>، فَدَخَلَ وَكَلَّمَ لَمْ يَحْنَثْ) لِرِزَالِ الْمَلِكِ بِالْبَيْعِ وَالطَّلَاقِ<sup>(٣)</sup>. (إِلَّا أَنْ يَقُولَ: دَارُهُ هَذِهِ، أَوْ زَوْجَتُهُ هَذِهِ، أَوْ عَبْدُهُ هَذَا، فَيَحْنَثُ) تَغْلِيْبًا لِلإِشَارَةِ (إِلَّا أَنْ يُرِيدَ مَا دَامَ مِلْكُهُ) فَلَا يَحْنَثُ. (وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُهَا مِنْ ذَا الْبَابِ، فَفَرَعَ وَنَصَبَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْهَا، لَمْ يَحْنَثْ بِالثَّانِي، وَيَحْنَثُ بِالْأَوَّلِ فِي الْأَصَحِّ) فِيهِمَا؛ حَمَلًا لِلْيَمِينِ عَلَى الْمَنْفَذِ دُونَ الْمَنْصُوبِ الْخَشَبُ وَنَحْوُهُ، وَالثَّانِي: الْعَكْسُ؛ حَمَلًا عَلَى الْمَنْصُوبِ، وَالثَّلَاثُ: لَا يَحْنَثُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ حَمَلًا عَلَى الْمَنْفَذِ وَالْمَنْصُوبِ مَعًا، هَذَا إِنْ أُطْلِقَ، فَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ بَعْضَ هَذِهِ الْمَحَامِلِ حُمِلَ عَلَيْهِ قَطْعًا.

(أَوْ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا حَنْثَ بِكُلِّ بَيْتٍ مِنْ طِينٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ آجَرٍ أَوْ خَشَبٍ أَوْ خَيْمَةٍ<sup>(٤)</sup>) أَوْ صُوفٍ أَوْ شَعْرٍ أَوْ وَبَرٍ أَوْ جِلْدٍ، فَإِنْ نَوَى نَوْعًا مِنْهَا حُمِلَ عَلَيْهِ (وَلَا يَحْنَثُ بِمَسْجِدٍ وَحَمَّامٍ وَكَنِيسَةٍ وَغَارٍ جَبَلٍ) لِأَنَّهَا لَا يَقَعُ عَلَيْهَا اسْمُ الْبَيْتِ إِلَّا بِتَقْيِيدٍ<sup>(٥)</sup>.

(١) أي الدار والعبء.

(٢) أي زوجته طلاقاً بائناً أو رجعيًا وانقضت عدتها، فإن كان الطلاق رجعيًا ولم تنقض العدة وكلم الزوجة حنث؛ لأن الرجعية في حكم الزوجات.

(٣) أي زوال الزوجية.

(٤) سواء أكان الحالف حضريًا أم بدويًا لأن اسم البيت يقع على ذلك كله حقيقة في اللغة كما لو حلف لا يأكل الخبز فإنه يحنث بجميع أنواعه.

(٥) فلا يشكل ذلك بتسمية المسجد بيتًا في قوله تعالى: (في بيوت أذن الله أن ترفع)، ولا بتسمية الكعبة بيتًا في قوله تعالى: (وطهر بيتي للطائفين)، كما لو حلف لا

(أَوْ لَا يَدْخُلُ عَلَى زَيْدٍ فَدَخَلَ بَيْتًا فِيهِ زَيْدٌ وَغَيْرُهُ) عَالِمًا بِذَلِكَ (حَنْثٌ<sup>(١)</sup>)، وَفِي قَوْلٍ: إِنَّ نَوَى الدُّخُولِ عَلَى غَيْرِهِ دُونَهُ لَا يَحْنُثُ (كَمَا فِي مَسْأَلَةِ السَّلَامِ الْآتِيَةِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الدُّخُولَ لَا يَتَّبَعُ بِخِلَافِ السَّلَامِ. (فَلَوْ جَهَلَ حُضُورَهُ) فِي الْبَيْتِ (فَخِلَافُ حَنْثِ النَّاسِي) وَالْجَاهِلِ فِي ذَلِكَ؛ الْأَظْهَرُ مِنْهُ: عَدَمُ الْحَنْثِ.

(قُلْتُ: وَلَوْ حَلَفَ لَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِ؛ فَسَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ هُوَ فِيهِمْ) علمه (وَاسْتِنَاءُ) بِاللَّفْظِ أَوْ بِالنِّيَّةِ (لَمْ يَحْنُثْ، وَإِنْ أَطْلَقَ حَنْثٌ فِي الْأَظْهَرِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ) لِيُظْهِرَ اللَّفْظُ فِي الْجَمِيعِ، وَالثَّانِي: وَجْهٌ بِأَنَّ اللَّفْظَ صَالِحٌ لِلْجَمِيعِ وَلِلْبَعْضِ فَلَا يَحْنُثُ بِالشَّكِّ، وَلَوْ جَهَلَهُ فِيهِمْ لَمْ يَحْنُثْ فِي الْأَظْهَرِ؛ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ.

### الحلف على أكل أو شرب

مع بيان ما يتناول به بعض المأكولات

(فَصْلٌ: حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الرُّعُوسَ وَلَا نِيَّةً لَهُ حَنْثَ بَرْعُوسٍ تَبَاعُ وَحَدَهَا) وَهِيَ رُعُوسُ الْعَنْمِ وَالْبَقَرِ وَالْإِبِلِ (لَا) بَرْعُوسٍ (طَيْرٍ وَحُوتٍ وَصَيْدٍ إِلَّا بِبَلَدٍ تَبَاعُ فِيهِ مُفْرَدَةً) ، فَيَحْنُثُ بِأَكْلِهَا فِيهِ بِخِلَافِ أَكْلِهَا فِي غَيْرِهِ، فَلَا يَحْنُثُ بِهِ فِي وَجْهِ صَحْحَةِ الْمُصَنَّفِ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ وَفِي الرُّوْضَةِ كَأَصْلِهَا، وَرَجَحَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالثَّوْيَانِيُّ، وَالْأَقْوَى: الْحَنْثُ، وَهُوَ

---

يجلس على بساط فجلس على الأرض فإنه لا يحنث مع أن الله تعالى سماها بساطا وكما لو حلف لا يجلس عند سراج فجلس عند الشمس مع أن الله تعالى سماها سراجا.

(١) لوجود صورة الدخول عليه.

أَقْرَبُ إِلَى ظَاهِرِ النَّصِّ، وَهَلْ يُعْتَبَرُ نَفْسُ الْبَلَدِ الَّذِي يَنْتَبِثُ فِيهِ الْعُرْفُ أَمْ كَوْنُ الْحَالِفِ مِنْ أَهْلِهِ؟ وَجَهَانٍ، فَإِنْ قَصَدَ أَنْ لَا يَأْكُلَ مَا يُسَمَّى رَأْسًا حَنْثَ بِرَأْسِ السَّمَكِ وَالطَّيْرِ وَغَيْرِهِ، وَإِنْ قَصَدَ نَوْعًا خَاصًّا لَمْ يَحْنَثْ بِغَيْرِهِ. انْتَهَى.

(وَالْبَيْضُ) إِذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُهُ (يَحْمِلُ عَلَى مُزَايِلِ بَائِضِهِ فِي الْحَيَاةِ كَذَجَاجٍ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ (وَنَعَامَةٍ وَحَمَامٍ، لَا سَمَكٍ وَجَرَادٍ) لِأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْهُ بَعْدَ الْمَوْتِ بِشِقِّ الْبَطْنِ فَيَحْنَثُ بِأَكْلِ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي.

(وَاللَّحْمُ) إِذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُهُ يُحْمَلُ (عَلَى نَعَمٍ) أَيِ إِبِلٍ وَبَقَرٍ وَغَنَمٍ (وَحَيْلٍ وَوَحْشٍ وَطَيْرٍ) مَأْكُولِينَ<sup>(١)</sup> فَيَحْنَثُ بِالْأَكْلِ مِنْ مُذَكَّاهَا، وَفِي الْمَيْتَةِ وَمَا لَا يُؤْكَلُ كَالذَّنْبِ وَجَهَانٍ، رَجَّحَ الْقَوْلُ وَغَيْرُهُ الْحَنْثَ، وَالشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالرُّوْيَانِيُّ: الْمَنْعُ، قَالَ فِي الرُّوضَةِ: الْمَنْعُ أَقْوَى (لَا سَمَكٍ وَجَرَادٍ) لِأَنَّهُمَا لَا يُفْهَمَانِ مِنْ إِبْطَالِ اللَّحْمِ عُرْفًا<sup>(٢)</sup> (وَشَحْمِ بَطْنٍ) وَشَحْمِ عَيْنٍ؛ لِأَنَّهُمَا يُخَالِفَانِ اللَّحْمَ فِي الصِّفَةِ كَالِاسْمِ (وَكَذَا كَرِشٍ<sup>(٣)</sup> وَكَبِدٍ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِمَا

---

(١) لوقوع اسم اللحم عليه حقيقة.

(٢) وإن سماه الله تعالى لحماً؛ ولهذا يصح أن يقال ما أكلت لحماً بل سمكا كما لا يحنث بالجلوس على الأرض إذا حلف لا يجلس على بساط، وإن سماها الله تعالى بساطاً.

(٣) بكسر الزاء ويجوز إسكانها مع فتح الكاف وكسرها وهو للحيوان كالمعدة للإنسان.



وَكَسَّرِ تَانِيَهُمَا (وَطَحَالَ) بِكَسْرِ الطَّاءِ (وَقَلْبِ) وَمَعَى وَرِئَةً (فِي الْأَصَحِّ<sup>(١)</sup>) وَالثَّانِي: نَظَرَ إِلَى أَنَّهَا تُقَامُ مَقَامَ اللَّحْمِ.

(وَالْأَصَحُّ: تَتَاوَلُهُ) ، أَيِ اللَّحْمِ (لَحْمَ رَأْسٍ وَلِسَانٍ) وَخَدَ وَأَكَارِعَ، وَالثَّانِي يَقُولُ: لَا يُفْهَمُ مِنْ إِبْطَاقِ اللَّحْمِ عُرْفًا<sup>(٢)</sup>، (وَشَحْمَ ظَهْرٍ وَجَنْبٍ) وَهُوَ الْأَبْيَضُ الَّذِي لَا يُخَالِطُهُ الْأَحْمَرُ؛ لِأَنَّهُ لَحْمٌ سَمِينٌ، وَلِهَذَا يَحْمَرُ عِنْدَ الْهَزَالِ، وَالثَّانِي: نَظَرَ إِلَى اسْمِ الشَّحْمِ<sup>(٣)</sup>، وَيُنَبِّنِي عَلَيْهِمَا الْخِلَافُ فِي قَوْلِهِ: (وَأَنَّ شَحْمَ الظَّهْرِ لَا يَتَنَاوَلُهُ الشَّحْمُ) إِذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُهُ<sup>(٤)</sup> (وَأَنَّ الْأَلْيَةَ وَالسَّنَامَ) بَفَتْحِ أَوَّلِهِمَا (لَيْسَا شَحْمًا وَلَا لَحْمًا) أَيِ لَيْسَ كُلُّ مِنْهُمَا مَا ذُكِرَ؛ لِمُخَالَفَتِهِ لَهُ فِي الْإِسْمِ وَالصِّفَةِ، فَلَا يَحْنُثُ بِهِمَا مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ شَحْمًا وَلَا لَحْمًا وَقِيلَ: هُمَا شَحْمٌ، وَقِيلَ: لَحْمٌ فَيَحْنُثُ.

(وَالْأَلْيَةُ لَا تَتَنَاوَلُ سَنَامًا وَلَا يَتَنَاوَلُهَا) فَلَا يَحْنُثُ مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ. (وَالدَّسَمُ يَتَنَاوَلُهُمَا) وَشَحْمَ ظَهْرٍ وَبَطْنٍ (وَكُلُّ دُهْنٍ) فَيَحْنُثُ بِأَكْلِ أَحَدِهَا مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ دَسَمًا، (وَلَحْمُ الْبَقَرِ يَتَنَاوَلُ

---

(١) لأنه يصح أن يقال أنها ليست لحماً.

(٢) وينبغي أن يكون الأذان كذلك وأما الجلد فلا يحنث به الحالف لا يأكل لحماً لأنه لا يؤكل غالباً لأنه جنس غير اللحم.

(٣) قال تعالى: (حرماً عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما) أي: ما علق بها منه فسماه شحماً، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك.

(٤) لما مر أنه لحم، والثاني: يتناوله؛ لما مر أيضاً أنه شحم، أما شحم البطن فيحنث به جزماً.

جَامُوسًا) فَيَحْنُثُ بِأَكْلِهِ مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمَ بَقَرٍ، وَيَحْنُثُ بِبَقْرِ الْوَحْشِ  
أَيْضًا.

(وَلَوْ قَالَ) فِي حَلْفِهِ (مُشِيرًا إِلَى حِنْطَةٍ: لَا آكُلُ هَذِهِ، حَنْثٌ بِأَكْلِهَا عَلَى  
هَيْئَتِهَا وَبِطَحِينِهَا وَخُبْرِهَا) عَمَلًا بِالْإِشَارَةِ. (وَلَوْ قَالَ) فِيهِ (لَا آكُلُ هَذِهِ  
الْحِنْطَةَ حَنْثٌ بِهَا مَطْبُوحَةً وَنَبِيئَةً وَمَقْلِيَّةً) بِفَتْحِ الْمِيمِ، (لَا بِطَحِينِهَا  
وَسَوِيْقِهَا وَعَجِينِهَا وَخُبْرِهَا) لِرِزَالِ اسْمِهَا.

(وَلَا يَتَنَاولُ رُطْبٌ تَمْرًا وَلَا بُسْرًا، وَلَا عِنَبٌ زَبِيبًا، وَكَذَا الْعُكُوسُ) فَلَا  
يَحْنُثُ بِأَكْلِ التَّمْرِ مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ رُطْبًا وَالْعُكُسُ، وَكَذَا الْبَاقِي.

(وَلَوْ قَالَ) فِي حَلْفِهِ (لَا آكُلُ هَذَا الرُّطْبَ فَتَتَمَرٌ<sup>(١)</sup> فَأَكَلَهُ، أَوْ لَا أَكَلِمَ ذَا  
الصَّبِيِّ فَكَلَّمَهُ شَيْخًا فَلَا حِنْثٌ) بِهِ (فِي الْأَصَحِّ) لِرِزَالِ الْإِسْمِ، وَالثَّانِي:  
يَحْنُثُ لِبَقَاءِ الصُّورَةِ وَإِنْ تَغَيَّرَتْ الصِّفَةُ.

(وَالْخُبْزُ يَتَنَاولُ كُلَّ خُبْزٍ كَحِنْطَةٍ وَشَعِيرٍ وَأُرْزٍ وَبَاقِلًا<sup>(٢)</sup> وَذُرَّةٍ) بِفَتْحِ  
الْهَمْزَةِ وَضَمِّ الرَّاءِ وَتَشْدِيدِ الزَّايِ وَاللَّامِ مَعَ الْقَصْرِ وَإِعْجَامِ الذَّالِ وَالْهَاءِ  
عَوَضًا مِنْ وَاوٍ أَوْ يَاءٍ (وَحِمَصٍ) بِكسْرِ الْحَاءِ وَفَتْحِ الْمِيمِ وَكسْرِ هَمَا،  
فَيَحْنُثُ بِأَكْلِ أَيِّ مِنْهَا مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ خُبْزًا وَلَا يَضُرُّ كَوْنُهُ غَيْرَ  
مَعْهُودٍ بَلَدِهِ، وَسَوَاءٌ ابْتَلَعَهُ بَعْدَ مَضْغٍ أَمْ دُونَهُ أَكَلَهُ عَلَى هَيْئَتِهِ أَمْ بَعْدَ

(١) أي صار تمرًا.

(٢) اسم للقول.

جَعَلَهُ ثَرِيدًا كَمَا قَالَ (فَلَوْ ثَرَدَهُ) بِالْمُثَلَّثَةِ مُخَفَّفًا (فَأَكَلَهُ حَنِثٌ) لَكِنْ لَوْ صَارَ فِي الْمَرْقَةِ كَالْحَسَوِ فَتَحَسَّاهُ لَمْ يَحْنَثُ.

(وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ سَوِيْقًا فَسَقَهُ أَوْ تَتَاوَلَهُ بِأَصْبُعٍ) مَبْلُولَةٍ (حَنِثٌ) لِأَنَّهُ يُعَدُّ أَكْلًا (وَإِنْ جَعَلَهُ فِي مَاءٍ فَشَرِبَهُ فَلَا) يَحْنَثُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَكْلًا (أَوْ) حَلَفَ (لَا يَشْرِبُهُ) أَيِ السَّوِيْقِ (فَبِالْعَكْسِ) أَيِ يَحْنَثُ فِي الثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى، (أَوْ) حَلَفَ (لَا يَأْكُلُ لَبَنًا أَوْ مَانِعًا آخَرَ) كَالْعَسَلِ (فَأَكَلَهُ بِخُبْزٍ حَنِثٌ) لِأَنَّ أَكْلَهُ كَذَلِكَ (أَوْ شَرِبَهُ فَلَا) يَحْنَثُ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْكُلْهُ (أَوْ) حَلَفَ (لَا يَشْرِبُهُ فَبِالْعَكْسِ) أَيِ يَحْنَثُ فِي الثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى، (أَوْ) حَلَفَ (لَا يَأْكُلُ سَمْنًا فَأَكَلَهُ بِخُبْزٍ جَامِدًا أَوْ ذَائِبًا) بِالْمُعْجَمَةِ (حَنِثٌ) كَمَا لَوْ أَكَلَهُ وَحْدَهُ (وَإِنْ شَرِبَهُ ذَائِبًا فَلَا) يَحْنَثُ (وَإِنْ أَكَلَهُ فِي عَصِيدَةٍ<sup>(١)</sup>) حَنِثٌ إِنْ كَانَتْ عَيْنُهُ ظَاهِرَةً) بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَتْ مُسْتَهْلَكَةً.

(وَيَدْخُلُ فِي فَكِهِةٍ) حَلَفَ لَا يَأْكُلُهَا (رُطْبٌ وَعَنْبٌ وَرُمَانٌ وَأَنْرُجٌ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَالرَّاءِ وَتَشْدِيدِ الْجِيمِ (وَرُطْبٌ وَيَابِسٌ) كَالْتَّمْرِ وَالزَّيْبِ.

(قُلْتُ) أَخَذًا مِنَ الرَّافِعِي فِي الشَّرْحِ (وَلَيْمُونٌ وَنَبَقٌ وَكَذَا بِطِيخٍ) بِكَسْرِ النَّبَاءِ فِيهِمَا (وَلُبٌّ فَسْتُقٍ) بِضَمِّ النَّاءِ وَفَتْحِهَا (وَبُنْدُقٍ وَغَيْرُهُمَا<sup>(٢)</sup>) فِي الْأَصَحِّ) فَهُوَ مِنْ يَابِسِ الْفَاكِهَةِ، وَالثَّانِي: يَنْفِيهَا عَنْهُ وَعَنِ الْبَطِيخِ (لَا

---

(١) وهي كما قاله ابن مالك: دقيق يلت بسمن وبطبخ، قال ابن قتيبة: سميت بذلك؛ لأنها تعصد بالآلة أي: تلوى.

(٢) من اللبوب، كلب لوز وجوز.

قِثَاءٍ) بِكَسْرِ الْقَافِ وَبِالْمُتَثَّنَةِ وَالْمَدِّ (وَحِيَارٌ وَبَاذَنْجَانٌ) بِكَسْرِ الدَّالِ الْمُعْجَمَةِ (وَجَزْرٌ) فَلَيْسَتْ مِنَ الْفَاكِهَةِ.

(وَلَا يَدْخُلُ فِي الثَّمَارِ) بِالْمُتَثَّنَةِ إِذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُهَا (يَابِسٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ) وَهِيَ جَمْعُ ثَمَرٍ<sup>(١)</sup> (وَلَوْ أَطْلُقَ بِطَيِّخٍ وَتَمَرٌ وَجَوْزٌ لَمْ يَدْخُلْ هِنْدِيٌّ) ، مِنْ الثَّلَاثَةِ فِيهَا فَلَا يَحْنُثُ بِأَكْلِهِ مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُهَا، وَالْهِنْدِيُّ مِنَ الْبُطِّيخِ الْأَخْضَرِ.

(وَالطَّعَامُ) إِذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُهُ (يَتَنَاولُ قُوتًا وَفَاكِهَةً وَأُدْمًا وَحُلُوءًا) ، وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ الرِّبَا الدَّوَاءُ وَفِيهِ هُنَا وَجْهَانِ.

(وَلَوْ قَالَ) فِي حَلْفِهِ (لَا أَكُلُ مِنْ هَذِهِ الْبَقَرَةِ تَنَاولَ لَحْمَهَا) فَيَحْنُثُ بِهِ (دُونَ وَلَدٍ) لَهَا (وَلَبَنِ) مِنْهَا فَلَا يَحْنُثُ بِهِمَا (أَوْ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَتَمَرٌ) يَحْنُثُ بِهِ (دُونَ وَرَقٍ وَطَرَفٍ غُصْنٍ) مِنْهَا عَمَلًا فِي الْحِنْثِ بِالْمُتَعَارَفِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ.

فَصَلَ (حَلَفَ لَا يَأْكُلُ هَذِهِ الثَّمَرَةَ فَاخْتَلَطَتْ) بِتَمَرٍ (فَأَكَلَهُ إِلَّا تَمَرَةً لَمْ يَحْنُثْ) لِحَوَازٍ أَنْ تَكُونَ الْمَتْرُوكَةُ هِيَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهَا. (أَوْ لِيَأْكُلَنَّهَا فَاخْتَلَطَتْ) بِتَمَرٍ (لَمْ يَبْرَ إِلَّا بِالْجَمِيعِ) لِاخْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ الْمَتْرُوكَةُ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهَا. (أَوْ لِيَأْكُلَنَّ هَذِهِ الرِّمَاطِيَّةَ فَإِنَّمَا يَبْرُ بِجَمِيعِ حَبِّهَا) وَلَوْ قَالَ

---

(١) فلا يحنث بأكله بخلاف الفاكهة ويدخل فيها يابسها، وفرق بأن الثمر اسم للرطب من الفاكهة، وصوب البلقيني إطلاقه على اليابس أيضا، وقال: أهل العرف يطلقون عليها ثمرا بعد اليبس.

لَا أَكُلُهَا فَتَرَكَ حَبَّةً لَمْ يَحْنُثْ (أَوْ لَا يَلْبَسُ هَذَيْنِ لَمْ يَحْنُثْ بِأَحَدِهِمَا) لِأَنَّ  
الْحَلْفَ عَلَيْهِمَا (فَإِنْ لَبَسَهُمَا مَعًا أَوْ مُرَّتَبًا حَنْثٌ أَوْ لَا أَلْبَسُ هَذَا وَلَا هَذَا  
حَنْثٌ بِأَحَدِهِمَا) لِأَنَّهُمَا يَمِينَانِ (أَوْ لِيَأْكُلَنَّ ذَا الطَّعَامِ غَدًا فَمَاتَ قَبْلَهُ) أَيْ  
الْعَدِ (فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) لِأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ زَمَنَ الْبِرِّ وَالْحَنْثِ (وَإِنْ مَاتَ أَوْ تَلَفَ  
الطَّعَامُ فِي الْعَدِ بَعْدَ تَمَكُّنِهِ مِنْ أَكْلِهِ حَنْثٌ) لِأَنَّهُ تَمَكَّنَ مِنَ الْبِرِّ (وَقَبْلَهُ)  
أَيْ التَّمَكُّنِ (قَوْلَانِ كَمُكْرِهِ) لِأَنَّهُ قَوَّتَ الْبِرَّ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ وَالْأَظْهَرُ فِيهِ:  
عَدَمُ الْحَنْثِ. (وَإِنْ أَتْلَفَهُ بِأَكْلٍ وَغَيْرِهِ قَبْلَ الْعَدِ حَنْثٌ) لِأَنَّهُ قَوَّتَ الْبِرَّ  
بِاخْتِيَارِهِ وَهَلْ الْحَنْثُ فِي الْحَالِ لِحُصُولِ الْيَأْسِ عَنِ الْبِرِّ أَوْ بَعْدَ مَجِيءِ  
الْعَدِ؟ فِيهِ قَوْلَانِ أَوْ وَجْهَانِ، وَعَلَى أَوَّلِهِمَا: لَوْ كَانَتْ كَفَّارَتُهُ بِالصَّوْمِ، جَازَ  
أَنْ يَتَوَيَّ صَوْمَ الْعَدِ عَنْهَا وَعَلَى ثَانِيهِمَا: حَنْثُهُ بِمُضِيِّ زَمَنِ إِمْكَانِ الْأَكْلِ  
مِنَ الْعَدِ أَوْ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْبَغَوِيِّ: الْأَوَّلُ.  
(وَإِنْ تَلَفَ أَوْ أَتْلَفَهُ أَجَنَبِيٌّ) قَبْلَ الْعَدِ (فَكُمُكْرِهِ) لِمَا تَقَدَّمَ وَالْأَظْهَرُ فِيهِ عَدَمُ  
الْحَنْثِ.

(أَوْ لَاقْضِيَنَّ حَقَّكَ عِنْدَ رَأْسِ الْهَلَالِ فَلْيَقْضِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ آخِرَ  
الشَّهْرِ) فَوُفِّتِ الْغُرُوبِ أَوَّلُ جُزْءٍ مِنَ اللَّيْلَةِ الْأُولَى مِنَ الشَّهْرِ. (وَإِنْ قَدَّمَ)  
الْقَضَاءَ عَلَى الْغُرُوبِ (أَوْ مَضَى بَعْدَ الْغُرُوبِ قَدَّرَ إِمْكَانَهُ) أَيْ الْقَضَاءُ  
(حَنْثٌ) فَيَتَبَغْيِي أَنْ بَعْدَ الْمَالِ وَيَتَرَصَّدُ ذَلِكَ الْوَقْتُ فَيَقْضِيهِ فِيهِ. (وَإِنْ  
شَرَعَ فِي الْكَيْلِ) أَوْ الْوَزْنِ (حِينَئِذٍ وَلَمْ يَفْرُغْ لِكَثْرَتِهِ إِلَّا بَعْدَ مُدَّةٍ لَمْ يَحْنُثْ)  
وَبِمِثْلِهِ أُجِيبُ فِيمَا لَوْ ابْتَدَأَ حِينَئِذٍ بِمُقَدِّمَةِ الْقَضَاءِ كَحَمْلِ الْمِيزَانِ.

(أَوْ لَا يَتَكَلَّمُ فَسَبَّحَ) الله (أَوْ قَرَأَ قُرْآنًا فَلَا حِنْثَ) بِهِ لِأَنَّ اسْمَ الْكَلَامِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ يَنْصَرِفُ إِلَى كَلَامِ الْأَدْمِيِّينَ فِي مُحَاوَرَاتِهِمْ وَفِي وَجْهِ أَنَّهُ يَحْنُثُ، (أَوْ لَا يُكَلِّمُهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ حِنْثٌ) لِأَنَّ السَّلَامَ عَلَيْهِ نَوْعٌ مِنَ الْكَلَامِ (وَإِنْ كَاتَبَهُ أَوْ رَاسَلَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدٍ أَوْ غَيْرِهَا) كَرَأْسٍ (فَلَا) حِنْثَ بِهِ (فِي الْجَدِيدِ) اقْتِصَارًا بِالْكَلَامِ عَلَى حَقِيقَتِهِ، وَالْقَدِيمِ: الْحِنْثُ حَمْلًا لِلْكَلَامِ عَلَى الْمَجَازِ مَعَ الْحَقِيقَةِ، وَفِي التَّنْزِيلِ لِلْقَدِيمِ "لَوْ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا" ، وَلِلْجَدِيدِ: {فَلَنْ أَكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا}، {فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ}، (وَإِنْ قَرَأَ آيَةً أَفْهَمَهُ بِهَا مَقْصُودَهُ وَقَصَدَ قِرَاءَةً لَمْ يَحْنُثْ) لِأَنَّهُ لَمْ يُكَلِّمَهُ (وَالْأَيُّ) أَيُّ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ قِرَاءَةً (حِنْثٌ) لِأَنَّهُ كَلَّمَهُ (أَوْ لَا مَالَ لَهُ حِنْثٌ بِكُلِّ نَوْعٍ وَإِنْ قَلَّ حَتَّى ثَوْبٍ بَدَنِهِ) لَصَدَقَ الْإِسْمُ عَلَيْهِ.

(أَوْ لَيَضْرِبَنَّهُ فَالْبُرُّ) فِيهِ (بِمَا يُسَمَّى ضَرْبًا، وَلَا يُشْتَرَطُ) فِيهِ (إِلْيَامٌ) وَقِيلَ يُشْتَرَطُ (إِلَّا أَنْ يَقُولَ ضَرْبًا شَدِيدًا) فَيُشْتَرَطُ فِيهِ الْإِلْيَامُ. (وَلَيْسَ وَضْعُ سَوَطٍ عَلَيْهِ وَعَضُّ وَخَنَقٌ) بِكَسْرِ الثَّوْنِ (وَنَنْفٍ شَعْرٍ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ (ضَرْبًا) قِيلَ وَلَا لَطْمٌ وَوَكْزٌ) أَيُّ دَفْعٌ وَالْأَصَحُّ أَنْ كُلًّا مِنْهُمَا ضَرْبٌ.

(أَوْ لَيَضْرِبَنَّهُ مِائَةً سَوَطٍ أَوْ خَشَبَةٍ فَشَدَّ مِائَةً) مِنَ السَّيَاطِ أَوْ الْخَشَبَاتِ. (وَضَرْبُهُ بِهَا ضَرْبَةٌ أَوْ) ضَرْبُهُ (بِعُتْكَالٍ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَبِالْمُثَلَّثَةِ أَيُّ عُرْجُونٍ (عَلَيْهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ) بِكَسْرِ الشَّيْنِ (بَرٌّ) إِنْ عَلِمَ إِصَابَةَ الْكُلِّ أَوْ تَرَكَهُ بَعْضٌ عَلَى بَعْضٍ فَوَصَلَهُ أَلَمُ الْكُلِّ) وَفِي الرُّوضَةِ كَأَصْلِهَا تَصَحِيحٌ أَنَّهُ لَا يَبْرُّ فِي قَوْلِهِ مِائَةُ سَوَطٍ بِالْعُتْكَالِ.

(قُلْتُ) أَخْذًا مِنَ الرَّافِعِيِّ فِي الشَّرْحِ (وَلَوْ شَكَ فِي إِصَابَةِ الْجَمِيعِ بَرَّ عَلَى النَّصِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ) وَفِي قَوْلٍ مُخَرَّجٍ: أَنَّهُ لَا يَبْرُرُ.

(أَوْ لِيَضْرِبَنَّهُ مِائَةً مَرَّةً لَمْ يَبْرُرْ بِهَذَا) الْمَذْكُورِ مِنَ الْعِتْكَالِ أَوْ الْمِائَةِ الْمَشْدُودَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَضْرِبْهُ بِهِ إِلَّا مَرَّةً.

(أَوْ لَا أَفَارِقُكَ حَتَّى أَسْتَوْفِيَ حَقِّي) مِنْكَ (فَهَرَبَ وَلَمْ يُمَكِّنْهُ اتِّبَاعُهُ لَمْ يَحْنُثْ) بِخِلَافِ مَا إِذَا أُمَكِّنَهُ.

(قُلْتُ) أَخْذًا مِنَ الرَّافِعِيِّ فِي الشَّرْحِ (الصَّحِيحُ: لَا يَحْنُثُ إِذَا أُمَكِّنَهُ اتِّبَاعُهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ) لِأَنَّهُ حَلَفَ عَلَى فِعْلٍ نَفْسِهِ فَلَا يَحْنُثُ بِفِعْلِ غَرِيمِهِ وَالْحِنْثُ مَبْنِيٌّ عَلَى حِنْثِ الْمُكْرَهِ الْمَرْجُوحِ.

(وَإِنْ فَارَقَهُ) الْحَالِفُ (أَوْ وَقَفَ حَتَّى ذَهَبَ) الْغَرِيمُ (وَكَانَا مَاشِيَيْنِ أَوْ أَبْرَأَهُ) مِنَ الْحَقِّ (أَوْ احْتَالَ) بِهِ (عَلَى غَرِيمٍ) لِلْغَرِيمِ (ثُمَّ فَارَقَهُ) فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ (أَوْ أَفْلَسَ) هُوَ أَيْ ظَهَرَ أَنَّهُ مُفْلِسٌ. (فَفَارَقَهُ لِيُوسِرَ) وَفِي الْمُحَرَّرِ إِلَى أَنْ يُوسِرَ. (حِنْثٌ) فِي الْمَسَائِلِ الْخَمْسِ لَوْجُودِ الْمَفَارَقَةِ فِي الْأَوَّلَيْنِ وَالْأَخِيرَةِ، وَلِتَقْوِيَّتِهِ فِي الثَّالِثَةِ الْبَرِّ بِاخْتِيَارِهِ وَلِعَدَمِ الْإِسْتِيفَاءِ الْحَقِيقِيِّ فِي الرَّابِعَةِ بِالِاخْتِيَالِ وَقِيلَ لَا حِنْثٌ فِيهَا نَظَرًا إِلَى تَسْمِيَةِ الْإِحْتِيَالِ اسْتِيفَاءً (وَإِنْ اسْتَوْفَى) حَقَّهُ (وَفَارَقَهُ فَوَجَدَهُ نَاقِصًا إِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ لَكِنَّهُ أَرْدَأُ) مِنْهُ (لَمْ يَحْنُثْ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جِنْسَ حَقِّهِ بِأَنْ كَانَ حَقُّهُ الدَّرَاهِمَ فَخَرَجَ مَا أَخَذَهُ نَحَاسًا أَوْ مَغْشُوشًا (حِنْثٌ عَالِمٌ) بِهِ (وَفِي غَيْرِهِ) وَهُوَ الْجَاهِلُ بِهِ. (الْقَوْلَانِ) فِي حِنْثِ النَّاسِي وَالْجَاهِلِ

أَظْهَرُهُمَا لَا ثُمَّ الْمَفَارَقَةُ الْمُرتَّبُ عَلَيْهَا الْحِنْثُ هِيَ الْقَاطِعَةُ لِخِيَارِ  
الْمَجْلِسِ فِي الْبَيْعِ.

(أَوْ) حَلَفَ (لَا أَرَى مُنْكَرًا إِلَّا رَفَعَهُ إِلَى الْقَاضِي، فَرَأَى) ذَلِكَ (وَتَمَكَّنَ)  
مِنَ الرَّفْعِ (فَلَمْ يَرْفَعْ حَتَّى مَاتَ حَنْثٌ وَيُحْمَلَ عَلَى قَاضِي الْبَلَدِ فَإِنْ  
عُزِلَ) وَتَوَلَّى غَيْرُهُ. (فَالْبُرُّ بِالرَّفْعِ إِلَى الثَّانِي أَوْ إِلَّا رَفَعَهُ إِلَى قَاضٍ بَرٍّ  
بِكُلِّ قَاضٍ) فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ وَغَيْرِهِ. (أَوْ إِلَى الْقَاضِي فَلَا فَرَاهُ) أَيِ الْمُنْكَرِ  
(ثُمَّ عُزِلَ) الْقَاضِي (فَإِنْ نَوَى مَا دَامَ قَاضِيًا حَنْثٌ إِنْ أَمَكَّنَهُ رَفَعَهُ فَتَرَكَهُ  
وَالَّا) أَيِ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنَهُ رَفَعَهُ لِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ. (فَكُمُكْرِهِ) وَالْأَظْهَرُ عَدَمُ  
حَنْثِهِ (وَإِنْ لَمْ يَنْوِ) مَا دَامَ قَاضِيًا (بَرٍّ بِرَفْعِ النَّيَّةِ بَعْدَ عُزْلِهِ) وَيَحْصُلُ  
الرَّفْعُ إِلَى الْقَاضِي بِإِخْبَارِهِ بِرَسُولٍ أَوْ كِتَابٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ صَاحِبِ  
الْمُنْكَرِ.

فَصَلَّ (حَلَفَ لَا يَبِيعُ أَوْ لَا يَشْتَرِي تَعَقَّدَ لِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ) بِوَلَايَةِ أَوْ وَكَالَةِ  
(حَنْثٌ وَلَا يَحْنُثُ بَعْدَ وَكِيلِهِ لَهُ أَوْ لَا يُرَوِّجُ أَوْ لَا يُطْلِقُ أَوْ لَا يُعْتِقُ أَوْ  
لَا يَضْرِبُ فَوَكَّلَ مَنْ فَعَلَهُ لَا يَحْنُثُ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ أَنْ لَا يَفْعَلَ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ)  
فَيَحْنُثُ. (أَوْ لَا يَنْكِحُ حَنْثٌ بَعْدَ وَكِيلِهِ لَهُ لَا يَقْبُولُهُ هُوَ لِعَيْرِهِ) لِأَنَّ  
الْوَكِيلَ فِي قَبُولِ النِّكَاحِ سَفِيرٌ مَحْضٌ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ تَسْمِيَةِ الْمُوَكَّلِ، (أَوْ  
لَا يَبِيعُ مَالَ زَيْدٍ قَبَاعَهُ بِإِذْنِهِ حَنْثٌ وَالَّا) أَيِ وَإِنْ بَاعَهُ مِنْ غَيْرِ إِذْنِهِ  
(فَلَا) حَنْثٌ لِفَسَادِ الْبَيْعِ وَهُوَ فِي الْحَلْفِ مُنْزَلٌ عَلَى الصَّحِيحِ، (أَوْ لَا  
يَهَبُ لَهُ فَأَوْجَبَ لَهُ فَلَمْ يَقْبَلْ لَمْ يَحْنُثْ) لِعَدَمِ تَمَامِ الْعَقْدِ (وَكَذَا إِنْ قِيلَ وَلَمْ  
يَقْبِضْ) لَا يَحْنُثُ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ مَقْصُودَ الْهَبَةِ مِنْ نَقْلِ الْمِلْكِ لَمْ



يَحْصُلُ، وَالثَّانِي: نَظَرَ إِلَى تَمَامِ الْعَقْدِ (وَيَحْنُثُ) الْحَالِفُ لَا يَهَبُ.  
(بِعُمْرِي وَرُقْبِي وَصَدَقَةٍ) لِأَنَّهَا أَنْوَاعٌ مِنَ الْهَبَةِ مَذْكُورَةٌ فِي بَابِهَا (لَا إِعَارَةَ  
وَوَصِيَّةٍ وَوَقْفٍ) فَلَيْسَتْ مِنْ مُسَمًّى الْهَبَةِ.

(أَوْ لَا يَتَصَدَّقُ لَمْ يَحْنُثْ بِهَبَةٍ فِي الْأَصَحِّ) وَالثَّانِي يَحْنُثُ بِهَا كَعَكْسِهِ  
وَقَالَ الْأَوَّلُ الصَّدَقَةُ أَحْصُ مِنَ الْهَبَةِ كَمَا تَقَدَّمَ فَلَا يَحْنُثُ بغيرِهَا، مِنْ  
الْهَبَةِ، (أَوْ لَا يَأْكُلُ طَعَامًا اشْتَرَاهُ زَيْدٌ لَمْ يَحْنُثْ بِمَا اشْتَرَاهُ مَعَ غَيْرِهِ)  
كَعَمَرُو شَرِكَةً. (وَكَذَا لَوْ قَالَ مِنْ طَعَامٍ اشْتَرَاهُ زَيْدٌ) لَمْ يَحْنُثْ بِمَا ذَكَرَ  
(فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْهُ مُشْتَرَكٌ، وَالثَّانِي قَالَ بِدُخُولِ مَنْ يُصَدِّقُ  
الْأَكْلَ مِمَّا اشْتَرَاهُ زَيْدٌ (وَيَحْنُثُ بِمَا اشْتَرَاهُ سَلَمًا) لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنَ الشِّرَاءِ (وَلَوْ  
اخْتَلَطَ مَا اشْتَرَاهُ بِمُشْتَرَى غَيْرِهِ لَمْ يَحْنُثْ) بِالْأَكْلِ مِنَ الْمُخْتَلِطِ (حَتَّى  
يَتَيَقَّنَ لَهُ مِنْ مَالِهِ) بَأَن يَأْكُلَ كَثِيرًا كَالْكَفِّ وَالْكَفَّيْنِ بِخِلَافِ الْقَلِيلِ كَعَشْرِ  
حَبَّاتٍ وَعِشْرِينَ حَبَّةً، فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَالِ الْآخَرِ.

(أَوْ لَا يَدْخُلُ دَارًا اشْتَرَاهَا زَيْدٌ لَمْ يَحْنُثْ بِدَارٍ أَخَذَهَا) أَيَّ بَعْضَهَا (بِشَفْعَةٍ)  
لِأَنَّ الْأَخْذَ بِهَا لَا يُسَمَّى شِرَاءً عُرْفًا.

## (كِتَابُ النَّذْرِ<sup>(١)</sup>)

(١) النذر في اللغة هو الوعد سواء كان بخير أو بشر، وشرعا: هو الوعد بخير خاصة، وقيل: هو التزام قربة لم تتعين بأصل الشرع، وقد ذكره المصنف عقب الأيمان لأن كلا منهما عقد يعقده المرء على نفسه تأكيدا لما التزمه ولأن النذر يتعلق به كفارة ككفارة اليمين.

والأصل في وجوب الوفاء بالنذر الكتاب والسنة، فمن الكتاب: قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، فالآية توجه أمراً للمؤمنين أن يوفوا بما التزموه عموماً سواء كان ذلك مع النفس كاليمين والنذر أو مع الغير كالتعاقدات. ومن الكتاب أيضاً قوله تعالى: (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئلاً)، أي: مسئلاً عنه.

والفرق بين العقد والعهد في الآيتين يأتي من وجهين، أحدهما: أن العقد ما كان بين متعاقدين والعهد ينفرد فيه الإنسان في حقه، والثاني: أن العقد التزام بوثيقة والعهد التزام بغير وثيقة وبذلك يكون العقد أؤكد من العهد ومن أجل الاختلاف بينهما أمر بهما في موضعين مختلفين.

وأما عن دليل السنة في وجوب الوفاء بالنذر، فمنه ما رواه الشافعي: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ»، ومن السنة أيضاً: ما روي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يأتي النذر على بن آدم شيئاً لم أقدره عليه ولكنه شيء استخرج به من البخل". وفي الحديث دلالة أخرى وهي أن الذي يبذل بالبر أفضل من الذي يبذل بالتزام النذر.

وقد اختلف فقهاء الشافعية في هل النذر مكروه أو قربة، على وجهين، الأول: يرى أنه مكروه، وقد اختاره النووي رحمه الله واستدل له بالحديث السابق إن النذر لا يرد شيئاً ولكن يستخرج به من البخل، والوجه الثاني: يرى أن النذر قربة من القرب وقد نقل هذا عن القاضي حسين والمتولي والغزالي.

## أنواع النذر

أركان النذر ثلاثة: ناذر وصيغة ومنذور، الركن الأول الناذر: وهو الشخص الذي نوى النذر ويشترط فيه التكليف وهو البلوغ والعقل، والإسلام والاختيار ونفوذ التصرف فيما ينذره، فلا يصح النذر من غير المكلف كالصبي والمجنون لأنهما ليسا أهلاً لذلك، وهناك خلاف في السكران، والأصح: أنه يصح نذره، وإن كان غير مكلف لتعديه بسكره، ولا يصح النذر من الكافر لعدم الأهلية للقربة أو الالتزام بها.

ولا يصح النذر من مكره عليه لخبر أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنَّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»، ولا يصح النذر ممن لا ينفذ تصرفه فيما ينذره وذلك كما لو نذر السفينة قربة مالية لأن السفينة لا يحسن التصرف في المال حتى وإن كانت عينية كعتق عبده، ويصح النذر من السفينة والمفلس في القرب البدنية كأن يعمل في بناء مسجد يوماً أو أكثر بغير أجر، وكذلك لا حجر على السفينة أو المفلس في القرب المالية التي في الذمة فيصح النذر منهما فيها لأنهما يؤديان بعد فك الحجر عنهما.

الركن الثاني: الصيغة وتتكون من الإيجاب والقبول ويشترط فيها لفظ يشعر بالإيجاب والقبول أما هنا فالأمر لا يحتاج للإيجاب والقبول بل يحتاج إلى أمر يشعر بالالتزام فلا ينعقد النذر بالنية؛ لأنه كسائر العقود يحتاج إلى لفظ يعرف به، وتنعقد الصيغة بالإشارة من الأخرس بشرط أن تكون مفهومة، وصيغة النذر كأن يقول: إن شفى الله مريضى فله علف صوم أو صلاة

الركن الثالث: المنذور وهو على ثلاثة أنواع أولها: العبادات المقصودة كالصلاة والصوم والحج، ويلزم الوفاء بها حتى وإن كانت العبادة من فروض الكفايات كالجهاد والصلاة على الجنائز، ويكون ملزماً بها وبصفاتهما كطول القراءة أو الركوع أو السجود في الصلاة أو الحج ماشياً، والنوع الثاني منها: القربات كزيارة المريض أو إفشاء السلام أو زيارة القادم من سفر وفي هذا النوع خلاف في الالتزام به، والثالث: المباحات كالأكل والنوم فلا يلزم.

بِالْمُعْجَمَةِ، (هُوَ صَرْبَانٍ: نَذَرَ لَجَاجٍ) وَغَضِبٍ (كَانَ كَلَّمْتَهُ) أَيُّ فَلَانًا، أَوْ  
إِنْ لَمْ أَخْرُجْ مِنَ الْبَلَدِ (فَلِلَّهِ عَلَيَّ عِتْقٌ أَوْ صَوْمٌ) أَوْ صَلَاةٌ <sup>(١)</sup>، (وَفِيهِ)  
إِذَا وَجَدَ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ (كَفَّارَةُ يَمِينٍ) لِأَنَّهُ يُشَبِّهُ الْيَمِينَ (وَفِي قَوْلٍ: مَا

---

(١) النذر يأتي على نوعين، أحدهما: نذر اللجاج، ومعناه التماذي في الخصومة، وقد  
سمي بذلك لوقوعه في حال الغضب، ومن أسمائه يمين اللجاج والغضب ويمين  
الغلق ونذر الغلق، والمراد منه ما خرج مخرج اليمين بأن يقصد الناذر منع نفسه أو  
غيرها من شيء أو يحدث عليه أو يحقق خيراً أو غضباً بالتزام قربة؛ ومثاله أن يقول:  
إِنْ لَمْ أَكَلِمْ فَلَانًا فَلِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا، أَوْ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ كَمَا قُلْتُ فَلِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا، وعند  
المعلق عليه فيه تجب كفارة اليمين ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم عن عائشة  
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "لَا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ،  
وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ"، ووجه الدلالة من الحديث أنه أثبت أن النذر فيه كفارة يمين أي  
عند وقوع المعلق عليه والنذر إما نذر لجاج أو نذر تبرر والتبرر لا تجب فيه الكفارة  
قطعاً فتعين أن الكفارة ثابتة في نذر اللجاج.

وهو مروي عن عمر وعائشة وابن عباس وابن عمر وحفصة وأم سلمة رضي الله عن  
الجميع، وهناك قول آخر في المسألة وهو أن الواجب ما سماه الناذر وسند هذا القول  
من المعقول وهو أنه التزم عبادة عند مقابلة شرط فتلزمه عند وجود الشرط، وهناك  
قول ثالث في المسألة رجحه النووي في المنهاج والرافعي في الشرح الكبير.

وهو أن الناذر يختار أي الأمرين شاء فإما أن يختار كفارة اليمين أو يختار أداء ما  
التزم به من غير أن يتوقف ذلك على قوله اخترت كذا حتى لو اختار معيناً منهما لم  
يتعين وله العدول عنه إلى غيره، وسبب ترجيح هذا القول عند الرافعي والنووي وعند  
العراقيين من الشافعية أنه يشبه النذر من حيث التزام القربة ويشبه اليمين من حيث  
المنع ولا سبيل إلى الجمع بين موجبهما ولا إلى تعطيلهما فوجب التخيير بينهما.

الْتَرَمَ، وَفِي قَوْلٍ: أَيُّهَمَا شَاءَ) وَعَلَى الْأَوَّلِ حُمِلَ حَدِيثُ مُسْلِمٍ: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ».

(قُلْتُ: الثَّالِثُ أَظْهَرُ) قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ أَيُّضًا (وَرَجَّحَهُ الْعِرَاقِيُّونَ) كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ (وَاللَّهُ أَعْلَمُ) قَالَ: لَكِنْ رَجَّحَ الْأَوَّلَ الْبَغَوِيُّ وَالرُّوْيَانِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ الْمَرْوَزِيُّ وَالْمَوْقِقُ بْنُ طَاهِرٍ وَغَيْرُهُمْ.

(وَلَوْ قَالَ: إِنْ دَخَلْتَ) الدَّارَ (فَعَلَيْ كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ نَذْرٍ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةُ بِالْدُّخُولِ) فِي الصُّورَتَيْنِ.

(وَنَذْرٌ تَبَرُّرٌ<sup>(١)</sup>؛ بَأَنْ يَلْتَزِمَ قُرْبَةً إِنْ حَدَثَتْ نِعْمَةٌ أَوْ ذَهَبَتْ نِقْمَةٌ كَأَنْ شَفَى مَرِيضِي) أَوْ ذَهَبَ عَنِّي كَذَا (فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَوْ فَعَلَيْ كَذَا) مِنْ صَوْمٍ أَوْ غَيْرِهِ

---

(١) النوع الثاني من أنواع النذر: نذر التبرر وهو من البر؛ لأن الناذر يطلب به البر والتقوى والتقرب لله تعالى، وهو على قسمين، القسم الأول منه يسمى نذر المجازاة وهذا النوع يكون معلقاً على شيء بأن يلتزم الناذر قربة إن حدثت له نعمة أو زالت عنه نعمة كأن يقول إن شفى الله مريضتي فله علي كذا أو إن نجحت في الامتحان فله علي كذا، ويلزم الشيء المنذور عند حصول المعلق عليه لقوله تعالى: (وَلْيُؤْفُوا نُذُورَهُمْ) وقوله: (وَأُؤْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ) ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِه»

وتقريباً على هذا النوع لو نذر إن شفى الله مريضه فشفي ثم شك هل نذر صدقة أو عتقاً أو صلاة أو صوماً فما الحكم؟

أجاب البغوي في فتاويه بأنه يحتمل أن عليه الإتيان بهذه الأمور كلها قياساً على من نسي صلاة من الخمس فإنه يجب عليه الإتيان بالخمس، وهناك وجه آخر وهو

(فَيَلْزِمُهُ ذَلِكَ إِذَا حَصَلَ الْمُعْلَقُ عَلَيْهِ) قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، (وَإِنْ لَمْ يُعْلَقْهُ بِشَيْءٍ كَلَّلَهُ عَلَى صَوْمٍ لَزِمَهُ) ذَلِكَ (فِي الْأَظْهَرِ) وَالثَّانِي لَا؛ لِعَدَمِ الْعَوْضِ.

أقسام النذر من حيث الالتزام به وعدمه

(وَلَا يَصِحُّ نَذَرُ مَعْصِيَةٍ) كَشُرْبِ الْخَمْرِ أَوْ الزِّنَا؛ لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ: «لَا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ» (وَلَا وَاجِبٍ) كَالصُّبْحِ أَوْ صَوْمِ أَوَّلِ رَمَضَانَ إِذْ لَا مَعْنَى لِإِجَابِهِ بِالنَّذْرِ<sup>(١)</sup>.

---

الأشبه والأولى بالقبول وقد ذكره البغوي حيث قال يجتهد بخلاف الأمر في الصلاة التي توجب عليه الإتيان بالصلوات الخمس لأن الأمر في الصلاة أننا نتيقن وجوب الخمس عليه فلا يسقط إلا بيقين أما هنا فنتقن أن الجميع لم يجب عليه بل الواجب واحد منها واشتبه عليه فيجتهد قياساً على الاجتهاد في القبلة فيجب عليه التوجه إلى جهة واحدة وكذلك الأمر في الأواني التي أصابتها نجاسة فيجتهد فيها وهذا الوجه هو الأولى.

والقسم الثاني من نذر التبرر هو الذي لم يعلق على شيء كأن يقول لله علي صيام كذا أو حج كذا أو صلاة فهل يلزمه ذلك أم لا؟ قولان أولهما يلزمه ذلك لعموم الأدلة المتقدمة، والثاني: لا لعدم العوض فيه.

(١) الذي يفرض التزامه بالنذر إما أن يكون معصية أو مباحاً أو طاعة، وقد بدأ المصنف بالأول منها وهو نذر المعصية، فلا يصح التزام المعصية بالنذر، ودليل ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا وَفَاءَ لِنَذَرٍ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ"، وفي رواية ابن حُجْرٍ: «لَا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ»، مثال ذلك ما لو نذر شرب الخمر أو القتل أو الزنا وكذلك لو نذرت المرأة أن تصلي في أيام الحيض أو نذر الرجل أن يصلي وهو محدث أو على جنابة. وإذا كان نذر فعل المعصية لا

(وَلَوْ نَذَرَ فِعْلٌ مُّبَاحٍ أَوْ تَرَكَهُ) كَقِيَامٍ أَوْ قُعُودٍ (لَمْ يَلْزِمَهُ الْفِعْلُ أَوْ التَّرَكُّ)  
رَوَى أَبُو دَاوُدَ حَدِيثٌ: «لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا أُبْنِغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ» (لَكِنْ إِنْ  
خَالَفَ لَزِمَهُ كَفَّارَةٌ يَمِينٍ عَلَى الْمُرَجَّحِ) فِي الْمَذْهَبِ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ،

---

ينعقد فإذا لم يفعل ما نذره فقد أحسن، وهل يلزمه في ذلك كفارة يمين أم لا؟ يجاب  
عن ذلك بأن المشهور أنه لا يلزمه كفارة يمين؛ لأنه لم يوجد صيغة اليمين ولا  
حقيقته، ومقابل المشهور رواية عن الربيع أنه يلزمه كفارة يمين؛ لما روي عن عائشة  
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَذَرُ فِي مَعْصِيَةٍ،  
وكفارتُهُ كفارةُ يمينٍ"، وقد اختار هذا القول العراقيين من أصحابنا، وغيرهم جزموا  
بالأول وحملوا الحديث على نذر اللجاج.

القسم الثاني: نذر الطاعة: والطاعة تنفرع إلى واجبات والعبادات المقصودة والقربات  
التي لم توضع لتكون عبادة.

(أ) فالواجبات: لا يصح نذرها لأنها واجبة بإيجاب الشرع ابتداء فلا معنى لالتزامها  
ومثال ذلك ما لو قال لله علي أن أصلي خمساً أو أصوم شهر رمضان ولا فرق في  
ذلك بين أن يعلق ذلك بحصول نعمة أو يلتزم ابتداء ومثاله أيضاً ما لو نذر ألا  
يشرب الخمر ولا يزني.

(ب) العبادات المقصودة: وهي التي وضعت في الأصل للتقرب بها وعرف من الشرع  
الاهتمام بتكليف الناس بإيقاعها عبادة وهذا النوع يلزم بالنذر بالاتفاق كالصدقة غير  
الواجبة والصوم غير الواجب وكذلك الصيام والحج والاعتكاف.

(ج) القربات التي لم توضع لتكون عبادة: وهي أعمال وأخلاق مستحسنة رغب الشرع  
فيها لعموم فائدتها وقد يبتغى بها وجه الله فينال الثواب بها كعبادة المرضى وزيارة  
القادمين من السفر وإفشاء السلام على المسلمين وفي لزومها بالنذر وجهان: الأول  
المنع لأنها ليست على أوضاع العبادات والثاني وهو الأظهر للزوم؛ لأن الشرع  
يرغب فيها والعبد يتقرب بها إلى الله تعالى فهي كالعبادات.

وَفِي قَوْلٍ أَوْ وَجْهِ: لَا كَفَّارَةَ، وَيُؤْخَذُ تَرْجِيحُهُ مِنَ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا حَيْثُ حَكَى الْخِلَافَ فِي نَذْرِ الْمَعْصِيَةِ إِنْ خُولِفَ، وَرَجَّحَ فِيهِ عَدَمَ الْكَفَّارَةِ ثُمَّ أُحِيلَ عَلَيْهِ نَذْرُ الْوَاجِبِ وَنَذْرُ الْمُبَاحِ الْمَذْكُورِ وَفِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ الصَّوَابُ أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ فِي الثَّلَاثَةِ<sup>(١)</sup>.

(١) شرع المصنف في بيان القسم الثالث وهو المباحات وهي التي لم يرد فيها استحباب وترغيب كالأكل والنوم والقيام والقعود فلو نذر فعلها أو تركها لم ينعقد نذره، لما روي عن ابن عباس، قال: بينما النبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس، فسأل عنه؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم. قال: "مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ، وَلْيَتَمَّ صُومَهُ"، وفي رواية "إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ وَأَمْرُهُ أَنْ يَرْكَبَ"، وقد خالف الإمام أحمد ما رآه الشافعي حيث يرى أن نذر المباح ينعقد وعلى الناذر أن يتخير بين الوفاء والكفارة ويمكن أن يتصور أن يقصد بالأكل التقوي على العبادة وبالنوم النشاط عند التهجد فينال بذلك الثواب لكن الفعل غير مقصود والثواب يحصل بالقصد الجميل.

وقد قدمنا قبل ذلك أن مذهب الشافعية عدم الوجوب في المباحات فإن قيل: إن امرأة أتت النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: يا رسول الله، إني نذرتُ أن أضربَ على رأسك بالدُّفِّ، قال: "أوفي بنذرك" قالت: إني نذرتُ أن أدبحَ بمكان كذا وكذا -مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية- قال: "لصنم؟" قالت: لا، قال: "لوثن؟ لا قالت: لا، قال: "أوف بنذرك".

أجيب بأنه لما حصل السرور للمسلمين بقدومه صلى الله عليه وسلم وأغاظ الكفار وأرغم المنافقين كان من القرب ولذلك استحب ضربه في النكاح ليخرج عن معنى السفاح، ويجاب عن إمكانية حصول الثواب على المباحات كالقصد من الأكل التقوي على العبادة ومن النوم النشاط عند التهجد بأن الثواب لم يكن على الفعل بل على النية والقصد.



(وَلَوْ نَذَرَ صَوْمَ أَيَّامٍ نُدَبُّ تَعَجُّلُهَا) مُسَارَعَةً إِلَى بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ (فَإِنْ قَيَّدَ بِتَفْرِيقٍ أَوْ مُوَالَاةٍ وَجَبَ) ذَلِكَ. (وَالَّا) أَيُّ وَإِنْ لَمْ يُقَيَّدَ (جَازًا) أَيُّ التَّفْرِيقُ وَالْوَلَاءُ.

(أَوْ سُنَّةٌ مُعَيَّنَةٌ) كَسُنَّةِ كَذَا أَوْ سُنَّةٍ مِنَ الْعَدِ أَوْ مِنْ أَوَّلِ شَهْرِ كَذَا (صَامَهَا) عَنْ نَذَرِهِ، إِلَّا مَا ذُكِرَ فِي قَوْلِهِ (وَأَفْطَرَ) أَيُّ مِنْهَا (الْعَبْدُ) أَيُّ يَوْمِيهِ (وَالْتَشْرِيقَ) أَيُّ أَيَّامُهُ الثَّلَاثَةَ أَنَّهَا غَيْرُ قَابِلَةٍ لِلصَّوْمِ لِحُرْمَتِهِ فِيهَا. (وَصَامَ رَمَضَانَ) مِنْهَا (عَنْهُ) لِأَنَّهُ غَيْرُ قَابِلٍ لِلصَّوْمِ غَيْرِهِ. (وَلَا قِضَاءً) لِمَا ذُكِرَ عَنِ النَّذْرِ لِأَنَّهُ غَيْرُ دَاخِلٍ فِيهِ لِمَا تَقَدَّمَ.

(وَإِنْ أَفْطَرْتُ بِحَيْضٍ وَنِفَاسٍ) فِي السُّنَّةِ (وَجَبَ الْقِضَاءُ) لِأَيَّامِهَا (فِي الْأَظْهَرِ) لِأَنَّهَا قَابِلَةٌ لِلصَّوْمِ.

(قُلْتُ) أَخَذًا مِنَ الرَّافِعِيِّ فِي الشَّرْحِ (الْأَظْهَرُ: لَا يَجِبُ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ) لِأَنَّهَا غَيْرُ قَابِلَةٍ لِلصَّوْمِ مِنْهَا فَلَا يَدْخُلُ فِي نَذَرِهَا.

(وَإِنْ أَفْطَرَ يَوْمًا بِلا عُدْرِ) مِنَ السُّنَّةِ (وَجَبَ قِضَاؤُهُ وَلَا يَجِبُ اسْتِثْنَاؤُهَا سُنَّةً فَإِنْ شَرَطَ التَّتَابُعَ وَجَبَ) اسْتِثْنَاؤُهَا (فِي الْأَصَحِّ) وَفَاءً بِالشَّرْطِ، وَالثَّانِي قَالَ: ذِكْرُهُ مَعَ التَّعْيِينِ لَغَوْ.

(أَوْ غَيْرُ مُعَيَّنَةٍ وَشَرَطَ) فِيهَا (التَّتَابُعَ وَجَبَ).

---

هل يصح نذر المكروه؟ قال النووي في المجموع ينعقد ويلزم الوفاء به بلا خلاف، لكن الزركشي قال: وليس كما قال بل كلام المتولى يفهم منه عدم الانعقاد وأشار إليه الرافعي تفقهاً لأن النذر تقرب والمكروه لا يتقرب به وهو المختار.

(وَلَا يَقْطَعُهُ صَوْمُ رَمَضَانَ عَنْ فَرْضِهِ وَفِطْرِ الْعِيدِ وَالتَّشْرِيقِ، وَيَقْضِيهَا تَبَاعًا مُتَّصِلَةً بِآخِرِ السَّنَةِ) لِيَفِي بِنَذْرِهِ، (وَلَا يَقْطَعُهُ حَيْضٌ) أَيِ فِي زَمَنِهِ (وَفِي قَضَائِهِ الْقَوْلَانِ) أَظْهَرُهُمَا: لَا يَجِبُ كَمَا تَقَدَّمَ (وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْهُ) أَيِ التَّتَابُعِ (لَمْ يَجِبْ) فَيَصُومُ كَيْفَ شَاءَ (أَوْ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ أَبَدًا لَمْ يَقْضِ أَثَانِي رَمَضَانَ)، اللَّازِمَةُ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ لِعَدَمِ دُخُولِهَا فِي النَّذْرِ لِمَا تَقَدَّمَ (وَكَذَا الْعِيدُ وَالتَّشْرِيقُ) الْأَيَّامُ الْخَمْسَةُ لَا يَقْضِي أَثَانِيَهَا (فِي الْأَظْهَرِ) لِمَا ذُكِرَ، وَالثَّانِي: يَقْضِيهَا؛ لِأَنَّ مَجِيءَ الْاِثْنَيْنِ فِيهَا غَيْرُ لَازِمٍ وَفِي الْاِثْنَيْنِ الْخَامِسُ فِي رَمَضَانَ هَذَا الْخِلَافُ بِتَرْجِيحِهِ، (فَلَوْ لَزِمَهُ صَوْمُ شَهْرَيْنِ تَبَاعًا لِكِفَارَةِ صَامَهُمَا وَيَقْضِي أَثَانِيَهُمَا) لِنَذْرِهِ (وَفِي قَوْلٍ: لَا يَقْضِي إِنْ سَبَقَتْ الْكِفَارَةُ النَّذْرَ).

(قُلْتُ: ذَا الْقَوْلُ أَظْهَرُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ) رَجَّحَهُ فِي الرُّوضَةِ أَيُّضًا، وَالرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ نَقَلَ تَرْجِيحَ كُلِّ عَنْ طَائِفَةٍ، وَالْأَوَّلُ نَاطِرٌ إِلَى وَقْتِ الْأَدَاءِ، وَالثَّانِي إِلَى وَقْتِ الْوُجُوبِ.

تَنْبِيْهُ: ذَكَرَ الْجَوْهَرِيُّ فِي جَمْعِ اثْنَيْنِ: أَثَانَيْنِ، وَبِهِ عَبَّرَ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ مُعَرِّفًا بِاللَّامِ، وَأَضَافَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا حَازِفًا لِنُوعِهِ، وَقَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: قَوْلُ الشَّيْخِ: أَثَانَيْنِ رَمَضَانَ صَوَابُهُ: أَثَانِي بَحَذْفِ النُّونِ انْتَهَى. وَكَأَنَّ وَجْهَهُ: التَّبَعِيَّةُ؛ لِحَذْفِهَا مِنَ الْمُفْرَدِ، وَوَجْهٌ إِثْبَاتِيهَا: أَنَّهَا مَحَلُّ الْإِعْرَابِ بِخِلَافِهَا فِي الْمُفْرَدِ، وَظَاهِرٌ عَلَى الْحَذْفِ بَقَاءُ سُكُونِ الْيَاءِ كَمَا نُقِلَ عَنْ ضَبْطِ الْمُصَنِّفِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ.

(وَتَقْضِي) بِالْفَوْقَانِيَّةِ (زَمَنَ حَيْضٍ وَنَفَاسٍ) أَي: أَثَانِيَهُمَا (فِي الْأَظْهَرِ) وَيُؤْخَذُ مِنَ الرُّوْضَةِ كَأَصْلِهَا تَرْجِيحُ عَدَمِ الْقَضَاءِ، وَلَعَلَّ السُّكُوتَ عَنْ زِيَادَتِهِ لِلْعِلْمِ بِهِ مِنَ الزِّيَادَةِ السَّابِقَةِ، وَلَوْ كَانَ لَهَا عَادَةٌ غَالِبَةٌ فَعَدَمُ الْقَضَاءِ فِيمَا يَقَعُ فِي عَادَتِهَا أَظْهَرُ<sup>(١)</sup>. (أَوْ) نَذَرَ (يَوْمًا بَعَيْنِهِ لَمْ يَصُمْ

---

(١) لو نذر صوم أيام فإنه يندب له تعجيل هذه الأيام مسارعة إلى براءة الذمة إلا إذا كان عليه صيام كفارة سبقت النذر فإنه يندب تعجيل الكفارة وتقدم على النذر ومحل المسارعة بصيام هذه الأيام عند انتفاء المانع، فلو عارضه بما هو أقوى منه كالمجاهد أو المسافر الذي تلحقه المشقة بالصوم فإن التأخير هو الأولى حتى يزول المانع، لكن لو خاف النادر أنه لو أخر الصوم عجز عنه مطلقاً إما لزيادة مرض لا يرجى برؤه أو تقدم في السن فإنه يلزمه التعجيل، ولو نذر أياماً معينة صحت على الأصح، ولو كانت هذه الأيام غير معدودة كأن يقول: لله علي أن أصوم أياماً فإنه يلزمه ثلاثة أيام وكذلك لو قيدها بأيام كثيرة فإنه يلزمه ثلاثة؛ لأنها أقل الجمع، ولو قيد صيام الأيام بالتفريق أو الموالاة لزمه ما التزم به، وإذا لم يقيد بتفريق أو موالاة جاز أيّاً منهما عملاً بمقتضى إطلاقه لكن الموالاة أفضل.

حكم نذر صيام سنة:

لو نذر صيام سنة معينة كأن يقول سنة كذا أو تبدأ من كذا أو من شهر كذا فإن عليه صيامها، ولكن لا يجوز له أن يصوم يومي الفطر والأضحى وأيام التشريق الثلاثة بل يفطر في هذه الأيام وجوباً؛ لأنها غير قابلة للصوم وصيام شهر رمضان من السنة أيضاً لا يقبل قضاء غيره؛ لأنه لو نذر صيامه لم ينعقد النذر لوجوبه بحكم الشرع.

ولو نذرت المرأة صيام سنة فأفطرت أيام الحيض والنفاس وجب القضاء عليها هذه الأيام لأن الوقت الذي أفطرت به قابل للصوم وإنما أفطرت لمعنى فيها فتقضي قياساً على الأيام التي تفتطرها من شهر رمضان لكن النووي رجح عدم القضاء لأن أيامها

لا تقبل الصوم فلا تدخل في النذر كالعيد وجمهور الشافعية يرجحون القول الثاني مع النووي.

ولو أفطر الناذر يوماً أو أياماً بغير عذر فإنه يأتّم ويجب عليه القضاء لتقويته البر باختياره ولا يجب عليه استئناف سنة جديدة؛ لأن التتابع إنما كان للوقت كما في شهر رمضان لأنه مقصود والمفهوم من كلام أئمتنا أنه لو أفطر بعذر لم يجب عليه القضاء إلا لعذر السفر فإن القضاء يجب عليه في الأصح لأنه يتعلق بمحض اختياره حيث اختار الفطر في السفر مع أن الله سبحانه وتعالى قال: (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ).

ولو اشترط في السنة التي نذر صومها أن تكون متتابعة فلو أفطر منها يوماً وجب عليه أن يستأنف السنة من جديد لأن ذكر التتابع يدل على أنه مقصود وهذا هو الأصح، ومقابلته لا يجب التتابع وعليه لا يجب عليه استئناف الصوم من أول السنة مرة أخرى لأن التتابع مع التعيين لغو.

لو نذر صيام سنة هلالية غير معينة وشرط فيها التتابع فإنه يجب عليه الوفاء بما التزمه ولا يقطع التتابع من السنة صوم رمضان أو فطر أيام العيدين والتشريق الثلاثة لأنه لا تقبل الصوم بحكم الشرع ويقضي عنها شهراً وخمسة أيام بدلاً منها لأنه التزم صوم سنة كاملة وقيل لا يقضي كالسنة المعينة لكن أصحاب القول الأول أجابوا بأن المعين في العقد لا يبدل بغيره، ولا يمنع التتابع في السنة لو كان الناذر امرأة أفطرت أيام حيضها ونفاسها لعدم إمكانية الاحتراز عنه وفي قضائها عن مدة الحيض والنفاس قولان الأظهر منهما لا يجب القضاء. وإذا لم يشترط التتابع في نذر صيام السنة لم يلزم ووجب عليه صيام ثلاثمائة وستين يوماً.

ولو نذر صيام يوم الاثنين دائماً لم يقض أيام الاثنين التي تأتي في شهر رمضان أو عيد الفطر أو عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة، ولو وجب عليه صيام شهرين متتابعين أو كفارة ففي هذه الحالة يجب عليه القضاء أيام الاثنين لأنه أدخل على

قَبْلَهُ) وَالصَّوْمُ بَعْدَهُ قَضَاءٌ، (أَوْ يَوْمًا مِنْ أُسْبُوعٍ) بِمَعْنَى جُمُعَةٍ (ثُمَّ نَسِيَهُ صَامَ آخِرَهُ وَهُوَ الْجُمُعَةُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ وَقَعَ قَضَاءٌ) وَإِنْ كَانَ هُوَ وَقَعَ أَدَاءً<sup>(١)</sup>. (وَمَنْ شَرَعَ فِي صَوْمٍ نَفَلَ فَنَذَرَ إِيْتَامَهُ لَزِمَهُ عَلَى الصَّحِيحِ)، وَالثَّانِي: لَا يَلْزِمُهُ؛ لِأَنَّهُ نَذَرَ صَوْمَ بَعْضِ الْيَوْمِ (وَإِنْ نَذَرَ بَعْضَ يَوْمٍ لَمْ يَنْعَقِدْ) نَذْرُهُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْهُودٍ شَرْعًا (وَقِيلَ) يَنْعَقِدُ وَ (يَلْزِمُهُ يَوْمٌ) أَقَلُّ الْمَعْهُودِ.

نفسه صوم الشهرين، وفي قول لا يقضي إن سبقت الكفارة النذر ورجح النووي هذا القول حيث نظر إلى وقت الوجوب بينما نظر أصحاب القول الأول إلى وقت الأداء. ولو نذرت المرأة صيام أيام الاثنين أبدأً فإنها تقضي أيام الاثنين التي تقع في حيضها ونفاسها في الأظهر لأنها لم تتحقق وقوعها فيه فلم تخرج هذه الأيام من نذرها، ومقابل الأظهر يمنع القضاء قياساً على أيام العيد ورجحه الشربيني الخطيب في مغني المحتاج والرافعي في المحرر.

(١) ولو نذر يوماً معيناً لم يصم عنه قبله فإن فعل لم يصح، قياساً على الواجب بأصل الشرع ولا يجوز تأخيره عن وقته بغير عذر، فإن أخره وأدى يوماً عنه صح وعدّ قضاءً.

ولو نذر يوماً من أسبوعٍ أي جمعة مثلاً ثم نسي اليوم الذي حدده فإنه يصوم آخر أيام الأسبوع ويوم السبت أول أيامه لخبر مسلم عن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي فَقَالَ: «خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ، وَخَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الْأَحَدِ، وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ، وَخَلَقَ الْمَكْرُوهَ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ، وَخَلَقَ النَّوْرَ يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ، وَبَثَّ فِيهَا الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَخَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فِي آخِرِ الْخَلْقِ، فِي آخِرِ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ، فِيمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ».

(أَوْ يَوْمَ قُدُومِ زَيْدٍ فَالْأَظْهَرُ: انْعِقَادُهُ) ، وَالثَّانِي قَالَ: لَا يُمَكِّنُ الْوَفَاءَ بِهِ؛ لِانْتِفَاءِ تَبَيُّتِ التَّيَّةِ الْمُشْتَرَطِ؛ لِانْتِفَاءِ الْعِلْمِ بِقُدُومِهِ قَبْلَ يَوْمِهِ، وَأَجَابَ الْأَوَّلُ: بِإِمْكَانِ الْعِلْمِ بِقُدُومِهِ قَبْلَ يَوْمِهِ فَيَبِيْتُ (فَإِنْ قَدِمَ لَيْلًا أَوْ يَوْمَ عِيدٍ أَوْ فِي رَمَضَانَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) لِعَدَمِ قَبُولِ الْأَوَّلِينَ لِلصَّوْمِ، وَالثَّلَاثُ لَصَوْمِ غَيْرِهِ، (أَوْ نَهَارًا وَهُوَ مُفْطِرٌ أَوْ صَائِمٌ قَضَاءً أَوْ نَذْرًا وَجَبَ يَوْمٌ آخَرُ عَنْ هَذَا) لِقَوَاتِ صَوْمِهِ، (أَوْ وَهُوَ صَائِمٌ نَفْلًا فَكَذَلِكَ وَقِيلَ) لَا، بَلْ (يَجِبُ تَتْمِيمُهُ وَيَكْفِيهِ) بِنَاءً عَلَى لُزُومِ الصَّوْمِ مِنْ وَقْتِ قَدِيمِهِ وَالصَّحِيحُ لَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، (وَلَوْ قَالَ: إِنْ قَدِمَ زَيْدٌ فَلِلَّهِ عَلَى صَوْمِ الْيَوْمِ التَّالِي لِيَوْمِ قُدُومِهِ، وَإِنْ قَدِمَ عَمَرُو فَلِلَّهِ عَلَى صَوْمِ أَوَّلِ خَمِيسٍ بَعْدَهُ) أَيُّ بَعْدِ قُدُومِهِ (فَقَدِمَا فِي الْأَرْبَعَاءِ وَجَبَ صَوْمُ الْخَمِيسِ عَنْ أَوَّلِ النَّذْرَيْنِ وَيَقْضِي الْآخَرَ) بِيَوْمٍ<sup>(١)</sup>.

(١) ومن بدأ في صوم نفل أو في صلاة نفل أو اعتكاف ثم نذر أن يتم ما بدأه تطوعاً فإنه يلزمه الإتمام لأن النفل عبادة فصح التزامها بالنذر، والثاني لا يلزمه لأن الشرع مكنه من إبطاله بعد انعقاده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المتطوع بالصيام لما روي عن أم هانئ، رضي الله عنها، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ، يَقُولُ: «الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ، إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ».

ولو نذر صوم بعض يوم هل يلزمه الصيام أم لا؟ والجواب أنه لا ينعقد نذره لأنه ليس بقربة، وقيل ينعقد ويلزمه يوم لأن صوم بعض اليوم ليس معهوداً شرعاً فلزمه يوم كامل.

ولو نذر أن يصوم يوم قدوم زيد فالأظهر من القولين انعقاده لإمكان الوفاء بالنذر ومقابل الأظهر عدم انعقاده لتعذر الوفاء به وأجيب عن ذلك بأنه إن علم قدوم زيد غداً أو في يوم محدد فإنه يمكنه الوفاء به بخلاف ما لو قدم ليلاً أو في أحد أيام

## نذر الحج

(فَصْلٌ) إِذَا (نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى) نَاوِيًا الْكَعْبَةَ (أَوْ إِيَّانَهُ) فَالْمَذْهَبُ: وَجُوبُ إِيَّانِهِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ (وَفِي قَوْلٍ مِنْ طَرِيقٍ: لَا يَجِبُ ذَلِكَ؛ حَمَلًا لِلنَّذْرِ عَلَى الْجَائِزِ، وَالْأَوَّلُ يَحْمِلُهُ عَلَى الْوَاجِبِ، وَإِنْ لَمْ يَنْوَ الْكَعْبَةَ فَقِيلَ: يُحْمَلُ عَلَيْهَا وَالْأَصَحُّ: لَا يَصِحُّ نَذْرُهُ. (فَإِنْ نَذَرَ الْإِيَّانَ لَمْ يَلْزِمَهُ مَشْيٌ) فَلَهُ الرُّكُوبُ.

(وَإِنْ نَذَرَ الْمَشْيَ أَوْ أَنْ يَحُجَّ أَوْ يَعْتَمِرَ مَاشِيًا فَالْأَطْهَرُ: وَجُوبُ الْمَشْيِ) وَالثَّانِي: لَهُ الرُّكُوبُ (فَإِنْ كَانَ قَالَ أَحُجُّ مَاشِيًا فَمِنْ حَيْثُ يُحْرِمُ) مِنْ الْمِيقَاتِ أَوْ قَبْلَهُ. (وَإِنْ قَالَ: أَمْشِي إِلَى بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى فَمِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ) يَمْشِي (فِي الْأَصَحِّ) وَالثَّانِي: يَمْشِي مِنْ حَيْثُ يُحْرِمُ (وَإِذَا أَوْجَبْنَا الْمَشْيَ

---

شهر رمضان أو أحد أيام العيد فلا شيء عليه لأنه قيده بيوم القدوم ويوم القدوم لم يوجد في محل يقبل الصوم.

ولو قدم زيد نهاراً والنادر مفطر أو صائم صيام قضاء أو نذر واجب فإنه يجب عليه الصوم ويلزمه يوم آخر قضاء عن اليوم المنذور، ولو كان النادر صائماً صيام نفل وقدم زيد قبل الزوال فكذلك يجب عليه صيام يوم آخر عن نذره في الأصح لأنه لم يأت بالواجب عليه بالنذر والنفل لا يقوم مقام الفرض، بل لو جاء من أول النهار لم يجزئ أيضاً لعدم تبين النية في الواجب، ومقابل الأصح يقول: لا بل يجب إتمام صيام اليوم بقصد كونه عن النذر ويكفيه عن نذره بناءً على أن لزوم الصوم من وقت قدوم زيد ويكون أوله تطوعاً وآخره فرضاً. ولو قال إن قدم زيد فله على أن أصوم اليوم التالي لقدومه وإن حضر عمرو لأصوم من أول خميس بعده فقداً يوم الأربعاء فإنه يصوم يوم الخميس عن النذر الأول ويقضي عن الثاني يوماً لتعذر الإتيان به في وقته.

فَرَكِبَ لِعُذْرِ أَجْزَأْهِ وَعَلَيْهِ دَمٌ فِي الْأَظْهَرِ) لِتَرْكِهِ الْوَاجِبَ، وَالثَّانِي: لَا دَمَ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ نَذَرَ الصَّلَاةَ قَائِمًا فَصَلَّى قَاعِدًا؛ لِعَجْزِهِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، (أَوْ بِلَا عُذْرِ أَجْزَأْهِ عَلَى الْمَشْهُورِ) لِأَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ إِلَّا هَيْئَةً التَّزَمَهَا (وَعَلَيْهِ دَمٌ) لِتَرْفُهِهِ بِتَرْكِهَا، وَالثَّانِي: لَا يُجْزِئُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِمَا التَّزَمَهُ بِالصِّفَةِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهَا، وَالِدَّمُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ شَاءٌ، وَفِي قَوْلٍ: بَدَنَةٌ، وَوُجُوبُ الْمَشْيِ فِيمَا ذَكَرَ فِي الْعُمْرَةِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا، وَفِي الْحَجِّ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ التَّحْلِيلَيْنِ، وَقِيلَ: مِنَ الْأَوَّلِ، وَلَهُ الرُّكُوبُ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ يَتَرَدَّدُ فِي خِلَالِ أَعْمَالِ النُّسُكِ لِعَرَضٍ تِجَارَةٍ وَغَيْرِهَا، فَلَهُ أَنْ يَرْكَبَ وَلَمْ يَذْكُرُوهُ، وَسَكَتَ عَلَيْهِ فِي الرُّوضَةِ.

(وَمَنْ نَذَرَ حَجًّا أَوْ عُمْرَةً لَزِمَهُ فِعْلُهُ بِنَفْسِهِ) إِنْ كَانَ صَحِيحًا (فَإِنْ كَانَ مَعْضُوبًا اسْتَتَابَ) كَمَا فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ.

(وَيُسْتَحَبُّ تَعْجِيلُهُ فِي أَوَّلِ) زَمَنِ (الْإِمْكَانِ) مُبَادَرَةً إِلَى بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ. (فَإِنْ) تَمَكَّنَ فَأَخَّرَ فَمَاتَ حُجٌّ مِنْ مَالِهِ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَحَجَّةِ الْإِسْلَامِ.

(وَإِنْ) نَذَرَ الْحَجَّ عَامَهُ وَأَمَكَّنَهُ لَزِمَهُ) فِيهِ (فَإِنْ مَنَعَهُ مَرَضٌ) بَعْدَ الْإِحْرَامِ (وَجَبَ الْقَضَاءُ أَوْ عَدُوٌّ) أَوْ سُلْطَانٌ أَوْ رَبُّ دَيْنٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى وَقَائِهِ. (فَلَا) قَضَاءَ (فِي الْأَظْهَرِ) أَوْ صَدَّهْ عَدُوٌّ أَوْ سُلْطَانٌ بَعْدَمَا أُحْرِمَ، قَالَ الْإِمَامُ: أَوْ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ لِلْعَدُوِّ فَلَا قَضَاءَ عَلَى النَّصِيِّ، وَخَرَجَ ابْنُ سُرَيْجٍ قَوْلًا بِوُجُوبِهِ، وَحَكَى الْإِمَامُ هَذَا الْخِلَافَ فِي الْمَرَضِ، وَإِنْ لَمْ يُمَكِّنْهُ فِي الْعَامِ.



قَالَ فِي التَّيَمِّمَةِ: بَأَنْ كَانَ مَرِيضًا وَقَتَ خُرُوجِ النَّاسِ وَلَمْ يَتِمَّكَنْ مِنَ الْخُرُوجِ مَعَهُمْ، أَوْ لَمْ يَجِدْ رُقَّةً وَكَانَ الطَّرِيقُ مَخُوفًا لَا يَتَأَنَّى لِلْأَحَادِ سُلُوكُهُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْمُنْدُورَ حَجٌّ فِي تِلْكَ السَّنَةِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ كَمَا لَا تَسْتَقِرُّ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ هَذَا مَا فِي الرُّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي الْمَسْأَلَةِ<sup>(١)</sup>، (أَوْ) نَذَرَ (صَلَاةً أَوْ صَوْمًا، فِي وَقْتٍ فَمَنَعَهُ مَرَضٌ أَوْ عَدُوٌّ وَجَبَ الْقَضَاءُ) لِتَعْيِينِ الْفِعْلِ فِي الْوَقْتِ<sup>(١)</sup>.

---

(١) لو نذر المشي إلى بيت الله الحرام أو قصده أو لم ينذر المشي لبيت الله بل نذر إتيانه فالمذهب وجوب إتيانه بحج أو عمرة لأن الله تعالى أوجب قصده بنسك فلزم بالنذر كسائر القرب، ولو نذر إتيان مكان من الحرم كالصفا والمروة أو مسجد الخيف أو منى أو مزدلفة فإنه يلزمه إتيان الحرم بحج أو عمرة لأن القرية إنما تتم في إتيان مكان الحرم بالنسك والنذر محمول على الواجب.

ولو نذر الإتيان إلى بيت الله الحرام أو الذهاب لم يلزمه المشي لأن الإتيان لا يقتضي المشي بل له الركوب قطعاً، أما لو نذر المشي إلى بيت الله الحرام أو أن يحج أو يعتمر ماشياً وهو قادر على المشي فالأظهر وجوب المشي لأنه التزام جعله وصفاً للعبادة فهو كما لو نذر أن يصوم صياماً متتابعاً، أما العاجز فلا يلزمه مشي ولو قدر عليه بمشقة شديدة لم يلزمه أيضاً.

ومقابل الأظهر أن المشي لا يلزم القادر عليه أيضاً لأنه لم يجب في جنسه مشي بأصل الشرع فلا يجب بالنذر، وهذا الخلاف مبني على أن الركوب في الحج أفضل أم المشي وفي هذه المسألة أقوال الأظهر عند النووي أن الركوب أفضل، ودليل هذا القول "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ رَاكِبًا وَالْخَيْرُ فِي كُلِّ مَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"، ولأن في الركوب زيادة مؤنة وإنفاق في سبيل الله، ومقابل الأظهر أن المشي أفضل وهو أرجح عند الرافعي وسنده أن الحج ماشياً فيه زيادة مشقة والأجر على قدر المشقة، وقد أجاب أصحاب هذا القول عن حج رسول الله

صلى الله عليه وسلم راكباً بأنه لو مشى في حجه لاقتدى به الناس ولا شك أن ذلك يشق على كثير منهم فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يشق على أمته، والقول الثالث : هما سواء أي الركوب والمشي.

ولو أكد في نذره أن يحج ماشياً فمن أي مكان يمشي؟ والجواب أنه يلزمه المشي من حيث يحرم بالميقات أو قبله أو بعده لأنه بهذه الصيغة التزم المشي في الحج وابتداء الحج من وقت الإحرام، أما إذا صرح بالمشي من محلة أهله فإنه يلزمه ذلك وكذا لو قال نذرت أن أمشي إلى بيت الله الحرام أو إلى الحرم ماشياً فيلزمه المشي من محلة أهله لأن قضيته أن يخرج من بيته ماشياً، ومقابل الأصح يمشي من حيث يحرم.

وإذا قلنا بوجوب المشي على الحاج الذي نذر ذلك فركب لعذر كالمشقة الظاهرة فإن النسك يجزئه ودليل ذلك ما ورد في الصحيحين "عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ، قَالَ: «مَا بَالُ هَذَا؟»، قَالُوا: نَذَرْنَا أَنْ يَمْشِيَ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَنْ تَغْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَعْنِيَّ»، وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ"

لكن هل يجب عليه دم؟ قولان الأظهر منهما أن عليه دم لتركه الواجب، ومقابل الأظهر لا دم عليه، وقياسه على ما لو نذر أن يصلي قائماً فصلى قاعداً لعجزه عن القيام، لكن رد هذا القول بأن الصلاة لا تجبر بالمال بخلاف الحج. ولو ترك المشي وركب بغية عذر فهل يجزئه الحج أم لا؟ المشهور من المذهب أن الحج يجزئه مع عصيانه وإثمه لأنه لم يأت بما التزمه، وهل عليه دم أم لا؟ والجواب أنه يأتي الخلاف السابق ففيه القولان الأول يلزمه دم والثاني لا يلزمه وإن قلنا بأنه يلزمه دم في المسألتين فإنه تجزئ فيه شاة وتجزئ عن الأضحية أيضاً، وإذا أمكنه تعجيل الحج فأخره حتى مات قبل أن يحج حُج من ماله لتقصيره أما إذا مات قبل التمكن من الأداء فلا شيء عليه كحجة الإسلام والعمرة كالحج في ذلك.

وإذا نذر أن يحج في عامه الذي هو فيه وأمكنه أداء الحج بأن كان على مسافة يمكنه فيها أن يحج منها فإن الحج يلزمه في هذا العام تقريباً على الصحيح في تعيين الزمان في العبادات، ولو كان نذر الحج ولم يحج حجة الإسلام فإن الواجب

## نذر الهدي

(أَوْ) نَذَرَ (هَدِيًّا) كَأَنَّ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَهْدِيَ هَذَا التَّوْبَ أَوْ الشَّاةَ إِلَى مَكَّةَ. (لَزِمَهُ حَمْلُهُ إِلَى مَكَّةَ وَالتَّصَدُّقُ بِهِ) بَعْدَ ذَبْحِ مَا يَذْبَحُ مِنْهُ، (عَلَى مَنْ بِهَا) مِنَ الْفُقَرَاءِ أَوْ الْمَسَاكِينِ (أَوْ) نَذَرَ (التَّصَدُّقَ عَلَى أَهْلِ بَلَدٍ مُعَيَّنٍ لَزِمَهُ) سِوَاءَ مَكَّةَ وَغَيْرِهَا<sup>(٢)</sup>، (أَوْ) نَذَرَ (صَوْمًا فِي بَلَدٍ لَمْ يَتَّعَيَّنْ) فَلَهُ

---

عليه حجتان إحداهما عن النذر الواجب والأخرى عن حجة الإسلام ويقدم فيها حجة الإسلام على حجة النذر وانعقاد النذر يكون في غير الفرض فإن منعه المرض وجب عليه القضاء.

ومثل المرض النسيان والخطأ في الطريق وقياسه على من نذر صوم سنة معينة فأفطر فيها بعذر المرض فإنه يقضي، ومحل القضاء إذا منعه المرض بعد الإحرام فإن كان مريضاً وقت خروج الناس ولم يتمكن من الخروج معهم أو لم يجد رفقة وكان الطريق مخوفاً لا يتأتى للأحاد سلوكه فلا قضاء عليه لأن المنذور حج في تلك السنة ولم يقدر عليه.

(١) لو نذر صلاة أو صوماً في وقت معين فمنعه منه مرض أو عدو فإنه يجب عليه القضاء في وقت آخر فإن قيل هلا كان ذلك في الحج فلا يجب فيه القضاء أجيب عن ذلك بأن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع وقد تجب الصلاة والصوم مع العجز فلزما بالنذر والحج لا يجب إلا عند الاستطاعة فكذاك حكم النذر.

(٢) من نذر أن يهدي شيئاً سماه من إبل أو بقر أو غنم أو غيرها كأن قال: لله علي أن أهدي شاة أو ثوباً إلى مكة أو الحرم؛ فيلزمه حمله إلى مكة أو الحرم لأنه محل الهدي ويلزمه التصديق بما سماه على من بمكة أو الحرم من الفقراء أو المساكين من المسلمين سواء كانوا غرباء أو مستوطنين، ويمتنع بيع الهدية وتفرقة ثمنها على مستحقيها فهي تنزل منزلة الأضحية والشاة عند إخراجها عن السائمة في الزكاة،

الصَّوْمُ فِي غَيْرِهِ سَوَاءٌ عَيَّنَ مَكَّةَ أَمْ غَيْرَهَا. (وَكَذَا صَلَاةٌ) نَذَرَهَا فِي مَكَانٍ لَمْ يَتَّعَيْنِ (إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ) فَيَتَّعَيْنُ (وَفِي قَوْلٍ: وَمَسْجِدَ الْمَدِينَةِ وَالْأَقْصَى)

(قُلْتُ) أَخَذًا مِنَ الرَّافِعِيِّ فِي الشَّرْحِ (الْأَظْهَرُ: تَعَيُّنُهُمَا كَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ) لِاشْتِرَاكِ الثَّلَاثَةِ فِي عِظَمِ الْفَضِيلَةِ، وَنَظَرًا لِقَوْلِ الْآخِرِ إِلَى أَنَّهِنَّ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا نُسُكٌ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ، وَعَلَى التَّعَيُّنِ يَقُومُ الْأَوَّلُ مَقَامَهُمَا فِي الْأَصَحِّ، وَيَقُومُ أَحَدُهُمَا مَقَامَ الْآخَرِ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ، وَصَحَّحَ فِي الرُّوضَةِ ثَالِثًا زَادَهُ: أَنَّهُ يَقُومُ أَوَّلُهُمَا مَقَامَ الْآخَرِ دُونَ عَكْسِهِ كَالصَّحِيحِ فِي نَذْرِ الْإِعْتِكَافِ، وَتَقَدَّمَ فِي كِتَابِهِ حَدِيثُ الشَّيْخَيْنِ: «لَا تُشَدُّ الرِّجَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ» وَحَدِيثُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي».

---

ويسن لمن أهدي شيئاً من البدن أو البقر أن يشعرها أي يجرحها بشيء له حد حتى يسيل الدم.

والأولي أن يكون ذلك في صفحة سنامها اليمنى وأن يقلدها بعري القرب ونحوها من الخيوط المفتولة والجلود ويقلد الغنم ولا يشعرها والحكمة من ذلك أن يعلم الناس بأنه هدي فلا يتعرض له أحد، فإن عطب منها شيء قبل أن يصل إلى مكة أو الحرم فإنه ينحره وجوباً في المنور ولا يجوز له ولا لرفقته الأكل من المنذور فإن لم ينحره حتى مات مع تمكنه ضمنه بالأكثر من قيمته أو مثله أما إذا لم يتمكن من الذبح حتى مات فإنه لا يضمن. لو نذر التصدق على أهل بلد كمكة أو المدينة بشيء فإنه يلزمه الوفاء به ولا يجوز نقله كالزكاة.

(أَوْ) نَذَرَ (صَوْمًا مُطْلَقًا فَيَوْمٌ) لِأَنَّهُ أَقَلُّ مَا يُفْرَدُ بِالصَّوْمِ. (أَوْ أَيَّامًا  
فَثَلَاثَةً) ذَكَرَهُ الْإِمَامُ.

(أَوْ) نَذَرَ (صَدَقَةً فِيمَا) أَيُّ بَأْيٍ شَيْءٍ (كَانَ) مِمَّا يَتَمَوَّلُ كَدَانِقٍ وَدُونَهُ.  
(أَوْ) نَذَرَ (صَلَاةً فَرَكَعَتَانِ) أَقَلُّ وَاجِبٍ مِنْهَا (وَفِي قَوْلٍ: رَكْعَةً) أَقَلُّ جَائِزٍ  
مِنْهَا (فَعَلَى الْأَوَّلِ: يَجِبُ الْقِيَامُ فِيهِمَا مَعَ الْقُدْرَةِ) عَلَيْهِ (وَعَلَى الثَّانِي: لَا)  
يَجِبُ فِيمَا يَأْتِي بِهِ.

(أَوْ) نَذَرَ (صَلَاةً قَائِمًا لَمْ يَجْزُ قَاعِدًا، بِخِلَافِ عَكْسِهِ) أَيُّ نَذَرَ الصَّلَاةِ  
قَاعِدًا فَتَجُوزُ قَائِمًا (أَوْ) نَذَرَ (طُولَ قِرَاءَةِ الصَّلَاةِ أَوْ سُورَةٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ  
الْجَمَاعَةِ لَزِمَهُ) مَا ذَكَرَ؛ لِأَنَّهُ طَاعَةٌ.

(وَالصَّحِيحُ انْعِقَادُ النَّذْرِ بِكُلِّ قُرْبَةٍ لَا تَجِبُ ابْتِدَاءً كَعِبَادَةِ لِمَرِيضٍ  
(وَتَشْيِيعِ جِنَازَةٍ وَالسَّلَامِ) لِأَنَّ الشَّارِعَ رَغَّبَ فِيهَا فَهِيَ كَالْعِبَادَةِ، وَالثَّانِي  
قَالَ: لَيْسَتْ عَلَى وَضْعِهَا<sup>(١)</sup>.

---

(١) لو نذر الصوم في بلد معين لزمه الصوم ولا يشترط أن يكن في البلد لعدم تأثير المكان في الصوم وأجره، ولو نذر صلاة في بلد معين لم يتعين هذا البلد ويصلي في أي مكان شاء لأن الصلاة لا تختلف باختلاف الأمكنة، أما لو نذر الصلاة في مسجد معين لم يتعين إلا المسجد الحرام فيتعين لعظم الصلاة فيه وكذلك مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى فيتعينان ورجح النووي تعيينهما كالصلاة في المسجد الحرام لاشتراك الثلاثة في عظم الفضيلة وإن تفاوتت الأجور، لما روي عن أبي هريرة، يُلْعَقُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا، وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى".

ولا تجزئ صلاة واحدة في هذه المساجد الثلاثة عن أكثر منها، فلو نذر ألف صلاة في المسجد الحرام لم تجزه صلاة واحدة في مسجد المدينة وكذلك لو نذر صلاة في مسجد المدينة لم تجزه ألف صلاة فيما سواه وإن عدلت بها قياساً على ما لو نذر قراءة ثلث القرآن فقرأ قل هو الله أحد لا تجزيه وإن كانت تعدل ثلث القرآن، ولا يلحق مسجد قباء بالمساجد الثلاثة وإن كان الترمذي أخرج أن صلاة فيه كعمرة.

فروع المراد منها هل يسلك الناذر بالنذر مسلك واجب الشرع أو جائزه؟ صحح النووي: الأول، واختار العراقيون: الثاني وهذه الفروع هي:

أولاً: لو نذر صوماً مطلقاً من غير أن يتعرض لعدد بلفظ أو نية فالواجب عليه: صوم يوم؛ لأن الصوم اسم جنس يقع على القليل والكثير والصوم لا يكون أقل من يوم، والمتيقن منه يوم فلا يلزمه أكثر منه، ولو نذر صيام أيام فالواجب ثلاثة أيام؛ لأنها أقل الجمع، ولو نذر شهوراً فقياسه ثلاثة وقيل أحد عشر شهراً لكونه من جموع الكثرة ويجب تبنييت النية في صوم النذر بناء على أنه يسلك به مسلك واجب الشرع.

ثانياً: لو نذر صدقة فتصدق بأقل ما يتمول أجزأه ذلك، فإن قيل هلا يتقدر بخمسة دراهم أو بنصف دينار كأقل شيء يجب في زكاة المال؟ يجاب عنه بأن الخطاء قد يشتركون في نصاب فيجب على أحدهم شيء قليل، ولو نذر التصديق بمال عظيم قال القاضي أبو الطيب: لا يتقدر بشيء وأي قدر تصدق به أجزأه ونقل عن البعض أنه أوجب فيه مائتي درهم، ولو قال ابتداء: مالي صدقة أو في سبيل الله فقله لغو لأنه لم يأت بصيغة التزام، ولو علقه على شيء فيكون نذر لجأج كقله: إن دخلت الدار فمالي صدقة وعليه فيلزمه أحد شيئين أحدهما أن يتبرع بماله كله، والثاني أن يكفر كفارة يمين.

ثالثاً: لو نذر صلاة فيجزئ عنه في ذلك أداء ركعتين حملاً على أقل واجب الشرع وفي قول تكفيه ركعة حملاً على جائز الشرع ولا تكفية سجدة التلاوة أو سجدة الشكر لأن كلا منهما لا يسمى صلاة ومثلهما صلاة الجنازة لأنها ليست واجبة عيناً وإن حصل تعيين فهو عارض فلا يحمل على النذر فلو أوجبنا الركعتين فنكون بذلك قد

## بَابُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ<sup>(١)</sup>

الَّذِي يَأْتِي ضَابِطُهُ، (هُوَ جَائِزٌ<sup>(٢)</sup> إِنْ كَانَ عَلَيْهِ) أَيُّ الْغَائِبِ (بَيِّنَةٌ) بِمَا

---

سلكنا بالنذر مسلك واجب الشرع فتجب الركعتان ويجب فيهما القيام مع القدرة ولو سرنا مع الثاني فلا يجب القيام فيهما.

رابعا: لو نذر الصلاة قائماً لم يجز فعلها وهو قاعد حال قدرته على القيام دون مشقة لأنه أقل مما التزمه لكن لو كانت هذه المشقة مع الكبر أو المرض فلا يلزمه القيام على الأصح، أما لو نذر الصلاة قاعداً فأتى بها قائماً جاز ذلك لإتيان بالأفضل، ولو نذر طول القراءة في الصلاة فرضاً أو نفلاً أو نذر طول الركوع والسجود فيلزمه ذلك إلا إذا كان إماماً يقوم لم يرضوا بالتطويل حيث إن التطويل في هذه الحالات مكروه، فعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا أَكَادُ أُدْرِكُ الصَّلَاةَ مِمَّا يُطَوَّلُ بِنَا فُلَانٍ، فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْ يَوْمِئِذٍ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ مُنْقِرُونَ، فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فليُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ، وَالضَّعِيفَ، وَذَا الْحَاجَةِ»، ولو نذر سورة معينة أو نذر الجماعة فإن السورة تلزمه وكذا الجماعة.

(١) الْغَائِبُ الَّذِي تُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ، وَيُحْكَمُ عَلَيْهِ بِمُوجِبِهَا: مَنْ هُوَ كَائِنٌ بِمَسَافَةٍ بَعِيدَةٍ، وَهِيَ الَّتِي لَا يَرْجِعُ مِنْهَا مُبَكِّرٌ إِلَى مَوْضِعِهِ الَّذِي بَكَرَ مِنْهُ لَيْلًا بَعْدَ فَرَاغِ الْمُحَاكِمِ؛ لِمَا فِي إِيْجَابِ الْحُضُورِ عَلَيْهِ مِنَ الْمَشَقَّةِ الْخَاصِلَةِ بِمُفَارَقَةِ الْأَهْلِ وَالْوَطَنِ فِي اللَّيْلِ، وَقِيلَ: هِيَ مَسَافَةٌ قَصْرٌ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ اخْتَبَرَهَا فِي مَوَاضِعَ فَمَا دُونَهَا فِي حُكْمِ الْحَاضِرِ.

(٢) لِقَوْلِ عُمَرَ فِي خُطْبَتِهِ: "مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الْأُسْفَعِ - بِالْفَاءِ الْمَكْسُورَةِ - مَالٌ فَلْيَأْتِنَا غَدًا، فَإِنَّا بَابِعُو مَالَهُ، وَقَاسِمُوهُ بَيْنَ غُرْمَائِهِ، وَكَانَ غَائِبًا"، وَلِقَوْلِهِ لِهُنْدٍ: (خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ) وَهُوَ قَضَاءٌ مِنْهُ عَلَى زَوْجِهَا، وَلَوْ كَانَ فَتَوَى لَقَالَ: لَكَ أَنْ

يُدَّعَى بِهِ (وَادَّعَى الْمُدَّعِي <sup>(١)</sup> جُحُودَهُ <sup>(٢)</sup>، فَإِنْ قَالَ: هُوَ <sup>(٣)</sup> مَقْرَرٌ <sup>(٤)</sup>) لَمْ تُسْمَعْ بَيِّنَتُهُ <sup>(٥)</sup> وَلَعْتَ دَعَوَاهُ، (فَإِنْ أَطْلَقَ) <sup>(٦)</sup> أَي: لَمْ يَتَعَرَّضْ لِجُحُودِهِ، وَلَا إِفْرَارِهِ (فَالْأَصَحُّ: أَنَّهَا) أَي: بَيِّنَتُهُ (تُسْمَعُ)؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَعْلَمُ جُحُودَهُ وَلَا

---

تَأْخُذِي، أَوْ لَا بَأْسَ عَلَيْكَ أَوْ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَقُلْ: خُذِي؛ لِأَنَّ الْمُفْتِيَّ لَا يَقْطَعُ، فَلَمَّا قَطَعَ كَانَ حُكْمًا.

وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: لَا يَصِحُّ الْإِسْتِدْلَالُ بِهِ؛ لِأَنَّ أَبَا سُفْيَانَ كَانَ حَاضِرًا بِمَكَّةَ، فَإِنَّ الْوَاقِعَةَ كَانَتْ بِمَكَّةَ لَمَّا حَضَرَتْ هُنَا الْمُبَايَعَةَ.

وَذَكَرَ الرَّافِعِيُّ فِي النَّفَقَاتِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ اسْتِفْتَاءً قَالَ ابْنُ شُهَبَةَ: وَهُوَ الَّذِي يَظْهَرُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْلِفُهَا، وَلَمْ يُقَدِّرِ الْمَحْكُومَ بِهَ لَهَا، وَلَمْ تَجِرِ دَعْوَى عَلَى مَا شَرَطُوهُ اهـ.

وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الْوَاقِعَةُ وَقَعَتْ مَرَّتَيْنِ، وَصَحَّ عَنْ عُمَرَ r أَنَّهُ حَكَمَ فِي امْرَأَةِ الْمُفْقُودِ أَنَّهَا تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ وَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. وَقَالَ ابْنُ حَرَمٍ: صَحَّ عَنْ عُثْمَانَ الْقَضَاءُ عَلَى الْغَائِبِ وَلَا مُخَالَفَ لَهُمَا مِنَ الصَّحَابَةِ، وَلِأَنَّ فِي الْمَنْعِ مِنْهُ إِضَاعَةً لِلْحُقُوقِ الَّتِي نُدِبَ الْحُكَّامُ إِلَى حِفْظِهَا فَإِنَّهُ لَا يَعْجُرُ الْمُمْتَنِعُ مِنَ الْوَفَاءِ عَنْ الْغَيْبَةِ.

(١) على الغائب.

(٢) أَي: الْحَقُّ الْمُدَّعَى بِهِ شَرَطٌ لِصِحَّةِ الدَّعْوَى وَسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْغَائِبِ، وَلَا يُكَلِّفُ الْبَيِّنَةَ بِالْجُحُودِ بِالِاتِّفَاقِ كَمَا حَكَاهُ الْإِمَامُ.

(٣) الغائب.

(٤) وَأَنَا أَقِيمُ الْبَيِّنَةَ اسْتَظْهَارًا مَخَافَةَ أَنْ يُنْكَرَ لَعْتَ دَعَوَاهُ.

(٥) لِتَصْرِيحِهِ بِالْمُنَافِي لِسَمَاعِهَا؛ لِأَنَّهَا لَا تَقَامُ عَلَى مُقَرَّرٍ.

(٦) المدعي.



إِقْرَارُهُ، وَالْبَيِّنَةُ تُسْمَعُ عَلَى السَّكَاةِ، فَلْتُجْعَلَ غَيْبَتُهُ كَسُكُوتِهِ. وَالثَّانِي<sup>(١)</sup>:  
نَظَرَ إِلَى أَنَّ الْبَيِّنَةَ إِنَّمَا يُحْتَاجُ إِلَيْهَا عِنْدَ الْجُودِ.

(و) الْأَصَحُّ (أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْقَاضِي نَصْبُ مُسَخَّرٍ) بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ  
الْمُشَدَّدَةِ (يُنْكَرُ عَنِ الْغَائِبِ)؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَكُونُ مُنْكَرًا<sup>(٢)</sup>.

وَالثَّانِي: يَلْزَمُهُ لِيَتَكُونَ الْبَيِّنَةُ عَلَى انْكَارٍ مُنْكَرٍ وَعَدَمِ الزُّوْمِ يَصْدُقُ بِمَا<sup>(٣)</sup>،  
قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْعَبَّادِيُّ وَغَيْرُهُ: إِنَّ الْقَاضِيَّ مُخَيَّرَ بَيْنَ النَّصْبِ وَعَدَمِهِ.

(وَيَجِبُ أَنْ يُحْلَفَهُ) أَيِ الْمُدَّعِي (بَعْدَ الْبَيِّنَةِ أَنَّ الْحَقَّ ثَابِتٌ فِي ذِمَّتِهِ)  
اِحْتِيَاطًا لِلْغَائِبِ<sup>(٤)</sup>؛ لِأَنَّهُ لَوْ حَضَرَ رَبَّمَا ادَّعَى مَا يُبْرِئُهُ مِنْهُ، (وَقِيلَ:  
يُسْتَحَبُّ)<sup>(٥)</sup> فَلَهُ تَرْكُهُ، وَبَابُ تَذَارُكِهِ إِنْ كَانَ هُنَاكَ دَافِعٌ غَيْرُ مُنْحَسِمٍ،  
(وَيَجْرِيَانِ) أَيِ: الْوَجْهَانِ<sup>(٦)</sup> (فِي دَعْوَى عَلَى صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ)، أَوْ  
مَيِّتٍ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ خَاصٌّ، وَإِنْ كَانَ فَيَحْلِفُ بِسُؤَالِ الْوَارِثِ، وَالْوُجُوبُ  
فِيهِمْ؛ أَوْلَى لِعَجْزِهِمْ عَنِ التَّدَارُكِ.

---

(١) مقابل الأصح: لا تسمع دعواه.

(٢) لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مُقَرًّا، فَيَكُونُ انْكَارُ الْمُسَخَّرِ كَذِبًا.

(٣) يَلْزَمُهُ لِيَتَكُونَ الْبَيِّنَةُ عَلَى انْكَارٍ مُنْكَرٍ.

(٤) يَمِينِ الْإِسْتِظْهَارِ.

(٥) تحليفه.

(٦) نصب مسخر.

(وَلَوْ ادَّعَى وَكِيلٌ عَلَى الْغَائِبِ <sup>(١)</sup> فَلَا تَحْلِفَ) <sup>(٢)</sup>، وَيُعْطَى الْمَالُ إِنْ كَانَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ هُنَاكَ مَالٌ. <sup>(٣)</sup>

(وَلَوْ حَضَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ <sup>(٤)</sup>، وَقَالَ لَوَكِيلِ الْمُدَّعِي: أَبْرَأَنِي مُوَكَّلُكَ، أَمَرَ <sup>(٥)</sup> بِالتَّسْلِيمِ لِلْوَكِيلِ، وَلَا يُؤْخَرُ الْحَقُّ إِلَى أَنْ يَحْضُرَ الْمُوَكَّلُ، وَإِلَّا لَانْجَرَ الْأَمْرُ إِلَى أَنْ يَتَعَذَّرَ اسْتِيفَاءُ الْحُقُوقِ بِالْوَكَالَةِ، وَيُمْكِنُ ثُبُوتُ الْإِبْرَاءِ مِنْ بَعْدِ أَنْ كَانَتْ لَهُ حُجَّةٌ. (وَإِذَا ثَبَتَ) عِنْدَ حَاكِمٍ (مَالٌ عَلَى غَائِبٍ، وَلَهُ مَالٌ) حَاضِرٌ <sup>(٦)</sup> (قَضَاهُ الْحَاكِمُ مِنْهُ) لِعَيَّتِهِ، (وَالَا) أَي: وَإِنْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ حَاضِرٌ، (فَإِنْ سَأَلَ الْمُدَّعِيُ إِنْهَاءَ الْحَالِ) <sup>(٧)</sup> فِي

---

(١) وَلَوْ ادَّعَى وَكِيلٌ عَنْ غَائِبٍ بِحَقٍّ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ، وَقُلْنَا كَمَا سَبَقَ بِوُجُوبِ التَّحْلِيفِ بَعْدَهَا.

(٢) عَلَى الْوَكِيلِ.

(٣) لِأَنَّ الْوَكِيلَ لَا يَخْلِفُ يَمِينَ الْإِسْتِظْهَارِ بِحَالٍ؛ لِأَنَّ الشَّخْصَ لَا يَسْتَحِقُّ بَيِّمِينَ غَيْرِهِ، وَلَوْ وَقَفْنَا الْأَمْرَ إِلَى أَنْ يَحْضُرَ الْمُوَكَّلُ لَانْجَرَ الْأَمْرُ إِلَى تَعَذُّرِ اسْتِيفَاءِ الْحُقُوقِ بِالْوَكَالَةِ.

(٤) أَي: كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَاضِرًا، فَادَّعَى عَلَيْهِ وَكِيلُ شَخْصٍ غَائِبٍ بِحَقٍّ، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ لَوَكِيلِ الْمُدَّعِي: أَبْرَأَنِي مُوَكَّلُكَ الْغَائِبُ عَمَّا ادَّعَيْتَهُ عَلَيَّ.

(٥) أَمَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالتَّسْلِيمِ لِلْحَقِّ الْمُدَّعَى بِهِ لِلْوَكِيلِ.

(٦) وَإِذَا ثَبَتَ عِنْدَ حَاكِمٍ مَالٌ عَلَى غَائِبٍ، وَحَكَمَ بِهِ عَلَيْهِ، وَلَهُ مَالٌ حَاضِرٌ، وَطَلَبَهُ الْمُدَّعِي، قَضَاهُ الْحَاكِمُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ وَجَبَ عَلَيْهِ، وَتَعَذَّرَ وَقَاؤُهُ مِنْ جِهَةٍ مِنْ عَلَيْهِ، فَقَامَ الْحَاكِمُ مَقَامَهُ، كَمَا لَوْ كَانَ حَاضِرًا فَأَمْتَنَعَ.

(٧) مِنْ سَمَاعِ بَيِّنَةٍ، أَوْ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ بَعْدَ ثُبُوتِ عَدَالَةِ الشَّاهِدِ.

ذَلِكَ (إِلَى قَاضِي بَلَدِ الْغَائِبِ) <sup>(١)</sup> أَجَابَهُ <sup>(٢)</sup> فَيُنْهِي (بِسْمَاعِ بَيِّنَةٍ لِيَحْكُمَ بِهَا) <sup>(٣)</sup> ثُمَّ يَسْتَوْفِي الْمَالَ (أَوْ) يُنْهِي إِلَيْهِ (حُكْمًا) إِنْ حَكَمَ (لِيَسْتَوْفِيَ) الْمَالَ <sup>(٤)</sup> (وَالَا نَهَاهُ أَنْ يُشْهَدَ عَدْلَيْنِ بِذَلِكَ) <sup>(٥)</sup>، يُؤَدِّيَانِهِ عِنْدَ الْقَاضِي الْآخَرِ، (وَيُسْتَحَبُّ) <sup>(٦)</sup> كِتَابُ بِهِ <sup>(٧)</sup> يَذْكُرُ فِيهِ مَا يَتَمَيَّزُ بِهِ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ)

(١) أَوْ سَأَلَ إِنْهَاءَ حُكْمٍ إِلَى قَاضِي بَلَدِ الْغَائِبِ.

(٢) أَجَابَهُ لِذَلِكَ إِنْ عَلِمَ مَكَانَ الْغَائِبِ؛ مُسَارَعَةً إِلَى قَضَاءِ الْحُقُوقِ.

(٣) فَيُنْهِي إِلَيْهِ سَمَاعَ بَيِّنَةٍ؛ لِيَحْكُمَ بِهَا، ثُمَّ يَسْتَوْفِي الْمَالَ، وَيُكْتَبُ فِي صِفَةِ إِنْهَائِهَا: سَمِعْتُ بَيِّنَةً عَادِلَةً قَامَتْ عِنْدِي بِأَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ كَذَا، فَأَحْكُمُ بِهَا، وَهُوَ مَشْرُوطٌ بِبُعْدِ الْمَسَافَةِ.

(٤) وَيُكْتَبُ فِي إِنْهَاءِ الْحُكْمِ: قَامَتْ عِنْدِي بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ عَلَى فُلَانٍ لِفُلَانٍ بِكَذَا، وَحَكَمْتُ لَهُ بِهِ، فَاسْتَوْفِ حَقَّهُ.

تَنْبِيْهُ: اعْلَمْ أَنَّ لِإِنْهَاءِ الْحَالِ إِلَى قَاضِي بَلَدِ الْغَائِبِ ثَلَاثَ دَرَجَاتٍ: الْأُولَى: سَمَاعُ الْبَيِّنَةِ، وَالثَّانِيَّةُ: قَوْلُ الْحَاكِمِ: ثَبَّتَ عِنْدِي، وَهِيَ تَسْتَلْزِمُ الْأُولَى بِخِلَافِ الْعَكْسِ، وَالثَّالِثَةُ: الْحُكْمُ بِالْحَقِّ، وَهُوَ أَرْفَعُ الدَّرَجَاتِ، وَتَسْتَلْزِمُ مَا قَبْلَهَا، وَحِينَئِذٍ فَالَّذِي يُرْتَبُ عَلَيْهِ الْمَكْتُوبُ إِلَيْهِ الْحُكْمُ هُوَ الثَّانِيَّةُ لَا الْأُولَى.

(٥) وَإِلِنْهَاءُ: أَنْ يُشْهَدَ عَدْلَيْنِ بِذَلِكَ، أَيْ: بِسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ خَاصَّةً، أَوْ بِالْحُكْمِ بِاسْتِيفَاءِ الْحَقِّ يُؤَدِّيَانِهِ عِنْدَ الْقَاضِي الْآخَرِ، وَلَوْ لَمْ يُشْهَدْهُمَا وَلَكِنْ أُنْشِأَ الْحُكْمُ بِحُضُورِهِمَا، فَلَهُمَا أَنْ يُشْهَدَا عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُشْهَدْهُمَا.

(٦) مَعَ الْإِشْهَادِ.

(٧) وَلَا يَجِبُ؛ لِأَنَّ الْإِعْتِمَادَ عَلَى الشَّهَادَةِ، وَفَائِدَةُ الْكِتَابِ لِيَذْكُرَ الشَّاهِدُ الْحَالَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ قَدْ يَنْسَاهُ.

وَالْمَحْكُومُ لَهُ <sup>(١)</sup> (وَيَخْتِمُهُ) <sup>(٢)</sup> وَيَحْمِلُ إِلَى قَاضِي بَلَدِ الْغَائِبِ، وَيَخْرُجُ إِلَيْهِ الْعَدْلَانِ وَيَقِفُ عَلَى مَا فِيهِ، (وَيَشْهَدَانِ) عِنْدَهُ <sup>(٣)</sup> (عَلَيْهِ) <sup>(٤)</sup> أَي: عَلَى الْحَاكِمِ بِهِ (إِنْ أَنْكَرَ) الْخَصْمُ الْمُخْضِرُ لِلْقَاضِي أَنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ فِيهِ

(١) يَذْكُرُ فِيهِ مَا يَتَمَيَّزُ بِهِ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ وَالْمَحْكُومُ لَهُ، مِنْ اسْمِ كُلِّ مِنْهُمَا، وَكُنْيَتِهِ، وَقَبِيلَتِهِ، وَحِلْيَتِهِ، وَغَيْرَ ذَلِكَ؛ لِيَسْهُلَ التَّمْيِيزُ، وَيَذْكُرَ أَسْمَاءَ شُهَدَاءِ الْكِتَابِ وَتَارِيخِهِ.

(٢) وَيَخْتِمُهُ، أَي: الْكِتَابَ نَذْبًا؛ حِفْظًا لِلْكِتَابَةِ، وَإِكْرَامًا لِلْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ، وَخَتَمَ الْكِتَابِ سُنَّةً مُتَّبَعَةً. رَوَى الْبُخَارِيُّ: (أَنَّهُ كَانَ يُرْسَلُ كُتْبُهُ غَيْرَ مَخْتُومَةٍ، فَاِمْتَنَعَ بَعْضُهُمْ مِنْ قَبُولِهَا إِلَّا مَخْتُومَةً، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا وَنَقَشَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ).

وَأِنَّمَا كَانُوا لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا غَيْرَ مَخْتُومٍ خَوْفًا عَلَى كَشْفِ أَسْرَارِهِمْ، وَإِصَاعَةِ تَذْيِيرِهِمْ. وَيَكُونُ الْخَتَمُ بَعْدَ قِرَاءَتِهِ عَلَى الشَّاهِدِ بِحَضْرَتِهِ، وَيَقُولُ: أَشْهَدُكُمَا أَنِّي كَتَبْتُ إِلَى فُلَانٍ بِمَا سَمِعْتُمَا، وَيَضَعَانِ خَطَّهُمَا فِيهِ، وَلَا يَكْفِي أَنْ يَقُولَ: أَشْهَدُكُمَا أَنَّ هَذَا خَطِّي وَأَنَّ مَا فِيهِ حُكْمِي مِنْ غَيْرِ قِرَاءَةٍ، وَيَنْدَفِعُ لِلشَّاهِدَيْنِ نُسْخَةُ أُخْرَى بِلاَ خَتَمٍ لِيُطَالِعَاهَا، وَيَتَذَكَّرَا عِنْدَ الْحَاجَةِ.

وَمِنْ صِفَةِ الْكِتَابِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ خَصَرَ - عَافَانَا اللَّهُ وَإِيَّاكَ - فُلَانٌ، وَادَّعَى عَلَى فُلَانٍ الْغَائِبِ الْمُقِيمِ بِبَلَدِكَ بِالشَّيْءِ الْفُلَانِيِّ، وَأَقَامَ عَلَيْهِ شَاهِدَيْنِ هُمَا فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَقَدْ عُدِلَا عِنْدِي وَحَلَفْتُ الْمُدَّعِي وَحَكَمْتُ لَهُ بِالْمَالِ فَسَأَلَنِي أَنْ أَكْتُبَ إِلَيْكَ فِي ذَلِكَ فَأَجَبْتُهُ وَأَشْهَدْتُ بِالْكِتَابِ فُلَانًا وَفُلَانًا، وَيُسْنُ أَنْ يَكْتُبَ اسْمَهُ وَاسْمَ الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ فِي الْعُنْوَانِ أَيْضًا، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بَلَدَ الْغَائِبِ كَتَبَ الْكِتَابَ مُطْلَقًا إِلَى كُلِّ مَنْ يَبْلُغُهُ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ مَنْ بَلَغَهُ عَمِلَ بِهِ.

(٣) عِنْدَ الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ.

(٤) أَي: عَلَى مَا صَدَرَ مِنَ الْقَاضِي الْكَاتِبِ مِنَ الْحُكْمِ، أَوْ الثَّبُوتِ الْمُجَرَّدِ عَنِ الْحُكْمِ. الْحُكْمِ.

عَلَيْهِ. (فَإِنْ قَالَ: لَسْتُ الْمُسَمَّى فِي الْكِتَابِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ <sup>(١)</sup>، وَعَلَى الْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ بِأَنَّ هَذَا الْمَكْتُوبَ اسْمُهُ وَنَسَبُهُ <sup>(٢)</sup>، فَإِنْ أَقَامَهَا فَقَالَ <sup>(٣)</sup>: لَسْتُ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ، لَزِمَهُ الْحُكْمُ إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مُشَارِكٌ لَهُ فِي الْإِسْمِ وَالصِّفَاتِ) <sup>(٤)</sup>، وَلَا يُبَالِي بِقَوْلِهِ، (فَإِنْ كَانَ) هُنَاكَ مُشَارِكٌ لَهُ فِيمَا ذُكِرَ (أَخْضَرَ، فَإِنْ اعْتَرَفَ بِالْحَقِّ طُولِبَ وَتَرَكَ الْأَوَّلَ، وَإِلَّا بَعَثَ إِلَى) الْحَاكِمِ (الْكَاتِبَ لِيَطْلُبَ مِنَ الشُّهُودِ زِيَادَةَ صِفَةٍ تُمَيِّزُهُ وَيَكْتُبُهَا ثَانِيًا، وَلَوْ حَضَرَ قَاضِي بَلَدٍ الْغَائِبِ بِبَلَدٍ الْحَاكِمِ فَشَافَهُهُ بِحُكْمِهِ <sup>(٥)</sup>، فَفِي إِمْضَائِهِ <sup>(٦)</sup> إِذَا عَادَ إِلَى وَلَايَتِهِ خِلَافَ الْقَضَاءِ بِعِلْمِهِ) وَقَدْ تَقَدَّمَ، (وَلَوْ نَادَاهُ) كَاتِبَيْنِ (فِي طَرَفَيْ وَلَايَتَيْهِمَا) <sup>(٧)</sup> أَمْضَاهُ <sup>(٨)</sup>، وَإِنْ اقْتَصَرَ <sup>(٩)</sup> عَلَى سَمَاعِ بَيِّنَةٍ كَتَبَ

(١) لأن الأصل براءة الذمة.

(٢) لأن الأصل عدم تسميته بهذا الاسم.

(٣) قال الغائب: صحيح ما قامت به البينة، لكن لست المحكوم عليه.

(٤) لأن الظاهر أنه المحكوم عليه.

(٥) على الغائب.

(٦) أي: تنفيذه.

(٧) أي: قَالَ قَاضِي بَلَدٍ الْحَاضِرِ وَهُوَ فِي طَرَفٍ وَلَايَتِهِ لِقَاضِي بَلَدٍ الْغَائِبِ فِي طَرَفٍ وَلَايَتِهِ: حَكَمْتُ بِكَذَا عَلَى فُلَانٍ الَّذِي بِبَلَدِكَ.

(٨) أَي تَقَدَّه؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ مِنَ الشَّهَادَةِ وَالْكِتَابَةِ فِي الْإِعْتِمَادِ عَلَيْهِ، وَكَذَا لَوْ كَانَ فِي الْبَلَدِ قَاضِيَانِ وَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: إِنِّي حَكَمْتُ بِكَذَا فَإِنَّهُ يُمَضِّيه إِذَا أَخْبَرَهُ بِهِ نَائِبُهُ فِي الْبَلَدِ وَعَكْسِهِ.

(٩) القاضي الكاتب.

سَمِعَتْ بَيِّنَةً عَلَى فُلَانٍ، وَيُسَمِّيَهَا إِنْ لَمْ يَعْدِلْهُمَا <sup>(١)</sup> (وَالْأَيُّ وَإِنْ عَدَلَهَا (فَالْأَصَحُّ جَوَازُ تَرْكِ التَّسْمِيَةِ) <sup>(٢)</sup> هُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ الْبُعْوِيِّ وَغَيْرِهِ. <sup>(٣)</sup> <sup>(٣)</sup> وَقَالَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ: لَا يَجُوزُ، وَعَبَّرَ فِي الْمُحَرَّرِ بِالشَّبْهِ <sup>(٤)</sup>، وَقَالَ وَقَالَ فِي الشَّرْحِ: يَجُوزُ أَنْ يُقَدَّرَ فِيهِ خِلَافٌ. (وَالْكِتَابُ بِالْحُكْمِ <sup>(٥)</sup> يَمْضِي مَعَ قُرْبِ الْمَسَافَةِ) كُبُغْدَهَا، (وَبِسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ لَا يُقْبَلُ عَلَى الصَّحِيحِ إِلَّا مَسَافَةٌ قَبُولِ شَهَادَةٍ عَلَى شَهَادَةٍ) وَهِيَ كَمَا سَيَأْتِي مَا فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى الَّتِي يَرْجِعُ مِنْهَا مُبَكَّرًا إِلَى مَوْضِعِهِ لَيْلًا، وَقِيلَ: هِيَ مَسَافَةُ الْقَصْرِ، وَالثَّانِي: يَقْبَلُ مَعَ قُرْبِ الْمَسَافَةِ وَمُنْتَهَاهَا مَسَافَةُ الْعَدْوَى <sup>(٦)</sup>.

(١) لِيُبْحَثَ الْمَكْتُوبُ إِلَيْهِ عَنْ عَدَالَتِهَا وَغَيْرِهَا حَتَّى يَحْكُمَ بِهَا.

(٢) وَيَأْخُذُ الْقَاضِي الْمَكْتُوبَ إِلَيْهِ اكْتِفَاءً بِتَعْدِيلِ الْقَاضِي الْكَاتِبِ لَهَا مِنْ غَيْرِ إِعَادَةِ تَعْدِيلِهَا، كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ أَنَّهُ الْقِيَاسُ، وَصَوَّبَهُ الْمُصَنِّفُ كَمَا يُسْتَعْنَى عَنْ تَسْمِيَةِ الشُّهُودِ.

(٣) وَالثَّانِي (مَقَابِلُ الْأَصَحِّ): الْمَنْعُ؛ لِأَنَّ الْأَخَرَ إِنَّمَا يَقْضِي بِقَوْلِهِمْ.

(٤) الْأَشْبَه: يَسْتَعْمَلُ هَذَا الْمَصْطَلَحُ فِيمَا لَوْ كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ حَكْمَانِ مَبْنِيَانِ عَلَى قِيَاسَيْنِ، لَكِنْ عِلَّةُ أَحَدِهِمَا أَقْوَى؛ فَيَكُونُ الْحُكْمُ الْمَبْنِي عَلَىهَا أَقْوَى شَبْهًا مِنَ الْعِلَّةِ.

(٥) قَدْ يَكُونُ الْكِتَابُ بِنَهَاءِ الْحُكْمِ، وَقَدْ يَكُونُ بِسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ فَقَطْ.

(٦) فَارَقَ عَلَى الْأَوَّلِ الْإِنْهَاءَ بِالْحُكْمِ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ قَدْ نَمَّ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْإِسْتِيفَاءُ، بِخِلَافِ بِخِلَافِ سَمَاعِ الْحُجَّةِ، إِذْ يَسْهُلُ اخْتِصَارُهَا مَعَ الْقُرْبِ.

وَالْعَبْرَةُ فِي الْمَسَافَةِ بِمَا بَيْنَ الْقَاضِيَيْنِ، لَا بِمَا بَيْنَ الْقَاضِيِ الْمَنْهِيِّ وَالْعَرِيمِ.

## (باب القسمة<sup>(١)</sup>)

(قَدْ يُقَسِّمُ) الْمُشْتَرِكُ (الشُّرَكَاءَ أَوْ مَنْصُوبَهُمْ أَوْ مَنْصُوبَ الْإِمَامِ<sup>(٢)</sup>)، وَشَرَطُ مَنْصُوبِهِ: ذَكَرَ حُرٌّ عَدْلٌ عَلِمَ الْمِسَاحَةَ بِكُسْرِ الْمِيمِ (وَالْحِسَابَ) وَلَا

---

(١) القسمة: المراد بها تمييز بعض الأنصباء من بعض، والقسام هو الذي يقسم الأشياء بين الناس، ودليل مشروعيتها: دل على مشروعية القسمة الكتاب والسنة؛ فمن الكتاب قوله تعالى: (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا) حيث تكلمت الآية عن القسمة في الأنصباء بين الورثة بصيغة الجواز والمشروعية، وهذه الآية مبينة لاستحقاق الورثة نصيبهم واستحقاقهم واستحباب المشاركة لمن لا نصيب له، قال ابن جبير: ضيع الناس هذه الآية.

ودليل القسمة من السنة، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقَسَّمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْخُدُودُ، وَصَرَفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ» فقد دل الحديث على مشروعية القسمة التي تنفي ضرر المشاركة وتمنع عنه أخذ الحق بالشفعة.

حكمة مشروعيتها: الحاجة داعية إليها ليتمكن كل واحد من الشركاء ليتصرف في ملكه ويتخلص من سوء المشاركة واختلاف الأيدي، وقد ذكر الشافعية القسمة في كتاب القضاء؛ لأن القاضي لا يستغني عن القسام لقسمة المشتركات، ولأن القاسم مثله مثل الحاكم.

(٢) بدأ المصنف في باب القسمة بالقول إن الشيء المشترك من الميراث قد يقوم بقسمته الشركاء أنفسهم لأن الحق لهم في القسمة وقد يتفق الشركاء فيما بينهم على أن يولوا من يقوم بقسمة التركة المشتركة بينهم، وقد يقسم التركة من ينصبه الإمام لذلك، وقد يقوم بذلك الإمام بنفسه لأن المقصود القسمة يحصل بكل ذلك، ولو وكل بعض الشركاء واحداً منهم أن يقسم عليهم فيفرز لكل واحد منهم نصيبه لم يجز، لأن على الوكيل أن يحتاط لنفسه ولموكله، وإن وكل جميع الشركاء أحدهم أن يقسم عنهم

يُشْتَرَطُ فِي مَنْصُوبِهِمُ الْعَدَالَةُ وَالْحُرِّيَّةُ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ عَنْهُمْ، وَمَنْصُوبُ  
الْإِمَامِ مُلَزَمٌ بِالْإِقْرَاعِ<sup>(١)</sup>. (فَإِنْ كَانَ فِيهَا تَقْوِيمٌ وَجَبَ قَاسِمَانِ) لِاشْتِرَاطِ  
الْعَدَدِ فِي الْمَقْوَمِ (وَالْأَفْقَاسِمَ، وَفِي قَوْلٍ) مِنْ طَرِيقِ (اِثْنَانِ) بِنَاءً لِلْقَوْلَيْنِ  
عَلَى أَنَّ مَنْصِبَ الْقَاسِمِ مَنْصِبُ الْحَاكِمِ أَوْ مَنْصِبُ الشَّاهِدِ وَالْكَلَامُ فِي  
مَنْصُوبِ الْإِمَامِ، وَلَوْ فَوَّضَ الشُّرَكَاءُ الْقِسْمَةَ إِلَى وَاحِدٍ بِالتَّرَاضِي جَازَ  
قَطْعًا<sup>(٢)</sup>، (وَلِلْإِمَامِ جَعْلُ الْقَاسِمِ حَاكِمًا فِي التَّقْوِيمِ فَيَعْمَلُ فِيهِ بِعَدْلَيْنِ

---

ويرى فيما يأخذه بالقسمة لكل واحد منهم رأيه لم يجز ولا يجوز حتى يوكل كل واحد  
منهم وكيلاً عن نفسه على الانفراد.

(١) بدأ المصنف بالشروط التي ينبغي توافرها في القاسم المولى من قبل الإمام  
فاشترط فيه أن يكون ذكراً حراً عدلاً لأنه نائب عن الحاكم وهذه الشروط ينبغي  
توافرها في الحاكم حيث ينظر في الحجة ويجتهد في الحكم ويلزم الخصوم به،  
والقسام في ذلك مثله مثل الحاكم لأنه ينظر في المساحة والتقدير ثم يجتهد في  
القسمة ثم يلزم الشركاء بعد إقرار نصيب كل واحد والقسمة من باب الولاية.

لهذا اشترطت فيمن يقسم هذه الشروط، وقوله علم المساحة والحساب مأخوذ من مسح  
الأرض ذرعاً وقوله علم المساحة يغني عن ذكر الحساب لأن المساحة تشمل الإمام  
بعلم الحساب، والمساحة والحساب آلة القسمة كما أن الفقه آلة القضاء.

إذا نصب الشركاء أحداً من قبلهم للقسمة والحساب فهل يشترط فيه نفس الشروط  
التي يتطلبها منصوب الإمام؟ يجاب عن ذلك بأن مفهوم كلام المصنف لا يشترط  
ذلك لأنه مجرد وكيل عنهم.

(٢) يريد أن يقول: إن كان في القسمة تقويم للسلعة بتقدير قيمتها فيجب نصب  
قاسمين لأن التقويم شهادة بالقيمة والشهادة يشترط فيها العدد فإذا لم يكن في القسمة  
تقويم فالواجب قاسم واحد في الأظهر والثاني الواجب اثنان والاختلاف بينهما مبني



وَيَقْسِمُ) بِنَفْسِهِ، (وَيَجْعَلُ الْإِمَامَ رِزْقَ مَنْصُوبِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ) فِيهِ مَالٌ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ (فَأَجْرَتُهُ عَلَى الشُّرَكَاءِ فَإِنْ اسْتَأْجَرُوهُ وَسَمَّى كُلُّ) مِنْهُمْ (قَدْرًا لَزِمَهُ، وَإِلَّا) بِأَنْ أَطْلَقُوا الْمُسَمَّى (فَالْأَجْرَةُ مُوزَعَةٌ عَلَى الْحِصَصِ وَفِي قَوْلٍ) مِنْ طَرِيقٍ (عَلَى الرُّءُوسِ) لِأَنَّ الْعَمَلَ يَقَعُ لَهُمْ جَمِيعًا<sup>(١)</sup>.

على هل القاسم حاكم أو شاهد فإن كان حاكماً فالواجب واحد وإن كان شاهداً فالواجب اثنان.

والراجح أنه حاكم وليس بشاهد، لكن إذا أتى الشركاء بمن يقسم لهم وانتفقوا عليه فإنه يجوز قاسم واحد قطعاً حتى وإن كان في المسألة خرص وتقدير.

(١) هذه المسألة من باب تفويض الحكم في مسألة واحدة فالقضاء يمكن تحديده بالزمان والمكان والحادثة كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح في قضية واحدة لأهل نجران فعَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: جَاءَ الْعَاقِبُ وَالسَّيِّدُ، صَاحِبَا نَجْرَانَ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدَانِ أَنْ يُلَاعِنَاهُ، قَالَ: فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: لَا تَفْعَلْ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ كَانَ نَبِيًّا فَلَا عَنَّا لَا نُفْلِحُ نَحْنُ، وَلَا عَقِبُنَا مِنْ بَعْدِنَا، قَالَا: إِنَّا نُعْطِيكَ مَا سَأَلْتَنَا، وَابْعَثْ مَعَنَا رَجُلًا أَمِينًا، وَلَا تَبْعَثْ مَعَنَا إِلَّا أَمِينًا. فَقَالَ: «لَأَبْعَثَنَّ مَعَكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ»، فَاسْتَشْرَفَ لَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «قُمْ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ» فَلَمَّا قَامَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذَا أَمِينٌ هَذِهِ الْأُمَّةُ»، فِيمَكُنْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ الْقَاسِمَ حَاكِمًا فِي النِّقَومِ فِيْفُوزُ لَهُ مَا يَقُومُ بِهِ الْحَاكِمُ مِنْ سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ ثُمَّ يَخْرُجُ الْحُكْمَ بِنَاءً عَلَى مَا تَرَجَّحَ عِنْدَهُ بَعْدَ سَمَاعِ كِلَا الْخَصْمَيْنِ فَيَأْخُذُ فِي النِّقَومِ بِقَوْلِ عَدْلَيْنِ ثُمَّ يَقْسِمُ بِنَفْسِهِ.

أما عن الأجرة التي يستحقها القاسم المنصب من جهة الإمام بأن الأصل في الأجرة أن تكون من بيت المال إن كان بيت المال منتظماً وفيه سعة؛ فتخرج من سهم المصالح العامة لأنها منها، فيعطى أجرة المثل بغير زيادة إلا أن يكون متبرعاً فلا

## الشيء المقسوم

(ثُمَّ مَا عَظَمَ الضَّرَرُ فِي قِسْمَتِهِ؛ كَجَوْهَرَةٍ وَثَوْبٍ نَفِيسَيْنِ وَرَوْجِي خُفٍّ: إِنْ طَلَبَ الشَّرَكَاءُ كُلُّهُمْ قِسْمَتَهُ لَمْ يُجِبْهُمْ الْقَاضِي، وَلَا يَمْنَعُهُمْ إِنْ قَسَمُوا بِأَنْفُسِهِمْ إِنْ لَمْ تَبْطُلْ مَنَفَعَتُهُ كَسَيْفٍ يَكْسِرُ) بِخِلَافِ مَا تَبَطَّلُ مَنَفَعَتُهُ فَيَمْنَعُهُمْ؛ لِأَنَّهُ سَفَهٌ.

---

أجرة له، فإن تعذر إخراج الأجرة من بيت المال فالأجرة على الشركاء جميعاً لأن القسمة لهم جميعاً، وهناك وجه ضعيف وهو أن الأجرة على القاسم وحده، فإن كان القاسم قد جاء من جهة الشركاء فإن أجرته عليهم، فإن سمي كل واحد قيمة ما سيدفعه لزمه ما حدده حتى وإن كان لا يساوي الجزء المقسوم وهنا تكون الأجرة متفاوتة بقدر ما سماه كل واحد، فإن سموا له أجرة مطلقة تحملوا الأجرة جميعاً وفي طريقة توزيعها عليهم وجهان الأصح توزيعها على قدر الحصص فمن له النصف يحمل نصف الأجرة ومن له الثلث يتحمل الثلث ومن له السدس يتحمل السدس وهكذا.

وهناك وجه آخر في المسألة وهو أن الأجرة موزعة على عدد الرؤوس لأن العمل في النصيب القليل كالعمل في النصيب الكثير، والطريقة الثانية ذكرها المراوزة، وطريقة العراقيين الجزم بالأول، وقد صحح ابن الرفعة والرافعي الطريق الأولى لأنه قد يكون له سهم من ألف سهم فلو ألزم بنصف الأجرة لربما استوعب قيمة نصيبه.

وإذا كان في الشركاء صبي وجبت الأجرة في ماله؛ لأن الإجابة إلى القسمة واجبة، ولو دعا الشركاء القاسم ولم يسموا له أجرة لا يستحق شيئاً قياساً على ما لو دفع ثوبه لقصار ليخطيه ولم يسم له أجرة، وأرى أن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً فالقصار معلوم أنه يأخذ أجرة قد تحدد قبل العمل وقد تحدد بعده لذلك أرى استحقاق القاسم للأجرة حتى وإن لم يتفق عليها مسبقاً.

(وَمَا يُبْطَلُ نَفْعُهُ الْمَقْصُودَ كَحَمَامٍ وَطَاخُونَةٍ صَغِيرَيْنِ لَا يُجَابُ طَالِبُ قِسْمَتِهِ فِي الْأَصَحِّ) لِمَا فِيهَا مِنَ الضَّرَرِ، وَالثَّانِي: يُجَابُ؛ لِدَفْعِهَا ضَرَرَ الشَّرِكَةِ (فَإِنْ أَمَكَّنَ جَعْلُهُ حَمَامَيْنِ) أَوْ طَاخُونَتَيْنِ (أُجِيبُ) وَإِنْ أُحْتِجَ إِلَى إِحْدَاثِ بِنَرٍ أَوْ مُسْتَوْقِدٍ.

(وَلَوْ كَانَ لَهُ عَشْرُ دَارٍ لَا يَصْلُحُ لِسُكْنَى، وَالْبَاقِي لِآخَرَ) يَصْلُحُ لِلْسُكْنَى (فَالْأَصَحُّ إِجْبَارُ صَاحِبِ الْعَشْرِ بِطَلَبِ صَاحِبِهِ دُونَ عَكْسِهِ) أَيُّ لَا يُجْبَرُ صَاحِبُ الْبَاقِي بِطَلَبِ صَاحِبِ الْعَشْرِ وَالْفَرْقُ أَنَّ صَاحِبَ الْعَشْرِ مُتَعَبِّتٌ فِي طَلَبِهِ، وَالْآخَرُ مَعْدُورٌ وَوَجْهُ الْمَرْجُوحِ فِي الْأُولَى ضَرَرُ صَاحِبِ الْعَشْرِ وَفِي الثَّانِيَةِ تَمْيِيزُ مِلْكِهِ<sup>(١)</sup>.

(١) الشيء المقسوم قسمان الأول منهما ما يعظم الضرر في قسمته، وقد مثل له بالشيء العظيم القدر الذي تتأثر قيمته بقسمته كالجوهر العظيمة الغالية الثمن وكذلك مصراعي باب وزوجي نعل أو خف فإن طلبوا القسمة من الحاكم فطلبهم مرفوض، بل ويمنعهم الحاكم جبراً؛ لأن منفعة الشيء ستبطل بالكلية فيكون ذلك من قبيل السفه وتضييع المال لما ورد في الصحيح: «كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلٍ وَقَالَ، وَكَثَّرَ السُّؤَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ، وَوَادِ الْبَنَاتِ، وَمَنْعِ وَهَاتِ».

وإذا قسم الشركاء بأنفسهم فإن كانت منفعة الشيء المقسوم ستبطل كلية فإن علة الحاكم منعهم من ذلك لما فيه من تضييع المال، لكن إن كانت المنفعة ستقل كما لو كان المطلوب قسمته سيقسم إلى نصفين يصلح كل واحد منهما سكناً فلا يجيبهم القاضي إلى القسمة لكن لو قسموا بأنفسهم لم يمنعهم، فإن اعترض أحد بأن هذه القسمة لو لم تكن من قبيل الحرام لما امتنع القاضي من قسمتها، وإذا كانت حراماً فينبغي ألا يمكنهم من قسمتها فكيف نوفق بين الفهمين؟ يجاب عن ذلك بأن إتلاف المال ممنوع فلذلك امتنع القاضي عن قسمته، لكن رخص لأحد الشريكين قسمته دفعاً

[قسمة مالا يعظم ضرره وأنواعها]

[النوع الأول: القسمة بالأجزاء].

(وَمَا لَا يَعْظُمُ ضَرَرُهُ قِسْمَتُهُ أَنْوَاعٌ: أَحَدُهَا: بِالْأَجْزَاءِ؛ كَمِثْلِيٍّ) مِنْ حُبُوبٍ وَدَرَاهِمَ وَأَدْهَانَ وَغَيْرِهَا (وَدَارٍ مُتَقَفَّةِ الْأَبْنِيَةِ وَأَرْضٍ مُشْتَبِهَةِ الْأَجْزَاءِ فَيُجْبَرُ الْمُتَمَتِّعُ عَلَيْهَا؛ إِذْ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِيهَا (فَتَعْدِلُ السَّهَامَ كَيْلًا) فِي الْمَكِيلِ (أَوْ وَزَنَى) فِي الْمَوْزُونِ (أَوْ ذَرَعًا) فِي الْمَذْرُوعِ وَالْأَرْضِ (بِعَدَدِ الْأَنْصِبَاءِ إِنْ اسْتَوَتْ) كَلِثْلَاثٍ لِرَيْدٍ وَعَمَرٍ وَبَكْرٍ (وَيَكْتُوبُ فِي كُلِّ رُقْعَةٍ اسْمَ شَرِيكَ أَوْ جُزْءٍ مُمَيَّزٍ بِحَدِّ أَوْ جِهَةٍ) مَثَلًا. (وَتُدْرَجُ فِي بَنَادِقَ مُسْتَوِيَةٍ) وَزَنَا وَشَكْلًا مِنْ طِينٍ مُجَفَّفٍ أَوْ شَمْعٍ. (ثُمَّ يَخْرُجُ مَنْ لَمْ يَحْضُرْهَا) أَيُّ الرِّقَاعِ

---

لسوء المشاركة فلم يمنعه القاضي في الثانية لأن القاسم يستعمل رخصة يزيل بها الضرر عن نفسه ثم تكلم المصنف عما يبطل نفعه المقصود منه بالقسمة كالحمام الصغير والطاحونة الصغيرة فلا يجاب طالب القسمة إلى طلبه لما فيه من الضرر المنهي عنه شرعاً، فعن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَضَى أَنَّ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، ومقابل الأصح يرى أن طالب القسمة يجاب إلى طلبه لأنه يطلب ضرر إزالة المشاركة، ومحل المنع إذا لم يمكن قسمة الحمام إلى حمامين فإن أمكن فإن طالب القسمة يجاب لطلبه ويجبر الممتنع.

ولو كان له عشر دار لا يصلح للسكنى والشريك الآخر له تسعة أعشار العشر وحده لا يمكن الانتفاع به بينما التسعة أعشار يمكن الانتفاع بها إما بذاتها أو بضمها إلى ملك آخر فإن طلب صاحب الأعشار التسعة يجاب لطلبه حتى وإن كان فيه ضرر لصاحب العشر لأن الضرر ليس ناشئاً عن القسمة، ولكنه ناشئ عن قلة نصيبه وهذا هو الأصح، ومقابله: يمنع صاحب التسعة أعشار من طلبه لدفع الضرر عن شريكه، لكن لو كان النصيب الأقل صالحاً للانتفاع به يجاب صاحبه للقسمة جبراً.

حِينَ الْكِتَابَةِ وَالْإِدْرَاجِ بَعْدَ جَعْلِهَا فِي حَجَرٍ مَثَلًا. (رُقْعَةً عَلَى الْجُزْءِ  
الْأَوَّلِ إِنْ كَتَبَ الْأَسْمَاءَ فَيُعْطِي مَنْ خَرَجَ اسْمُهُ، أَوْ عَلَى اسْمِ زَيْدٍ إِنْ  
كَتَبَ الْأَجْزَاءَ) فَيُعْطِي ذَلِكَ الْجُزْءَ، وَيَفْعَلُ كَذَلِكَ فِي الرُقْعَةِ الثَّانِيَةِ،  
فَيَخْرِجُهَا عَلَى الْجُزْءِ الثَّانِي، أَوْ عَلَى اسْمِ عَمْرٍو، وَتَتَعَيَّنُ الثَّلَاثَةُ لِلْبَاقِي  
إِنْ كَانَتْ أَثَلَاثًا، وَتَعَيَّنُ مَنْ يُبْنَدُ بِهِ مِنَ الشُّرَكَاءِ وَالْأَجْزَاءِ مَنُوطٍ بِنَظَرِ  
الْقَاسِمِ، (فَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْأَنْصِبَاءُ كَنِصْفٍ وَثُلُثٍ وَسُدُسٍ) فِي أَرْضٍ  
(جُزِّتِ الْأَرْضُ عَلَى أَقَلِّ السَّهَامِ) وَهُوَ السُّدُسُ فَتَكُونُ سِتَّةَ أَجْزَاءٍ  
(وَقُسِّمَتْ كَمَا سَبَقَ، وَيُحْتَرَزُ عَنْ تَفْرِيقِ حِصَّةٍ وَاحِدٍ) وَهُوَ فِي غَيْرِ  
الْأَقَلِّ فِي كِتَابَةِ الْأَجْزَاءِ فِي سِتِّ رِقَاعٍ إِذَا بُدِيَ بِصَاحِبِ السُّدُسِ وَخَرَجَ  
عَلَى اسْمِهِ الْجُزْءُ الثَّانِي أَوْ الْخَامِسُ فَيُفَرَّقُ حِصَّةٌ غَيْرُهُ، فَيُبْنَدُ بِمَنْ لَهُ  
النِّصْفُ مَثَلًا، فَإِنْ خَرَجَ عَلَى اسْمِهِ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي أُعْطِيَهُمَا  
وَالثَّلَاثُ، وَيُنْتَبِى بِصَاحِبِ الثُّلُثِ، فَإِنْ خَرَجَ عَلَى اسْمِهِ الْجُزْءُ الرَّابِعُ أُعْطِيَهُ  
وَالْخَامِسُ، وَتَعَيَّنَ السَّادِسُ لِصَاحِبِ السُّدُسِ، وَفِي كِتَابَةِ الْأَسْمَاءِ زَيْدٌ  
وَعَمْرٌو وَبَكْرٌ فِي ثَلَاثِ رِقَاعٍ أَوْ سِتِّ إِنْ خَرَجَ اسْمُ بَكْرٍ صَاحِبِ السُّدُسِ  
عَلَى الْجُزْءِ الْأَوَّلِ أَخَذَهُ، وَإِنْ خَرَجَ عَلَى الْجُزْءِ الثَّانِي اسْمُ عَمْرٍو صَاحِبِ  
الثُّلُثِ أَخَذَهُ مَعَ الثَّلَاثِ، وَتَعَيَّنَتِ الثَّلَاثَةُ الْبَاقِيَةُ لِزَيْدٍ صَاحِبِ النِّصْفِ، وَلَا  
يَخْفَى الْحُكْمُ لَوْ خَرَجَ اسْمُ زَيْدٍ قَبْلَ اسْمِ عَمْرٍو أَوْ أَحَدُهُمَا أَوَّلًا وَتَوَسَّطَ  
بَيْنَهُمَا اسْمُ بَكْرٍ وَلَا تَفْرِيقَ لِحِصَّتَيْهِمَا فِي ذَلِكَ<sup>(١)</sup>.

(١) هذا هو القسم الثاني من أنواع القسمة وهو ما لا يعظم ضرره في القسمة، وهذا  
القسم أنواع لكن فقهاء الشافعية مختلفون في عدها فالمرأوزة يرونها ثلاثة، والعراقيون

يرونها اثنان، وقد سار النووي على طريقة المراززة بعدها ثلاثة، وسنسير مع المصنف على أنها ثلاثة أنواع، الأول: قسمة الأجزاء وتسمى قسمة المتشابهات وهي التي لا يحتاج فيها إلى رد شيء من بعضهم ولا إلى تقويم، ومثلها المثليات كالحبوب لكن يشترط فيها السلامة من العيب فإن الحب المعيب والنقد المغشوش يعدان من المتقومات وإذا جوزنا المعاملة بالمغشوش فهي من المثليات، ومثلها دار متفقة الأبنية أو أرض مشتبهة الأجزاء ومثلها الثياب الغليظة التي لا تنقص قيمتها بالقطع والحكم فيها أنه يجبر الممتنع عن القسمة عليها حتى وإن كانت الأنصاء متفاوتة لأنه لا ضرر على الممتنع في ذلك ولكي ينتفع طالب القسمة بماله على الوجه الأكمل ويتخلص من ضرر المشاركة.

ومعنى الدار متفقة الأبنية كأن تقوم البناية على شقق متساوية في المساحة وعدد الغرف والمرافق وعند القسمة تعدل السهام كيلاً في المكيل ووزناً في الموزون وذرعاً في المذروع وعدداً في المعدود فالمكيل كالحبوب والموزون كالتفاح والمذروع كالأرض والمعدود كالبطيخ وتكون القسمة على مقدار عدد الأنصاء كما لو كانت الأنصبة ثلاثة مثلاً فنجعل الأجزاء ثلاثة ثم نأتي بالرقاع ونكتب في كل رقعة اسم شريك ثم نضع الرقع في بنادق متساوية من الطين واستواؤها في الشكل والوزن فأى اسم خرج أولاً يكون الجزء الأول نصيبه وإن كان قد كتب الأسماء فيأخذ رقعة فيها اسم ويضعها على جزء وكذلك الثانية والثالثة.

وإذا اختلفت الأنصاء كنصف وثلث وسدس فإن الأرض تجزأ على أقل السهام ثم توزع بناء على كتابة الأسماء أو الأجزاء والأولى كتابة الأسماء لأننا لو كتبنا الأجزاء وخرج نصيب صاحب السدس الثاني أو الخامس فإنه يفرق بين نصيب من له النصف أو الثلث، فإن فرق لأجزاء لا يبدأ بصاحب السدس بل يبدأ بصاحب النصف أو الثلث فإن خرج الأول أخذ الثلاثة تباعاً وإن خرج الثاني أخذ ما قبله وما بعده، ولو خرج له الثالث أخذه مع اللذين قبله ثم يخرج باسم الآخرين وهكذا، ويجوز الاختصار على رقعة واحدة لكل واحد رقعة فيخرج رقعة على الجزء الأول فإن خرج لصاحب

[النوع الثاني: القسمة بالتعديل].

(الثَّانِي) مِنْ الْأَنْوَاعِ: الْقِسْمَةُ (بِالتَّعْدِيلِ) بِأَنْ تَعْدَلَ السَّهَامُ بِالْقِيَمَةِ (كَأَرْضٍ تَخْتَلِفُ قِيَمَةُ أَجْزَائِهَا بِحَسَبِ قُوَّةِ إِنْبَاتٍ وَقُرْبِ مَاءٍ) فَإِذَا كَانَتْ لِاثْنَيْنِ نِصْفَيْنِ وَقِيَمَةُ ثُلُثِهَا الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَا ذَكَرَ كَقِيَمَةِ ثُلُثِهَا الْخَالِي عَنْ ذَلِكَ، جَعَلَ الثُّلُثَ سَهْمًا وَالثُّلُثَانِ سَهْمًا، وَأَفْرَعَ بِكِتَابَةِ الْأَسْمَيْنِ أَوْ الْجُزَائِنِ نَحْوَ مَا تَقَدَّمَ، فَمَنْ خَرَجَ لَهُ جُزْءٌ أَخَذَهُ (وَيُجْبَرُ) الْمُمْتَنِعُ (عَلَيْهَا فِي الْأَظْهَرِ) إِلْحَاقًا لِلتَّسَاوِي فِي الْقِيَمَةِ بِالتَّسَاوِي فِي الْأَجْزَاءِ، وَالثَّانِي: لَا يُجْبَرُ لِاخْتِلَافِ الْأَعْرَاضِ وَالْمَنَافِعِ وَعَلَى الْأَوَّلِ أُجْرَةُ الْقَاسِمِ بِحَسَبِ الْمَأْخُودِ وَقِيلَ بِحَسَبِ الشَّرِكَةِ فِي الْأَصْلِ.

(وَلَوْ اسْتَوَتْ قِيَمَةُ دَارَيْنِ أَوْ حَانُوتَيْنِ) لِاثْنَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ (فَطَلَبَ جَعَلَ كُلِّ) مِنْهُمَا (لِوَاحِدٍ فَلَا إِجْبَارَ) فِي ذَلِكَ، تَجَاوَرَ مَا ذَكَرَ أَوْ تَبَاعَدَ؛ لِشِدَّةِ اخْتِلَافِ الْأَعْرَاضِ بِاخْتِلَافِ الْمَالِ وَالْأَبْنِيَةِ (أَوْ) قِيَمَةِ (عَبِيدٍ أَوْ ثِيَابٍ مِنْ نَوْعٍ أُجْبِرَ) الْمُمْتَنِعُ؛ لِقَلَّةِ اخْتِلَافِ الْأَعْرَاضِ فِيهَا (أَوْ نَوْعَيْنِ) كَعَبْدَيْنِ تُرْكِيٍّ وَهِنْدِيٍّ وَتَوْبَنِينِ إِبْرِسِمَ وَكَتَّانَ. (فَلَا) إِجْبَارَ فِي ذَلِكَ<sup>(١)</sup>.

---

السدس أخذه ثم إن خرج الثاني لصاحب الثلث أخذه مع ما بعده وتعينت الثلاثة الباقية لصاحب النصف وإن خرج الأول لصاحب النصف أخذه مع الثاني والثالث وإن خرج الرابع لصاحب الثلث أخذه مع ما بعده وتعين الباقي لصاحب السدس.

(١) شرع المصنف في النوع الثاني مما لا يعظم الضرر في قسمته وهو المسمى بقسمة التعديل ومعناه أن تعدل السهام بالقيمة، وهذا النوع يقسم لقسمين أحدهما ما يعدد المقسوم فيه شيئاً واحداً، والثاني: ما يعدد فيه المقسوم شيئين، وما يعدد فيه المقسوم شيئاً واحداً أشار إليه المصنف بقوله كأرض تختلف أجزاؤها بحسب قوة

الإنبات وقرب الماء، أو أرض يختلف جنس ما فيها كبستان بعضه نخل وبعضه عنب أو بعضها حجر وبعضها بالطوب اللبن فإن كانت لاثنتين نصفين وقيمة ثلثها كقيمة ثلثها الباقيين جعل الثلث الأول سهم والثلثين الباقيين سهم، وإن اختلفت الأنصباء بالقيمة إلى النصف والثلث والسدس جعلت ستة أسهم بالقيمة لا بالمساحة، وإن امتنع أحد من الشركاء عن القسمة أجبر عليها إلحاقاً للتساوي في القيمة بالتساوي في الأجزاء وهو الأظهر في المذهب، ومقابله يقول بمنع الإجماع لاختلاف الأغراض والمنافع.

ثم شرع المصنف في القسم الثاني من هذا النوع (قسمة التعديل) وهو ما يعد فيه المقسوم شيئين فصاعداً فقال: ولو استوت قيمة دارين أو حانوتين فإن كان لاثنتين على وجه المساواة وطلب واحد منهما أن يكون لكل واحد منهما داراً أو حانوتاً ولشريكه الآخر كذلك فلا إجماع لأحد الشريكين على الآخر سواء كان هناك تباعد بين الدارين أو الحانوتين أو تجاور لاختلاف الأغراض باختلاف المحال والأبنية.

ولو استوت قيمة الثياب أو الدواب أو أشجار أو غيرها من سائر العروض وكانوا من نوع واحد وأمكن التسوية حتى وإن اختلف العدد فإن الممتنع عن القسمة يجبر عليها إن زالت الشركة بالقسمة كثلاثة من العبيد بين شريكين قيمة أحدهم مائة وقيمة الاثنتين الآخرين مائة أو ثلاثة من العبيد قيمتهم متساوية بين ثلاثة من الشركاء والإجماع على القسمة هنا بسبب اختلاف الأغراض في القسمة، لكن إن بقيت الشركة في البعض كأن يكون هناك عبيد بين اثنين من الشركاء وقيمة أحدهما على النصف من قيمة الآخر فطلب أحد الشريكين القسمة لكي يختص من خرجت له قرعة الأقل قيمة به ويبقى له الربع في العبد الثاني فالمذهب عدم إجبار الممتنع عن القسمة عليها لأن ضرر الشركة لا يرتفع بالكلية.

ثم ذكر المصنف صورة أخرى وهي ما إذا كانت القسمة تشتمل على نوعين مختلفين كعبيدين أحدهما تركي والآخر هندي أو جنسين مختلفين كعبد وثوب فهنا لا يجبر الممتنع عن القسمة عليها لتفاوت الأغراض بكل نوع وكل جنس.



[النوع الثالث: قسمة الرد]:

(الثَّالِثُ) مِنَ الْأَنْوَاعِ الْقِسْمَةُ (بِالرَّدِّ؛ بَأَن يَكُونَ فِي أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ) مِنَ الْأَرْضِ (بِئْرٍ أَوْ شَجَرٍ لَا يُمَكِّنُ قِسْمَتَهُ، فَيَرُدُّ مَنْ يَأْخُذُهُ) بِالْقِسْمَةِ بِأَن خَرَجَ لَهُ بِالْقُرْعَةِ (قِسْطُ قِيَمَتِهِ) فَإِنْ كَانَتْ أَلْفًا وَلَهُ النِّصْفُ رَدَّ خَمْسِمِائَةٍ. (وَلَا إِجْبَارَ فِيهِ، وَهُوَ بَيْعٌ) وَقِيلَ: فِيْمَا يُقَابِلُ الْمَرْدُودَ وَفِيْمَا سِوَاهُ الْخِلَافُ فِي قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ (وَكَذَا التَّعْدِيلُ) بَيْعٌ (عَلَى الْمَذْهَبِ) وَقِيلَ: فِيْمَا الْخِلَافُ فِي قِسْمَةِ الْأَجْزَاءِ (وَقِسْمَةُ الْأَجْزَاءِ إِفْرَازٌ فِي الْأَظْهَرِ) وَالثَّانِي: بَيْعٌ، وَدُخُولُ الْإِجْبَارِ فِيْمَا؛ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهِ، وَمَعْنَى أَنَّ الْقِسْمَةَ إِفْرَازٌ: أَنَّهَا تُبَيِّنُ أَنَّ مَا خَرَجَ لِكُلِّ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ مَثَلًا هُوَ الَّذِي مَلَكَهُ، وَوَجْهٌ أَنَّهَا بَيْعٌ: أَنَّهَا لَمَّا انْفَرَدَ بِهَا كُلُّ مِنَ الشَّرِكَيْنِ بِبَعْضِ الْمُشْتَرِكِ بَيْنَهُمَا كَأَنَّهُ بَاعَ كُلُّ مِنْهُمَا مَا كَانَ لَهُ مِمَّا انْفَرَدَ بِهِ صَاحِبُهُ، بِمَا كَانَ لِصَاحِبِهِ مِمَّا انْفَرَدَ هُوَ بِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيْمَا لَفْظُ الْبَيْعِ.

(وَيُشْتَرَطُ فِي) قِسْمَةِ (الرَّدِّ الرِّضَا بَعْدَ خُرُوجِ الْقُرْعَةِ) كَمَا فِي الْإِبْتِدَاءِ .

(وَلَوْ تَرَاضِيََا بِقِسْمَةٍ مَا لَا إِجْبَارَ فِيْمَا اشْتَرَطَ الرِّضَا بَعْدَ الْقُرْعَةِ فِي الْأَصَحِّ، كَقَوْلِهِمَا: رَضِينَا بِهَذِهِ الْقِسْمَةِ أَوْ بِمَا أَخْرَجَتْهُ الْقُرْعَةُ) اعْتَرَضَ قَوْلُهُ: لَا إِجْبَارَ فِيْمَا بِأَن صَوَابَهُ عَكْسُهُ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ: الْقِسْمَةُ الَّتِي يُجْبَرُ عَلَيْهَا إِذَا جَرَتْ بِالتَّرَاضِي إِلَى آخِرِهِ، وَيُجَابُ بِأَن الْمُرَادَ: مَا انْتَقَى فِيْمَا الْإِجْبَارُ مِمَّا هُوَ مَحَلُّهُ الَّذِي هُوَ قِسْمَةُ التَّعْدِيلِ وَالْأَجْزَاءِ، وَهُوَ أَصْرَحُ فِي الْمُرَادِ مِمَّا فِي الْمُحَرَّرِ وَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: قِسْمَةُ الْإِجْبَارِ لَا يُعْتَبَرُ فِيْمَا، التَّرَاضِي لَا عِنْدَ إِخْرَاجِ الْقُرْعَةِ وَلَا بَعْدَهَا، وَإِذَا تَرَاضِيََا بِقَاسِمٍ

يُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا فَهَلْ يُشْتَرَطُ الرِّضَا بَعْدَ خُرُوجِ الْفُرْعَةِ، أَمْ يَكْفِي الرِّضَا  
الْأَوَّلُ؟ قَوْلَانِ، أَظْهَرُهُمَا: الْإِشْتِرَاطُ<sup>(١)</sup>.

(١) شرع المصنف في بيان النوع الثالث من قسمة ما لا ضرر فيه وهو قسمة الرد ومعناها هي التي يحتاج فيها لرد أحد الشريكين على الآخر مالا أجنبياً، كأن يكون في أحد الجانبين من الأرض المشتركة بئر يزيد من قيمتها باعتباره يروي الأرض زيادة على زراعة الأرض التي في هذا الجانب مثل التي في الجانب الآخر أو أن يكون في الأرض شجر لا يمكن قسمته وغير موجود مثله في الجانب الآخر. ولا يمكن قسمة كل من البئر أو الشجر وكلا الجانبين بهذه الصفة لا يعادل الآخر إلا بضم شيء من المال إليه فالذي يأخذ الجانب الذي فيه البئر أو الشجر باعتبار أن القرعة أعطته هذا الجانب فيرد قسط المال الذي يوازي به نصيب الشريك الآخر فلو افترضنا أن قيمة الأرض في كل جانب تساوي عشرة آلاف ثم تزيد الناحية التي فيها البئر أو الشجر بعشرة آلاف أخرى فإن الشخص الذي خرج من نصيبه البئر أو الشجر يرد للشريك الآخر ما يساوي قيمة نصيبه من البئر أو الشجر فيعطيه خمسة آلاف.

وهو بذلك يرد قسط الشريك الآخر، وقسمة الرد لا إجبار فيها لأن فيها تملك ما لا شركة فيه وهو بهذه الصفة بيع على المشهور لوجود معنى البيع فيه لأن البيع مقابلة مال بمال، وأما غير الرد من أنواع القسمة فقد اختلفوا فيه؛ حيث اختلفوا في قسمة التعديل هل هي بيع أم لا؟ فقالوا: إن التعديل بيع على المذهب لأن كل جزء مشترك بينهما، وقد دخلها الإجبار للحاجة مثل بيع الحاكم مال المدين جبراً، ومقابل المذهب يرى أنه بيع وقيل بيع في القدر المقابل بالمردود، وأما عن قسمة الأجزاء فهي إفراز وليست بيعاً في الأظهر لأنها لو كانت بيعاً لما دخلها الإجبار ولما جاز الاعتماد فيها على القرعة، ومقابل الأظهر يقول: إن قسمة الأجزاء بيع لأن جميع أجزاء المال

## نقض الأحكام في القسمة

(وَلَوْ ثَبَّتْ بَيِّنَةٌ غَلَطَ أَوْ حَيْفٌ فِي قِسْمَةِ إِجْبَارٍ نَقَضَتْ. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ وَادَّعَاهُ وَاحِدٌ) مِنَ الشَّرِيكَيْنِ (فَلَهُ تَخْلِيفُ شَرِيكِهِ) فَإِنْ نَكَلَ وَحَلَفَ الْمُدَّعِي نَقَضَتْ الْقِسْمَةُ.

(وَلَوْ ادَّعَاهُ فِي قِسْمَةٍ تَرَاضٍ) بِأَنْ نَصَبَا قَاسِمًا أَوْ اقْتَسَمَا بِأَنْفُسِهِمَا وَرَضِيَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ (وَقُلْنَا: هِيَ بَيْعٌ فَلَا أَصَحَّ: أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِلْغَلَطِ فَلَا فَائِدَةٌ لِهَذِهِ الدَّعْوَى)، وَالثَّانِي: لَهُ أَثَرٌ؛ لِأَنَّهُمَا تَرَاضِيَا لِاعْتِقَادِهِمَا أَنَّهَا قِسْمَةٌ عَدَلٍ فَتُنْقَضُ الْقِسْمَةُ إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِالْغَلَطِ وَيَحْلِفُ الشَّرِيكُ إِنْ لَمْ تَعْمُ.

---

كانت مشتركة بينهما فإذا اقتسما باع كل منهما ما كان له من حصة صاحبه بمال في حصته.

شرط الرضا في قسمة الرد: شرع المصنف بعد ذلك في الكلام عن اشتراط الرضا في قسمة الرد في ابتداء القرعة وبعد انتهائها على الصحيح والسبب في ذلك أنها بيع والبيع لا يحصل بالقرعة فاحتاج الأمر إلى التراضي بعد خروج القرعة كما احتاج إليه قبلها، ومقابل الصحيح يقول يلزم الرد بمجرد خروج القرعة ويلزم من خرج له النصيب الأكبر أن يدفع بدل ما يقابل الزائد كالقسمة التي أجبر عليها.

وأجاب أصحاب الصحيح بأن هذه القسمة اعتبر التراضي في ابتدائها بخلاف الإجماع عليها، ولو تراضى الشريكان أو الشركاء بقسمة الشيء الذي لا إجماع فيه فإنه يشترط فيه الرضا بعد خروج القرعة في الأصح، وصيغة الرضا كأن يقولوا رضينا بهذه القسمة أو بما أخرجته القرعة فلا بد من الصيغة لأن الرضا أمر خفي لا اطلاع لنا عليه فوجب أن يعبر عنه بأمر ظاهر يدل عليه والأصح أنه لا يشترط فيه الإتيان بلفظ البيع أو التملك وهو الأصح.

(قُلْتُ) كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ. (وَإِنْ قُلْنَا: إِفْرَارٌ نُقِضَتْ إِنْ ثَبَتَ) الْعَلْتُ (وَالَا فَيَحْلِفُ شَرِيكُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ).

(وَلَوْ اسْتَحَقَّ بَعْضُ الْمُقْسُومِ شَائِعًا) كَالْتُلُثِ (بَطَلَتْ فِيهِ، وَفِي الْبَاقِي خِلَافٌ تَفْرِيقِ الصَّفَقَةِ) فِي قَوْلٍ: تَبْطُلُ فِيهِ أَيْضًا، وَالْأَظْهَرُ: يَصِحُّ وَيَنْبُتُ الْخِيَارُ (أَوْ مِنَ النَّصِيِّينَ مُعَيَّنٌ سَوَاءً) بِالنَّصَبِ (بَقِيَتْ) أَيْ الْقِسْمَةُ فِي الْبَاقِي (وَالَا) أَيْ وَإِنْ كَانَ الْمُعَيَّنُ مِنْ أَحَدِهِمَا أَكْثَرَ مِنَ الْمُعَيَّنِ مِنَ الْآخَرِ. (بَطَلَتْ) تِلْكَ الْقِسْمَةُ لِأَنَّ مَا بَقِيَ لِكُلِّ وَاحِدٍ لَا يَكُونُ قَدَرٌ حَقِّهِ بَلْ يَحْتَاجُ أَحَدُهُمَا إِلَى الرُّجُوعِ عَلَى الْآخَرِ وَتَعُودُ الْإِشَاعَةُ<sup>(١)</sup>.

---

(١) شرع المصنف في الكلام على نقض الأحكام الثابتة في القسمة ورد ذلك إلى وجود غلط أو ظلم أو جور بين في القسمة فإن هذه القسمة تنقض لكن يلزم لذلك ثبوت هذا الخطأ أو الظلم بالبينة أو بإقرار الخصم أو باليمين المردودة أو الشاهد مع اليمين، وكذلك لو ثبت ظلم القاضي بأن قامت بينة على ذلك أو على كذب الشهود، لكن إن ادعى أحد الشريكين أن في القسمة غلطاً ولم يقم بينة على ما يقول فله تحليف شريكه لأن الذي يدعي على خصمه ما لو أقر به لنفعه فأنكر له تحليفه فإن حلف تصير القسمة صحيحة وإن نكل المدعى عليه وحلف المدعي فإن القسمة تنقض.

إثبات الغلط أو الجور في قسمة التراضي لا أثر للغلط في قسمة التراضي حيث إنهم ينصبون قاسماً أو يقتسموا بأنفسهم ويرضوا بعد القسمة لأن قسمة التراضي تعد من قبيل البيع على الأصح في المذهب فلا فائدة لهذه الدعوى حتى وإن تحقق الغبن لأنه قد رضي بترك الزيادة فصار كمن اشترى شيئاً وغبن فيه، ومقابل الأصح يرى أن للغلط أو الجور أثر في نقض القسمة فتتقضى لاعتقادهما أنهما قد تراضيا على أنها

## (كتاب الشهادات<sup>(١)</sup>)

قسمة عدل فبان خلاف ذلك، لكن إن قلنا إن قسمة التراضي إفراز وليست بيعاً فإنها تتقضى بادعاء الغلط عند ثبوته بالبينة.

ولو استحق بعض المقسوم شائعاً كالربع مثلاً بطلت هذه القسمة فيه أي الربع وفي الباقي الخلاف الوارد في تفريق الصفقة والأظهر في هذا الخلاف الصحة مع ثبوت الخيار ومقابل الأظهر البطلان وهو المفتي به في المذهب، ولو لم يستحق بعض المقسوم شائعاً من النصيبين قدر معين حال كونه سواء بقيت تلك القسمة في الباقي وإلا بأن كان المعين من أحد النصيبين أكثر من المعين من النصيب الآخر وبطلت تلك القسمة لأن ما يبقى لكل واحد لا يكون حقه، بل يحتاج أحدهما للرجوع على الآخر وتعود الإشاعة.

(١) الشهادة مصدر شهد وهي من الشهود والحضور قال الجوهرى: الشهادة خبر قاطع والشاهد حامل هذه الشهادة ومؤديها لأنه شاهد لما غاب عن غيره.

دليل مشروعيتها: دل على مشروعية الشهادة الكتاب والسنة والإجماع، أما الدليل من الكتاب فقوله تعالى: (وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ)، وقوله تعالى: (وَاسْتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ) وقوله: (فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ) فقد دلت الآيات المذكورة على الأمر بالشهادة في الحقوق وعلى وجوب أداء الشهادة على الشهود.

وأما أدلة السنة على أداء الشهادة: فمنه ما روي في الصحيحين: "إِنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ خَرَجَ إِلَيْنَا، فَقَالَ مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَحَدَّثَنَا بِمَا قَالَ: فَقَالَ صَدَقَ، لَفِي أَنْزِلْتُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي شَيْءٍ، فَأَخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ» فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ إِذَا يَخْلِفُ وَلَا يُبَالِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا، وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ»، ومن أدلة السنة أيضاً ما روي عن ابن عباس رضي

جَمْعُ شَهَادَةٍ، وَتَحَقُّقُ بِشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ لَهُ وَمَشْهُودٍ عَلَيْهِ وَمَشْهُودٍ بِهِ  
وَتَأْتِي الْأَرْبَعَةُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا.

### [شروط الشاهد]

(شَرَطُ الشَّاهِدِ: مُسْلِمٌ حُرٌّ مُكَلَّفٌ عَدْلٌ ذُو مَرْوَةٍ غَيْرُ مُتَّهِمٍ) فَلَا تُقْبَلُ  
شَهَادَةُ أَضْدَادِهِمْ، وَسَكَتَ عَنِ النُّطْقِ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ لَا تَأْتِي بِهِ بِذُونِهِ.  
(وَشَرَطُ الْعَدَالَةِ) الْمُحَقَّقُ لَهَا: (اجْتِنَابُ الْكِبَائِرِ) أَيُّ كُلِّ مِنْهَا (وَ) اجْتِنَابُ  
(الْإِضْرَارِ عَلَى صَغِيرَةٍ) فَبَارِتْكَابٍ كَبِيرَةٍ أَوْ إِضْرَارٍ عَلَى صَغِيرَةٍ مِنْ نَوْعٍ  
أَوْ أَنْوَاعٍ تَنْتَفِي الْعَدَالَةُ، إِلَّا أَنْ تَغْلِبَ طَاعَاتُ الْمُصْرِ عَلَى مَا أَصَرَ عَلَيْهِ

---

اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّهَادَةِ، فَقَالَ: «هَلْ  
تَرَى الشَّمْسَ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَعَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ، أَوْ دَعْ». غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ  
طَاوُوسٍ، تَقَرَّدَ بِهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ"

والشهادة تعتبر إحدى الوثائق في إثبات الحقوق والعقود وهي أعم من الرهن  
والضمان لأنها تجوز فيما لا يجوز فيه الرهن والضمان  
والأمور التي يشهد فيها على ضربين حقوق وعقود أما الحقوق فالشهادة فيها مندوب  
إليها لحفظها على أهلها، وأما الشهادة في العقود فتتقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول: ما  
كانت الشهادة فيه واجبة وشرطاً في صحته وهي عقود الزواج، والثاني: ما كانت  
الشهادة وثيقة فيه ولم تكن شرطاً في صحته كالأجارة والرهن والقراض والوكالة،  
والثالث: ما كان مختلفاً في وجوبها وهي عقود البيع ومذهب جمهور الفقهاء من  
الشافعية والحنفية والمالكية أن الشهادة مستحبة وليست بواجبة، بينما رأى بعض  
الفقهاء كسعيد بن المسيب وداود وأهل الظاهر أن الشهادة في البيع واجبة ورأى  
الجمهور أولى لما ساقوه من أدلة وردهم على أدلة القائلين بالوجوب لا يتسع المقام  
لذكرها هنا.

فَلَا تَنْتَقِي الْعَدَالَةَ عَنْهُ، وَمِنْ الْكَبَائِرِ: الْقَتْلُ وَالزَّيْنُ وَاللَّوْاطُ وَشُرْبُ الْخَمْرِ  
الْقَدْرِ الْمُسْكِرِ وَغَيْرِهِ، وَالسَّرِقَةُ وَالْقَذْفُ وَشَهَادَةُ الزُّورِ، وَمِنْ الصَّغَائِرِ:  
النَّظَرُ إِلَى مَا لَا يَجُوزُ، وَالْغَيْبَةُ، وَالسُّكُوتُ عَلَيْهَا، وَالْكَذِبُ الَّذِي لَا حَدَّ  
فِيهِ وَلَا ضَرَرَ، وَالْإِشْرَافُ عَلَى بُيُوتِ النَّاسِ، وَهَجْرُ الْمُسْلِمِ فَوْقَ ثَلَاثٍ،  
وَالْجُلُوسُ مَعَ الْفَسَاقِ إِيْنَاسًا لَهُمْ<sup>(١)</sup>.

(١) ذكر الشارح أن أركان الشهادة أربعة وهي شاهد ومشهود له ومشهود عليه  
ومشهود به ثم بدأ في تفصيل هذه الأركان فبدأ بالشاهد والشروط المتعلقة به فبدأ  
بشرط الإسلام فلا تقبل شهادة الكافر على المسلم لأن الشهادة من باب الولاية ولا  
ولاية لغير المسلم على المسلم لقوله تعالى: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ  
سَبِيلًا)، وقد خالف الحنفية حيث يرون قبول شهادة الكافر على الكافر.

وقد استدلل الشافعية على منع الكافر من الشهادة بقوله تعالى: (وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ  
مِنْكُمْ)، والكافر ليس بعدل وليس منا، كما أن شهادة الفاسق ترد والكافر أفسق الفاسق  
لكذبه على الله تعالى، والذي يكذب على الله تعالى لا يؤمن من الكذب على خلقه.

والشرط الثاني في الشاهد الحرية: فلا تقبل شهادة الرقيق يستوي في ذلك أن يكون  
العبد قنا خالصاً أو مبعوضاً أو مكاتباً لأن العبد لا ولاية له على نفسه والشهادة ولاية  
فلا تكون لفاقدتها، ثم ذكر الشرط الثالث وهو التكليف: ومعناه البلوغ والعقل، أو الرشد  
وهو صلاح الدين والمال؛ فلا تقبل شهادة المجنون بالإجماع لقوله تعالى: "لَيْسَ عَلَى  
الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ" والمجنون من المرضى  
والصبي أيضاً لا تقبل شهادته لقوله تعالى "وَأَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ" والصبي  
لم يبلغ مبلغ الرجال.

والشرط الرابع في الشاهد هو العدالة: فلا تقبل شهادة الفاسق، وقبول شهادة العدل  
لقوله تعالى: " وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ " ولقوله تعالى: " مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ "  
والعدل مرضي بخلاف الفاسق، ولا تقبل شهادة الفاسق لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

## الأعمال التي يمكن أن تؤثر في الشهادة والتي لا تؤثر فيها.

آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) والنبأ هو الخبر وكل شهادة خبر فلا تقبل شهادة الفاسق، وتمنع شهادة الفاسق أيضاً لقوله تعالى: (أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ) والمنع من المساواة إذا أوجب قبول العدل فإنه أيضاً يوجب رد شهادة الفاسق والعدل في الشهادة هو من توافرت فيه ثلاث خصال أولها أن يكون من أهل الشهادة فيكون مكلفاً حراً مسلماً وقد تكلمنا عنها سابقاً والثانية كمال دينه بمحافظته على الطاعة واجتنابه للكبائر وعدم إصراره على الصغائر، والكبيرة هي ما وجب فيها الحد وتوجه إليها الوعيد.

والصغيرة ما قل فيها الإثم واللمم فيه أقوال أحسنها هو الذي لا يجب عليه حد في الدنيا ولم يستحق عليه في الآخرة عقوبة، ومثال الكبائر تقديم الصلاة أو تأخيرها عن وقتها بغير عذر ومنع الزكاة وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأكل الربا وأكل مال اليتيم والإفطار في رمضان من غير عذر وعقوق الوالدين وشهادة الزور وغيرها، ومثال الصغائر النظر المحرم والإشراف على بيوت الناس وكثرة الخصومات والهجر فوق ثلاث.

والخصلة الثالثة التي تكتمل بها العدالة هي أن يكون الشاهد صاحب مروءة والمراد بها الاستقامة والمروء تقتضي أن يكون غير متهم في شهادته لقوله تعالى: (ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا) والريبة حاصلة بالتهمة لقوله صلى الله عليه وسلم " عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الظَّنَّةِ وَلَا ذِي الْحَنَّةِ"، وقد سكت المصنف عن شروط ينبغي توافرها في الشاهد ولم يذكرها منها أن يكون ناطقاً لأن شهادة الأخرس لا تقبل، ومنها أن يكون يقظاً فلا تقبل شهادة مغفل؛ لأنه ربما رأى أمراً والتبس عليه فهمه أو فاتته بعضه لغفلة.



(وَيَحْرُمُ اللَّعْبُ بِالنَّزْدِ عَلَى الصَّحِيحِ) لِحَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ: «مَنْ لَعِبَ  
بِالنَّزْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ»، وَفِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ: «فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ  
فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ» أَيُّ: وَذَلِكَ حَرَامٌ، وَالثَّانِي: يُكْرَهُ كَالشَّطْرَنْجِ (وَيُكْرَهُ)  
اللَّعْبُ (بِشَّطْرَنْجٍ) بِكُسْرِ أَوَّلِهِ الْمُعْجَمِ وَالْمُهْمَلِ وَفَتْحِهِ؛ لِأَنَّهُ صَرَفُ الْعُمْرِ  
إِلَى مَا لَا يُجْدِي (فَإِنْ شُرِطَ فِيهِ مَالٌ مِنَ الْجَانِبَيْنِ) أَيُّ أَنْ مَنْ غَلَبَ مِنَ  
اللَّاعِبَيْنِ كَانَ لَهُ عَلَى الْآخَرِ كَذَا (فَقِمَارٌ) مُحَرَّمٌ، فَتُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ،  
بِخِلَافِ مَا إِذَا شُرِطَ مِنْ جَانِبِ أَحَدِ اللَّاعِبَيْنِ أَيُّ إِنْ غَلَبَ بِضَمِّ أَوَّلِهِ  
بَذَلَهُ لِلْآخَرِ، وَإِنْ غَلَبَ أَمْسَكَهُ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ فَلَا تُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ، لَكِنَّهُ عَقْدُ  
مُسَابَقَةٍ عَلَى غَيْرِ آلَةٍ قِتَالٍ فَلَا يَصِحُّ (وَيُبَاحُ الْحَدَاءُ) بِضَمِّ الْحَاءِ وَالْمَدِّ،  
(وَسَمَاعُهُ) وَهُوَ مَا يُقَالُ خَلْفَ الْإِبِلِ مِنْ رَجَزٍ وَغَيْرِهِ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ  
تَنْشِيطِهَا لِلسَّيْرِ وَإِيقَاطِ النَّوَامِ، (وَيُكْرَهُ الْغِنَاءُ) بِكُسْرِ الْغَيْنِ وَالْمَدِّ (بَلَا آلَةٍ  
وَسَمَاعُهُ) لِمَا فِيهِ مِنَ اللَّهْوِ، (وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ آلَةٍ مِنْ شِعَارِ الشَّرْبَةِ)  
لِلْخَمْرِ (كَطَنْبُورٍ وَعُودٍ وَصَنْجٍ وَمِزْمَارٍ عِرَاقِيٍّ وَاسْتِمَاعُهَا) ؛ لِأَنَّهَا تُطْرِبُ  
(لَا يَرَاعُ فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهُ يُنَشِّطُ عَلَى السَّيْرِ فِي السَّفَرِ.

(قُلْتُ: الْأَصَحُّ تَحْرِيمُهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ) قَالَ فِي الرُّوُضَةِ بَعْدَ تَضَحُّجِهِ  
أَيْضًا: وَهُوَ هَذِهِ الرَّمَارَةُ الَّتِي يُقَالُ لَهَا الشَّبَابَةُ.

(وَيَجُوزُ دُفُّ لِعُرْسٍ وَخِتَانٍ، وَكَذَا غَيْرُهُمَا)، مِمَّا هُوَ سَبَبٌ لِإِظْهَارِ  
السُّرُورِ (فِي الْأَصَحِّ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ جُلَاجِلٌ) فِي وَاحِدٍ مِنَ الثَّلَاثَةِ، وَقِيلَ:  
لَا يُبَاحُ مَا هِيَ فِيهِ فِي وَاحِدٍ مِنْهَا وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ فِي الثَّالِثِ: لَا يَجُوزُ  
الْخَالِي عَنْهَا فِيهِ.

(وَيَحْرُمُ ضَرْبُ الْكُوبَةِ وَهِيَ: طَبْلٌ طَوِيلٌ ضَيِّقُ الْوَسَطِ) وَاسِعُ الطَّرْفَيْنِ؛ لِحَدِيثٍ: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْمَعْنَى فِيهِ: التَّشَبُّهُ بِمَنْ يَعْتَادُ ضَرْبَهُ وَهُمْ الْمُخَنَّثُونَ، قَالَهُ الْإِمَامُ، (لَا الرَّقْصُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ تَكْسُرٌ، كَفِعْلِ الْمُخَنَّثِ)، بِكَسْرِ النُّونِ وَبِالْمَثَلَةِ فَيَحْرُمُ. (وَيُبَاحُ قَوْلُ شَعْرٍ) أَيِ إِنْشَاؤُهُ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ (وِإِنْشَادُهُ) وَاسْتِمَاعُهُ (إِلَّا أَنْ يَهْجُو) فِيهِ وَلَوْ بِمَا هُوَ صَادِقٌ فِيهِ (أَوْ يُفَحِّشَ) فِيهِ بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْحَاءِ، (أَوْ يُعَرِّضَ) وَفِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ: يُشَبِّبُ فِيهِ (بِامْرَأَةٍ مُعَيَّنَةٍ) أَوْ غُلَامٍ مُعَيَّنٍ فَيَحْرُمُ وَتُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ بِخِلَافِ الْمُبْهَمِينَ؛ لِأَنَّ التَّشْبِيهَ صَنْعَةٌ، وَغَرَضُ الشَّاعِرِ تَحْسِينُ الْكَلَامِ لَا تَحْقِيقُ الْمَذْكُورِ.

(وَالْمُرُوءَةُ) لِلشَّخْصِ (تَخْلُقُ بِخُلُقٍ أَمْثَالِهِ فِي زَمَانِهِ وَمَكَانِهِ، فَالْأَكْلُ فِي سُوقٍ)، وَالشُّرْبُ فِيهَا لِغَيْرِ سُوقٍ إِلَّا إِذَا غَلَبَهُ الْعَطَشُ وَمِثْلُهُ الْجُوعُ (وَالْمَشْيُ) فِيهَا (مَكْشُوفَ الرَّأْسِ) أَوْ الْبَدَنِ غَيْرَ الْعَوْرَةِ مِمَّنْ لَا يَلِيقُ بِهِ مِثْلُهُ، (وَقُبْلَةُ زَوْجَةٍ وَأَمَةٍ) لَهُ (بِحَضْرَةِ النَّاسِ وَإِكْتَارُ حِكَايَاتِ مُضْحَكَةٍ) بَيْنَهُمْ (وَلُبْسُ فَقِيهِ قَبَاءً وَقَلْنَسُوءَةٌ حَيْثُ) أَيِ فِي بَلَدٍ (لَا يَعْتَادُ) لِلْفَقِيهِ (وَإِكْبَابٌ عَلَى لَعِبِ الشَّطْرَنْجِ أَوْ) عَلَى (غِنَاءٍ أَوْ سَمَاعِهِ وَإِدَامَةِ رَقْصٍ يُسْقِطُهَا) أَيِ الْمُرُوءَةُ.. (وَالْأَمْرُ فِيهِ) أَيِ فِي مُسْقِطِهَا (يَخْتَلِفُ) بِالْأَشْخَاصِ وَالْأَحْوَالِ وَالْأَمَاكِنِ) فَيُسْتَنْفَعُ مِنْ شَخْصٍ دُونَ آخَرَ وَفِي حَالٍ دُونَ حَالٍ وَفِي بَلَدٍ دُونَ آخَرَ كَمَا عَلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ، (وَحِرْفَةٌ دَنِيَّةٌ) بِالْهَمْزِ (كَحِجَامَةٍ وَكُنْسٍ وَدَبْغٍ مِمَّا لَا تَلِيقُ بِهِ) بِالْفُوقَانِيَّةِ (يُسْقِطُهَا)

لِإِشْعَارِهِمَا بِالْخِسَّةِ (فَإِنْ اِعْتَادَهَا وَكَانَتْ حِرْقَةً أَبْيَهُ فَلَا) تُسْقِطُهَا (فِي الْأَصَحِّ) وَالثَّانِي: نَعَمْ لِمَا تَقَدَّمَ، قَالَ فِي الرُّوضَةِ: لَمْ يَتَعَرَّضِ الْجُمْهُورُ لِهَذَا الْقَيْدِ، وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَنْقَيَدَ بِصَنْعَةِ آبَائِهِ أَيْ الْمَذْكُورِ فِي الشَّرْحِ بَلْ يُنْظَرُ هَلْ تَلِيْقُ بِهِ هُوَ أَمْ لَا<sup>(١)</sup>.

(١) بعد أن انتهى المصنف من شرط العدالة بدأ يتكلم عن الأعمال التي يمكن أن تؤثر في الشهادة بالرد وعدمه، فبدأ الكلام عن النرد والشطرنج وهما اللبتان المعروفتان وحكم النرد أنه يحرم اللعب به لخبر عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ» وهو مع ذلك صغيرة من الصغائر وهذا هو الصحيح في المذهب ومقابل الصحيح أنه يكره اللعب به وهي كلمة فارسية معربة واسمها نردشير وفي الحديث عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ شِيرٍ، فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خَنْزِيرٍ وَدَمِهِ»

أما عن حكم اللعب بالشطرنج فإنه يكره والفرق بينه وبين النرد أن الشطرنج وضع أصلاً لصحة الفكر والتدبير، فهو يعين على تدبير الحروب والحساب أما النرد فموضوعه ما يخرج به الحصى ونحوه كالأزلام، ومثل النرد لعب الطاب، وقد أفتى السبكي بتحريمه، لأن العمدة فيه على ما تخرجه الجرائد الأربع وقال غيره بكرهته كالشطرنج والقول بتحريمه أصح قياساً على النرد، فإذا شرط في الشطرنج اللعب على مال من الجانبين بأن من يغلب يأخذ ماله ومال صاحبه فيكون بذلك قماراً فيحرم بالإجماع وعليه ترد شهادته به لارتكابه كبيرة من الكبائر، لكن إن كان المال من جانب واحد من أحد اللاعبين فليس بقمار وهو حرام أيضاً لأنه من باب تعاطي العقود الفاسدة لكن لا ترد به الشهادة لأنه خطأ بتأويل لكن إن اقترن به فحش أو تأخير فريضة عن وقتها عمداً أو سهواً وتكرر ذلك فهو حرام وترد به الشهادة.

ويكره اللعب بالحمّام ومهارشة الديكة ومحارشة الكلاب والقردة ونطاح الكباش.

وبياح الحداء وهو ما يقال خلف الإبل من رجز شعر وغيره وإباحته؛ لأخبار وردت فيه صحيحة، ولما فيه من تنشيط الإبل وإيقاظ للنائم، وقد ذكر الغزالي في إحياء علوم الدين عن أبي بكر الدينوري أنه كان في البادية فاستضافه رجل فرأى عنده عبداً أسوداً مقيداً فسأله عنه فقال مولاه : إنه ذو صوت طيب وكانت له عيس فحملها أحمالاً ثقيلة وحداها فقطعت مسيرة ثلاثة أيام في يوم واحد فلما حطت أحمالها ماتت كلها قال فشغعت فيه فشغعتني ثم سألته أن يحدو لي فرفع صوته فسقطت لوجهي من طيب صوته حتى أشار إليهِ مولاه بالسكوت، وبياح سماع الحداء واستماعه ودليله ما قاله الشافعي رحمه الله: وَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُدَاءَ وَالرَّجَزَ، وَأَمَرَ ابْنُ رَوَاحَةَ فِي سَفَرِهِ فَقَالَ: «حَرِّكَ بِالْقَوْمِ»، فَأَنْدَفَعَ يَرْجُزُ .

ويكره سماع الأغاني، ودليله قوله تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا)، قال ابن مسعود: هو والله الغناء، وقد روي هذا الكلام عن ابن عباس وجماعة من التابعين ومحل كراهة الغناء إن كان بلا آلة من آلات اللهو المحرمة، أما عن تحسين الصوت بقراءة القرآن فإنه مسنون ولا بأس فيه بترديد الآية للتدبر ولا بأس باجتماع الجماعة في القراءة بالألحان إلا إذا أفرط في المد والإشباع حتى ولد حروفاً من الحركات أو أسقط حروفاً فإنه يحرم ويفسق به القارئ ويأثم المستمع لأنه عدل به عن المنهج القويم ويسن ترتيل القراءة وتدبرها والبكاء عندها واستماع لشخص حسن الصوت ومدارسته وهو أن يقرأ على غيره ويقرأ عليه غيره.

ويحرم استعمال آلة من شعار الشراب وهم القوم الذين اجتمعوا على الشارب المحرم مع استعمال آلة كالعود والطنبور والصنج والعود هو الآلة الوترية المعروفة والطنبور ومثله الربابة المعروفة والصنج ويقال له الصفاقين وهو من صفر أي نحاس تضرب إحداها على الأخرى وقيل هو من صفر عليه أوتار يضرب بها، ومن المعازف الرباب وسميت بذلك لخلو جوفها فلا تحرم على الأصح من المذهب، لكن النووي يرى أن الأصح تحريمها والأول قال بعدم الحرمة لأنها تنشط على السير في السفر

ومال على ترجيح هذا القول كثير من الفقهاء وقد استندوا إلى عدم ورود دليل معتبر في تحريمه.

ويجوز الدف وقد سمي بذلك لتدفيف الأصابع عليه ويجوز استعماله لعرس ودليل ذلك ما رواه الترمذي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ، وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْذُّفُوفِ»، ويجوز استعماله أيضاً لختان ونحوه؛ لما روي أَنَّ عَمَرَ كَانَ إِذَا سَمِعَ صَوْتَ دُفٍّ أَوْ كَبَرٍ فَقَالُوا: عُرْسٌ أَوْ خَتَانٌ، سَكَتَ. ، وقد جوز فريق من الفقهاء استعمالهما في المناسبات مثل العرس كالميلاد أو العيد أو قدوم غائب أو شفاء مريض ودليله عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي بُرَيْدَةَ، يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ جَاءَتْ جَارِيَّةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ أَنْ رَدَّكَ اللَّهُ سَالِمًا أَنْ أَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِالْذُّفِّ وَأَتَغَنَّى، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ كُنْتَ نَذَرْتَ فَأَضْرِبِي وَإِلَّا فَلَا. فَجَعَلْتُ تَضْرِبُ، لِأَنَ الْمَرَادَ مِنْهُ إِظْهَارَ السُّرُورِ قَالَ الْبَغَوِيُّ فِي كِتَابِهِ شَرْحَ السَّنَةِ يَسْتَحَبُّ فِي الْعُرْسِ وَالْوَلِيمَةِ وَوَقْتُ الْعَقْدِ وَالزَّفَافِ وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ فِي الْمَذْهَبِ، وَيَبَاحُ اسْتِخْدَامُ الدَّفِّ حَتَّى وَإِنْ كَانَ فِيهِ جَلَاظِلٌ لِأَنَّ الْخَبَرَ غَيْرُ مُقَيَّدٍ وَالَّذِي ادَّعَى غَيْرَ ذَلِكَ فَعَلِيهِ الْإِثْبَاتُ.

واستكمالاً لما بدأه المصنف بالكلام عن الأعمال التي يمكن أن يكون لها تأثير على الشهادة بالرد أو القبول تكلم عن الكوبة وفسرها بأنها طبل طويل ضيق الوسط واسع الطرفين ودليل تحريمها خبر «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيَّ، أَوْ حُرِّمَ الْخَمْرُ، وَالْمَيْسِرُ، وَالْكُوبَةُ» قَالَ: «وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» قَالَ سُفْيَانُ: فَسَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ بَدِيْمَةَ عَنِ الْكُوبَةِ، قَالَ: «الطَّبْلُ»، وَسَبَبُ تَحْرِيمِهَا أَنَّهُ تَشَبَهَ بِالْمَخْنَثِينَ، وَكَمَا يَحْرَمُ ضَرْبُهَا يَحْرَمُ الْاسْتِمَاعُ إِلَيْهَا.

أما عن الرقص من الرجال فهو غير محرم؛ لأنه مجرد حركات على استقامة أو اعوجاج ولا يكره بل يباح بدليل خبر الصحيحين عن عَائِشَةَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرْنِي، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْخَبَشَةِ، وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُمْ فَقَالَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعُوهُمْ، أَمَّا بَنِي أَرْفَدَةَ يَغْنِي مِنَ الْأَمْنِ»، وكانت عائشة رضي الله عنها صغيرة أو قبل أن تنزل آيات الحجاب، لذلك قيل: يكره الرقص، وقال العز بن عبد السلام الرقص لا يتعاطاه إلا ناقص العقل ولا يصلح إلا للنساء ثم استثنى ما فيه تكسر كفعل المخنس وهو من يتخلق بأخلاق النساء، ويلاحظ أن كلام الفقهاء هنا عن حركات الرجال التي تتخذ صورة الرقص لأن الكلام هنا عن صفات الرجال الذين يصلحون لأداء الشهادة أما عن الرقص المعروف الآن فحرمة لا تحتاج إلى نظر أو دليل لأن مخالفة الشرع فيه بادية من كشف العورات والنظر المحرم وإثارة الغرائز والشهوات.

أما عن قول الشعر وإنشاده فهو مباح ودليله ما روي عن الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ سَمِعَ حَسَانَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيَّ، يَسْتَشْهِدُ أَبَا هُرَيْرَةَ: أَنْشُدَكَ اللَّهَ، هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يَا حَسَّانُ، أَجِبْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ» قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَعَمْ، وقال الأصمعي: سمعت شعر الهذليين على محمد بن إدريس الشافعي، وروى الشافعي وغيره عن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الشَّعْرُ كَلَامٌ حَسَنُهُ كَحَسَنِ الْكَلَامِ، وَقَبِيحُهُ كَقَبِيحِهِ» .

وقد استثنى من الشعر بعض الصور منها الهجاء للمسلم المعصوم ولو بما فيه وعليه يحمل حديث ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَأَنَّ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا»، ويستثنى كذلك الفحش فيه كأن يجاوز الحد في الإطراء والمدح لحديث ما كان الحياء في شيء إلا زانه ولا كان الفحش في شيء إلا شانه".

ومن المنهي عنه في الشعر التعريض بالمرأة أي التشبيب بها غير أمته وزوجته، والمراد بالتشبيب أي ذكر صفاتها من طول وقصر وصدغ وغيرها فيحرم ذلك وترد به شهادته لما فيه من الإيذاء وقيد المصنف قوله التعريض بامرأة معينة فإن كانت غير معينة فلا ترد شهادته كما أنشد كعب بن زهير قصيدته بين يدي رسول الله صلى الله

عليه وسلم وأولها: بانث سعاد فقلبي اليوم متبول، وفي التشبيب بأتمه وزوجته خلاف لكن إن شيب بأتمه وزوجته مما حقه الإخفاء فتد به شهادته لسقوط مروءته كما لو وصف امرأته بأعضائها الباطنة.

ثم اشترط المصنف المروءة وعرفها بأحسن ما قيل فيها وهي تخلق المرء بخلق أمثاله من أبناء عصره ممن يراعي مناهج الشرع وآدابه في زمانه ومكانه، وقيل: إن المروءة تعني التحرز عما يسخر منه الناس، وقيل: هي أن يصون نفسه عن الأذناس ولا يشينها عند الناس، ثم ذكر أمثلة يختلف الناس فيها في المروءة كالأكل والشرب في السوق لغير أهل السوق، والمشي في الأسواق مكشوف الرأس أو جزء من البدن غير العورة مما لا يليق بمثله ولغير حاجة كإحرام بحج أو عمرة والإكثار من الحكايات المضحكة عادة فإن كانت طبعاً فيه فلا تضر وليس الفقيه للبقاء.

وقد سمي بذلك لاجتماع أطرافه وقلنسوة وهي ما يلبس على الرأس إن كان في بلد أهله لا يعتادون لبسهما والغناء وسماعه والإكثار من الرقص للرجال على الوصف المبين قبل ذلك، ومنه الحرفة الدنيئة المباحة كحجامة وكنس ودبغ وحارس حمام وقصاب وإسكاف ونخال وحذاء والحارس عموماً إن كانت هذه الحرفة لا تليق بأمثاله.

وإذا كانت الحرفة الدنيئة حرفة أبيه وأخذها عنه فلا تسقط عدالته لكن إذا نظرنا للحرف وأصحابها نجد أن عادات الناس قد تغيرت ونظرتهم لأصحاب هذه الحرف لم تعد هي تلك النظرة السابقة، فلا يستطيع أحد أن يرد شهادة قصاب (جزار) أو سماك لمجرد أن مهنته هذه بل أصبحت مصدر فخر واعتزاز، كما أن الأعمال لم تعد اليوم مجرد اختيار بل يمكن القول إن الناس يجبرون عليها نظراً لعدم توافر الأعمال اللائقة بكل إنسان حسب دراسته وتعليمه، لكن هناك حرف غير مباحة كالعراف والمنجم والكاهن، فلا تقبل شهادتهم لأن شعارهم التلبيس على العامة، ولا يقدح في الشهادة السؤال عند الحاجة إليه، لكن إن اتخذها مهنة أو حرفة فإن شهادته ترد.

(وَالْتَهْمَةُ) بِضَمِّ النَّاءِ وَفَتْحِ الْهَاءِ فِي الشَّخْصِ (أَنْ يَجُرَّ إِلَيْهِ) بِشَهَادَتِهِ (نَفْعًا أَوْ يَدْفَعَ عَنْهُ) بِهَا (ضَرَرًا فَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ لِعَبْدِهِ) الْمَأْدُونِ لَهُ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ، (وَمُكَاتِبِهِ وَغَرِيمٍ لَهُ مَيِّتٍ أَوْ عَلَيْهِ حَجَرٌ فَلَسٍ، وَبِمَا هُوَ وَكِيلٌ فِيهِ وَبِبَرَاءَةٍ مِنْ ضَمْنِهِ) هُوَ (وَبِجَرَاةٍ مُؤَرِّثِهِ) غَيْرِ أَصْلِهِ وَفَرَعِهِ قَبْلَ انْدِمَالِهَا؛ لِأَنَّهُ لَوْ مَاتَ كَانَ الْأَرْضُ لَهُ.

(وَلَوْ شَهِدَ لِمُورِثٍ لَهُ مَرِيضٍ أَوْ جَرِيحٍ بِمَالٍ قَبْلَ الْإِنْدِمَالِ) وَهُوَ غَيْرُ أَصْلٍ وَفَرَعٍ لَهُ، (قُبِلَتْ) شَهَادَتُهُ (فِي الْأَصَحِّ) وَالثَّانِي قَالَ: لَا كَالْجِرَاةِ لِلتَّهْمَةِ، وَفُرِقَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْجِرَاةَ سَبَبٌ لِلْمَوْتِ النَّاقِلِ لِلْحَقِّ إِلَيْهِ، بِخِلَافِ الْمَالِ وَبَعْدَ الْإِنْدِمَالِ تُقْبَلُ قِطْعًا؛ لِإِنْتِفَاءِ التَّهْمَةِ، (وَتُرَدُّ شَهَادَةُ عَاقِلَةٍ يَفْسُقُ شُهُودُ قَتْلِ) يَحْمِلُونَهُ مِنْ خَطَأٍ أَوْ شِبْهِ عَمْدٍ بِخِلَافِ شُهُودِ إِقْرَارٍ بِذَلِكَ أَوْ شُهُودِ عَمْدٍ، وَذِكْرُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ هُنَا مَعَ تَقْدِيمِهَا فِي كِتَابِ دَعْوَى الدِّمِ لَا يُعَدُّ تَكَرُّرًا؛ لِأَنَّهُ لِلتَّمْثِيلِ، (و) تُرَدُّ شَهَادَةُ (غُرَمَاءِ مُفْلِسٍ يَفْسُقُ شُهُودُ دَيْنٍ آخَرَ) لِأَنَّهُمْ يَدْفَعُونَ بِهَا ضَرَرَ الْمَرَاحِمَةِ<sup>(١)</sup>.

---

(١) بدأ المصنف في شرط عدم التهمة في شهادة الشاهد، ومعنى التهمة: أن يجبر الشاهد بشهادته إلى نفسه نفعاً أو يدفع بها ضرراً.

وقد بدأ بالصور التي يجبر بها إلى نفسه نفعاً فرد شهادة الشاهد لعبده لأن العبد وما ملكت يداه ملك لسيده فلو شهد له فكأنما شهد لنفسه وكذلك شهادة السيد لمكاتبه لأن له في ماله علة ويمكن أن يعود له هذا المال إن عجز العبد عن سداد الأقساط التي عليه وكذلك الشهادة لغريم له ميت أو عليه حجر بفلس لأنه لما تعلق حقه بالمال فيهما فكأنه يشهد لنفسه وربما يظهر غريم آخر للميت أو للمحجور عليه كما ترد شهادة الشاهد ببراءة من ضمنه لأنه يدفع بها ضرراً عن نفسه لأنه بضمانه فإن عليه



(وَلَوْ شَهِدَ أَيْ الشَّاهِدَانِ (لَاثْنَيْنِ بِوَصِيَّةٍ) مِنْ تَرَكَهَ (فَشَهِدَا) أَيْ الْإِثْنَانِ  
(لِلشَّاهِدَيْنِ بِوَصِيَّةٍ مِنْ تِلْكَ التَّرَكَةِ قُبِلَتْ الشَّهَادَتَانِ فِي الْأَصَحِّ) وَالثَّانِي:  
الْمَنْعُ لِاحْتِمَالِ الْمُوَاطَّاةِ، وَيُدْفَعُ بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا مَعَ أَنَّ كُلَّ شَهَادَةٍ  
مُنْفَصِلَةٌ عَنِ الْأُخْرَى<sup>(١)</sup>.

(وَلَا تُقْبَلُ) الشَّهَادَةُ (لِلْأَصْلِ وَلَا فَرْعٍ) لِلشَّاهِدِ (وَتُقْبَلُ) مِنْهُ (عَلَيْهِمَا، وَكَذَا)  
تُقْبَلُ مِنْ ابْنَيْنِ (عَلَى أَبِيهِمَا بِطَّلَاقِ ضَرَّةٍ أُمِّهِمَا أَوْ قَذْفِهَا فِي الْأَظْهَرِ)  
وَالثَّانِي: الْمَنْعُ؛ لِأَنَّهَا تَجُرُّ نَفْعًا إِلَى الْأُمِّ فَالْقَذْفُ مُحَوِّجٌ إِلَى اللَّعَانِ  
الْمُسَبِّبِ لِلْفِرَاقِ، وَالْأَوَّلُ قَالَ: لَا عِبْرَةَ بِمِثْلِ هَذَا الْجَرِّ، (وَإِذَا شَهِدَ لِقَرْعِ)

---

سداد ما قصر فيه فذلك لا تقبل شهادته، كما ترد شهادة الوارث لمورثه بأن فلانا قد  
جرحه لأنه لو مات من أثر هذا الجرح فإن له الأرض فتكون شهادته قد جلبت له  
نفعاً.

وبعد انتهاء المصنف من صور الشهادة الجالبة للنفع شرع في الشهادة الدافعة  
للضرر ومن هذه الصور رد شهادة العاقلة إذا فسقوا الشهود في جريمة القتل خطأً  
أو شبه العمد لأنهم سيحملون دية القتل فهم بذلك يدفعون الضرر عن أنفسهم فترد  
شهادتهم، بخلاف القتل العمد فلا ترد شهادتهم فيه، ومن صور الشهادة الدافعة للضرر  
إذا شهد الدائنون لرجل حكم عليه بالإفلاس بأن الشهود الذين شهدوا بوجود دين جديد  
على المفلس إنما هم فسقة فترد شهادتهم لأنهم بهذه الشهادة يدفعون ضرر مشاركة  
ومزاحمة صاحب الدين الجديد فهم أصحاب مصلحة في عدم ثبوت هذا الدين.

(١) لو شهد شاهدان لاثنتين بوصية من تركه المتوفى فقام الاثنان للذان شهد لهما  
الشاهدان فشهدا هما للشاهدين بوصية أيضاً من نفس تلك التركة فإن شهادتهما  
لبعضهما تقبل لانتفاء التهمة وفقاً للأصح في المذهب، ومقابله لا تقبل لاحتمال  
وجود التواطؤ بينهما.

أَوْ أَصْلٍ لَهُ (وَأَجَنْبِيٍّ قُبِلْتُ لِلْأَجَنْبِيِّ فِي الْأَظْهَرِ) مِنْ قَوْلِي تَفْرِيقِ الصَّفَقَةِ وَالثَّانِي: لَا تَفْرِيقَ فَلَا تُقْبَلُ لَهُ.

(قُلْتُ) أَخْذَاً مِنَ الرَّافِعِيِّ فِي الشَّرْحِ (وَتُقْبَلُ لِكُلِّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ) مِنَ الْآخِرِ (وَالْأَخِ) مِنْ أَخِيهِ (وَصَدِيقٍ) مِنْ صَدِيقِهِ (وَاللَّهُ أَعْلَمُ) إِذْ لَا تُهْمَةُ.

(وَلَا تُقْبَلُ مِنْ عَدُوٍّ) لِشَخْصٍ عَلَيْهِ (وَهُوَ مَنْ يُبْغِضُهُ بِحَيْثُ يَتَمَنَّى زَوَالَ نِعْمَتِهِ وَيَحْزَنُ بِسُرُورِهِ وَيَفْرَحُ بِمُصِيبَتِهِ) وَذَلِكَ قَدْ يَكُونُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، وَقَدْ يَكُونُ مِنْ أَحَدِهِمَا، (وَتُقْبَلُ لَهُ) أَيُّ لِلْعَدُوِّ (وَكَذًا عَلَيْهِ فِي عَدَاوَةِ دِينٍ كَكَافِرٍ وَمُتَبَدِّعٍ) أَيُّ غَيْرِ سُنِّيٍّ (وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ مُتَبَدِّعٍ لَا تُكْفَرُهُ) بِبِدْعَتِهِ كَمُنْكَرِي صِفَاتِ اللَّهِ وَخَلْقِهِ، أَفْعَالٍ عَبِيدِهِ وَجَوَازِ رُؤْيِيَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ لِاعْتِقَادِهِمْ أَنَّهُمْ مُصِيبُونَ فِي ذَلِكَ لِمَا قَامَ عِنْدَهُمْ بِخِلَافٍ مِنْ نُكْفَرُهُ بِبِدْعَتِهِ كَمُنْكَرِي خُذُوثِ الْعَالَمِ وَالْبُعْثِ وَالْحَشْرِ لِلْأَجْسَامِ وَعِلْمِ اللَّهِ بِالْمَعْدُومِ وَبِالْجُزْئِيَّاتِ لِإِنْكَارِهِمْ بَعْضَ مَا عُلِمَ مَجِيءُ الرَّسُولِ بِهِ ضَرُورَةً فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ، (لَا مُعْقَلٍ لَا يَضْبِطُ وَلَا مُبَادِرٍ) بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا فَكُلُّ مَنْهُمْ مُتَهَمٌ وَيُسْتَنْتَى مِنَ الثَّانِي مَا ذَكَرَ فِي قَوْلِهِ:

(وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى) مَا ذَكَرَ فِي قَوْلِهِ كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ، بِأَنْ يَشْهَدَ بِتَرْكِهَا، (وَفِيمَا لَهُ فِيهِ حَقٌّ مُؤَكَّدٌ؛ كَطَّلَاقٍ وَعَتَقٍ وَعَفْوٍ عَنْ قِصَاصٍ وَبَقَاءِ عِدَّةٍ وَانْقِضَائِهَا) ، بِأَنْ يَشْهَدَ بِمَا ذَكَرَ لِيَمْنَعَ مِنْ مُخَالَفَةِ مَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ (وَحَدِّ اللَّهِ) تَعَالَى بِأَنْ يَشْهَدَ بِمُوجِبِهِ، وَالْأَفْضَلُ فِيهِ السِّتْرُ، كَحَدِّ الزَّنا وَالسَّرْقَةِ وَقَطْعِ الطَّرِيقِ، (وَكَذًا النَّسَبُ عَلَى الصَّحِيحِ) لِأَنَّ فِي وَضْلِهِ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى، وَالثَّانِي قَالَ: هُوَ حَقٌّ

لَا دَمِيَّ وَحَقُّهُ كَالْقِصَاصِ وَحَدُّ الْقَذْفِ وَالْبَيْعِ وَالْإِقْرَارِ لَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ، وَصُورَتُهَا مَثَلًا: أَنْ يَقُولَ الشُّهُودُ ابْتِدَاءً لِلْقَاضِي: نَشْهَدُ عَلَى فُلَانٍ بِكَذَا فَأَحْضَرَهُ لِنَشْهَدَ عَلَيْهِ فَإِنْ ابْتَدَعُوا وَقَالُوا: فُلَانٌ زَنَى فَهُمْ قَذْفَةٌ، وَإِنَّمَا تُسْمَعُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا فَلَوْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّ فُلَانًا أَعْتَقَ عَبْدَهُ أَوْ أَنَّهُ أَخُو فُلَانَةٍ مِنَ الرِّضَاعِ لَمْ يَكْفِ حَتَّى يَقُولَا: إِنَّهُ يَسْتَرْقُهَا، أَوْ إِنَّهُ يُرِيدُ نِكَاحَهَا، وَمَا تُقْبَلُ فِيهِ هَلْ تُسْمَعُ فِي الدَّعْوَى؟ قِيلَ: لَا؛ اكْتِفَاءً بِالْبَيِّنَةِ، وَقِيلَ: نَعَمْ؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ قَدْ لَا تُسَاعِدُ وَيُرَادُ اسْتِخْرَاجُ الْحَقِّ بِإِقْرَارِ الْمُدْعَى عَلَيْهِ "وَمَتَى حَكَمَ) الْقَاضِي (بشاهدين فبأنا كافرين أو عبدتين أو صبيتين نَقَضَهُ هُوَ وَغَيْرُهُ) لَتَيَقُنِ الْخَطَأَ فِيهِ (وَكَذَا فَاسِقَانِ فِي الْأَظْهَرِ) كَمَا فِي الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ، وَالثَّانِي: لَا يُنْقَضُ؛ لِأَنَّ قَبُولَهُمَا بِالْاجْتِهَادِ وَقَبُولَ بَيِّنَةٍ فَسَقِيَهُمَا بِالْاجْتِهَادِ، وَلَا يُنْقَضُ الْاجْتِهَادُ بِالْاجْتِهَادِ وَعُورِضَ بِأَنَّ الْحُكْمَ بِالْاجْتِهَادِ يُنْقَضُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ.

(وَلَوْ شَهِدَ كَافِرٌ أَوْ عَبْدٌ أَوْ صَبِيٌّ ثُمَّ أَعَادَهَا بَعْدَ كَمَالِهِ قُبِلَتْ أَوْ فَاسِقٌ تَابَ) بَعْدَهَا وَأَعَادَهَا (فَلَا) تُقْبَلُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي ذَلِكَ بِخِلَافِهِمْ، (وَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِي غَيْرِهَا بِشَرْطِ اخْتِبَارِهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ مُدَّةً يُظَنُّ بِهَا صِدْقُ تَوْبَتِهِ وَقَدَرُهَا الْأَكْثَرُونَ بِسَنَةٍ) وَقِيلَ تُقَدَّرُ بِسَنَةِ أَشْهُرٍ وَقِيلَ لَا تَتَقَدَّرُ بِمُدَّةٍ، وَيَخْتَلِفُ الظَّنُّ بِالْأَشْخَاصِ وَأَمَارَاتِ الصِّدْقِ (وَيُشْتَرَطُ فِي تَوْبَةِ مَعْصِيَةٍ قَوْلِيَّةٍ الْقَوْلُ فَيَقُولُ الْقَاضِي مَثَلًا: قَذْفِي بَاطِلٌ وَأَنَا نَادِمٌ عَلَيْهِ لَا أَعُودُ إِلَيْهِ، وَكَذَا شَهَادَةُ الزُّورِ) قَوْلُ فِيهَا عَلَى وَزَانِ ذَلِكَ: شَهَادَتِي بَاطِلَةٌ، وَأَنَا نَادِمٌ عَلَيْهَا وَلَا أَعُودُ إِلَيْهَا.

(قُلْتُ) أَخْذًا مِنَ الرَّافِعِيِّ فِي الشَّرْحِ: (وَ) الْمَعْصِيَةُ (غَيْرُ الْقَوْلِيَّةِ) كَالزَّيْنِ وَالشُّرْبِ وَالسَّرِقَةِ (يُسْتَرْطُ) فِي التَّوْبَةِ مِنْهَا (إِفْلَاحٌ) عَنْهَا (وَنَدَمٌ) عَلَيْهَا (وَعَزَمَ أَنْ لَا يَعُودَ) إِلَيْهَا، (وَرَدُّ ظُلَامَةِ آدَمِيٍّ) إِنْ تَعَلَّقْتُ بِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِنْ مَالٍ وَغَيْرِهِ، فَيُؤَدِّي الرِّكَاءَ لِمُسْتَحِقِّهَا وَيَرُدُّ الْمَعْصُوبَ إِنْ بَقِيَ وَبَدَلَهُ إِنْ تَلَفَ لِمُسْتَحِقِّهِ وَيُمْكِنُ مُسْتَحِقُّ الْقِصَاصِ وَحَدُّ الْقَذْفِ مِنَ الْإِسْتِيفَاءِ وَمَا هُوَ حَدُّ لِلَّهِ تَعَالَى كَالزَّيْنِ وَالشُّرْبِ إِنْ لَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَلَهُ أَنْ يُظْهِرَهُ وَيَقْرَ بِهِ لِيَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَلَهُ أَنْ يَسْتُرَ عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ الْأَفْضَلُ وَإِنْ ظَهَرَ فَقَدْ قَاتَ السِّتْرُ فَيَأْتِي الْإِمَامَ وَيَقْرُ بِهِ لِيُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ<sup>(١)</sup>.

(١) شهادة الأقارب لبعضهم. ألصق الناس بالقرابة الأصل والفرع فبدأ بهما وقال لا تقبل شهادة أصل لفرعه ولا فرع لأصله لأن الشهادة تعتبر كأنما يشهد لنفسه، أما الشهادة عليهما فإنها تقبل لانتفاء التهمة، وتقبل الشهادة من الفروع على أبيهما بأنه طلق ضرة أمهم أو قذفها في الأظهر لضعف التهمة في نفع أمهم من وراء هذه الشهادة لأنه إن أراد طلقها أو نكح عليها مع إمساكها، ومقابل الأظهر يمنع هذه الشهادة لأنها تجر نفعاً إلى الأم وهو انفرادها بالأب وإذا كان الحق مشتركاً بين فرعه وشخص أجنبي فشهد لهما بنبوت هذا الحق فإن شهادته لفرعه لا تصح قطعاً لأنها تجر نفعاً وأما بالنسبة للأجنبي فالأظهر أنها تقبل بناءً على القياس على تقريب الصفة والثاني لا تفرق الصفة وعليه فلا تجوز شهادته للأجنبي منفرداً .

شهادة كل من الزوجين للآخر. جزم الرافعي والنووي بقبول شهادة كل منهما للآخر لأن الذي بينهما عقد يطرأ ويزول، ولا يصح هنا الاحتجاج بأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم لعائشة على من شهد بالإفك لأن الذي حكم هو الله سبحانه لذلك لم يجلداهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد نزول الآيات، ولو شهد أحد الزوجين على

الآخر فشهادته مقبولة قطعاً لعدم التهمة، لكن لو شهد عليها بالزنا فلا تقبل لأنه يدعي خيانتها لفراسه فهي شهادة له وليس له طريق غلا الملاعنة. وتقبل شهادة الأخ لأخيه وكذلك بقية الحواشي وهم من دون الأصل والفرع من الأقارب كما تقبل شهادة الصديق لصديقه لضعف التهمة لأنهما لا يتهمان تهمة الأصل والفرع وأما إن كانت الشهادة عليه في كل ما ذكر قبلت الشهادة قطعاً لعدم التهمة.

شهادة العدو على عدوه. غير مقبولة لحديث رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا زَانٍ وَلَا زَانِيَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ»، والمراد بالعداوة هنا العداوة الظاهرة الدنيوية أي من يبغضه حتى يتمنى زوال نعمته والعداوة غير البغضاء فالبغضاء بالقلب والعداوة بالفعل وهي أغلظ فلا يفسر الأغلظ بالأخف والضابط في ذلك العرف.

والعداوة هي العداوة الدنيوية أما العداوة الدينية فلا ترد بها الشهادة كأن يشهد مسلم على كافر أو سني على مبتدع لأن العداوة الدينية لا توجب رد الشهادة وتقبل شهادة المبتدع الذي لا نكفره ببدعته ولا نفسه بها كالمنكر لصفات الله تعالى والمنكر لخلقه أفعال العباد وجواز رؤية الله تعالى يوم القيامة لا اعتقادهم أنه مصيبون لما وجدوه من أدلة عندهم.

وأما عن القول بأننا لا نكفرهم بذلك فدليلنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَتَفَرَّقَتِ النَّصَارَى عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَتَفَرَّقَتْ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً»، فقد نص الحديث على أن الثلاث والسبعون فرقة من أمته فجعل من خالف في شيء غير معلوم من الدين بالضرورة من الأمة، والذي نكفره ببدعته من أنكر حدوث العالم والبعث والحشر وعلم الله تعالى بالمعذوم والجزئيات لإنكار بعض ما علم مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم به ضرورة فهؤلاء لا تقبل لهم شهادة ولا شهادة من يدعو الناس إلى بدعته.

وأما سب الصحابة فهناك خلاف على هل يكفر أم لا؟ أولاً اتفقوا على أن من سب عائشة رضي الله عنها بالإفك بعد من حدوا حد القذف فهو كافر لأنه مكذب لله ولكتابه ولرسوله، وأما من سب الشيخان ففيه وجهان للأصحاب أحدهما يكفر والثاني لا يكفر حتى وإن أخذنا بالثاني فهو فاسق لا تقبل له شهادة، ومن سب بقية الصحابة فهو فاسق مردود الشهادة.

قال سلطان العلماء: البدعة منقسمة إلى واجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة والطريق في ذلك أن تعرض على قواعد الشريعة فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة كالاغتسال بعلم النحو وإن دخلت في قواعد التحريم فهي محرمة كمذهب القدرية والمرجئة والمجسمة والرافضة والرد على هؤلاء من البدع الواجبة، وإن دخلت في قواعد المندوب فهي مندوبة كبناء المستشفيات والمدارس وكل بر وإحسان لم يكن في العهد الأول ولو دخلت في قواعد المكروه فهي مكروهة كزخرفة المساجد وتزيين المصاحف.

ولو دخلت في قواعد المباح فهي مباحة كالمصافحة عقب الصلوات والتوسع في المأكل والملبس، وقال الشافعي رحمه الله المحدثات ضربان: أحدهما ما خالف الكتاب أو السنة أو الإجماع فهو بدعة وضلالة والثاني ما أحدث من الخير فهو غير مذموم. ولا تقبل شهادة مغفل لا يضبط عموماً أو لا يضبط غالباً وهو من تلتبس عليه الحوادث بخلاف من لا يضبط نادراً فتقبل شهادته والأغلب فيه الحفظ ولا يسلم أحد من النسيان، ولا تقبل شهادة مبادر وهو من يأتي ليذلي بشهادته قبل أن يطلب منه ذلك أو قبل الدعوى ودليله حديث الصحيحين عن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ يُحَدِّثُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» - قَالَ عِمْرَانُ: فَلَا أَذْرِي أَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ قَرْنِهِ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً - «ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلَا يُؤْفَوْنَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السَّمَنُ». وهذا لا يتعرض مع الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي

بشهادته قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَها» فهذا محمول على ما تسمع فيه شهادة الحسبة. شهادة الحسبة: الحسبة معناها طلب الأجر والثواب من الله سواء سبق هذه الشهادة دعوى أم لا وسواء كانت في حضور المشهود عليه أو في غيبته وإنما تقبل شهادة المحتسب في حقوق الله تعالى الخالصة كالصلاة والصيام والزكاة بأن يشهد أن فلاناً امتنع عن الصلاة أو الصيام أو إخراج الزكاة، وتقبل أيضاً فيما لله فيه حق مؤكد كالطلاق بئناً كان أو رجعيّاً بخلاف الخلع فإن فيه حقاً مالياً وتقبل أيضاً في العفو عن القصاص سواء كان في النفس أو في الأطراف وكذلك في بقاء العدة أو انقضائها لما في بقاء العدة من صيانة الفروج وعدم استباحتها بغير طريق شرعي .

ولما في انقضاء العدة من الصيانة بقصد التعفف بالنكاح وكذلك التحريم بالرضاع والمصاهرة، وتقبل الحسبة أيضاً في الحدود التي لله تعالى كالزنا والسرقة وقطع الطريق بأن يشهد بأن فلاناً زنا أو سرق وكذلك الشهادة بالنسب لما في وصل النسب من حق الله تعالى وتقبل أيضاً في الوقف والوصية وتحريم المصاهرة والإسلام والكفر والبلوغ والإحصان والتعديل

ولو حكم القاضي بشهادة شاهدين فظهر أنهما عند أداء الشهادة أو عند الحكم بها كانا كافرين أو عبيدين أو صبيين أو امرأتين أو خنثيين أو أحدهما كذلك فيجب على القاضي نقض الحكم لتيقنه الخطأ، وكذلك إن اتضح أن الشهود كانا فاسقين ينقض الحكم على الأظهر في المذهب لأن العدالة في الشهود معتبرة، ومقابل الأظهر يقول إن الحكم لا ينقض لأن قبولهما كان بالاجتهاد والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.

ولو شهد شاهدان ثم فسقا أو ارتدا قبل الحكم لم يحكم بشهادتهما لأن ذلك يدعو للريبة وربما كان موجوداً عند الشهادة وإن عمي الشاهدان أو جنا أو خرسا أو ماتا حكم القاضي بشهادتهما لأن هذه الأمور لا توقع في الريبة فيما مضى.

ولو شهد كافر معلوم الكفر أو مرتد علمت رده أو صبي أو عبد ثم أعاد شهادته بنفس الهيئة التي كان عليها بعد كماله بأن أسلم الكافر أو رجع المرتد بعد استنابته

## عدد الشهود

(فَصْلٌ: لَا يُحْكَمُ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ (إِلَّا فِي هَلَالِ رَمَضَانَ) فَيُحْكَمُ بِهِ فِيهِ (فِي الْأَظْهَرِ) كَمَا تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ وَذَكَرَهُ هُنَا لِلْحَصْرِ فِيهِ لَا يُعَدُّ تَكَرُّارًا (وَيُشْتَرَطُ لِلزَّانَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ)، قَالَ تَعَالَى: (وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ) الْآيَةُ (وَالْإِقْرَارُ بِهِ اثْنَانِ) كَغَيْرِهِ (وَفِي قَوْلٍ: أَرْبَعَةٌ) كَغَفْلِهِ، وَلَا يَثْبُتُ لِلْوَأْطِ وَأَتْيَانُ الْبَهِيمَةِ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ، وَفِي وَجْهِ مِنْ طَرِيقٍ: يَنْبُتَانِ بِأَثْنَيْنِ، وَلَا بُدَّ فِي الشَّهَادَةِ بِزَنًا مِنْ ذِكْرِهِ

---

أو بلغ الصبي أو حرر العبد فإن شهادته تقبل لانقضاء التهمة ولأن المتصف بذلك لا يعبر بشهادته

ولو شهد الفاسق الذي تاب من فسقه أو عدو تاب من عداوته أو من لا مروءة له ثم عادت إليه مروءته فلا تقبل شهادته للتهمة لأن المتصف بأي من هذه الصفات يعبر بشهادته وتقبل شهادته في غير تلك الشهادة التي شهد فيها أيام فسقه بعد اختباره في صدق توبته.

ثم تكلم المصنف بعد ذلك عن أنواع التوبة وشروطها فذكر أن التوبة نوعان الأول توبة من معصية قولية وهذه يشترط فيها القول فيقول القاذف مثلاً قذفي باطل ونامد عليه وعازم على ألا أعود إليه لكي يندفع عار القذف، ويمكن أن يشترط تكذيب نفسه بين يدي القاضي وفي شهادة الزور يقول الشاهد فيها شهادتي باطلة وأنا نامد عليها ولا أعود لمثلها.

والنوع الثاني من التوبة عن المعصية غير القولية كالسرقة والزنا وشرب المسكر فيشترط فيها الإقلاع عنها والندم عليها والعزم على ألا يعود لمثلها ورد ظلامة الآدمي من مال وغيره كقصاص وحد قذف إن تعلق به، وعليه فيرد الزكاة لمستحقها ويرد المغصوب إن بقي وبذله إن تلف لمستحقه منه ويستحلّه منه أو من وارثه فإن لم يجد وارثاً سلمها لقاضي أمين فإن تعذر وجوده تصدق بها أو يسدد بها ديناً عليه إن وجد.



مُفَسَّرًا، فَيَقُولُونَ رَأَيْنَاهُ أَدْخَلَ ذَكَرَهُ أَوْ قَدَرَ الْحَشْفَةَ مِنْهُ فِي فَرْجِهَا عَلَى سَبِيلِ الزَّيْنِ (وَلِمَالٍ وَعَقْدٍ مَالِيٍّ، كَبَيْعٍ وَإِقَالَةٍ وَحَوَالَةٍ وَضَمَانٍ وَحَقٍّ مَالِيٍّ كَخِيَارٍ وَأَجَلٍ رَجُلَانٍ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَانِ) لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَاسْتَشْهِدُوا) أَيُّ فِيمَا يَقَعُ لَكُمْ {شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} فَعُمُومُ الْأَشْخَاصِ فِيهِ مُسْتَلْزِمٌ لِعُمُومِ الْأَحْوَالِ الْمُخْرَجِ مِنْهُ مَا تُشْتَرَطُ فِيهِ الْأَرْبَعَةُ وَمَا لَا يَكْتَفِي فِيهِ بِالرَّجُلِ وَالْمَرَأَتَيْنِ، (وَلِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ عُقُوبَةِ اللَّهِ تَعَالَى) كَحَدِّ الشُّرْبِ وَقَطْعِ الطَّرِيقِ وَالْقَتْلِ بِالرِّدَّةِ (أَوْ لِأَدَمِيٍّ) كَالْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ أَوْ الطَّرْفِ وَحَدِّ الْقَذْفِ (وَمَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ رَجَالٌ غَالِبًا؛ كَنِكَاحٍ وَطَلَاقٍ وَرَجْعَةٍ وَإِسْلَامٍ وَرِدَّةٍ وَجَرْحٍ وَتَعْدِيلٍ وَمَوْتٍ وَإِعْسَارٍ وَوَكَالَةٍ وَوَصَايَةٍ وَشَهَادَةٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلَانِ) رَوَى مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ «مَضَتْ السُّنَّةُ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ وَلَا فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ» وَقِيسٌ عَلَى الثَّلَاثَةِ بَاقِي الْمَذْكُورَاتِ بِجَامِعٍ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِمَالٍ وَلَا يُقْصَدُ مِنْهَا مَالٌ، وَالْقَصْدُ مِنَ الْوَكَالَةِ وَالْوَصَايَةِ الرَّاجِعَتَيْنِ إِلَى الْمَالِ: الْوَلَايَةُ وَالْخِلَافَةُ لَا الْمَالُ.

(وَمَا يَخْتَصُّ بِمَعْرِفَتِهِ النِّسَاءُ أَوْ لَا يَرَاهُ رَجَالٌ غَالِبًا كَبَكَارَةٍ وَوِلَادَةٍ وَحَيْضٍ وَرِضَاعٍ وَعُيُوبٍ تَحْتَ الثِّيَابِ) كَبَرَصٍ وَرَفَقٍ وَقَرْنٍ، (يَتَّبْتُ بِمَا سَبَقَ وَبِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ) رَوَى مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ: «مَضَتْ السُّنَّةُ أَنَّهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ مِنْ وَلَادَةِ النِّسَاءِ وَعُيُوبِهِنَّ» وَقِيسٌ بِمَا ذَكَرَ بَاقِي الْمَذْكُورَاتِ وَاخْتَرَزَ بِقَوْلِهِ تَحْتَ الثِّيَابِ عَمَّا قَالَ النَّبَعَوِيُّ: الْعَيْبُ فِي وَجْهِ الْحُرَّةِ وَكَفَّيْهَا لَا يَتَّبْتُ إِلَّا بِرَجُلَيْنِ وَفِي وَجْهِ

الْأَمَّةَ وَمَا يَبْدُو عِنْدَ الْمَهْنَةِ يَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، (وَمَا لَا يَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ لَا يَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَيَمِينٍ وَمَا ثَبَّتَ بِهِمْ ثَبَّتَ بِرَجُلٍ وَيَمِينٍ) ، رَوَى مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ: «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ»، (إِلَّا عُيُوبَ النِّسَاءِ وَنَحْوَهَا) بِالنَّصْبِ فَلَا تَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَيَمِينٍ؛ لِحَظَرِهَا، (وَلَا يَثْبُتُ شَيْءٌ بِامْرَأَتَيْنِ وَيَمِينٍ) لِعَدَمِ وُرُودِهِ وَقِيَامُهَا مَقَامَ رَجُلٍ فِي غَيْرِ ذَلِكَ لَوُرُودِهِ.

(و) فِي الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ (إِنَّمَا يَخْلِفُ الْمُدَّعِي بَعْدَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ وَتَعْدِيلِهِ وَيَذْكُرُ) وَجُوبًا (فِي حَلْفِهِ صِدْقَ الشَّاهِدِ) فَيَقُولُ: وَاللَّهِ إِنَّ شَاهِدِي لَصَادِقٌ وَإِنِّي مُسْتَحِقٌّ لِكَذَا، قَالَ الْإِمَامُ وَلَوْ قَدَّمَ ذَكَرَ الْحَقِّ وَأَخَّرَ تَصْدِيقَ الشَّاهِدِ لَا بَأْسَ، وَذَكَرُ صِدْقِ الشَّاهِدِ لِيَحْصُلَ الْإِرْتِبَاطُ بَيْنَ الْيَمِينِ وَالشَّهَادَةِ الْمُخْتَلَفَتَيْنِ الْجِنْسِ، (فَإِنْ تَرَكَ) الْمُدَّعِي (الْحَلْفَ) بَعْدَ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ (وَطَلَبَ يَمِينَ خَصْمِهِ فَلَهُ ذَلِكَ) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَوَرَّعُ عَنِ الْيَمِينِ وَيَمِينِ الْخَصْمِ تَسْقِطُ الدَّعْوَى، (فَإِنْ نَكَلَ) عَنِ الْيَمِينِ (فَلَهُ) أَيُّ الْمُدَّعِي (أَنْ) يَخْلِفَ يَمِينَ الرَّدِّ فِي الْأَظْهَرِ) وَالثَّانِي: الْمَنْعُ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ الْحَلْفَ فَلَا يَعُودُ إِلَيْهِ وَعَلَى هَذَا يُحْبَسُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَتَّى يَخْلِفَ أَوْ يَقَرَّ وَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ لَمْ يَخْلِفِ الْمُدَّعَى سَقَطَ حَقُّهُ مِنَ الْيَمِينِ وَلَيْسَ لَهُ مُطَالَبَةُ الْخَصْمِ كَمَا سَيَأْتِي فِي كِتَابِ الدَّعْوَى<sup>(١)</sup>.

(١) بعد انتهاء المصنف من الشروط التي ينبغي توافرها في الشاهد والأمور التي ترد بها شهادته والأمور التي لا ترد بها شرع هنا في عدد الشهود المقبول في الشهادة فأخبرنا بأن عدد الشهود يختلف حسب الأمر المشهود عليه فقد يكون المطلوب رجلاً

واحداً وقد يطلب في بعض الأمور رجلان وقد يطلب أربعة رجال وقد يطلب رجل وامرأتان أو أربع نسوة.

فبدأ المصنف بما يكفي فيه شاهد واحد وهو ثبوت هلال شهر رمضان، لكن لو نذر صيام شهر رجب فشهد واحد برؤيته فهل يجب عليه الصيام إن قلنا بثبوته في شهر رمضان فوجهان حكاهما ابن الرفعة ورجح ابن المقري منهما الوجوب بشهادة واحد فقط، ولو مات ذمي فشهد عدل مسلم بإسلامه لم تكف شهادته بالنسبة للإرث.

أما في الغسل والتكفين والصلاة عليه والدفن في مقابر المسلمين ففيها وجهان الراجح منهما قبول شهادة الواحد في ذلك، وأيضاً شهادة العدل الواحد في القسامة لوث، ومنا الاكتفاء بخارص واحد في زكاة النبات بناءً على أن الخرص شهادة، ومنها ثبوت هلال ذي الحجة بشهادة العدل الواحد وفيه وجهان أيضاً والراجح القبول، ومنها ثبوت هلال شوال بشهادة العدل الواحد.

ثم تكلم المصنف بما تقبل فيه شهادة الأربعة رجال وهو الزنا ودليله قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ)، ولما جاء في الحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أُمَهِلَهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، والدليل من المعقول أن هذا الفعل يقع من اثنين فصار كالشهادة على فعلين وكل فعل يحتاج لرجلين فصاروا أربعة شهود، والزنا من أغلظ الفواحش فغلظت الشهادة فيه ليكون أستر وتقبل شهادتهم إذا قالوا: حانت منا التفاتة فرأينا أو تعمدنا النظر لإقامة الشهادة، لكن لو قالوا تعمدنا النظر لغير الشهادة فسقوا وترد شهادتهم ولا بد وأن يقولوا في شهادتهم رأيناه أدخل حشفته أو قدراً من فاقدها في فرجها ومثل الزنا في ذلك اللواط وإتيان البهائم لأنه كالجماع وكذلك إتيان الميتة لا يثبت إلا بأربعة، أما الإقرار بالزنا فلا يشترط لإقراره أربعة شهود بل يثبت الإقرار به بشاهدين في الأظهر كغيره من الإقرار بالسرقة والشرب.

وأما ما يكتفي فيه بشاهدين من الرجال أو رجل وامرأتان وهي سائر العقود في إثباتها أو فسخها كالبيع والإقالة والحوالة والضمان والصلح والرهن والشفعة والمساابقة والحقوق المالية كالخيار المجلس منه والشرط والأجل والجنابة التي توجب مالاً والدليل على ذلك قوله تعالى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى)، وقد فهم من التخيير قبول المرأتين مع وجود الرجلين.

ثم تكلم المصنف عما يكتفى فيه بشاهدين من الرجال فقط ولا تقبل فيه شهادة النساء وهو ما ليس بمال ولا يقصد منه المال كباقي الحدود غير الزنا لأنها حقوق لله تعالى كالردة وقطع الطريق والشرب، أو ما كان عقوبة لآدمي كقتل النفس أو الاعتداء عليها بإتلاف عضو منها وكذلك ما يطلع عليه الرجال غالباً من غير العقوبات كالنكاح والطلاق والرجعة والعتاق والولاء وانقضاء عدة بالأشهر وبلوغ وإيلاء وظهار وإسلام وردة وجرح للشاهد أو تعديل له والموت والإعسار والولاية والوصاية والشهادة على الشهادة، وأما سبب الاكتفاء بالرجال فقط في هذه الأمور لأنه سبحانه قد نص على شهادة الرجلين في الطلاق والرجعة والوصاية وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ وَوَلِيِّ مُرْشِدٍ".

وقد روى مالك عن الزُّهْرِيِّ، قَالَ: " مَضَّتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ: أَلَّا تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ "، ويستثنى من ذلك أمور منها ما لو ادعت امرأة أن رجلاً نكحها وطلقها وطلبت شطر الصداق أو أنها زوجة فلان الميت فيثبت المدعى برجل وامرأتين أو بشاهد ويمين لأن المقصود هنا المال، ولو ادعى واحد من الكفار الإسلام قبل أسره وأقام على ذلك بينة برجل وامرأتين فإنهم يكفون في الشهادة لأن المطلوب هو نفي الاسترقاق. ثم انتقل المصنف إلى ما يثبت برجلين أو رجل وامرأتين أو أربع نسوة وهو ما لا يطلع عليه الرجال غالباً كالبكرة والثيوبة للأنثى والرتق والقرن والولادة وحيض ورضاع وعيوب النساء تحت الثياب

كجراحة على الفرج واستهلال ولد لما روي عن الزُّهري، قال: «مَصَّتِ السُّنَّةُ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَطْلُعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ مِنْ وَلَادَاتِ النِّسَاءِ وَعُيُوبِهِنَّ، وَتَجُوزَ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ وَحَدَّهَا فِي الْإِسْتِهْلَالِ، وَأَمْرَتَانِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ».

الحقوق المثبتة بالشهادة:

وبعد أن انتهى المصنف من العدد الذي تثبت به الشهادات انتقل إلى الحقوق المثبتة بالشهادة فذكر أن كل حق من الحقوق لا يمكن إثباته برجل وامرأتين لا يثبت بشاهد ويمين لأن الرجل والمرأتين أقوى من الشاهد واليمين فإذا لم يثبت الحق بما هو أقوى لم يثبت بالأقل منه، وكل ما ثبت بالرجل والمرأتين فإنه يثبت بالرجل واليمين. ودليل ذلك ما روي عن ابن عباس، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَضَى بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ " وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ "، وقد استنتج من ذلك عيوب النساء فإنها لا تثبت بشاهد ويمين لخطورتها بخلاف المال.

ثم ذكر المصنف أنه لا يوجد من الحقوق ما يثبت بامرأتين ويمين في الأمور المالية وفيما تقبل فيه شهادة النسوة فقط على الأصح من المذهب لعدم ورود شيء من الأدلة يؤيد ذلك.

ثم شرع في المسائل التي يكتفى فيها بشاهد ويمين وشرطه فذكر أن المدعي يحلف بعد أن تثبت شهادة الشاهد وبعد تعديله لأنه يتقوى بجانبه، وعند حلف المدعي لليمين فلا بد له من ذكر أن شاهده صادق فيما شهد به وأنه مستحق لهذا، وإذا ترك المدعي حلف اليمين بعد شهادة شاهده وطلب يمين خصمه فله ذلك لأن المدعي قد يتورع عن حلف يمينه فإذا حلف الخصم سقطت الدعوى وإن امتنع المدعي عن اليمين ثم امتنع الخصم عن حلف اليمين فللمدعي بعد ذلك أن يحلف اليمين المردودة قياساً على ما لو لم يكن له شاهد ونكل المدعي عليه، والثاني لا ترد عليه لأنه ترك الحلف فلا يعود إليه.

(وَلَوْ ادَّعَتْ وَرَثَةُ مَالًا لِمُورَثِهِمْ وَأَقَامُوا شَاهِدًا وَخَلَفَ مَعَهُ بَعْضُهُمْ أَخَذَ نَصِيبَهُ وَلَا يُشَارِكُ فِيهِ) كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ.

(وَيَبْطُلُ حَقُّ مَنْ لَمْ يَخْلِفْ بِكُؤْلِهِ إِنْ حَصَرَ وَهُوَ كَامِلٌ فَإِنْ كَانَ غَائِبًا أَوْ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَقْبِضُ نَصِيبَهُ إِذَا زَالَ عُدْرُهُ خَلَفَ وَأَخَذَ بِغَيْرِ إِعَادَةِ شَهَادَةٍ وَقِيلَ فِي قَوْلٍ: يَقْبِضُ نَصِيبَهُ وَيُوقَفُ، وَلَوْ تَغَيَّرَ حَالُ الشَّاهِدِ قَبْلَ الْخَلْفِ لَمْ يَقْدَحْ فِي أَحَدٍ وَجْهَيْنِ.

(وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ عَلَى فِعْلٍ كَزِنَا وَغَضَبٍ وَإِتْلَافٍ وَوَلَادَةٍ) وَرِضَاعٍ (إِلَّا بِالْإِنْبَصَارِ) لَهُ مَعَ فَاعِلِهِ فَلَا يَكْفِي فِيهِ السَّمَاعُ مِنَ الْغَيْرِ، (وَتُقْبَلُ) فِيهِ (مِنْ أَصَمٍّ) لِإِنْبَصَارِهِ (وَالْأَقْوَالُ كَعَقْدٍ) وَفَسْخٍ وَإِقْرَارٍ بِهِمَا (يُشْتَرِطُ سَمْعُهَا وَإِنْبَصَارُ قَائِلِهَا) فَلَا تُقْبَلُ فِيهَا شَهَادَةُ أَصَمٍّ لَا يَسْمَعُ شَيْئًا، (وَلَا يُقْبَلُ أَعْمَى) حَمَلَ شَهَادَةً فِي مُبْصِرٍ، (إِلَّا أَنْ يُقَرَّ) رَجُلٌ (فِي أُذُنِهِ) بِطَلَاقٍ أَوْ عَتَقٍ أَوْ مَالٍ لِرَجُلٍ مَعْرُوفٍ الْإِسْمِ وَالنَّسَبِ، (فَيَتَعَلَّقُ بِهِ حَتَّى يَشْهَدَ) عَلَيْهِ (عِنْدَ قَاضٍ بِهِ) فَيُقْبَلُ (عَلَى الصَّحِيحِ) ، وَالثَّانِي الْمَنْعُ سَدًّا لِلْبَابِ (وَلَوْ حَمَلَهَا بَصِيرٌ ثُمَّ عَمِيَ شَهِدَ إِنْ كَانَ الْمُشْهُودُ لَهُ وَعَلَيْهِ مَعْرُوفِي الْإِسْمِ وَالنَّسَبِ) بِخِلَافِ مَجْهُولِيهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا أَخَذًا مِنْ مَفْهُومِ الشَّرْطِ.

(وَمَنْ سَمِعَ قَوْلَ شَخْصٍ أَوْ رَأَى فِعْلَهُ فَإِنْ عَرَفَ عَيْنَهُ وَاسْمَهُ وَنَسَبَهُ شَهِدَ عَلَيْهِ فِي حُضُورِهِ إِشَارَةً وَعِنْدَ غَيْبَتِهِ وَمَوْتِهِ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ فَإِنْ جَهِلَهُمَا لَمْ يَشْهَدَ عِنْدَ مَوْتِهِ وَغَيْبَتِهِ)، وَكَذَا إِنْ جَهِلَ أَحَدَهُمَا فِيمَا يَظْهَرُ.

(وَلَا يَصِحُّ تَحْمُلُ شَهَادَةٍ عَلَى مُنْتَقِبَةٍ) بِالنُّونِ قَبْلَ التَّاءِ مَنْ انْتَقَبَتْ كَمَا فِي الصِّحَاحِ، (اعْتِمَادًا عَلَى صَوْتِهَا) فَإِنَّ الْأَصْوَاتَ تَتَشَابَهُ (فَإِنْ عَرَفَهَا

بَعَيْنِهَا أَوْ بِاسْمٍ وَنَسَبٍ جَارَ) التَّحْمُلُ عَلَيْهَا مُنْتَقِبَةً. (وَيَشْهَدُ عِنْدَ الْأَدَاءِ بِمَا يَعْلَمُ) مِمَّا ذُكِرَ فَيَشْهَدُ فِي الْعِلْمِ بِعَيْنِهَا عِنْدَ حُضُورِهَا وَفِي الْعِلْمِ بِالْإِسْمِ وَالنَّسَبِ عِنْدَ غَيْبِهَا وَمَوْتِهَا، (وَلَا يَجُوزُ التَّحْمُلُ عَلَيْهَا بِتَغْرِيفِ عَدْلٍ أَوْ عَدْلَيْنِ) أَنَّهَا فَلَانَةٌ بِنْتُ فُلَانٍ (عَلَى الْأَشْهَرِ) ، الْمُعَبَّرُ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَفِي الرُّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ، وَقِيلَ: يَجُوزُ بِتَغْرِيفِ عَدْلٍ؛ لِأَنَّهُ خَبَرٌ، وَقِيلَ: بِتَغْرِيفِ عَدْلَيْنِ؛ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ الشَّهَادَةِ عَلَى النَّسَبِ بِالسَّمَاعِ مِنْهُمَا، وَالْأَوَّلُ مَبْنِيٌّ عَلَى اشْتِرَاطِ السَّمَاعِ مِنْ جَمْعٍ يُؤْمَنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ (وَالْعَمَلُ عَلَى خِلَافِهِ) أَيِ الْأَشْهَرُ وَهُوَ التَّحْمُلُ بِمَا ذُكِرَ وَفِي ذِكْرِ الْعَمَلِ بِهِ الْمَزِيدُ عَلَى الرُّوْضَةِ وَأَصْلُهَا إِشَارَةٌ إِلَى الْمِيلِ إِلَيْهِ<sup>(١)</sup>.

(١) لو ادعى ورثة ميت كلهم أو بعضهم أن لمورثهم مالا سواء كان هذا المال عينا أو دينا أو منفعة لمورثهم وأقاموا عليه شاهداً بالمال بعد أن أثبتوا موته ووراثتهم منه ثم حلف البعض وامتنع البعض فإن الذي حلف يأخذ نصيبه، أما الذي لم يحلف فلا يأخذ شيئاً لأن الحجة قامت في حق الحالف وحده ويبطل حق الذي لم يحلف إن نكل عن اليمين مع وجود الشاهد، وإن كان غائباً أو صغيراً أو ذاهب العقل فلا يقبض نصيبه على المذهب إلا إذا زال عذره بالحضور بعد غياب أو بالبلوغ بعد الصغر أو بالإفاقة بعد الجنون ومع زوال العذر لا بد من الحلف لأن الاستحقاق بالشاهد ثم اليمين، وهناك وجه ضعيف عبر عنه بقليل أنه يقبض نصيبه ويوقف حتى زوال العذر.

ثم بدأ المصنف بالكلام في مستند علم الشاهد من البناء على اليقين والعلم فشرع في الكلام عنها بعد جواز الشهادة على فعل الزنا وشرب الخمر والغصب والإتلاف والولادة والرضاع والاصطياد وإحياء الموات وكون اليد على المال إلا إذا كان الشاهد

بصيراً لأنه يصل به إلى العلم واليقين فلا يكفي أن يقول الشاهد سمعت من غيري؛ لأن الله تبارك وتعالى قال: (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّهَادَةِ، فَقَالَ: «هَلْ تَرَى الشَّمْسَ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَعَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ، أَوْ دَعْ». غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ طَاوُوسٍ، تَقَرَّدَ بِهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ، وَيَسْتَنْتَى مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ أَمْسَكَ بِالْفَاعِلِ مُتَلَبِّساً ولم يتركه حتى ذهب به إلى القاضي وشهد عليه عنده أنه فعل كذا وكذا فشهادته تقبل، وتقبل الشهادة من الأصم في الأفعال لأنه يبصر ويجوز تعمد النظر لفرجي الزانين لتحمل الشهادة لأنهما هتكا حرمة أنفسهما

وأما عن شهادة الأقوال كالعقد والفسخ والطلاق والإقرار فيشترط في الشاهد أن يسمعها فلا تقبل من أصم كما أنه لا بد من إبطار قائلها وقت نطقه بالشهادة. ولا يقبل القاضي شهادة أعمى فيما يتعلق بالبصر لجواز تشابه الأصوات إلا في صورة الضبط وهي أن يقر إنسان في أذنه بنحو طلاق أو عتق أو مال لشخص معروف الاسم والنسب فيتعلق الأعمى به ولا يتركه حتى يشهد عليه بما سمعه منه عند قاضي بما قاله فيقبل على الصحيح لحصول العلم أنه المشهود عليه ومقابله المنع.

ولو حمل الشاهد الشهادة في شيء محتاج للبصر وهو بصير ثم عمي فإنه يشهد إن كان المشهود عليه معروف الاسم والنسب لإمكان الشهادة عليهما فيقول أشهد أن فلان بن فلان أقر لفلان بن فلان بكذا، والشاهد الذي يسمع قول شخص ويرى فعله فإن عرف عينه واسمه ونسبه وشهد عليه في حضوره إشارة لا باسمه ونسبه عند غيبته وموته ودفنه فإنه يشهد عليه باسمه ونسبه لحصول التمييز بذلك فإن جهل الاسم والنسب لم يشهد عند موته وغيبته فإن مات ولم يدفن أحضر ليشاهد صورته ويشهد على عينه فإن دفن فلا يجوز نبش القبر إلا إذا اشتدت الحاجة إليه ولم تتغير صورته فإنه يجوز النبش.



## تسجيل الحقوق

(وَلَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى عَيْنِهِ بِحَقِّ فَطْلَبِ الْمُدَّعِي التَّسْجِيلِ سَجَلِ الْقَاضِي بِالْحَلِيَّةِ لَا الْأِسْمَ وَالنَّسَبِ مَا لَمْ يُثْبِتَا)، وَلَا يَكْفِي فِيهِمَا قَوْلُ الْمُدَّعِي، وَلَا إِقْرَارُ مَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ؛ لِأَنَّ نَسَبَ الشَّخْصِ لَا يَثْبُتُ بِإِقْرَارِهِ، وَيَثْبُتُ بَبَيِّنَةٍ حَسْبَةِ عَلَى الصَّحِيحِ، فَإِذَا قَامَتْ عِنْدَ الْقَاضِي بِنَسَبِهِ سَجَلٌ بِهِ (وَلَهُ الشَّهَادَةُ بِالتَّسَامُعِ عَلَى نَسَبٍ) لِذِكْرِ أَوْ أَنْثَى (مِنْ أَبِي وَقِيلَةٍ وَكَذَا أُمِّ فِي الْأَصَحِّ) كَالْأَبِ، وَالثَّانِي: الْمَنْعُ؛ لِإِمْكَانِ رُؤْيَةِ الْوِلَادَةِ (وَمَوْتِ عَلَى الْمَذْهَبِ) وَفِي وَجْهِهِ مِنْ طَرِيقِ: الْمَنْعُ؛ لِأَنَّهُ يُمَكِّنُ فِيهِ الْمُعَايَنَةَ، (لَا عِنَقِ وَوَلَاءٍ وَوَقْفٍ وَنِكَاحٍ وَمِلْكٍ فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّ مُشَاهَدَةَ أَسْبَابِهَا مُتَيَسِّرَةٌ وَعِبَارَةُ الْمُحَرَّرِ فِيهَا رَجَحَ الْمَنْعُ.

(قُلْتُ: الْأَصَحُّ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ وَالْأَكْثَرِينَ فِي الْجَمِيعِ الْجَوَازُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ) لِأَنَّ مُدَّتَهَا تَطُولُ فَتَعْسُرُ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى ابْتِدَائِهَا فَتَمَسُّ الْحَاجَةَ إِلَى إِثْبَاتِهَا بِالتَّسَامُعِ، وَالرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ نَقَلَ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ الْمَنْعَ عَنْ طَائِفَةٍ وَالْجَوَازَ عَنْ أُخْرَى، زَادَ فِي الرَّوْضَةِ: الْجَوَازُ أَقْوَى وَأَصَحُّ وَهُوَ

---

ولا يصح تحمل الشهادة على منتقبة اعتماداً على صوتها لأن الأصوات تتشابه فمن لم يسمع صوتها ولم يرها بأن كانت وراء ستر فهي أولى بالمنع ولا يمنع الحائل الرقيق من تحمل الشهادة فإن عرفها بعينها أو باسم ونسب جاز تحمل الشهادة ولا يضر النقاب بل يجوز كشف الوجه ويشهد المتحمل على المنتقبة عند الأداء بما يعلم ولا يجوز التحمل على المرأة المنتقبة بتعريف عدل أو عدلين أنها فلانة بنت فلان على الأشهر والعمل على خلاف الأشهر المعبر به.

الْمُخْتَارُ وَسَكَتَ فِيهَا عَلَى قَوْلِ الرَّافِعِيِّ فِي الْمَلِكِ أَقْرَبُ الْوَجْهَيْنِ إِلَى  
إِطْلَاقِ الْأَكْثَرَيْنِ: الْجَوَارِ، وَالظَّاهِرُ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِلَى آخِرِهِ.

(وَشَرَطُ التَّسَامُعِ) فِي اسْتِنَادِ الشَّهَادَةِ إِلَيْهِ (سَمَاعُهُ) أَيِ الْمَشْهُودِ بِهِ (مِنْ)  
جَمْعٍ يُؤْمَنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ) لِكَثْرَتِهِمْ فَيَقَعُ الْعِلْمُ أَوْ الظَّنُّ الْقَوِيُّ  
بِحَبْرِهِمْ (وَقِيلَ يَكْفِي) سَمَاعُهُ (مِنْ عَدْلَيْنِ) وَعَلَى الْأَوَّلِ: لَا تُشْتَرَطُ  
الْعَدَالَةُ وَلَا الْحَرِيَّةُ وَالذُّكُورَةُ، وَعَبَّرَ فِي الرُّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي الثَّلَاثَةِ  
بِیَنْبَغِي.

(وَلَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى مَلِكٍ بِمَجَرَّدِ يَدٍ) أَوْ تَصَرُّفٍ، (وَلَا بِيَدٍ وَتَصَرُّفٍ  
فِي مُدَّةٍ قَصِيرَةٍ، وَتَجُوزُ فِي طَوِيلَةٍ فِي الْأَصَحِّ)، وَالثَّانِي قَالَ: قَدْ يُوجَدُ  
إِنْ مِنْ غَاصِبٍ وَوَكِيلٍ وَمُسْتَأْجِرٍ، وَمَرْجِعُ الطُّولِ وَالْقَصْرِ: الْعُرْفُ،  
وَقِيلَ: أَقْلُ الطَّوِيلَةِ: سَنَةٌ (وَشَرَطُهُ) أَيِ التَّصَرُّفِ الْمُنْظَمِ إِلَى الْبَلَدِ  
(تَصَرُّفُ مُلَّاكٍ) فِي الْعَقَارِ، (مِنْ سُكْنَى وَهَدْمٍ وَبِنَاءٍ وَبَيْعٍ) وَفَسْخِ بَعْدَهُ  
(وَرَهْنٍ) وَلَا يَكْفِي التَّصَرُّفُ مَرَّةً وَاحِدَةً؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ ظَنًّا (وَتُبْنَى  
شَهَادَةُ الْإِعْسَارِ عَلَى قَرَائِنٍ وَمَخَايِلِ الضَّرِّ وَالْإِضَاقَةِ) مَصْدَرُ أَضَاقَ  
الرَّجُلُ: ذَهَبَ مَالُهُ، وَالضِّيقُ بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ مَصْدَرُ ضَاقَ الشَّيْءُ،  
وَبِالْفَتْحِ جَمْعُ الضِّيقَةِ، وَهِيَ الْفَقْرُ وَسُوءُ الْحَالِ، وَالضَّرُّ بِالْفَتْحِ: خِلَافُ  
النَّفْعِ، وَبِالضَّمِّ: الْهَزَالُ وَسُوءُ الْحَالِ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ هُنَا، وَمَخَايِلُ: جَمْعُ  
مَخِيلَةٍ مِنْ خَالَ بِمَعْنَى ظَنٍّ أَيْ مَا يُظَنُّ بِهَا مَا ذُكِرَ بِأَنَّهُ يُرَاقَبُ الشَّاهِدُ

الْمَشْهُودَ لَهُ فِي خَلَوَاتِهِ وَذَلِكَ طَرِيقٌ لِحَبْرَةِ بَاطِنِهِ الَّتِي ذُكِرَ فِيهَا فِي  
النَّقْلِيسِ، وَشَرَطُ شَاهِدِهِ أَيْ إِعْسَارِ شَخْصٍ خَبْرَةَ بَاطِنِهِ<sup>(١)</sup>.

(١) لو قامت بينة على المدعى عليه بحق فطلب المدعي تسجيل ذلك كتابة في  
سجل القاضي فإنه يجوز للقاضي أن يسجل عليه بالصفات بأن يكتب حضر رجل  
ذكر أنه فلان بن فلان ومن صفاته كذا وكذا أي من الطول والقصر والبياض والسمرة  
والسمن والهزال وعجلة اللسان وثقله وما في شعره من جعود وسبوبة وسواد وبياض  
فلا يسجل ذلك بالاسم والنسب لأن الشخص لا يثبت بإقراره بأن يقول أقر أنا فلان  
بن فلان بل يثبت بالبينة أو علم القاضي فإن ثبت بذلك سجل بهما  
ثم أشار هنا إلى ما يثبت بالتسامع أي باستقاضة الخبر وهذا يكون في نسب لذكر أو  
أنثى أو لقبيلة فيقال هذا ابن فلان أو ابن فلانة أو ينسب لقبيلة كذا لأن الحاجة  
داعية إلى إثبات الأنساب إلى الأجداد والمتوفين والقبائل القديمة فسومح فيه، والنسب  
لألم يثبت بالتسامع أيضاً على الأصح في المذهب، ومقابلته يمنع التسامع بالنسب  
إلى الأم لإمكان رؤية الولادة، وصورة الاستقاضة في التحمل أن يسمع الناس ينسبون  
فلاناً إلى أو إلى القبيلة وامتد ذلك فترة ولا تقدر هذه المدة بسنة بل بمدة تغلب على  
الظن صحة ذلك، ويثبت الموت أيضاً بالتسامع على المذهب لأن مثله مثل النسب  
لأنه قد يعسر الاطلاع عليه.

ويخالف ذلك الولاء والعق والوقف والنكاح والملك في الأصح لأن المشاهدة في مثل  
هذه الأمور ميسورة وأسبابها غير متعددة لكن النووي رحمه الله أشار إلى أن الأصح  
عند الأكثرين من فقهاء الشافعية جواز ثبوت الأمور السابقة بالتسامع أيضاً لأنها  
أمر مؤبدة فإن طالت المدة عسر إقامة البينة على ابتدائها فمست الحاجة إلى ثبوتها  
بالاستقاضة والدليل على ذلك اليقين بأن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله  
عليه وسلم وأن فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم ولا مستند غير  
السماع.

## فصل في تحمل الشهادة

(فَصْلٌ: تَحْمُلُ الشَّهَادَةُ فَرَضُ كِفَايَةِ فِي النِّكَاحِ وَكَذَا الْإِقْرَارُ وَالتَّصَرُّفُ الْمَالِيُّ وَكِتَابَةُ الصَّكِّ فِي الْأَصَحِّ) أَمَّا فَرَضِيَّةُ التَّحْمُلِ فِي النِّكَاحِ فَلِتَوَقُّفِ الْإِنْعِقَادِ عَلَيْهِ، وَفِي الْإِقْرَارِ وَتَالِيهِ؛ لِلْحَاجَةِ إِلَى اثْبَاتِهِمَا عِنْدَ التَّنَازُعِ، وَالثَّانِي قَالَ: لَا تَتَوَقَّفُ صِحَّتُهُمَا وَاسْتِيفَاءُ مَقَاصِدِهِمَا عَلَيْهِ، وَقَالَ: هُوَ مَنْدُوبٌ، وَأَمَّا فَرَضِيَّةُ كِتَابَةِ الصَّكِّ؛ فَلِأَنَّهَا لَا يُسْتَعْنَى عَنْهَا فِي حِفْظِ الْحَقِّ وَالْمَالِ، وَلَهَا أَثَرٌ ظَاهِرٌ فِي التَّذَكُّرِ وَالثَّانِي قَالَ: هِيَ مَنْدُوبَةٌ وَالْفَرَضِيَّةُ فِيهَا دُونُهَا فِيمَا قَبْلَهَا الْمُعَبَّرُ فِيهِ فِي الرُّوْضَةِ

---

والشرط الذي يقبل به الشهادة بالتسامع هو سماع المشهود به من جمع كثير يؤمن بتواطؤهم على الكذب أو توافقههم عليه بحيث يقع العلم أو الظن القوي بخبرهم لأن الأصل في الشهادة اعتمادها إذا كان علمها علم اليقين فإن لم تصل إليه فالظن القريب ومقابل القول السابق أنه لا يشترط الجمع الكثير، بل يكفي السماع من عدلين فقط إذا سكن القلب واطمأن إلى قولهما لأن الحاكم يعتمد قول العدلين.

ولا تجوز الشهادة على الملك بمجرد وضع اليد عليه لأن وضع اليد لا يستلزم الملك لأنه قد يكون بطريق الإجارة أو العارية ولا بيدٍ وتصرف في مدة قصيرة عرفاً لأن امتداد اليد والتصرف مع طول الزمان من غير منازع يغلب على الظن الملك، ومقابل الأصح لا يجوز لأن اليد والتصرف قد يوجدان من مستأجر ووكيل وغاصب والتصرف المنظم إلى اليد إذا كان عقاراً فيشترط فيه أن يتصرف فيه تصرف الملاك من سكنى وهدم وبناء ودخول وخروج وبيع وفسخ بعد البيع ورهن وإجارة لأنها تدل على الملك مع عدم النكير، ولا يكفي التصرف في ذلك مرة واحدة، وتبنى شهادة الإعسار على قرائن خفية من أحوال المعسر وعلى مظنة الضر والضيق وهو الفقر وسوء الحال لأنه لا يمكن فيه التوصل إلى اليقين بل يكفي الاعتماد لما تدل عليه القرائن.

بِالصَّحِيحِ؛ لِأَنَّ الْحُجَّةَ بِالشَّاهِدِ لَا بِهَا، فَفِي التَّعْبِيرِ بِالْأَصَحِّ فِي الثَّلَاثِ تَغْلِيْبٌ لِلثَّالِثَةِ ثُمَّ عَلَى فَرْضِيَّةِ التَّحْمَلِ مَنْ طُلِبَ مِنْهُ يَلْزَمُهُ إِذَا حَصَرَهُ الْمُحْمَلُ فَإِنْ دُعِيَ لِلتَّحْمَلِ فَأَلْأَصَحُّ: عَدَمُ وَجُوبِ الإِجَابَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُحْمَلُ مَرِيضًا أَوْ مَحْبُوسًا أَوْ امْرَأَةً مُخَدَّرَةً أَوْ قَاضِيًا يُشْهَدُهُ عَلَى أَمْرِ ثَبَّتَ عِنْدَهُ، فَتَلْزَمُهُ الإِجَابَةُ.

(وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْقَضِيَّةِ إِلَّا اثْنَانِ) بِأَنْ لَمْ يَتَحَمَّلْ سِوَاهُمَا، أَوْ مَاتَ غَيْرُهُمَا، أَوْ جُنَّ أَوْ فَسَقَ أَوْ غَابَ، (لَزِمَهُمَا الْأَدَاءُ) إِذَا دُعِيَ لَهُ؛ قَالَ تَعَالَى: (وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا)، (فَلَوْ أَدَّى وَاحِدٌ وَامْتَنَعَ الْآخَرُ وَقَالَ) لِلْمُدَّعِي (اخْلَفْ مَعَهُ عَصَى) لِأَنَّ مِنْ مَقَاصِدِ الْإِشْهَادِ التَّوَرُّعُ عَنِ الْيَمِينِ.

(وَإِنْ كَانَ) فِي الْقَضِيَّةِ (شُهُودٌ) كَأَرْبَعَةٍ (فَالْأَدَاءُ فَرَضٌ كِفَايَةٌ) عَلَيْهِمْ (فَلَوْ طُلِبَ مِنْ اثْنَيْنِ) مِنْهُمْ (لَزِمَهُمَا فِي الْأَصَحِّ) وَإِلَّا لَأَفْضَى إِلَى التَّوَاكُلِ، وَالثَّانِي قَاسَ عَلَى مَا إِذَا دُعِيَ لِلتَّحْمَلِ لَا تَلْزَمُهُمَا الإِجَابَةُ وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ) فِي الْقَضِيَّةِ (إِلَّا وَاحِدٌ لَزِمَهُ) الْأَدَاءُ، (إِنْ كَانَ فِيمَا يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَإِلَّا فَلَا) يَلْزَمُهُ (وَقِيلَ لَا يَلْزَمُ الْأَدَاءُ إِلَّا مَنْ تَحَمَّلَ قَصْدًا لَا اتِّفَاقًا) وَالْأَصَحُّ يَلْزَمُ الْآخَرَ<sup>(١)</sup>.

---

(١) بدأ المصنف بتحمل الشهادة في النكاح فذكر بأن تحمل الشهادة فيه فرض على الكفاية لأن الإشهاد من شروطه، وفرض الكفاية إذا فعله البعض سقط الإثم عن الباقيين، وإذا امتنع عنه الجميع أثموا جميعاً، وأيضاً كتابة الصك وهو الكتاب فالتحمل

## [شروط وجوب أداء الشهادة]

(وَلَوْجُوبِ الْأَدَاءِ شَرْطٌ أَنْ يُدْعَى مِنْ مَسَافَةِ الْعُدْوَى) فَأَقْلَ، وَهِيَ كَمَا تَقَدَّمَ الَّتِي يَرْجِعُ مِنْهَا مُبَكَّرًا لَيْلًا إِلَى مَوْضِعِهِ (وَقِيلَ: دُونَ مَسَافَةِ قَصْرِ)

---

فيه أيضاً من فروض الكفاية في الأصح من المذهب للحاجة إلى إثبات ذلك عند التنازع.

ولأنه لا يستغني عنها في حفظ الحق والمال ومحل كون التحمل للشهادة فرض كفاية إذا كان الشهود كثيرين، فإن لم يوجد إلا العدد المعتبر في الحكم يكون فرض عين لحرمة كتمان الشهادة لقوله تعالى: (وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ).

ولأنها أمانة حصلت عنده فعليه أداؤها، فإن لم يوجد إلا اثنان يصلحان لتحمل الشهادة بأن مات الباقيون أجنبوا أو فسقوا أو غابوا فإن أداء الشهادة يكون لازماً وفرض عين على هذين الاثنين لقوله تعالى: (وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا)، ولأنه يؤدي فرضاً التزمه في ذمته فوجب عليه الأداء لذلك ولو أدى واحد منهما الشهادة وامتنع الآخر بغير عذر وقال الممتنع للمدعي احلف مع الشاهد فإن هذا الممتنع يأثم حتى وإن كان القاضي يحكم بمقتضى الشاهد واليمين لأن من مقاصد الإشهاد التورع عن اليمين، وإن كان في القضية أربعة شهود فالأداء يكون فرض كفاية لحصول الغرض بشهادة بعضهم فإن شهد اثنان منهم سقط الإثم عن الباقيين، ولو طلب المدعي منهم اثنان بعينهما لزمتهما الشهادة لكي لا يفضي الأمر إلى التواكل، والثاني: لا يلزمهما بل هي فرض على الكفاية كالذي يتحمل الشهادة، وإذا لم يكن في القضية إلا شاهد واحد فإنه يتعين عليه أداء الشهادة في الحق الذي يثبت بشاهد ويمين، وإن لم يثبت الحق بذلك أو كان القاضي ممن لا يرى ثبوته بالشاهد واليمين فلا يلزم هذا الشاهد أن يؤدي شهادته؛ لأنه لن يقوم عليها أداء حق ولن تجدي وحدها في إثباته وهناك وجه ضعيف أنه يلزمه الأداء إلا إذا تحمل الشهادة قصداً لا اتفاقاً.

وَهَذَا يَزِيدُ عَلَى الْأَوَّلِ بِمَا بَيْنَ الْمَسَافَتَيْنِ فَإِنْ دُعِيَ مِنْ مَسَافَةِ الْقَصْرِ لَمْ يَجِبَ عَلَيْهِ الْحُضُورُ لِلْأَدَاءِ لِبُعْدِهَا.

(وَأَنْ يَكُونَ عَدْلًا، فَإِنْ دُعِيَ ذُو فَسَقٍ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ) كَشَارِبِ الْخَمْرِ (قِيلَ: أَوْ مُخْتَلَفٍ فِيهِ) كَشَارِبِ النَّبِيذِ. (لَمْ يَجِبْ) عَلَيْهِ الْأَدَاءُ وَالْأَصَحُّ فِي الثَّانِي وَجُوبُ الْأَدَاءِ وَإِنْ عُهِدَ مِنَ الْقَاضِي رَدُّ الشَّهَادَةِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَغَيَّرُ اجْتِهَادُهُ.

(وَأَنْ لَا يَكُونَ مَعْدُورًا بِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ) كَتَخْدِيرِ الْمَرْأَةِ، (فَإِنْ كَانَ أَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِهِ أَوْ بَعَثَ الْقَاضِي مَنْ يَسْمَعُهَا) وَإِذَا اجْتَمَعَتِ الشُّرُوطُ وَكَانَ فِي صَلَاةٍ أَوْ حَمَامٍ أَوْ عَلَى طَعَامٍ فَلَهُ التَّأْخِيرُ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ<sup>(١)</sup>.

---

(١) يشترط لوجوب أداء الشهادة عدة شروط، الأول: أن يدعى الشاهد إليها من مسافة العدوى فأقل، ومسافة العدوى هي التي يتمكن المبكر إليها من الرجوع إلى أهله في يومه وكانت المسافة التي يمكن سيرها في اليوم الواحد بريدين والبريد يساوي أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال والميل يساوي ألف وسبعمئة وخمسين متراً فمسافة العدوى تساوي ما يقارب سبعة وأربعين كيلو متراً فهي على النصف من مسافة القصر عند الشافعية، فلو دعي من فوق هذه المسافة لم يجب عليه إجابة هذا اطلب للضرر، ويمكن القول إن هذه المسألة تترك للعرف؛ لأن ما تعارف عليه الناس قديماً أصبح يقطع الآن في وقت هين ويسير، بل يمكن استدعاء أحد الناس من دولة أخرى ويمكنه العودة في نفس اليوم فيترك تحديد المسافة ليس بالمسافة ولكن بالضابط الذي وضعه الفقهاء لذلك وهو السفر والعودة في يوم واحد، فإذا دعا الحاكم أو قاضي القضاة فيجب الحضور من أي مسافة، وقد حدث ذلك في عهد عمر بن الخطاب

## [الشهادة على الشهادة]

(تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي غَيْرِ عُقُوبَةٍ) كَمَا لَوْ عَقِدَ وَفَسَخَ وَطَلَّقَ وَعَتَقَ وَوَلَدَ وَرَضَاعٌ وَوَقَفَ مَسْجِدٍ وَزَكَاةً وَجِهَةً عَامَّةً، (وَفِي عُقُوبَةٍ الْآدَمِيِّ عَلَى الْمَذْهَبِ) كَقِصَاصٍ وَحَدٍّ قَذْفٍ بِخِلَافِ عُقُوبَةِ اللَّهِ تَعَالَى كَحَدِّ الزَّنا وَالشُّرْبِ عَلَى الْأَظْهَرِ، وَمِنْهُ حَرَجَ قَوْلٌ فِي عُقُوبَةِ الْآدَمِيِّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ عِلَّتَهُ أَنَّ الْعُقُوبَةَ لَا يُوسَعُ بِأُيُهَا وَدُفِعَ التَّخْرِيجُ بِأَنَّ الْعِلَّةَ أَنَّ حَقَّ

---

حيث استحضر شهوداً من الكوفة للمدينة، وقيل: إذا دعي من مسافة القصر لم يجب عليه الحضور

الشرط الثاني: أن يكون المدعو عدلاً فإذا دعا فاسقاً معلوم الفسق كشارب خمر مثلاً فإنه يحرم عليه الأداء ولا يأثم القاضي إذا لم يقصر في معرفة عدالته، ويتجه وجوب الأداء إذا كان فيه إنقاذ نفس أو عضو أو بضع، لكن إذا دعي للشهادة من اختلف في فسقه كشارب النبيذ لم يجب عليه الأداء لكن الأصح الوجوب لأنه قد يتغير اجتهد القاضي.

الشرط الثالث: ألا يكون المدعو للشهادة معذوراً بمرض ونحوه كخوفه على ماله أو تعطل كسبه في ذلك اليوم إلا إذا قام بدفع بدل كسبه له، فإن كان المدعو معذوراً لم يلزمه أداء الشهادة وأشهد على شهادته غيره أو يرسل القاضي إليه من يسمع الشهادة منه دفعاً للمشقة، والأصل أنه ليس للشاهد أخذ رزق لتحمل الشهادة من الإمام أو أحد الرعية وأما أخذه من بيت المال فحكمه حكم القاضي في ذلك وله أخذ الأجرة للأداء من المشهود له على التحمل وإن تعين عليه إن دعي له فإن تحمل بمكانه فلا أجرة له وليس له أن يأخذ أجرة لمجرد الأداء لأنه فرض عليه، فلا يستحق عنه عوضاً ولأنه كلام يسير لا أجرة لمتله والفرق بين الأداء والتحمل في أخذ الأجرة أنه إن أخذ للأداء ورث تهمة قوية مع أن زمن الأداء يسير ولا تغوت بهذا الزمن منفعة متقومة بخلاف زمن التحمل لأنه سيدعى من مسافة فله نفقة الطريق وأجرة الركوب.



اللَّهِ مَبْنِيٍّ عَلَى الْمُسَاهَلَةِ بِخِلَافِ حَقِّ الْأَدَمِيِّ، فَلِذَلِكَ عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ فِيهِ بِالْمَذْهَبِ، وَهَذَا الْخِلَافُ وَالتَّخْرِيجُ وَالتَّرْجِيحُ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ فِي الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ وَالْكَتَبِ إِلَى قَاضِي بَلَدِهِ لِيُنَيِّي عَلَيْهِ، وَأَحَالَ هُنَا عَلَيْهِ حُكْمَ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ، وَاقْتَصَرَ عَلَى تَصْحِيحِ الْقَبُولِ فِي الشَّقِّ الْأَوَّلِ، وَالْمَنْعِ فِي الثَّانِي، وَتَبِعَهُ فِي الْإِقْتِصَارِ فِي الرُّوْضَةِ وَعَبَّرَ بِالْمَذْهَبِ خِلَافَ تَغْيِيرِهِ فِي الْمِنْهَاجِ فِي الْقَضَاءِ بِالْأَظْهَرِ، (وَتَحْمُلُهَا بِأَنَّ يَسْتَرْعِيهِ) الْأَصْلُ (فَيَقُولُ: أَنَا شَاهِدٌ بِكَذَا وَأُشْهِدُكَ) عَلَى شَهَادَتِي (أَوْ أَشْهَدُ عَلَى شَهَادَتِي، أَوْ يَسْمَعُهُ يَشْهَدُ عِنْدَ قَاضٍ) إِنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ كَذَا فَلَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَرْعِهِ، (أَوْ) يَسْمَعُهُ (يَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ أَلْفًا عَنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ أَوْ غَيْرِهِ) ، كَقَرَضٍ فَتَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى شَهَادَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَشْهَدَ عِنْدَ قَاضٍ، (وَفِي هَذَا وَجْهٌ) بِالْمَنْعِ لِاحْتِمَالِ التَّوَسُّعِ فِيهِ (فَلَا يَكْفِي سَمَاعُ قَوْلِهِ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ كَذَا أَوْ أَشْهَدُ بِكَذَا أَوْ عِنْدِي شَهَادَتُهُ بِكَذَا) ؛ لِأَنَّ النَّاسَ قَدْ يَتَسَاءَلُونَ فِي إِطْلَاقِ ذَلِكَ عَلَى عِدَّةٍ وَنَحْوِهَا.

(وَلْيُبَيِّنَ الْفَرْعُ عِنْدَ الْأَدَاءِ جِهَةَ التَّحْمُلِ) فَإِنْ اسْتَرْعَاهُ الْأَصْلُ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ فُلَانًا شَهِدَ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ كَذَا، وَأَشْهَدُنِي عَلَى شَهَادَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَرْعِهِ بَيَّنَّ أَنَّهُ شَهِدَ عِنْدَ الْقَاضِي أَوْ أَنَّهُ أَسْنَدَ الْمَشْهُودَ بِهِ إِلَى سَبَبِهِ (فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ) جِهَةَ التَّحْمُلِ (وَوَثَّقَ الْقَاضِي بِعِلْمِهِ فَلَا بَأْسَ) فِي ذَلِكَ

كَأَن يَقُولَ: أَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ فُلَانٍ بِكَذَا<sup>(١)</sup>، (وَلَا يَصِحُّ التَّحْمُلُ عَلَى شَهَادَةِ مَرْدُودِ الشَّهَادَةِ) كَفَاسِقٍ وَرَقِيقٍ وَعَدُوٍّ (وَلَا تَحْمِلُ النِّسْوَةُ) وَإِنْ كَانَتْ

(١) تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها : بدأ المصنف بجواز قبول الشهادة على الشهادة والدليل على ذلك هو عموم قول الله تعالى: (وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ) ولأن الحاجة إليها ماسة ولأنه قد يتعذر أداء الأصل للشهادة ولأن الشهادة حق لازم فيشهد عليها كسائر الحقوق ولأنها طريق مظهرة للحق فكان كالإقرار يمكن الإشهاد عليها لكن جواز قبول الشهادة على الشهادة إنما يكون في غير عقوبة لله تعالى كالأقارب والعقود والفسوخ والرضاع والولادة وعيوب النساء وسواء كان فيه حق لآدمي أو حق لله تعالى كالزكاة ووقف المساجد وهلال رمضان للصوم وهلال ذي الحجة للحج وتقبل في إثبات عقوبة لآدمي على المذهب كالقصاص وحد القذف أما العقوبة التي لله تعالى كالزنا وشرب الخمر فلا تقبل فيها الشهادة على الشهادة على الأظهر من المذهب وكذلك الإحصان فيمن ثبت زناه لا تقبل فيه شهادة على الشهادة .

أسباب تحمل الشهادة: ذكر المصنف أن لتحمل الشهادة أسباباً ثلاثة: السبب الأول: أن يطلب الشاهد الأصلي من المتحمل رعاية الشهادة وحفظها، لأن الشهادة على الشهادة نيابة فاعتبر فيها الإذن فيقول الأصلي للمتحمل أنا شاهد بكذا أي بأن لفلان على فلان كذا وأشهدك على شهادتي أو أشهدتك على شهادتي أو يقول أشهد على شهادتي ومتى صح طلب الرعاية الشهادة جاز للمسترعي ولغيره ممن سمعها أن يشهد على الشهادة أيضاً ويشترط فيها لفظ الشهادة.

السبب الثاني لتحمل الشهادة: أن يسمع الشاهد الأصلي أي الذي رأى الحادثة أو الواقعة يشهد عند قاضي أن لفلان على فلان كذا فله عندئذ أن يشهد على شهادته حتى وإن لم يسترعه.

السبب الثالث: أن يسمعه يقول أشهد أن لفلان على فلان كذا ثمن بيع أو قرض فإذا بين سبب شهادته جاز لمن سمعه أن يشهد على شهادته لأن إسناده إلى السبب يرفع احتمال الوعد والتساهل وهذا السبب الأخير فيه احتمال أنه لا يجوز التوسع فيه، ولا

الأُصولُ أَوْ بَعْضُهُمْ نِسَاءً وَكَانَتْ الشَّهَادَةُ فِي وَلَادَةٍ أَوْ رِضَاعٍ أَوْ مَالٍ؛  
لِأَنَّ شَهَادَةَ الْفَرْعِ تُثَبِّتُ شَهَادَةَ الْأَصْلِ، لَا مَا شَهِدَ بِهِ الْأَصْلُ، (فَإِنْ مَاتَ  
الْأَصْلُ أَوْ غَابَ أَوْ مَرِضَ لَمْ يَمْنَعْ) ذَلِكَ (شَهَادَةُ الْفَرْعِ) لِأَنَّ مَحَلَّهَا كَمَا  
سَيَأْتِي بِشَرْطِهِ وَذَكَرَ هُنَا تَوَاطُّةً لِمَا بَعْدَهُ، (وَإِنْ حَدَثَ رِدَّةٌ أَوْ فِسْقٌ أَوْ  
عَدَاوَةٌ مَنَعَتْ) شَهَادَةَ الْفَرْعِ (وَجُنُونُهُ) أَيُّ الْأَصْلِ (كَمَوْتِهِ عَلَى الصَّحِيحِ)  
وَالثَّانِي: كَفِسْقٍ فَيَمْنَعُ شَهَادَةَ الْفَرْعِ.

(وَلَوْ تَحَمَّلَ فَرْعٌ فَاسِقٌ أَوْ عَبْدٌ) أَوْ صَبِيٌّ (فَأَدَّى وَهُوَ كَامِلٌ قُبِلَتْ)  
شَهَادَتُهُ. (وَتَكْفِي شَهَادَةُ اثْنَيْنِ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ) كَمَا لَوْ شَهِدَ عَلَى مُقَرَّرَيْنِ،  
(وَفِي قَوْلٍ: يُشْتَرَطُ لِكُلِّ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ اثْنَانِ) لِأَنَّ شَهَادَتَهُمَا عَلَى وَاحِدٍ  
قَائِمَةٌ مَقَامَ شَهَادَتِهِ فَلَا تَقُومُ مَقَامَ شَهَادَةِ غَيْرِهِ، (وَشَرَطُ قَبُولِهَا) أَيُّ شَهَادَةِ  
الْفَرْعِ (تَعَذُّرٌ أَوْ قِصْرُ الْأَصْلِ بِمَوْتٍ أَوْ عَمَى أَوْ مَرَضٍ يَشُقُّ) بِهِ  
(حُضُورُهُ أَوْ غَيْبُهُ لِمَسَافَةِ عَدُوٍّ وَقِيلَ قِصْرٌ) فِي الْأَوَّلِ تَوَسَّعَ بِحَذْفِ  
لَفْظَةِ فَوْقَ وَلَوْ ذَكَرَهَا قَبْلَ مَسَافَةٍ، وَقَالَ: وَقِيلَ لِمَسَافَةِ قِصْرٍ كَانَ مُوَافِقًا  
لِمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا وَالْمَحَرَّرِ، (وَأَنْ يُسَمِّيَ الْأُصُولَ) لِتُعْرَفَ

---

يكفي في تحمل الشهادة قطعاً سماع قول الشاهد الأصلي لفلان على فلان كذا أو  
أشهد بكذا، أو عندي شهادة بكذا لاحتمال أنه يريد أن له عليه ذلك من جهة وعد  
وعده إياه ويشير بكلمة على أن مكارم الأخلاق تقتضيه أن يوفي بها، ولا بد للشاهد  
الفرع وهو المتحمل للشهادة عن شهادة الشاهد الأصلي أن يبين جهة التحمل كأن  
يقول أشهد على شهادة فلان بكذا كما أنه لا بد وأن يثق القاضي بعلمه بمعرفته  
لشروط التجمل وإذا تحقق ذلك فإن القاضي يجيز تحمله لحصول الغرض بذلك.

عَدَالَتُهُمْ (وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يُزَكِّيَهُمُ الْفُرُوعُ فَإِنْ زَكَّوْهُمْ قَبْلَ) ذَلِكَ مِنْهُمْ  
وَأَشْتَرَطَهُ بَعْضُهُمْ تَتِمَّةً لِشَهَادَتِهِمْ، (وَلَوْ شَهِدُوا عَلَى شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ أَوْ  
عُدُولٍ) بِذِكْرِهِمْ (وَلَمْ يُسَمَّوْهُمْ لَمْ يَجْزُ) أَيَّ لَمْ يَكْفِ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ قَدْ  
يَعْرِفُ جَرَحَهُمْ لَوْ سَمَّوْهُمْ، وَلِأَنَّهُ يَنْسُدُّ بَابَ الْجَرَحِ عَلَى الْحَصَمِ.

### [رجوع الشهود عن الشهادة]

(فَصْلٌ) إِذَا (رَجَعُوا) أَيَّ الشُّهُودُ (عَنِ الشَّهَادَةِ قَبْلَ الْحُكْمِ امْتَنَعَ) الْحُكْمُ  
بِهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَصَدَّقُوا فِي الْأَوَّلِ أَوْ فِي الثَّانِي، فَلَا يَبْقَى ظَنٌّ  
الصِّدْقِ فِيهَا، (أَوْ بَعْدَهُ) أَيَّ الْحُكْمِ (وَقَبْلَ اسْتِيفَاءِ مَالِ اُسْتَوْفَى أَوْ  
عُقُوبَةِ) كَالْقِصَاصِ وَحَدِّ الْقَذْفِ وَالزِّنَا وَالشُّرْبِ (فَلَا) يُسْتَوْفَى؛ لِأَنَّهَا  
تَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ، وَالرُّجُوعُ شُبْهَةٌ وَالْمَالُ لَا يَسْقُطُ بِهَا (أَوْ بَعْدَهُ) ، أَيَّ  
الِاسْتِيفَاءِ (لَمْ يُنْقَضْ) أَيَّ الْحُكْمُ (فَإِنْ كَانَ الْمُسْتَوْفَى قِصَاصًا أَوْ قَتْلَ  
رِدَّةٍ أَوْ رَجَمَ زِنَا أَوْ جَلَدَهُ وَمَاتَ) الْمَجْلُودُ (وَقَالُوا تَعَمَّدْنَا) شَهَادَةُ الزُّورِ  
(فَعَلَيْنَهُمْ قِصَاصٌ أَوْ دِيَّةٌ مُعْلَظَةٌ<sup>(١)</sup>) مُورَعَةٌ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ، وَيُحْدَثُونَ  
فِي شَهَادَةِ الزِّنَا حَدَّ الْقَذْفِ ثُمَّ يُرْجَمُونَ، وَقِيلَ: يُقْتَلُونَ بِالسَّيْفِ (وَعَلَى  
الْقَاضِي) الرَّاجِعِ ثَوْنَ الشُّهُودِ (قِصَاصٌ) أَوْ دِيَّةٌ مُعْلَظَةٌ (إِنْ قَالَ:  
تَعَمَّدْتُ) الْحُكْمُ بِشَهَادَةِ الزُّورِ<sup>(٢)</sup> (وَإِنْ رَجَعَ هُوَ وَهُمْ فَعَلَى الْجَمِيعِ

(١) فِي مَالِهِمْ.

(٢) فَإِنْ قَالَ: أَخْطَأْتُ فِدْيَةً مَخْفِةً عَلَيْهِ لَا عَلَى عَاقِلَتِهِ إِنْ لَمْ تَصَدِّقْهُ.

قِصَاصٌ) أَوْ دِيَّةٌ مُعَلَّظَةٌ، (إِنْ قَالُوا: تَعَمَّدْنَا، فَإِنْ قَالُوا: أَخْطَأْنَا) أَوْ عُفِيَ  
عَلَى مَالٍ، (فَعَلَيْهِ<sup>(١)</sup>) نِصْفُ دِيَّةٍ وَعَلَيْهِمْ نِصْفٌ مِنْهَا.

(وَلَوْ رَجَعَ مُزَكٍّ<sup>(٢)</sup>) فَالْأَصَحُّ: أَنَّهُ يَضْمَنُ) وَيَتَعَلَّقُ بِهِ قِصَاصٌ؛ لِأَنَّهُ  
بِالتَّزْكِيَةِ يُلْجِئُ الْقَاضِيَ إِلَى الْحُكْمِ الْمُفْضِي إِلَى الْقَتْلِ، وَالثَّانِي: الْمَنْعُ؛  
لِأَنَّهُ كَالْمُضْمَكِ مَعَ الْقَاتِلِ (أَوْ رَجَعَ وَلِيٌّ) دَمٍ (وَحْدَهُ<sup>(٣)</sup>) فَعَلَيْهِ قِصَاصٌ  
أَوْ دِيَّةٌ<sup>(٤)</sup> أَوْ مَعَ الشُّهُودِ<sup>(٥)</sup> فَكَذَلِكَ) عَلَى الْوَلِيِّ وَحْدَهُ مَا ذَكَرَ؛ لِأَنَّهُ  
الْمُبَاشِرُ وَهُمْ مَعَهُ كَالْمُضْمَكِ مَعَ الْقَاتِلِ، (وَقِيلَ: هُوَ وَهُمْ شُرَكَاءُ) لِتَعَاوُنِهِمْ  
عَلَى الْقَتْلِ، فَعَلَى الْجَمِيعِ الْقِصَاصُ أَوْ الدِّيَّةُ؛ نِصْفُهَا عَلَى الْوَلِيِّ  
وَنِصْفُهَا عَلَى الشُّهُودِ، وَلَوْ رَجَعَ الْقَاضِي مَعَهُمْ فَتُلْتُ الدِّيَّةُ عَلَيْهِ وَتُلْتُ  
عَلَى الْوَلِيِّ وَتُلْتُ عَلَى الشُّهُودِ، وَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ أَخَذَ تَرْجِيحَ الْأَوَّلِ مِنْ  
بُدَاءَةِ الرَّافِعِيِّ بِهِ النَّاقِلِ فِي الشَّرْحِ تَرْجِيحَهُ عَنِ الْإِمَامِ وَتَرْجِيحَ الثَّانِي عَنْ  
الْبَغَوِيِّ، وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: رَجَحَ كِلَا مَرَجِحُونَ، لَكِنَّهُ فِي الرَّوْضَةِ زَادَ:  
الْأَصَحُّ: الْأَوَّلُ.

(وَلَوْ شَهِدَا بِطَلَاقٍ بَائِنٍ أَوْ رِضَاعٍ) مُحَرَّمٍ (أَوْ لِعَانٍ وَفَرَّقَ الْقَاضِي) فِي  
الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ (فَرَجَعَا) عَنِ الشَّهَادَةِ (دَامَ الْفِرَاقُ<sup>(٦)</sup>)، وَقَوْلُهُمَا الْمُحْتَمَلُ

---

(١) أي: على القاضي.

(٢) وحده عن تعديل الشهود ولو قبل شهادتهم.

(٣) دون الشهود.

(٤) بكمالها؛ لأنه المباشر للقتل.

(٥) أي: رجع مع الشهود.

(٦) لأن قولهما في الرجوع محتمل فلا يرد الحكم بقول محتمل.

لَا يُرَدُّ بِهِ الْقَضَاءُ (وَعَلَيْهِمْ<sup>(١)</sup>) هُوَ أَخْصَرُ مِنْ عَلَيْهِمَا، (مَهْرٌ مِثْلُ<sup>(٢)</sup>)،  
وَفِي قَوْلٍ: نِصْفُهُ إِنْ كَانَ الْفِرَاقُ (قَبْلَ وَطْءٍ) لِأَنَّهُ الَّذِي فَاتَ عَلَى الزَّوْجِ  
وَالأَوَّلُ نَظَرَ إِلَى بَدَلِ النُّبْضِ الْمُفْقُوتِ، وَلَوْ رَجَعَا عَنْ الشَّهَادَةِ بِطَلَاقٍ  
رَجَعِيٍّ فَلَا غُرْمَ إِذْ لَمْ يُقَوِّتَا شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ يُرَاجِعْ حَتَّى انْقَضَتْ الْعِدَّةُ  
التَّحَقَّ بِالْبَائِنِ وَوَجَبَ الْغُرْمُ وَقِيلَ: لَا؛ لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ الرَّجْعَةِ.

(وَلَوْ شَهِدَا بِطَلَاقٍ) بَائِنٍ (وُفِرَّقَ فَرَجَعَا فَقَامَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ كَانَ بَيْنَهُمَا  
رِضَاعٌ) مُحَرَّمٌ (فَلَا غُرْمَ) إِذْ لَمْ يُقَوِّتَا<sup>(٣)</sup>.

(وَلَوْ رَجَعَ شُهُودُ مَالٍ) عَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ بَعْدَ الْحُكْمِ بِهِ وَدَفَعَهُ (غَرِمُوا فِي  
الْأَظْهَرِ) لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ؛ لِحُصُولِ الْحِيلُولَةِ بِشَهَادَتِهِمْ، وَالثَّانِي: الْمَنْعُ<sup>(٤)</sup>.

(وَمَتَّى رَجَعُوا كُلُّهُمْ وَزَعَ عَلَيْهِمُ الْغُرْمَ) بِالسَّوِيَّةِ (أَوْ بَعْضُهُمْ وَبَقِيَ) مِنْهُمْ  
(نِصَابٌ)<sup>(٥)</sup> (فَلَا غُرْمَ) عَلَى الرَّاجِعِ؛ لِقِيَامِ الْحُجَّةِ بِمَنْ بَقِيَ، (وَقِيلَ: يَغْرُمُ  
قِسْطُهُ) لَوْ قُوعِ الْحُكْمِ بِشَهَادَةِ الْجَمِيعِ الْمُفْقُوتِ كُلِّ مِنْهُمْ لِقِسْطِهِ.

## (كِتَابُ الدَّعْوَى<sup>(١)</sup> وَالْبَيِّنَاتِ)

(١) أي: على الشهود الراجعين للزوج.

(٢) لأنه بدل ما فوتاه عليه.

(٣) لأننا تبينا أن شهادتهما لم تقوت على الزوج شيئاً، ولو غرما قبل قيام البينة شيئاً  
استردا ما غرماه.

(٤) لأن الضمان باليد أو الإلتلاف ولم يوجد واحد منهما.

(٥) كأن رجع من ثلاثة واحد فيما يثبت بشاهدين.

(١) الدعوى في اللغة: اسم للدعاء وهي الطلب والتمني، وتجمع على دعاوى بفتح الواو وكسرهما وسميت دعوى؛ لأن المدعى يدعو صاحبه إلى مجلس الحكم ليخرج من دعواه، وشرعا: إخبار بحق له على غيره عند حكم.

(وَالْبَيِّنَاتُ) جَمْعُ بَيِّنَةٍ وَهُمْ الشُّهُودُ؛ لِأَنَّ بِهِمْ يَتَّبِعُ الْحَقُّ، وَأَفْرَدَ الْمُصَنِّفُ الدَّعْوَى لِأَنَّ حَقِيقَةَ الدَّعْوَى وَاحِدَةٌ، وَجَمَعَ الْبَيِّنَاتِ؛ لِاخْتِلَافِ أَنْوَاعِهَا بِكُونِهَا شَاهِدًا أَوْ شَاهِدِينَ أَوْ أَرْبَعَةً مِنَ الرِّجَالِ أَوْ مِنَ النِّسَاءِ.

وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ الْكِتَابِ وَالسَّنَةِ: أَمَا الْكِتَابُ فَمِنْهُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ). وَأَمَا السَّنَةُ فَمِنْهَا: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ».

هذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع. ففيه أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه، فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك. وقد بين صلى الله عليه وسلم الحكمة في كونه لا يعطى بمجرد دعواه لأنه لو كان أعطى بمجرد ادعائه قوم دماء قوم وأمواله واستبيح، ولا يمكن المدعى عليه أن يصون ماله ودمه. وأما المدعي فيمكنه صيانتهما بالبينه. وقوله: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ". وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ جَانِبَ الْمُدَّعِي ضَعِيفٌ لِدَعْوَاهُ خِلَافَ الْأَصْلِ فَكُلِّفَ الْحُجَّةُ الْقَوِيَّةُ وَهِيَ الْبَيِّنَةُ؛ لِأَنَّهَا قَوْلٌ صَادِرٌ مِنْ غَيْرِهِ، وَجَانِبَ الْمَدْعَى عَلَيْهِ قَوِيٌّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ، فَكُلِّفَ بِالْحُجَّةِ الضَّعِيفَةِ وَهِيَ الْيَمِينُ؛ لِأَنَّ الْحَالِفَ مَتَّهَمٌ فِي يَمِينِهِ بِالْكَذِبِ؛ لِأَنَّهُ يَدْفَعُ بِهَا عَنْ نَفْسِهِ بِخِلَافِ الشَّاهِدِ.

الدَّعْوَى تَشْتَمِلُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ: مُدَّعٍ، مُدَّعَى عَلَيْهِ، وَمُدَّعَى بِهِ، وَمُدَّعَى عِنْدَهُ.

الدَّعْوَى اسْمٌ لِلدَّعَاءِ تَتَعَلَّقُ بِمُدَّعِي بِاخْتِلَافِهِ تَخْتَلِفُ الْبَيِّنَةُ فَجُمِعَتْ<sup>(١)</sup>.

(تُشْتَرَطُ<sup>(٢)</sup> الدَّعْوَى عِنْدَ قَاضٍ<sup>(٣)</sup> فِي عُقُوبَةٍ لَأَدْمِيٍّ (كَقِصَاصٍ وَ) حَدٍّ (قَذْفٍ) فَلَا يَأْخُذُهَا مُسْتَحِقُّهَا بِدُونِ رَفْعٍ إِلَى الْقَاضِي؛ لِخَطَرِهَا وَالِاحْتِيَاطِ فِي إِثْبَاتِهَا وَاسْتِيفَائِهَا<sup>(٤)</sup>، (وَإِنْ اسْتَحَقَّ) شَخْصٌ (عَيْنًا) عِنْدَ آخَرَ (فَلَهُ

---

(١) تَخْتَلِفُ الْبَيِّنَةُ: بِكَوْنِهَا شَاهِدًا أَوْ شَاهِدَيْنِ أَوْ أَرْبَعَةً مِنَ الرِّجَالِ أَوْ مِنْ النِّسَاءِ وَسُمِّيَ الشُّهُودُ بَيِّنَةً؛ لِأَنَّ بِهِمْ يَتَبَيَّنُ الْحَقُّ.

(٢) لإقامة الدعوى ستة شروط: أَحَدُهَا: أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةً غَالِبًا بِأَنْ يُفَصِّلَ الْمُدَّعِي مَا يَدَّعِيهِ؛ لِأَنَّ الْأَحْكَامَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ هَذِهِ الْأَحْوَالِ. ثَانِيهَا: أَنْ تَكُونَ مُلْزِمَةً، فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى هَبَةِ شَيْءٍ أَوْ بَيْعِهِ أَوْ إِقْرَارٍ بِهِ حَتَّى يَقُولَ الْمُدَّعِي وَقَبَضْتُهُ بِإِذْنِ الْوَاهِبِ وَيَلْزِمُ الْبَائِعَ أَوْ الْمُقَرَّرَ التَّسْلِيمَ إِلَيَّ. وَثَالِثُهَا: أَنْ يُعَيِّنَ مُدَّعِي عَلَيْهِ، فَلَوْ قَالَ قَتَلَهُ أَحَدٌ هَؤُلَاءِ، لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ، لِإِيْهَامِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. وَرَابِعُهَا: أَنْ يَكُونَ كُلُّ مَنْ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ غَيْرَ حَرَبِيٍّ، لَا أَمَانَ لَهُ. وَخَامِسُهَا: أَنْ يَكُونَ كُلُّ مَنْ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُكَلَّفًا، فَلَا تَصَحُّ الدَّعْوَى مِنَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، وَلَا عَلَيْهِمْ. وَسَادِسُهَا: أَنْ لَا تُتَاقَضَ دَعْوَى أُخْرَى فَلَوْ ادَّعَى عَلَى وَاحِدٍ انْفِرَادَهُ بِقَتْلِ ثُمَّ ادَّعَى عَلَى آخَرَ شَرِكَةً أَوْ انْفِرَادًا لَمْ تُسْمَعِ الدَّعْوَى الثَّانِيَّةُ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَى تُكَذِّبُهَا نَعَمَ إِنْ صَدَّقَهُ الْآخَرُ فَهُوَ مُؤَاخَذٌ بِإِقْرَارِهِ وَتُسْمَعُ الدَّعْوَى عَلَيْهِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي أَصْلِ الرُّوْضَةِ.

(٣) حكم إقامة الدعوى عند غير القاضي:

الأصل رفع الدعوى عند قاضى، ولكن رفع الدعوى ليس مقصورا على القاضي، فيجوز رفع الدعوى لمحكم رضىا الخصمان بحكمه، وكذلك الوزير والأمير ممن يرجى الخلاص على يده.

(٤) في عقوبة لأدمي، كقصاص وحدّ قذف فلا دعوى في عقوبة الله، وإن توقفت على الحاكم، لأنها لا بد فيها من الرفع إلى القاضي، ولكن لا يدعى فيها، وكذا التعزير لحق الله، إلا أن تعلق به مصلحة عامة، كطرح حجارة بطريق، ولا يستقل



أَخْذُهَا) بِدُونِ رَفْعٍ إِلَى الْقَاضِي (إِنْ لَمْ يَخَفْ فِتْنَةً وَإِلَّا وَجَبَ الرُّفْعُ إِلَى قَاضٍ) تَحَرُّراً عَنْهَا<sup>(١)</sup>، (أَوْ دَيْنًا عَلَى غَيْرِ مُمْتَنِعٍ مِنَ الْأَدَاءِ طَالَبُهُ وَلَا يَحِلُّ أَخْذُ شَيْءٍ لَهُ<sup>(٢)</sup>، أَوْ عَلَى مُنْكَرٍ وَلَا بَيِّنَةٍ) لَهُ (أَخَذَ جِنْسَ حَقِّهِ مِنْ مَالِهِ) إِنْ ظَفَرَ بِهِ (وَكَذًا غَيْرَ جِنْسِهِ إِنْ فَقَدَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ) لِلضَّرُورَةِ، وَفِي قَوْلٍ مِنْ طَرِيقٍ: الْمَنْعُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتِمَّكُنُ مِنْ تَمْلُكِهِ<sup>(٣)</sup>، (أَوْ عَلَى مُقَرَّرٍ

---

صاحبها باستيفائها لعظم خطرهما، والاحتياط في إثباتها واستيفائها، فإن خالف واستوفى وقع الموقع، وإن حرم لافتياته على الإمام.

(١) أخذ الإنسان لعين ماله بنفسه إما أن يترتب عليه ضرر أو لا، فإذا لم يترتب على الأخذ ضرر: إن استحقَّ شخص عينًا تحت يد عادية، فله أو وليه إذا لم يكن كامل الأهلية أخذها مستقلاً بالأخذ بلا رفع لقاض، وبلا علم من هي تحت يده للضرورة، إن لم يخف من أخذها فتنة أو ضرر سواء على نفسه أو على غيره؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أذن لهند في أخذ النفقة، وهي في الذمة؛ فعين المال أولى. وإن ترتب على أخذه حقه بنفسه ضرر: وجب الرفع إلى قاض أو نحوه ممن له إلزام الحقوق، كمحتسب وأمير، إن علم أن الحق لا يتخلص إلا عنده؛ لتمكنه من الخلاص به، فلا حاجة على إثارة الفتنة.

(٢) إذا كان للشخص ديناً حالاً والمدين غير ممتنع من الأداء، فللدائن مطالبته، ليؤدي ما عليه، ولا يحل أخذ شيء له، لأن مَنْ عليه الحق مخيرٌ في الدفع من أي مال شاء، فليس للمستحق إسقاط حقه من ذلك الخيار، فإن خالف وأخذ شيئاً من ماله لم يملكه ولزمه رده، فإن تلف عنده ضمنه.

(٣) إذا كان للشخص دين والمدين منكر له فهل يحل له أخذه سواء وجد جنس ماله أو غير جنسه أو لا؟ أولاً: إذا وجد جنس ماله، فإذا كان المدين منكراً للدين ولا بينة للدائن عليه، ووجد الدائن جنس حقه لدى المدين، أخذه جوازاً من مال المدين عند الظفر به؛ لعجزه عن أخذه إلا كذلك.

مُمْتَنِعٍ وَمُنْكَرٍ وَلَهُ بَيِّنَةٌ فَكَذَلِكَ) أَيُّ لَهُ أَخْذُ حَقِّهِ اسْتِقْلَالًا (وَقِيلَ: يَجِبُ الرِّفْعُ إِلَى قَاضٍ) وَالْأَوَّلُ قَالَ فِيهِ مُؤَنَّةٌ وَمَشَقَّةٌ وَتَضْيِيعُ زَمَانٍ<sup>(١)</sup>.

(وَإِذَا جَازَ الْأَخْذُ فَلَهُ كَسْرُ بَابٍ وَنَقْبُ جِدَارٍ لَا يَصِلُ الْمَالُ إِلَّا بِهِ) وَلَا يَضْمَنُ مَا فَوْتُهُ<sup>(٢)</sup> (ثُمَّ الْمَأْخُوذُ مِنْ جِنْسِهِ) أَيُّ الْحَقُّ (يَتَمَلَّكُهُ، وَمِنْ غَيْرِهِ

---

ثانيا: إذا لم يجد جنس ماله: فلصاحب الدين أخذ حقه من غير جنسه على المذهب للضرورة؛ لما روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها: أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله؛ إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت من ماله وهو لا يعلم، فهل على ذلك شيء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: (خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وولدك) فجوز لها الأخذ من غير فرق بين الجنس وغيره.

والقول الثاني: لا يأخذه؛ لأنه لا يتمكن من تملكه

(١) إذا كان الدين على مقر، ولكنه ممتنع من الأداء، أو الدين عند منكر له، ولصاحب الدين بينة على إثباته، فله أخذ حقه بنفسه دون الرفع إلى القاضي؛ لأن في المرافعة مؤنة ومشقة وتضييع زمان. وقيل: يجب الرفع إلى قاض كما لو أمكنه تخليص الحق بالمطالبة والتقاضي. ورد عليه: بأن في ذلك مؤنة ومشقة وتضييع زمان.

(٢) إذا جاز لصاحب الحق أخذ حقه من غير رفع لقاض، فله كسر باب، ونقب جدار لا يصل المال إلا به؛ لأن من استحق شيئا استحق الوصول إليه، ولا يضمن ما فوته على الأصح؛ كمن لم يقدر على دفع الصائل إلا بإتلاف ماله، فأنتفله لا يضمن. واستشكل البلقيني هذا، وقال: أصل الظفر: القياس على قصة هند، وبينها وبين المديون فرق، وهو تكرر نفقة الزوجة والأولاد كل يوم، فيشق الرفع إلى القاضي، ولو سلم .. فمن أين في المقيس عليه كسر باب ونقب جدار؟ ولم أجد للشافعي نصا بذلك، ولم يذكره أكثر الأصحاب وإنما ذكره القاضي الحسين، وجرى عليه أتباعه،

يَبِيعُهُ) اسْتِقْلَالًا (وَقِيلَ: يَجِبُ رَفْعُهُ إِلَى قَاضٍ يَبِيعُهُ<sup>(١)</sup>) وَفِي الْمُحَرَّرِ رَجَّحَ كُلًّا مِنْهُمَا طَائِفَةً وَبَدَأَ فِيهِ بِالْأَوَّلِ، وَقُوَّةُ كَلَامِ الشَّرْحِ تُعْطِي تَرْجِيحَهُ وَفِي أَصْلِ الرُّوضَةِ: أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ: الْإِسْتِقْلَالُ، ثُمَّ بَيَّعَ الْقَاضِي بَعْدَ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى اسْتِحْقَاقِ الْمَالِ. (وَالْمَأْخُذُ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ) أَيِ الْأَخْذِ (فِي الْأَصَحِّ فَيَضْمَنُهُ إِنْ تَلَفَ قَبْلَ تَمْلُكِهِ وَبَيْعِهِ) لِأَنَّهُ أَخَذَهُ لِعَرَضِ نَفْسِهِ كَالْمُسْتَمِ، وَالثَّانِي قَالَ: أَخَذَهُ لِلتَّوْتُقِ وَالتَّوَصَّلِ بِهِ إِلَى الْحَقِّ كَالْمُرْتَهِنِ، وَإِذْنُ الشَّرْعِ فِي الْأَخْذِ يَقُومُ مَقَامَ إِذْنِ الْمَالِكِ عَلَيْهِمَا<sup>(٢)</sup>،

والدليل يخالفه، ثم يترتب عليه دخول السُّرَّاق ونحوهم، وقد يكون الباب أكثر ثمنًا من الدين وهذا ضرر لا يصار إليه.

(١) هل المال المأخوذ استقلالًا يملك بمجرد الأخذ أو لابد من الرفع إلى القاضي: من أخذ حقه بنفسه إما أن يكون أخذ جنس ماله أو لا، إذا استوفى حقه من جنس ماله، ملكه بمجرد الأخذ، بدلا عن حقه، وإذا كان المأخوذ من غير جنس حقه، يبيعه بنفسه استقلالًا للحاجة، كما أنه يأخذه بنفسه، وله أن يוכל من يبيعه، فإذا باعه فليبيعه بنقد البلد، ثم يشتري به جنس حقه، إن لم يكن نقد البلد. وقيل: يجب رفعه إلى قاضٍ ليبيعه، لأنه تصرف في مال غيره لنفسه.

(٢) إذا تلف المأخوذ في يد الأخذ قبل تملكه ففي ضمانه وجهان: الأصح: على الأخذ ضمان ما أخذه إن تلف في يده قبل تملكه وبيعه بالأكثر من قيمته من حين أخذه إلى حين التلف كالمغاصب؛ لأنه أخذه بغير إذن المالك لغرض نفسه كالمستام (وهو الذي يفصل يطلب الزيادة، فعليه ضمان السلعة إن تلفت في يده، بل أولى؛ فإن المالك لم يأذن فيه، لِأَنَّ الْمُضْطَرَّ إِذَا أَخَذَ ثَوْبَ غَيْرِهِ لِدَفْعِ الْحَرِّ وَتَلَفَتْ فِي يَدِهِ ضَمِنَهُ فَكَذَا هُنَا. الوجه الثاني: لا يضمنه من غير تقريط؛ لأنه مأخوذ للتوثق والتوصل به إلى الحق؛ فأشبه الرهن، وإذن الشارع في الأخذ يقوم مقام إذن المالك.

(وَلَا يَأْخُذُ) الْمُسْتَحَقُّ (فَوْقَ حَقِّهِ إِنْ أُمِّكْنَ الْاِقْتِصَارُ) عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنُهُ بَأَنْ لَمْ يَظْفَرْ إِلَّا بِمَتَاعٍ تَزِيدُ قِيَمَتُهُ عَلَى حَقِّهِ أَخَذَهُ، وَلَا يَضْمَنُ الزِّيَادَةَ فِي الْأَصَحِّ؛ لِغُذْرِهِ وَبَاعَ مِنْهُ بِقَدْرِ حَقِّهِ إِنْ أُمِّكْنَ بِتَجْزِئَةٍ وَإِلَّا بَاعَ الْكُلَّ وَأَخَذَ مِنْ ثَمَنِهِ قَدْرَ حَقِّهِ وَرَدَّ الْبَاقِي بِهَبَةٍ وَنَحْوِهَا<sup>(١)</sup>، (وَلَهُ أَخْذُ مَالِ غَرِيمِ غَرِيمِهِ) كَأَنْ يَكُونَ لِزَيْدٍ عَلَى عَمْرٍو دَيْنٌ وَلِعَمْرٍو عَلَى بَكْرٍ مِثْلُهُ، لِزَيْدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ بَكْرٍ مَا لَهُ عَلَى عَمْرٍو، وَلَا يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ رَدُّ عَمْرٍو وَإِقْرَارُ بَكْرٍ لَهُ، وَلَا جُحُودُ بَكْرٍ اسْتِحْقَاقَ زَيْدٍ عَلَى عَمْرٍو، كَذَا فِي الرُّوَضَةِ كَأَصْلِهَا، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ: عِلْمُ الْغَرِيمَيْنِ بِالْأَخْذِ وَتَنْزِيلُ مَالِ الثَّانِي مَنْزِلَةَ الْأَوَّلِ<sup>(٢)</sup>.

---

مَحَلُّ الْخِلَافِ كَمَا قَالَه الماوردي والرويانى: إِذَا تَلَفَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنَ الْبَيْعِ، فَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْهُ فَلَمْ يَفْعَلْ ضَمَنَ قَطْعًا، وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: مَحَلُّهُ الْخِلَافُ فِي غَيْرِ الْجِنْسِ. أَمَّا الْمَأْخُودُ مِنَ الْجِنْسِ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ ضَمَانٌ يَدِّ قَطْعًا لِحُصُولِ مِلْكِهِ بِالْأَخْذِ عَنْ حَقِّهِ.

(١) وَلَا يَأْخُذُ الْمُسْتَحَقُّ فَوْقَ حَقِّهِ إِنْ أُمِّكْنَ الْاِقْتِصَارَ عَلَى قَدْرِ حَقِّهِ، لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِهِ وَهُوَ الْوَصُولُ إِلَى حَقِّهِ، فَإِنْ زَادَ فَالزِّيَادَةُ مَضْمُونَةٌ عَلَيْهِ؛ لِتَعْدِيهِ بِأَخْذِ أَكْثَرٍ مِنْ حَقِّهِ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ الْاِقْتِصَارُ؛ بَأَنْ كَانَ حَقُّهُ خَمْسِينَ فَوُجِدَ سَيِّفًا يَسَاوِي مِائَةَ أَخْذِهِ، وَلَا يَضْمَنُ الزِّيَادَةَ فِي الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَى حَقِّهِ إِلَّا بِهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَبَاعَ مِنْهُ قَدْرَ حَقِّهِ إِنْ أُمِّكْنَ بَيْعَ بَعْضِهِ وَرَدَ الزِّيَادَةَ عَلَى الْمَالِكِ بِهَبَةٍ وَنَحْوِهَا، وَإِنْ تَعَذَّرَ بَيْعُ قَدْرِ حَقِّهِ فَقَطَّ بَاعَ الْجَمِيعَ، وَأَخْذَ مِنْ ثَمَنِهِ قَدْرَ حَقِّهِ، وَرَدَّ مَا زَادَ عَلَى حَقِّهِ عَلَى مَالِكِهِ.

(٢) وَلِصَاحِبِ الْحَقِّ إِنْ تَعَذَّرَ أَخْذَ حَقِّهِ مِنْ غَرِيمِهِ فَلَهُ أَخْذُهُ مِنْ مَالِ غَرِيمِ غَرِيمِهِ، بَأَنْ يَكُونَ لِزَيْدٍ عَلَى عَمْرٍو دَيْنٌ، وَلِعَمْرٍو عَلَى بَكْرٍ مِثْلُهُ؛ يَجُوزُ لِزَيْدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ بَكْرٍ مَا لَهُ مِنْ حَقِّ عَمْرٍو، وَلَا يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ رَدُّ عَمْرٍو أَوْ مَنَعُ عَمْرٍو زَيْدًا عَنْ

(وَالْأَظْهَرُ: أَنَّ الْمُدَّعِيَّ مَنْ يُخَالِفُ قَوْلَهُ الظَّاهِرَ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَنْ يُوَافِقُهُ) ذِكْرًا؛ لِتَعْلُقِ الدَّعْوَى بِهِمَا، وَالثَّانِي: أَنَّ الْمُدَّعِيَّ مَنْ لَوْ سَكَتَ خَلَى وَلَمْ يُطَالَبْ بِشَيْءٍ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَنْ لَا يُخْلِي وَلَا يَكْفِيهِ السُّكُوتُ، فَإِذَا طَالَبَ زَيْدٌ عَمْرًا بِدَيْنٍ فِي ذِمَّتِهِ أَوْ عَيْنٍ فِي يَدِهِ فَأَنْكَرَ فزَيْدٌ لَوْ سَكَتَ تَرَكَ، وَيُخَالِفُ قَوْلَهُ الظَّاهِرَ مِنْ بَرَاءَةِ عَمْرٍو، وَعَمْرٍو لَا يَتْرُكُ، وَيُؤَافِقُ قَوْلَهُ الظَّاهِرَ، فَهُوَ مُدَّعَى عَلَيْهِ وَزَيْدٌ مُدَّعٍ عَلَى الْقَوْلَيْنِ، وَلَا يَخْتَلِفُ مُوجِبُهُمَا غَالِبًا وَقَدْ يَخْتَلِفُ، مِنْهُ قَوْلُهُ، (فَإِذَا أَسْلَمَ زَوْجَانِ قَبْلَ وَطْءٍ فَقَالَ) الرَّوْجُ: (أَسْلَمْنَا مَعًا فَالِنِكَاحِ بَاقٍ وَقَالَتْ) أَسْلَمْنَا (مُرْتَبًا) فَلَا نِكَاحَ، (فَهُوَ) عَلَى الْأَظْهَرِ (مُدَّعٍ)؛ لِأَنَّ مَا قَالَهُ خِلَافَ الظَّاهِرِ، وَهِيَ مُدَّعَى عَلَيْهَا، وَعَلَى الثَّانِي: هِيَ مُدَّعِيَةٌ وَهُوَ مُدَّعَى عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا لَوْ سَكَتَتْ تَرَكَتْ وَهُوَ لَا يَتْرُكُ لَوْ سَكَتَ؛ لِزَعْمِهَا انْفِسَاخَ النِّكَاحِ، فَعَلَى الْأَوَّلِ:

الأخذ من مال بكر، وتصرف زيد بالأخذ، وعدم حسابان ذلك عن دينه على بكر، ولا إقرار بكر لعمره بالدين، ولا جحود بكر استحقاق زيد على عمرو. وَلِلْمَسْأَلَةِ شُرُوطٌ: الْأَوَّلُ: أَنَّ لَا يَطْفَرُ بِمَالِ الْغَرِيمِ. الثَّانِي: أَنَّ يَكُونَ غَرِيمَ الْغَرِيمِ جَاحِدًا أَوْ مُمْتَنِعًا أَيْضًا، وَعَلَى الْإِمْتِنَاعِ يُحْمَلُ الْإِقْرَارُ الْمَذْكُورُ. الثَّالِثُ: أَنَّ يُعْلِمَ الْأَخِذُ الْغَرِيمَ أَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ مَالِ غَرِيمِهِ حَتَّى إِذَا طَالَبَهُ الْغَرِيمُ بَعْدَ كَانَ هُوَ الظَّالِمُ. الرَّابِعُ: أَنَّ يُعْلِمَ غَرِيمَ الْغَرِيمِ وَحِيلَتُهُ أَنَّ يُعْلِمَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ. فَإِذَا طَالَبَهُ أَنْكَرَ، فَإِنَّهُ بِحَقٍّ، وَلَهُ اسْتِيفَاءُ دَيْنٍ لَهُ عَلَى آخَرٍ جَاحِدًا لَهُ بِشُهُودٍ دَيْنٍ آخَرَ لَهُ عَلَيْهِ قَدْ أَدَّى وَلَمْ يَعْلَمُوا أَدَاءَهُ، وَلِأَخِذِ الْغَرِيمَيْنِ إِذَا كَانَ لَهُ عَلَى الْآخَرِ مِثْلُ مَالِهِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ جَحَدَ حَقِّ الْآخَرِ إِنْ جَحَدَ الْآخَرُ حَقَّهُ لِيَحْصَلَ النِّقَاصُ، وَإِنْ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ النَّقْدَيْنِ لِلضَّرُورَةِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ دُونَ مَا لِلْآخَرِ عَلَيْهِ جَحَدَ مِنْ حَقِّهِ بِقَدْرِهِ.

تَحْلِفُ الْمَرْأَةُ وَيَرْتَفِعُ النِّكَاحُ، وَعَلَى الثَّانِي: يَحْلِفُ الزَّوْجُ وَيَسْتَمِرُّ  
النِّكَاحُ<sup>(١)</sup>.

(وَمَتَى ادَّعَى نَقْدًا أُشْطِرَ بَيَانُ جِنْسٍ وَنَوْعٍ وَقَدَرٍ، وَصَحَّةٍ وَتَكْسُرٍ إِنْ  
اخْتَلَفَتْ بِهِمَا قِيَمَةٌ) كِمَاءَةٌ دِرْهَمٍ فَضَّةٍ ظَاهِرِيَّةٍ صِحَاحٍ أَوْ مُكْسَرَةٍ،  
وَاشْتِرَاطُ ذَلِكَ الْمُفِيدِ لِعِلْمِهِ؛ لِتَصِحَّ الدَّعْوَى بِهِ<sup>(٢)</sup> (أَوْ) ادَّعَى (عَيْنًا

(١) حكم ادعاء أحد الزوجين الإسلام قبل الآخر: أولاً: ادعاء الزوجة ما يفسخ  
النكاح، إِذَا أَسْلَمَ زَوْجَانِ قَبْلَ وَطْءٍ، فَقَالَ الزَّوْجُ: أَسْلَمْنَا مَعًا فَالنِّكَاحُ بَيْنُنَا بَاقٍ، وَقَالَتْ  
الزَّوْجَةُ: أَسْلَمْنَا مُرْتَبًّا، فَلَا نِكَاحَ بَيْنُنَا، فَالزَّوْجُ عَلَى الْأُظْهَرِ: مُدَّعٍ، لِأَنَّ إِسْلَامَهُمَا مَعًا  
خِلَافُ الظَّاهِرِ فَعَلِيهِ الْبَيِّنَةُ، وَالزَّوْجَةُ مُدَّعَى عَلَيْهَا؛ لِمَوَافَقَتِهَا الظَّاهِرَ فَتَحْلِفُ، وَيَرْتَفِعُ  
النكاح.

وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي: الزَّوْجَةُ مُدَّعِيَّةٌ، وَالزَّوْجُ مُدَّعَى عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا لَوْ سَكَتَتْ تَرِكَتْ وَهُوَ  
لَا يُتْرَكُ لَوْ سَكَتَ لَزَعْمُهَا انْفِسَاحَ النِّكَاحِ، فَعَلَى الْأَوَّلِ: تَحْلِفُ الزَّوْجَةُ وَيَرْتَفِعُ النِّكَاحُ،  
وَعَلَى الثَّانِي: يَحْلِفُ الزَّوْجُ وَيَسْتَمِرُّ النِّكَاحُ.

ثانياً: ادعاء الزوج ما يفسخ النكاح: لَوْ قَالَ الزَّوْجُ لَزَوْجَتِهِ: أَسْلَمْتُ قَبْلِي فَلَا نِكَاحَ بَيْنُنَا  
وَلَا مَهْرَ لَكَ، وَقَالَتْ: بَلْ أَسْلَمْنَا مَعًا صُدِّقَ فِي الْفُرْقَةِ بِلَا يَمِينٍ، وَفِي الْمَهْرِ بِيَمِينِهِ  
عَلَى الْأُظْهَرِ: لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ، وَصُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا عَلَى الثَّانِي: لِأَنَّهَا لَا تَتْرَكُ  
بِالسُّكُوتِ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ يَزْعُمُ سُقُوطَ الْمَهْرِ، فَإِذَا سَكَتَتْ وَلَا بَيِّنَةَ جُعِلَتْ نَاكِلَةً وَحَلَفَ هُوَ  
وَسَقَطَ الْمَهْرُ.

(٢) الأموال سواء كانت ديناً أو عيناً لها شروط لإقامة الدعوى وهي:  
الأوّل: أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةً فَعَلِيَّةً، مَتَى ادَّعَى شَخْصٌ دَيْنًا نَقْدًا أَوْ غَيْرُهُ مِثْلِيًّا أَوْ مُتَقَوِّمًا،  
أَشْطَرِ فِيهِ لِصَحَّةِ الدَّعْوَى بَيَانُ جِنْسِهِ كَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَنَوْعِهِ كَخَالِصٍ أَوْ مَغْشُوشٍ  
وَقَدَرِهِ كِمَاءَةٍ، وَصِفَةٍ يَخْتَلِفُ بِهَا الْغَرَضُ. الشَّرْطُ الثَّانِي: لِصَحَّةِ الدَّعْوَى أَنْ تَكُونَ  
الدَّعْوَى تَلْزِمُهُ، فَلَوْ ادَّعَى عَلَى غَيْرِهِ هِبَةً أَوْ بَيْعًا أَوْ دَيْنًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا الْغَرَضُ مِنْهُ

تَنْضِبُ مِثْلِيَّةً أَوْ مُتَقَوِّمَةً (كَحَيَوَانٍ) وَحُبُوبٍ وَثِيَابٍ. (وَصَفَهَا بِصِفَةِ السَّلَمِ، وَقِيلَ: يَجِبُ مَعَهَا ذِكْرُ الْقِيَمَةِ) هَذَا إِنْ بَقِيَتْ (فَإِنْ تَلَفَتْ وَهِيَ مُتَقَوِّمَةٌ وَجِبَ ذِكْرُ الْقِيَمَةِ) لِأَنَّهَا الْوَاجِبُ، أَوْ مِثْلِيَّةٌ فَلَا يَجِبُ وَيَكْفِي الضَّبْطُ بِالصِّفَاتِ<sup>(١)</sup> (أَوْ) ادَّعَى (نِكَاحًا لَمْ يَكْفِ الْإِطْلَاقُ عَلَى الْأَصَحِّ بَلْ يَقُولُ: نَكَحْتُهَا بِوَلِيِّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ وَرِضَاهَا إِنْ كَانَ يُشْتَرَطُ بِأَنْ كَانَتْ غَيْرَ مُجْبَرَةٍ، وَالثَّانِي: يَكْفِي الْإِطْلَاقُ فِيهِ كَالْمَالِ<sup>(٢)</sup>).

تَحْصِيلُ الْحَقِّ فَلْيَذْكُرْ فِي دَعْوَاهُ وَجُوبَ التَّسْلِيمِ كَأَنْ يَقُولَ: وَيَلْزَمُهُ التَّسْلِيمُ إِلَيَّ أَوْ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ مِنَ الْأَدَاءِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَرْجِعُ الْوَاهِبُ وَيُفْسَخُ الْبَيْعُ وَيَكُونُ الدَّيْنُ مُوجِبًا أَوْ مَنْ عَلَيْهِ مُفْلِسًا، وَلَوْ قَصَدَ بِالْدَّعْوَى رَفْعَ الْمُنَازَعَةِ لَا تَحْصِيلُ الْحَقِّ، فَقَالَ: هَذِهِ الدَّارُ لِي، وَهُوَ يَمْنَعُهَا سُمِعَتْ دَعْوَاهُ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ هِيَ فِي يَدِهِ؛ لِأَنَّهُ يُمَكِّنُ أَنْ يُنَازِعَهُ. (١) إِذَا ادَّعَى الشَّخْصَ عَيْنًا مِنْ غَيْرِ النَّقْدَيْنِ إِمَّا أَنْ تَنْضِبُ بِالصِّفَةِ أَوْ لَا، فَإِذَا ادَّعَى عَيْنًا وَهَذِهِ الْعَيْنُ تَنْضِبُ بِالصِّفَةِ مُتَقَوِّمَةً كَانَتْ كَحَيَوَانٍ وَثِيَابٍ أَوْ مِثْلِيَّةٍ كَحُبُوبٍ فَيَجِبُ وَصْفُهَا بِصِفَةِ السَّلَمِ، لِحَصُولِ الْمَقْصُودِ بِهِ.

هَذَا إِذَا كَانَتْ الْعَيْنُ بَاقِيَةً أَمَا إِذَا تَلَفَتْ وَهِيَ مِنَ الْأَمْوَالِ الْقِيَمِيَّةِ وَجِبَ ذِكْرُ الْقِيَمَةِ، لِأَنَّهَا الْوَاجِبَةُ عِنْدَ التَّلَفِ، فَلَا حَاجَةَ لَذِكْرِ شَيْءٍ مَعَهَا مِنَ الصِّفَاتِ، وَلَكِنْ يَجِبُ ذِكْرُ الْجِنْسِ فَيَقُولُ عَبْدُ قِيَمَتِهِ مَائَةً، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْأَمْوَالِ الْمِثْلِيَّةِ، فَلَا يَجِبُ ذِكْرُ الْقِيَمَةِ وَيَكْفِي الضَّبْطُ بِالصِّفَاتِ، أَمَا إِذَا ادَّعَى عَيْنًا لَمْ تَنْضِبُ بِالصِّفَاتِ كَالْجَوَاهِرِ وَالْيَوَاقِيتِ وَجِبَ ذِكْرُ الْقِيَمَةِ فَيَقُولُ: جَوْهَرٌ قِيَمَتُهُ كَذَا.

(٢) مَنْ ادَّعَى نِكَاحًا لَمْ يَكْفِ الْإِطْلَاقُ عَلَى الْأَصَحِّ، بَلْ يَقُولُ: نَكَحْتُهَا بِوَلِيِّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ وَرِضَاهَا إِنْ كَانَ يُشْتَرَطُ، أَيْ لكونها غير مجبرة؛ لأن النكاح فيه حق الله تعالى والآدمي، وإذا وقع لا يمكن استرداكه فلا يسمع دعواه إلا ببيئة كالقتل. والثاني: يكفي الإطلاق فيه كما اكتفى في دعوى استحقاق المال به؛ كما لا يشترط ذكر انتقاء الموانع؛ كالردة والرضاع.

(أَوْ) ادَّعَى (عَقْدًا مَالِيًّا؛ كَبَيْعٍ وَهَبَةٍ كَفَى الْإِطْلَاقُ فِي الْأَصَحِّ) وَالثَّانِي: يُشْتَرَطُ التَّقْصِيلُ، فَيَقُولُ فِي الْبَيْعِ: تَعَاقدْنَا بِثَمَنِ مَعْلُومٍ وَنَحْنُ جَائِزًا التَّصَرُّفِ وَتَفَرَّقْنَا عَنْ تَرَاضٍ<sup>(١)</sup>.

(وَمَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ بِحَقِّ (لَيْسَ لَهُ تَحْلِيفُ الْمُدَّعِي) عَلَى اسْتِحْقَاقِهِ؛ لِأَنَّهُ كَطْعَنٍ فِي الشُّهُودِ<sup>(٢)</sup>، (فَإِنْ ادَّعَى أَدَاءً) لَهُ (أَوْ إِبْرَاءً) مِنْهُ (أَوْ شِرَاءً عَيْنٍ) مِنْ مُدَّعِيهَا (أَوْ هِبَتَهَا وَإِقْبَاضَهَا) مِنْهُ (حَلْفَهُ) أَيِ خَصْمِهِ (عَلَى نَفْيِهِ) وَهُوَ أَنَّهُ مَا تَأْدَى مِنْهُ الْحَقُّ وَلَا أَبْرَاهُ مِنْهُ، وَلَا بَاعَهُ الْعَيْنَ وَلَا وَهَبَهُ إِيَّاهَا<sup>(٣)</sup> (وَكَذَا لَوْ ادَّعَى عِلْمَهُ بِفُسْقٍ شَاهِدِهِ أَوْ كَذِبِهِ) فَإِنْ يُحْلِفُهُ عَلَى نَفْيِهِ (فِي الْأَصَحِّ) فَإِنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِذَلِكَ بَطَلَتْ الشَّهَادَةُ، وَالثَّانِي: لَا

---

(١) الدعوى بالعقود المالية هل تقبل بإطلاقها أو لابد من ذكر الشروط: فيها وجهان: الوجه الأول: الأصح أن من رفع دعوى بالعقود المالية كالبيع والإجازة والهبة كفى الإطلاق، لأنه أخف حكمًا من النكاح، ولهذا: لا يشترط فيه الإشهاد، ولابد من وصف الصحة، لأنه مشترط في كل عقد. والوجه الثاني: الإطلاق لا يكفي ويشترط فيه أن يقول: تبايعنا بثلثين معلوم ونحن جائزنا التصرف، وتفرقنا عن تراض.

(٢) من قامت عليه بينة ليس له تحليف المدعى على استحقاق ما ادعاه؛ لقوله تعالى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ)، ولم يوجب اليمين إلا على من أنكر ولا بينة، ولأنه تكليف حجة بعد حجة، بل هو كالطعن في الشهود.

(٣) الإدعاء بالخروج من الحق: فإن ادعى بعد إقامة البينة مسقطا لها من أداء له أو إبراء منه أو شراء عين من مدعيها أو هبتها أو إقباضها منه، حلفه خصمه على نفي ما ادعاه؛ وهو أنه ما تأدى منه الحق ولا أبراه من الدين ولا باعه العين ولا وهبه إياها لاحتمال ما يدعيه، وهذا إذا ادعى حدوث شيء من ذلك بعد قيام البينة ومضى زمن إمكان ما يدعيه من مسقطات الحق، وإلا فلا يلتفت إلى قوله.



يُحْلَفُهُ وَيَكْتَفِي بِظَاهِرِ الْعَدَالَةِ وَتَعْدِيلِ الْمُرَكِّينَ<sup>(١)</sup> (وَإِذَا أُسْتُمِهَلَ) مَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ، (لِيَأْتِيَ بِدَافِعٍ أُمَهْلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) وَقِيلَ: يَوْمًا فَقَطْ<sup>(٢)</sup>.

(وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى دَيْنٍ مُؤَجَّلٍ فِي الْأَصَحِّ) إِذْ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا الْإِزَامُ فِي الْحَالِ، وَالثَّانِي: تُسْمَعُ لِعَرَضِ الثُّبُوتِ وَالثَّلَاثِ: إِنْ كَانَ لَهُ بَيِّنَةٌ تُسْمَعُ لِعَرَضِ التَّسْجِيلِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ لَمْ تُسْمَعِ<sup>(٣)</sup>.

(فَصْلٌ) إِذَا (أَصَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى السُّكُوتِ عَنْ جَوَابِ الدَّعْوَى جُعِلَ كَمُنْكَرٍ نَاكِلٍ) فَتَرَدُّ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي وَعَلَى الْمُتَكَلِّمِ. (فَإِنْ ادَّعَى) عَلَيْهِ (عَشْرَةَ فَقَالَ: لَا تَلْزُمْنِي الْعَشْرَةَ لَمْ يَكْفِ حَتَّى يَقُولَ: وَلَا بَعْضُهَا، وَكَذَا يَحْلِفُ) إِنْ حَلَفَ؛ لِأَنَّ مُدَّعِيَ الْعَشْرَةِ مُدَّعٍ لِكُلِّ جُزْءٍ مِنْهَا فَاشْتَرِطَ

---

(١) إِذَا ادَّعَى الْخَصْمُ عِلْمَ الْمُدَّعَى بِفَسْقِ شَاهِدِهِ أَوْ كَذِبِهِ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ أَوَّلًا فِيهِ وَجْهَانِ: الْأَصَحُّ لَهُ تَحْلِيفُهُ عَلَى نَفْيِ مَا ادَّعَاهُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَقْرَأَ لَهُ بِهِ لَبْطَلَتِ الشَّهَادَةُ. وَالثَّانِي: لَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدَّعِ عَلَيْهِ حَقًّا، وَإِنَّمَا ادَّعَى عَلَيْهِ أَمْرًا لَوْ ثَبَتَ نَفَعَهُ.

(٢) إِذَا طَلَبَ الْإِمْهَالَ مِنْ أَقِيمَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ لِيَأْتِيَ بِدَافِعٍ كَمْ يَمَهْلُ فِيهِ وَجْهَانِ: الْأَوَّلُ: أُمَهْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ؛ لِأَنَّهَا مَدَّةٌ قَرِيبَةٌ لَا يَعْظُمُ فِيهَا الضَّرَرُ، وَمَقِيمُ الْبَيِّنَةِ قَدْ يَحْتَاجُ إِلَى مِثْلِهَا لِلْفَحْصِ عَنِ الشُّهُودِ، الثَّانِي: يَوْمًا فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَتَعَتًّا، وَيَشْبَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي ذَلِكَ إِلَى نَظَرِ الْقَاضِي وَاجْتِهَادِهِ، وَظَاهِرُ عِبَارَتِهِ وَجُوبُ الْإِمْهَالِ.

(٣) الدَّعْوَى بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ فِي سَمَاعِهَا ثَلَاثَةَ أَوْجِهٍ: الْأَوَّلُ: لَا تَسْمَعُ دَعْوَى دَيْنٍ مُؤَجَّلٍ فِي الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا الْإِزَامُ وَمَطَالِبَةٌ فِي الْحَالِ فَيَفُوتُ نِظَامُ الدَّعْوَى. وَهُوَ الرَّاجِحُ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: تَسْمَعُ لِيُثَبَّتَ فِي الْحَالِ وَيُطَالَبَ بِهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، فَقَدْ يَمُوتُ مِنْ عَلَيْهِ فَيَتَعَجَّلُ الطَّلَبُ. وَالْوَجْهُ الثَّلَاثُ: تَسْمَعُ إِنْ كَانَ لَهُ بَيِّنَةٌ لِيُسَجَّلَ فِي أَمْنِ غَيْبَتِهَا وَمَوْتِهَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَلَا. الْمَنْعُ.

مُطَابَقَةُ الْإِنْكَارِ وَالْيَمِينِ دَعْوَاهُ، (فَإِنْ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْعَشْرَةِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فَنَاقِلٌ) عَمَّا دُونَ الْعَشْرَةِ، (فَيَخْلِفُ الْمُدَّعِي عَلَى اسْتِحْقَاقِ دُونَ عَشْرَةٍ بِجُزْءٍ وَيَأْخُذُهُ<sup>(١)</sup>) ، وَإِذَا ادَّعَى مَا لَا مُضَافًا إِلَى سَبَبٍ كَأَقْرَضْتُكَ كَذَا كَفَاهُ فِي الْجَوَابِ: لَا تَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئًا<sup>(٢)</sup> ، أَوْ) ادَّعَى (شُفْعَةً كَفَاهُ) فِي الْجَوَابِ (لَا تَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئًا، أَوْ لَا تَسْتَحِقُّ تَسْلِيمَ الشِّفْعِ) وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِي قَدْ يَكُونُ صَادِقًا وَيَعْرِضُ مَا يُسْقِطُ الْمَدْعَى، وَلَوْ اعْتَرَفَ بِهِ

(١) مطابقة جواب المدعى عليه للدعوى: إِنْ ادَّعَى عَلَيْهِ عَشْرَةٌ مَثَلًا، فَقَالَ فِي جَوَابِهِ: هِيَ عِنْدِي، أَوْ لَيْسَ لَكَ عِنْدِي شَيْءٌ، فَهَذَا جَوَابٌ لِلدَّعْوَى ظَاهِرٌ سَوَاءٌ بِالْإِقْرَارِ أَوْ بِالْإِنْكَارِ، وَإِنْ قَالَ: لَا يَلْزَمُنِي الْعَشْرَةُ لَمْ يَكْفِ فِي الْجَوَابِ حَتَّى يَقُولَ مُضَافًا لِمَا سَبَقَ وَلَا بَعْضُهَا وَيَخْلِفُ إِنْ حَلَفَ الْقَاضِي؛ لِأَنَّ مُدَّعِيَ الْعَشْرَةِ مُدَّعٍ لِكُلِّ جُزْءٍ مِنْهَا، فَاسْتَرْتِطَ أَنْ يُطَابِقَ الْإِنْكَارُ وَالْيَمِينُ

دَعْوَاهُ وَإِنَّمَا يُطَابِقَانِهَا إِنْ نَفَى كُلَّ جُزْءٍ مِنْهَا فَإِنْ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْعَشْرَةِ وَاقْتَصَرَ فِي حَلْفِهِ عَلَيْهِ فَنَاقِلٌ عَمَّا دُونَ الْعَشْرَةِ فَيَخْلِفُ الْمُدَّعِي عَلَى اسْتِحْقَاقِ دُونَ عَشْرَةٍ بِجُزْءٍ وَإِنْ قَلَّ مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدِ دَعْوَى وَيَأْخُذُ مَا دُونَ الْعَشْرَةِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الدَّعْوَى ، وَالنُّكُولُ مَعَ الْيَمِينِ كَالْإِقْرَارِ ، نَعَمْ إِنْ نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنِ الْعَشْرَةِ وَقَدْ اقْتَصَرَ الْقَاضِي فِي تَخْلِيفِهِ عَلَى عَرْضِ الْيَمِينِ عَلَى الْعَشْرَةِ فَقَطْ لَمْ يَخْلِفِ الْمُدَّعِي عَلَى اسْتِحْقَاقِ مَا دُونَ الْعَشْرَةِ إِلَّا بَعْدَ تَجْدِيدِ دَعْوَى وَنُكُولِ الْخَصْمِ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا نَكَلَ عَنْهَا فَلَا يَكُونُ نَاكِلًا عَنْ بَعْضِهَا.

(٢) جواب المدعى عليه في دعوى القرض:

إذا ادعى ما لا مضافاً إلى سبب كأقترضتك كذا كفاه في الجواب على هذه الدعوى: لا تستحق أنت علي شيئاً أو لا يلزمني تسليم شيء إليك؛ لأن المدعي قد يكون صادقاً في الإقراض وعرض ما يقتضي إسقاطه من أداء أو إبراء، فلو نفى السبب كذب، أو اعترف به وادعى المسقط طوالب ببينة، وقد يعجز عنها فيقبل الإطلاق للضرورة.

وَادَّعَى الْمُسْقِطَ طَوْلِبَ بِالْبَيِّنَةِ وَقَدْ يَعْجِزُ عَنْهَا، فَدَعَتْ الْحَاجَّةُ إِلَى قَبُولِ الْجَوَابِ الْمُطْلَقِ<sup>(١)</sup>، (وَيُخْلِفُ عَلَى حَسَبِ جَوَابِهِ هَذَا) وَلَا يَكْلَفُ التَّعَرُّضَ لِنَفْيِ الْجِهَةِ (فَإِنْ أَجَابَ بِنَفْيِ السَّبَبِ الْمَذْكُورِ حَلَفَ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: لَهُ حَلَفٌ بِالنَّفْيِ الْمُطْلَقِ) كَمَا لَوْ أَجَابَ بِهِ، وَالْأَوَّلُ رَاعَى مُطَابَقَةَ الْيَمِينِ لِلْجَوَابِ<sup>(٢)</sup>، (وَلَوْ كَانَ بِيَدِهِ مَرُهُونٌ أَوْ مُكْرَى وَادَّعَاهُ مَالِكُهُ كَفَاهُ) فِي الْجَوَابِ (لَا يَلْزُمُنِي تَسْلِيمُهُ) وَلَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لِلْمَلِكِ (فَلَوْ اعْتَرَفَ بِالْمَلِكِ وَادَّعَى الرَّهْنَ وَالْإِجَارَةَ، فَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ لَا يَقْبَلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ)، وَالثَّانِي: يَقْبَلُ قَوْلُهُ بِدُونِهَا (فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا) عَلَى الْأَوَّلِ (وَخَافَ أَوَّلًا إِنْ اعْتَرَفَ

---

(١) إِذَا ادَّعَى عَلَيْهِ شُفْعَةً كَفَاهُ فِي الْجَوَابِ لَا تَسْتَحِقُّ أَنْتَ عَلَيَّ شَيْئًا أَوْ، وَلَا نَظَرَ لِكُونِ الْعَامَّةِ لَا يَعْدُونَ الشُّفْعَةَ مُسْتَحَقَّةً عَلَى الْمُشْتَرِي أَوْ لَا تَسْتَحِقُّ تَسْلِيمَ الشَّقْصِ وَلَا يُشْتَرِطُ التَّعَرُّضُ لِنَفْيِ تِلْكَ الْجِهَةِ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ يُصَدِّقُ فِيهَا وَلَكِنْ عَرَضَ مَا أَسْقَطَ الْحَقَّ مِنْ نَحْوِ آدَاءٍ أَوْ إِبْرَاءٍ أَوْ إِعْسَارٍ أَوْ عَفْوٍ فَإِنْ نَفَاهَا كُذِّبَ وَإِنْ أَقَرَّ بِهَا لَمْ يَجِزْ بَيِّنَةً فَاقْتَضَتْ.

(٢) حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عِنْدَ الْإِنْكَارِ: وَيُخْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى حَسَبِ جَوَابِهِ هَذَا لِيُطَابِقَ الْحَلْفُ وَالْجَوَابُ، فَإِنْ أَجَابَ بِنَفْيِ السَّبَبِ الْمَذْكُورِ حَلَفَ عَلَيْهِ؛ لِيُطَابِقَ الْيَمِينُ الْجَوَابَ وَقِيلَ: لَهُ حَلَفٌ بِالنَّفْيِ الْمُطْلَقِ كَمَا لَوْ أَجَابَ بِهِ وَيَرُدُّهُ وَضُوحُ الْفَرْقِ أَوْ بِالطَّلَاقِ فَكَذَلِكَ وَلَا يَكْلَفُ التَّعَرُّضَ لِنَفْيِ السَّبَبِ فَإِنْ تَعَرَّضَ لَهُ جَارَ لَكِنْ لَوْ أَقَامَ الْمُدَّعَى بَيْنَهُ بِهِ، لَمْ تَسْمَعْ بَيِّنَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِآدَاءٍ أَوْ إِبْرَاءٍ؛ لِأَنَّهَا تَثَبَتِ الْحَقَّ وَقَدْ نَفَاهُ أَوَّلًا، وَعَلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى دَيْنًا وَهُوَ مُوجَّلٌ وَلَمْ يَذْكُرْ الْأَجَلَ كَفَى الْجَوَابُ بِمَا يَلْزُمُنِي تَسْلِيمُهُ الْآنَ وَيُخْلِفُ عَلَيْهِ، وَلَوْ ادَّعَى عَلَى مَنْ حَلَفَ لَا يَلْزُمُنِي تَسْلِيمُ شَيْءٍ إِلَيْكَ بَأَنَّ حَلْفَكَ إِنَّمَا كَانَ لِإِعْسَارٍ وَالْآنَ أَيْسَرْتُ سَمِعْتُ دَعْوَاهُ وَيُخْلِفُ لَهُ مَا لَمْ تَتَكَرَّرْ دَعْوَاهُ بِحَيْثُ يَظُنُّ مِنْهُ التَّعْنُّتُ.

بِالْمَلِكِ) لِلْمُدَّعِي (جَحْدُهُ) بِسُكُونِ الْحَاءِ (الرَّهْنُ وَالْإِجَارَةُ فَحِيلَتُهُ أَنْ يَقُولَ) فِي الْجَوَابِ (إِنْ ادَّعَيْتَ مِلْكًا مُطْلَقًا فَلَا يُلْزِمُنِي تَسْلِيمُ) لِمُدَّعَاكَ، (وَإِنْ ادَّعَيْتَ مَرْهُونًا فَادْكُرْهُ لِأُجِيبَ) ، وَكَذَا يُقَالُ فِي الْمُوجَرِ <sup>(١)</sup>.

(وَإِذَا ادَّعَى عَلَيْهِ عَيْنًا) عَقَارًا أَوْ مَنْقُولًا (فَقَالَ: لَيْسَ هِيَ لِي، أَوْ هِيَ لِرَجُلٍ لَا أَعْرِفُهُ، أَوْ لِابْنِي الطِّفْلِ، أَوْ وَقَفْتُ عَلَى الْفُقَرَاءِ، أَوْ مَسَجِدٍ كَذَا، فَالْأَصَحُّ: أَنَّهُ لَا تَنْصَرِفُ الْخُصُومَةُ) عَنْهُ (وَلَا تُنَزَعُ) الْعَيْنُ، (مِنْهُ، بَلْ يَحْلِفُ الْمُدَّعِي أَنَّهُ لَا يُلْزِمُهُ التَّسْلِيمُ) لِلْعَيْنِ (إِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةً) بِهَا، (وَالثَّانِي: تَنْصَرِفُ عَنْهُ وَيُنْتَزَعُ الْحَاكِمُ الْعَيْنَ مِنْ يَدِهِ، فَإِنْ أَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً عَلَى اسْتِحْقَاقِهَا أَخَذَهَا، وَإِلَّا حَفِظَهَا إِلَى أَنْ يَظْهَرَ مَالِكُهَا، وَفِي وَجْهِ فِي الْأَوَّلَيْنِ: تُسَلِّمُ الْعَيْنُ لِلْمُدَّعِي إِذْ لَا مُزَاحِمَ لَهُ <sup>(٢)</sup>، (وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ)

(<sup>١</sup>) وَإِذَا كَانَ بِيَدِهِ مَرْهُونٌ أَوْ مُكْرَى وَادَّعَاهُ مَالِكُهُ أَوْ نَائِبُهُ كَفَّاهُ فِي الْجَوَابِ: لَا يُلْزِمُنِي تَسْلِيمُهُ إِلَيْكَ؛ لِأَنَّهُ جَوَابٌ مُفِيدٌ وَلَا يُلْزِمُهُ التَّعَرُّضُ لِلْمَلِكِ، فَلَوْ اعْتَرَفَ الْمُدَّعِي عَلَيْهِ بِالْمَلِكِ لِلْمُدَّعَى، وَادَّعَى أَنْ الْعَيْنَ تَحْتَ يَدِهِ بِالرَّهْنِ أَوْ الْإِجَارَةِ، وَكَذَّبَهُ الْمُدَّعِي، فَفِيهِ وَجْهَانِ:

الصَّحِيحُ: أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ فِي دَعْوَى الرَّهْنِ وَالْإِجَارَةِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُمَا، الْوَجْهَ الثَّانِي: يَقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ادِّعَائِهِ بِأَنَّ الْعَيْنَ تَحْتَ يَدِهِ بِالرَّهْنِ وَالْإِجَارَةِ بَدُونِ بَيِّنَةٍ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ فِي يَدِهِ. فَإِنْ عَجَزَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنِ الْبَيِّنَةِ، وَخَافَ أَوَّلًا إِنْ اعْتَرَفَ بِالْمَلِكِ لِلْمُدَّعَى جَحْدَهُ الرَّهْنِ أَوْ الْإِجَارَةَ فَحِيلَةُ الْمُدَّعَى: أَنْ يَقُولَ فِي الْجَوَابِ: إِنْ ادَّعَيْتَ مِلْكًا مُطْلَقًا عَنْ رَهْنٍ وَإِجَارَةٍ، فَلَا يُلْزِمُنِي تَسْلِيمُ مَا ادَّعَيْتَهُ عَلَيَّ، وَإِنْ ادَّعَيْتَ عَلَيَّ مِلْكًا مَرْهُونًا عِنْدِي أَوْ مُوجَرًا عِنْدِي فَادْكُرْهُ لِأُجِيبَ عَنْهُ.

(<sup>٢</sup>) إِذَا ادَّعَى شَخْصٌ عَلَى آخَرٍ عَلَيْهِ عَيْنًا عَقَارًا أَوْ مَنْقُولًا، فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الْجَوَابِ: لَيْسَ هِيَ لِي مُقْتَصِرًا عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يُضِفْهُ لَشَخْصٍ بَعِينِهِ، أَوْ أَضَافَهَا

أَيِّ بِالْمَذْكُورِ (لِمُعَيَّنٍ حَاضِرٍ يُمَكِّنُ مُخَاصَمَتَهُ وَتَخْلِيفُهُ سِئْلَ فَإِنْ صَدَّقَهُ صَارَتْ الْخُصُومَةُ مَعَهُ، وَإِنْ كَذَّبَهُ تُرِكَ فِي يَدِ الْمُقَرَّرِ) كَمَا تَقَدَّمَ تَصْحِيحُهُ فِي كِتَابِ الْإِفْرَارِ، (وَقِيلَ: يُسَلَّمُ إِلَى الْمُدَّعَى وَقِيلَ: يَحْفَظُهُ الْحَاكِمُ لظُهُورِ مَالِكٍ) لَهُ<sup>(١)</sup>، (وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ لِعَائِبٍ، فَأَلْصَحُّ: انْصِرَافُ الْخُصُومَةِ عَنْهُ، وَيُوقَفُ الْأَمْرُ حَتَّى يَتَقَدَّمَ الْعَائِبُ، فَإِنْ كَانَ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ قَضَى بِهَا،

لشخص مجهول كقولهِ وَهِيَ لِرَجُلٍ لَا أَعْرِفُهُ أَوْ لَا أَسْمِيهِ أَوْ لِمَعْلُومٍ لَا يُمَكِّنِي مُخَاصَمَتَهُ وَتَخْلِيفُهُ كَقَوْلِهِ: هِيَ لِابْنِي الطِّفْلِ أَوْ الْمَجْنُونِ مَلِكٌ لَهُ، وَلَوْ عَبَّرَ بِمَحْجُورِهِ كَانَ أَوْلَى أَوْ قَالَ هِيَ وَقَفَتْ عَلَى الْفُقَرَاءِ، أَوْ عَلَى مَسْجِدٍ كَذَا وَكَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هُوَ النَّاطِرُ، فِيهَا وَجْهَانِ: الْأَصَحُّ: أَنَّهُ لَا تَنْصَرِفُ الْخُصُومَةُ عَنْهُ وَلَا تَنْتَرَعُ الْعَيْنُ مِنْهُ، لِأَنَّ ظَاهِرَ الْيَدِ لِلْمَلِكِ وَمَا صَدَرَ مِنْهُ لَيْسَ بِمُزِيلٍ وَلَمْ يَظْهَرْ لِعَيْنِهِ اسْتِحْقَاقُ بَلٍ يُخْلَفُ الْمُدَّعِي أَنَّهُ لَا يَلْزُمُهُ التَّسْلِيمُ لِلْعَيْنِ الْمُدَّاعَاةَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَيِّنَةٌ بِهَا رَجَاءٌ أَنْ يُعَرَّ أَوْ يَنْكُلَ فَيُخْلَفَ الْمُدَّعِي وَتَثَبَّتْ لَهُ الْعَيْنُ فِي الْأَوَّلَيْنِ، وَفِيمَا لَوْ أَصَافَهَا لِعَيْنٍ مُعَيَّنٍ، وَالْبَدَلُ لِلْحَيْلُولَةِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ، وَالْوَجْهَ الثَّانِي: تَنْصَرِفُ عَنْهُ وَيَنْتَرَعُ الْحَاكِمُ الْعَيْنَ مِنْ يَدِهِ، فَإِنْ أَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً عَلَى اسْتِحْقَاقِهَا أَخَذَهَا، وَإِلَّا حَفِظَهَا إِلَى أَنْ يَظْهَرَ مَالِكُهَا.

(١) جواب الدعوى عن العقار والمنقول لمعين: إذا أقر المدعى عليه بالمدعى به لمعين حاضر، فالمعين إما أن يقر بذلك أو ينكر: أولاً: إِنْ أَقَرَّ المدعى عليه بالمدعى به لِمُعَيَّنٍ حَاضِرٍ بِالْبَلَدِ يُمَكِّنُ مُخَاصَمَتَهُ وَتَخْلِيفُهُ، سِئْلَ عَنْ ذَلِكَ فَإِنْ صَدَّقَ المعين المدعى عليه، صَارَتْ الْخُصُومَةُ مَعَهُ، لِصَيْرُورَةِ الْيَدِ لَهُ، وَالْخُصُومَةُ إِنَّمَا تَدُورُ بَيْنَ مُتَنَازِعِينَ، وَتَقْيِيدُهُ بِإِمْكَانِ مُخَاصَمَتِهِ لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا أَقَرَّ بِهِ لِمَنْ لَا تُمَكِّنُ مُخَاصَمَتَهُ وَهُوَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لَا تَنْصَرِفُ الْخُصُومَةُ عَنْهُ، بَلْ تَنْصَرِفُ عَنِ المدعى عليه لَوْلِيِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ.

ثانياً: وَإِنْ كَذَّبَهُ فِيهِ ثَلَاثَةٌ أَوْجَهَ: الْوَجْهَ الْأَوَّلُ: الْأَصَحُّ تُرِكَ فِي يَدِ الْمُقَرَّرِ. وَقِيلَ: يُسَلَّمُ إِلَى الْمُدَّعِي إِذْ لَا طَالِبَ لَهُ سِوَاهُ. وَقِيلَ: يَحْفَظُهُ الْحَاكِمُ لظُهُورِ مَالِكِهِ.

وَهُوَ قَضَاءٌ عَلَى غَائِبٍ فَيُخْلَفُ مَعَهَا وَقِيلَ: عَلَى حَاضِرٍ) إِذْ الْخُصُومَةُ مَعَهُ فَلَا يَخْلِفُ مَعَهَا، وَصَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ فَلَهُ تَحْلِيفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَلْزِمُهُ تَسْلِيمُهُ إِلَيْهِ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُدَّعَى وَأَخَذَهُ، وَإِذَا عَادَ الْغَائِبُ وَصَدَّقَ الْمُقَرَّرَ رَدَّ إِلَيْهِ بِلَا حُجَّةٍ؛ لِأَنَّ الْيَدَ لَهُ بِإِقْرَارِ صَاحِبِ الْيَدِ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الْمُدَّعَى <sup>(١)</sup> الْخُصُومَةَ مَعَهُ.

---

(١) جواب الدعوى لغائب: إن أقر المدعى عليه بالمدعى به لغائب عن البلد ولا بينة تشهد له بملكه، فالأصح: انصراف الخصومة عن المدعى عليه، ويوقف الأمر حتى يقدم الغائب، لأن المال بظاهر إقرار المدعى عليه لغيره؛ بدليل: أن الغائب لو قدم وصدقه أخذه.

والثاني: لا تتصرف الخصومة عن المدعى عليه؛ لأن المال في يده، والظاهر: أنه له، فلا يمكن من صرف الخصومة عنه بالإضافة إلى غائب قد يرجع وقد لا يرجع، ويخالف: ما إذا أضاف إلى صبي أو مجنون؛ فإن هناك يمكن مخاصمة وليه. فإن كان للمدعي بينة قضي بها، وهو قضاء على غائب، فيحلف المدعى مع البينة؛ لأن المال صار له بحكم الإقرار. وقيل: هو قضاء على حاضر فلا يحلف مع البينة؛ لأن الدعوى توجهت إليه فيوجه القضاء عليه.

وإن لم يكن للمدعي بينة فله تحليف المدعى عليه، أنه لا يلزمه تسليمه إليه، فإن نكل، حلف المدعي وأخذ المال من يده، ثم إذا عاد الغائب وصدق المقر رد المال عليه بلا حجة؛ لأن اليد له بإقرار صاحب اليد، ثم يستأنف المدعي الخصومة معه؛ هذا كله إذا لم يقر المدعى عليه بينة أن المال للغائب، فإن أقامها.. نظر إن ادعى أنه وكيل من جهة الغائب وأثبت الوكالة.. فبينته على أن المال للغائب مسموعة مرجحة على بينة المدعي، وإن لم تثبت الوكالة، فأوجه؛ أصحها: لا تسمع بينته؛ لأنه ليس بمالك ولا نائب.

فَصَلِّ (تُغْلِظُ يَمِينُ مُدَّعٍ وَمُدَّعَى عَلَيْهِ فِيمَا لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا يُقْصَدُ بِهِ مَالٌ) ، كَدَعَوَى دَمٍ وَنِكَاحٍ وَطَلَاقٍ وَرَجْعَةٍ وَإِلْءٍ وَعِنَقٍ وَوَلَاءٍ وَوَصَايَةٍ وَوَكَالَةٍ (وَفِي مَالٍ يَبْلُغُ نِصَابَ زَكَاةٍ) عِشْرِينَ مِثْقَالًا ذَهَبًا أَوْ مِائَتِي دِرْهَمٍ فِضَّةً وَلَا تَغْلِظُ فِيمَا دُونَهُ إِلَّا أَنْ يَرَاهُ الْقَاضِي لِحُجْرَةٍ فِي الْحَالِفِ فَلَهُ ذَلِكَ، بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ: أَنَّ التَّغْلِظَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى طَلَبِ الْخَصْمِ، (وَسَبَقَ بَيَانُ التَّغْلِظِ فِي) كِتَابِ (الْلِّعَانِ) بِرَمَانٍ؛ وَهُوَ بَعْدَ عَصْرِ جُمُعَةٍ، وَمَكَانٍ؛ كَعِنْدَ مَنْبَرِ الْجَامِعِ فَيَأْتِي هُنَا، وَالتَّغْلِظُ بِهِمَا مُسْتَحَبٌّ، وَكَذَا بِزِيَادَةِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ هُنَا كَذَلِكَ كَأَنْ يَقُولَ: وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَعْلَمُ مِنَ السِّرِّ مَا يَعْلَمُ مِنَ الْعَلَانِيَةِ، فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ: وَاللَّهِ كَفَى، (وَيُخْلِفُ عَلَى النَّبْتِ فِي فِعْلِهِ) إِثْبَاتًا كَانَ أَوْ نَفْيًا؛ لِأَنَّهُ يَعْلَمُ حَالَ نَفْسِهِ، (وَكَذَا فِعْلٍ غَيْرِهِ) أَيِ عَلَى النَّبْتِ (إِنْ كَانَ إِثْبَاتًا) لِأَنَّهُ يَسْهُلُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ، (وَإِنْ كَانَ نَفْيًا فَعَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ) أَيِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُهُ؛ لِأَنَّهُ يَعْسُرُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ<sup>(١)</sup>.

---

(١) يَنْدُبُ تَغْلِظُ يَمِينُ مُدَّعٍ وَهِيَ الْيَمِينُ الْمُرْدُودَةُ، أَوْ مَعَ الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ، وَيَنْدُبُ أَيْضًا تَغْلِظُ يَمِينِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِيمَا لَيْسَ بِمَالٍ، وَلَا يُقْصَدُ بِهِ مَالٌ، كَدَعَوَى دَمٍ وَنِكَاحٍ وَطَلَاقٍ وَرَجْعَةٍ وَلِّعَانٍ وَإِلْءٍ وَوَصَايَةٍ وَوَكَالَةٍ وَوِلَادَةٍ وَرِضَاعٍ وَعُيُوبِ نِسَاءٍ، وَلَيْسَ قَبُولُ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِيهَا مَنفَرَدَاتٌ لِقَلَّةِ خَطَرِهَا، بَلْ لِأَنَّ الرِّجَالَ لَا يَطْلَعُونَ عَلَيْهَا غَالِبًا وَالْمَعْنَى فِي التَّغْلِظِ أَنَّ الْيَمِينَ مَوْضُوعَةً لِلرَّجْرِ عَنِ التَّعَدِّيِّ، فَشَرَعَ التَّغْلِظُ مُبَالَعَةً وَتَأَكِيدًا لِلرَّدْعِ، فَاخْتَصَّ بِمَا هُوَ مُتَأَكَّدٌ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ كَهَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ .

التغليظ في المال:

(وَلَوْ ادَّعَى دَيْنًا لِمُورَثِهِ فَقَالَ: أَبْرَأْنِي حَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِالْبَرَاءَةِ) وَهُوَ حَلَفٌ عَلَى نَفْيِ فِعْلٍ غَيْرِهِ<sup>(١)</sup> (وَلَوْ قَالَ جَنَى عَبْدُكَ عَلَيَّ بِمَا يُوجِبُ، كَذَا فَأَلْصَحُ حَلْفُهُ عَلَى النَّبْتِ) لِأَنَّ عَبْدَهُ مَالُهُ وَفِعْلُهُ كَفِعْلِهِ، وَالثَّانِي: يُنْظَرُ إِلَى أَنَّهُ فِعْلٌ غَيْرُهُ.

(قُلْتُ) أَخَذًا مِنْ الرَّافِعِيِّ فِي الشَّرْحِ (وَلَوْ قَالَ: جَنَتَ بِهِمُتُكَ حَلَفَ عَلَى النَّبْتِ قَطْعًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ) لِأَنَّ ضَمَانَ جِنَائِيَّتِهَا بِتَقْصِيرِهِ فِي حِفْظِهَا لَا بِفِعْلِهَا.

(وَيَجُوزُ النَّبْتُ) فِي الْحَلْفِ (بِظَنٍّ مُؤَكَّدٍ يَعْتَمِدُ خَطُّهُ أَوْ خَطُّ أَبِيهِ) وَتَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ جَوَازُ الْحَلْفِ اعْتِمَادًا عَلَى خَطِّ مُورَثِهِ إِذَا وَثِقَ بِخَطِّهِ وَأَمَانَتِهِ، وَنُقِلَ الشَّيْخَيْنِ عَنِ الشَّامِلِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْحَلْفُ اعْتِمَادًا عَلَى

---

وَيَغْلُظُ الْيَمِينِ فِي مَالٍ يَبْلُغُ نِصَابَ زَكَاةٍ، أَوْ لَا فِي الْقَلِيلِ وَهُوَ مَا دُونَ النِّصَابِ، إِلَّا أَنْ يَرَى الْقَاضِي التَّغْلِيظَ بَجَرَّةٍ فِي الْحَالِفِ فَلَهُ، التَّغْلِيظُ بِالْمَكَانِ فِي الْمَسْجِدِ وَبِالزَّمَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَحُضُورَ جَمْعٍ، وَالصَّوَابُ أَنَّهُ لَا يَغْلُظُ بِالْجَمْعِ هُنَا، وَيَنْدُبُ التَّغْلِيظَ بِزِيَادَةِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ: بِأَنْ يَقُولَ: وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ وَالْعَلَانِيَةَ، وَيَنْدُبُ وَضْعَ الْمَصْحَفِ فِي حَجَرِ الْحَالِفِ، وَيَحْلِفُ عَلَى الْقَطْعِ، فِي فِعْلِهِ، أَيْ نَفْيًا كَانَ أَوْ إِثْبَاتًا، لِأَنَّهُ يَعْلَمُ حَالَ نَفْسِهِ.

(١) لو ادعى على شخص دينًا لمورثه فقال المدعى عليه: أبرأني منه المورث قبل وفاته أو استوفاه أو أحوال به، حلف المدعى على نفي العلم بالبراءة ونحوها؛ لأنه حلف على نفي فعل الغير، ولا بد أن يضم إلى الدعوى: وأنت تعلم أنه أبرأني منه ونحوه.



خَطَّهُ حَتَّى يَتَذَكَّرَ ، (وَتُغْتَبَرُ نِيَّةُ الْقَاضِي الْمُسْتَخْلَفِ) لِلْخَصْمِ <sup>(١)</sup> (فَلَوْ وَرَى أَوْ تَأَوَّلَ خِلَافَهَا أَوْ اسْتَتْنَى بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُ الْقَاضِي لَمْ يَدْفَعْ) ذَلِكَ (إِثْمَ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ) وَفِي ذَلِكَ حَدِيثُ مُسْلِمٍ: «الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَخْلَفِ» حُمِلَ عَلَى الْقَاضِي <sup>(٢)</sup> ، قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: إِذَا حَلَفَ الْإِنْسَانُ

---

(١) تعتبر نية القاضي المستخلف؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَخْلَفِ"

قال الإمام النووي، رضي الله عنه: هذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف القاضي. فإذا ادعى رجل على رجل حقاً، فحلفه القاضي، فحلف وورى فنوى غير ما نوى القاضي - انعقدت يمينه على ما نواه القاضي. ولا تنفعه التورية. وهذا مجمع عليه، ولأنه لو اعتبر نية الحالف، لبطلت فائدة الأيمان وضاعت الحقوق؛ إذ كل أحد يحلف على ما يقصد. وإنما قال: القاضي المستخلف، ولم يقل: المستخلف؛ ليخرج ما لو حلفه الغريم أو غيره، فإن العبرة بنية الحالف، وكذا لو حلف هو بنفسه ابتداءً.

(٢) إذا خالف الحالف في نيته أو تأوَّلَ خلاف نية القاضي أو استتنى بحيث لا يسمع القاضي، فعليه إثم اليمين الفاجرة، لأن اليمين شرعت ليهاب الخصم الإقدام عليها خوفاً من الله، فلو صح تأويله بطلت هذه الفائدة، لأن كل شيء قابل للتأويل في اللغة، ويأثم الحالف في مخالفته للقاضي مقيد بقيدتين: الأولى: إذا كان الحلف بالله؛ فإن حلفه القاضي بالطلاق أو العتاق فحلف، نفعته التورية؛ لأنه ليس للقاضي التحليف بغير الله. الثاني: أن لا المدعى يكون ظالماً في نفس الأمر ومثله: لو ادعى على معسر فقال المدعى عليه: لا يستحق علي، وتأوله باستحقاق التسليم الآن، صح، ولا يؤاخذ بيمينه؛ لعدم قدرته على التسليم، بل خصمه ظالم بمطالبته إن علم ومخطئ إن جهل، فلا أثم إذا قدر على التورية. جمع المصنف بين التورية والتأويل؛ لأن التورية: قصد ما يخالف ظاهره اللفظ، والتأويل: اعتقاد خلافه، فمن التورية أن يقول: ماله على درهم ولا دينار، فدرهم: قبيلة، ودينار: رجل معروف، وما له قبلي

ابْتِدَاءً أَوْ حَلْفَهُ غَيْرُ الْقَاضِي مِنْ قَاهِرٍ أَوْ خَصْمٍ أَوْ غَيْرِهِمَا فَلَا عِتْبَارُ  
بِنِيَّةِ الْحَالِفِ وَتَنْفَعُهُ التَّوْرِيَةُ<sup>(١)</sup>.

(وَمَنْ تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ يَمِينٌ) فِي دَعْوَى فِي الْمُحَرَّرِ وَالرَّوَضَةِ وَأَصْلُهَا بَدَلُ  
يَمِينٍ دَعْوَى، (لَوْ أَقَرَّ بِمَطْلُوبِهَا لَزِمَهُ فَأَنْكَرَ حَلَفَ<sup>(٢)</sup>) لِحَدِيثِ: «الْبَيِّنَةُ  
عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» وَرَوَاهُ النَّبْهَقِيُّ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ  
حَدِيثُ: «الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ»، (وَلَا يَخْلِفُ قَاضٍ عَلَى تَرْكِهِ الظُّلْمَ

---

ثوب ولا شقة ولا قميص، فالثوب: الرجوع، والشقة: البعد، والقميص: غشاء القلب.  
والاستثناء أن يقول عقب اليمين: إن شاء الله، إما سرًّا أو ينويه بقلبه، وتعتقد اليمين  
في الجميع. وأحترز بقوله: (بحيث لا يسمع القاضي) عما إذا سمع .. فإن اليمين لا  
تعتقد قطعًا، وعليه الإعادة؛ لأنه طلب منه يمينًا جازمة ولم يأت بها. قال النووي في  
شرح مسلم: التورية في غير تحليف الحاكم وإن كان لا يحنث بها لا يجوز فعلها؛  
حيث يبطل

بها حق المستحق بالإجماع.

(١) يجوز للمدعى عليه التورية في يمينه، إذا حلف ابتداء من نفسه أو إذا حلفه غير  
القاضي من قاهر أو خصم، أو حلفه القاضي بغير الله، كأن حلفه بطلاق ونحوه،  
وتنفعه التورية وإن حرمت، حيث يبطل بها حق مستحق، فنفعها من حيث عدم انعقاد  
اليمين.

(٢) ومن وجبت عليه يمين وألزم بها في دعوى صحيحة، فإن أقر بما فيها لزمه ما  
أقر به، إن أنكر حلف، لقوله عليه الصلاة والسلام: "وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ".

فِي حُكْمِهِ، وَلَا شَاهِدٌ أَنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ) فِي شَهَادَتِهِ؛ لِأَنَّ مَنْصِبَهُمَا يَأْبَى ذَلِكَ<sup>(١)</sup>.

(وَلَوْ قَالَ مُدَّعَى عَلَيْهِ: أَنَا صَبِيٌّ) وَهُوَ مُحْتَلَمٌ (لَمْ يَخْلِفْ وَوَقَفَ) الْأَمْرُ (حَتَّى يَبْلُغَ) فَيُدَّعَى عَلَيْهِ<sup>(٢)</sup>.

(وَالْيَمِينُ تَقِيدُ قَطْعَ الْخُصُومَةِ فِي الْحَالِ لَا بَرَاءَةً فَلَوْ حَلَفَهُ ثُمَّ أَقَامَ بَيِّنَةً) بِمُدَّعَاهُ (حُكْمَ بِهَا) لِمَا ذَكَرَ<sup>(٣)</sup>، (وَلَوْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) الَّذِي طَلَبَ الْمُدَّعَى تَحْلِيْفَهُ (قَدْ حَلَفَنِي مَرَّةً) عَلَى مَا ادَّعَاهُ عِنْدَ قَاضٍ (فَلْيُخْلِفْ أَنَّهُ لَمْ يُحْلِفْنِي) عَلَيْهِ، (مُكِّنَ) مِنْ ذَلِكَ (فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّ مَا قَالَهُ مُحْتَمَلٌ غَيْرُ مُسْتَبْعَدٍ، وَالثَّانِي: الْمَنْعُ؛ إِذْ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَدَّعِيَ الْمُدَّعَى أَنَّهُ حَلَفَهُ

---

(١) وَلَا يَخْلِفُ قَاضٍ عَلَى تَرْكِهِ الظُّلْمَ فِي حُكْمِهِ، وَلَا يَحْلِفُ شَاهِدٌ أَنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ فِي شَهَادَتِهِ، لِارْتِفَاعِ مَنْصِبَيْهِمَا عَلَى ذَلِكَ.

(٢) وَلَوْ قَالَ مُدَّعَى عَلَيْهِ: أَنَا صَبِيٌّ وَالْوَقْتُ يَحْتَمِلُ ذَلِكَ لَمْ يَخْلِفْ، لِأَنَّ يَمِينَهُ تُنْبِئُ صِبَاهُ وَالصَّبِيَّ لَا يَخْلِفُ، وَوَقَفَ الْأَمْرُ حَتَّى يَبْلُغَ ثُمَّ يَدَّعَى عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ لَوْ أَقَرَّ بِالْبُلُوغِ فِي وَقْتِ اخْتِمَالِهِ قَبْلَ، وَمِنْ ثَمَّ ادَّعَى أَنَّ هَذِهِ مِنَ الْمُسْتَشْتَبَاتِ مِنَ الصَّابِطِ، نَعَمْ لَوْ سُبِيَ كَافِرٌ فَأَنْبَتَ فَادَّعَى اسْتِعْجَالَ الْإِنْبَاتِ بِدَوَاءٍ حَلَفَ، فَإِنْ نَكَلَ قُتِلَ.

(٣) أَلْيَمِينُ تَقِيدُ قَطْعَ الْخُصُومَةِ فِي الْحَالِ وَلَا تَقِيدُ بَرَاءَةَ ذِمَّةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ خَالِفًا بِالْخُرُوجِ مِنْ حَقِّ صَاحِبِهِ، كَأَنَّهُ عَلِمَ كَذِبَهُ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ لَا تَوْجِبُ الْبَرَاءَةَ، فَلَوْ حَلَفَهُ ثُمَّ أَقَامَ بَيِّنَةً بِمُدَّعَاهُ أَوْ شَاهِدًا لِيَخْلِفَ مَعَهُ حُكْمَ بِهَا. وَكَذَا لَوْ رُدَّتِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى فَتَكَلَّ ثُمَّ أَقَامَ بَيِّنَةً، وَالْحَصْرُ فِي خَبَرِ «شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ لَيْسَ لَكَ إِلَّا ذَلِكَ»، إِنَّمَا هُوَ حَصْرٌ لِحَقِّهِ فِي النَّوْعَيْنِ: أَيْ لَا ثَالِثَ لِهُمَا. وَأَمَّا مَنْعُ جَمْعِهِمَا فَلَا دَلَالََةَ لِلْخَبَرِ عَلَيْهِ، وَقَدْ لَا تُعِيدُهُ الْبَيِّنَةُ وَشَمَلُ إِطْلَاقِهِ الْبَيِّنَةُ: الْحُجَّةُ الْكَامِلَةُ، وَكَذَا الشَّاهِدُ الْوَاحِدُ إِذَا حَلَفَ مَعَهُ.

عَلَى أَنَّهُ مَا حَلَفَهُ، وَهَكَذَا فَيَدُورُ الْأَمْرُ وَلَا يَنْفَصِلُ. وَأُجِيبَ بِعَدَمِ سَمَاعِ ذَلِكَ مِنَ الْمُدَّعِي لِئَلَّا يَتَسَلَّلَ<sup>(١)</sup>.

(وَإِذَا نَكَلَ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنِ الْحَلِفِ الْمَطْلُوبِ مِنْهُ (حَلَفَ الْمُدَّعِي) لِتَحْوُلِ الْحَلِفِ إِلَيْهِ (وَقُضِيَ لَهُ، وَلَا يُقْضَى) لَهُ (بِنُكُولِهِ) أَيِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى طَالِبِ الْحَقِّ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ (وَالنُّكُولُ أَنْ يَقُولَ: أَنَا نَاكِلٌ أَوْ يَقُولَ لَهُ الْقَاضِي احْلِفْ فَيَقُولَ: لَا أَحْلِفُ) فَقَوْلُهُ هَذَا نُكُولٌ<sup>(٢)</sup> (فَإِنْ سَكَتَ حَكَمَ

---

(١) ادعاء المدعى عليه سبق تحليفه وطلب اليمين من المدعى على ذلك: فيه وجهان: إذا قال المدعى عليه الذي طلب تحليف: قد حلفني المدعى مرة قبل ذلك أمام قاض، فليحلف أنه لم يحلفني، مكن في الأصح، لأن ما قاله محتمل غير مستبعد. والوجه الثاني: لا يحلف المدعى على ما يدعيه المدعى عليه من سبق تحليفه؛ لأنه لا يؤمن أن يدعي المدعي أنه حلفه على أنه ما حلفه، وهكذا فيدور. وأجاب الأول عن هذا: بمنع إجابة المدعي إلى ما ذكر المدعى عليه، لإفضاء ذلك إلى التسلسل، هذا كله إذا قال: حلفني عند قاض آخر أو أطلق، أما إذا قال: عندك أيها القاضي، فإن حفظ القاضي ذلك، لم يحلفه ومنع المدعي ما طلبه، وإن لم يحفظه حلفه، ولا ينفعه إقامة البينة عليه في الأصح؛ لأن القاضي متى تذكر حكمه أمضاه، وإلا فلا يعتمد البينة.

(٢) إِذَا أَنْكَرَ مُدَّعَى عَلَيْهِ فَأَمَرَ بِالْحَلِفِ فَأَمْتَنَعَ وَ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينَ ،حَلَفَ الْمُدَّعِي بَعْدَ أَمْرِ الْقَاضِي لَهُ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ، إِنْ كَانَ مُدَّعِيًا عَنْ نَفْسِهِ ،لِتَحْوُلِ الْيَمِينَ إِلَيْهِ وَقُضِيَ لَهُ بِالْحَقِّ أَيِ: مُكِّنَ مِنْهُ إِذْ الَّذِي فِي الرُّوْضَةِ وَأَضْلَاهَا أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ بَعْدَ الْيَمِينَ إِلَى الْقَضَاءِ لَهُ بِهِ وَلَا يُقْضَى لِلْمُدَّعَى بِالْحَقِّ بِنُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، إِلَّا بَعْدَ حَلْفِ الْمُدَّعَى - وَصَحَّ أَنَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى طَالِبِ الْحَقِّ؛ لِأَنَّ

الْقَاضِي بِنُكُولِهِ) إِذَا لَمْ يَظْهَرْ كَوْنُ سُكُوتِهِ لِدَهْشَةٍ وَغَبَاوَةٍ وَنَحْوِهِمَا  
(وَقَوْلُهُ) أَيُّ الْقَاضِي (لِلْمُدَّعِي اخْلِفْ حُكْمَ بِنُكُولِهِ) أَيُّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي  
سُكُوتِهِ، وَفِي الرُّوضَةِ كَأَصْلِهَا نَازِلٌ مَنَزَلَةٌ الْحُكْمُ بِهِ<sup>(١)</sup>.

---

النُّكُولُ كَمَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَحَرُّرًا عَنِ الْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَوَرُّعًا عَنِ  
الْيَمِينِ الصَّادِقَةِ، فَلَا يَقْضِي مَعَ التَّرَدُّدِ وَتَرَدُّدِ الْيَمِينِ فِي كُلِّ حَقٍّ يَتَعَلَّقُ بِالْأَدْمِيِّ.  
وَالنُّكُولُ: يَحْضُلُ بِأُمُورٍ مِنْهَا أَنْ يَقُولَ بَعْدَ عَرْضِ الْيَمِينِ عَلَيْهِ: أَنَا نَاكِلٌ أَوْ يَقُولَ لَهُ  
الْقَاضِي اخْلِفْ فَيَقُولُ: لَا أَحْلِفُ، لَصِرَاحَتِهِمَا فِي الْامْتِنَاعِ، فَيُرَدُّ الْيَمِينُ وَإِنْ لَمْ يَحْكَمْ  
القَاضِي بِالنُّكُولِ.

(١) متى يحكم على المدعى عليه بالنكول: إن سكت المدعى عليه بعد عرض اليمين  
عليه لا لدهوة ونحوها حكم القاضي بنكوله كما لو السكوت عن الجواب في الابتداء  
ينزل منزلة الإنكار، ولا تشرع اليمين المردودة عند سكوت المدعى عليه، إلا إذا حكم  
الحاكم بنكوله، وإنما يحكم الحاكم بنكوله إذا لم يظهر كون السكوت لدهوة أو غباوة  
ونحوهما، وهذا بخلاف ما لو صرح بالنكول برد وإن لم يحكم القاضي. والحكم: أن  
يقول: (جعلتك ناكلاً)، أو (نكلتك) بالتشديد. ويستحب للقاضي أن يعرض اليمين على  
المدعى عليه ثلاث مرات، والاستحباب فيما إذا سكت أكثر منه فيما إذا صرح  
بالنكول. وعن أبي حنيفة: أن العرض ثلاثاً شرط، وإذا تقرس القاضي سلامة جانب  
المدعى عليه شرح له حكم النكول؛ فإن لم يشرح وحكم بأنه ناكل وقال المدعى عليه:  
لم أعرف حكم النكول: ففي نفوذ الحكم احتمالان: أظهرهما: النفوذ إذا كان من حقه  
أن يبحث ويعرف قبل أن ينكل. وإذا كان المدعى عليه لا يعرف معنى النكول، وجب  
على القاضي أن يعرفه ذلك، وليس هذا تلقين دعوى.

حكم حلف المدعى عليه بعد نكوله:

(وَالْيَمِينُ الْمَرْدُودَةُ) وَهِيَ يَمِينُ الْمُدَّعِي بَعْدَ نُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَرُدُّهَا هُوَ أَوْ الْقَاضِي (فِي قَوْلٍ: كَبَيِّنَةٍ وَفِي الْأَطْهَرِ: كإِقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَلَوْ أَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَهَا بَيِّنَةً بِأَدَاءٍ أَوْ إِبْرَاءٍ لَمْ تَسْمَعْ) عَلَى الثَّانِي؛ لِتَكْذِيبِهِ لَهَا بِإِقْرَارِهِ وَتُسْمَعُ عَلَى الْأَوَّلِ <sup>(١)</sup> (فَإِنْ لَمْ يَحْلِفِ الْمُدَّعَى وَلَمْ يَتَعَلَّلْ بِشَيْءٍ سَقَطَ حَقُّهُ مِنَ الْيَمِينِ وَلَيْسَ لَهُ مُطَالَبَةُ الْخَصْمِ) وَلَهُ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ (وَإِنْ تَعَلَّلَ بِإِقَامَةِ بَيِّنَةٍ أَوْ مُرَاجَعَةِ حِسَابِ أُمُهِلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَقِيلَ: أَبَدًا) لِأَنَّ الْيَمِينِ حَقُّهُ فَلَهُ تَأْخِيرُهُ إِلَى أَنْ يَشَاءَ كَالْبَيِّنَةِ، وَفُرِّقَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْبَيِّنَةَ قَدْ لَا تُسَاعِدُهُ وَلَا تَحْضُرُ وَالْيَمِينُ إِلَيْهِ. (وَإِنْ اسْتَمْهَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حِينَ أُسْتُخْلِفَ لِيَنْظُرَ حِسَابَهُ لَمْ يُمَهَّلْ) إِلَّا أَنْ يَرْضَى الْمُدَّعَى؛ لِأَنَّهُ مَقْهُورٌ بِطَلَبِ الْإِقْرَارِ أَوْ الْيَمِينِ بِخِلَافِ الْمُدَّعَى (وَقِيلَ) يُمَهَّلُ (ثَلَاثَةً) كَالْمُدَّعَى (وَلَوْ اسْتَمْهَلَ فِي ابْتِدَاءِ الْجَوَابِ) لِيَنْظُرَ فِي الْحِسَابِ (أُمُهِلَ إِلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأُضْلِحَهَا إِنْ شَاءَ أَيُّ الْمُدَّعَى.

(وَمَنْ طُوْلِبَ بَرْكَاتٍ فَادَّعَى دَفْعَهَا إِلَى سَاعٍ آخَرَ أَوْ غَلِطَ خَارِصٌ وَأَلْزَمَنَاهُ الْيَمِينَ) عَلَى وَجْهِ (فَنَكَلَ وَتَعَدَّرَ رُدُّ الْيَمِينِ) بِأَنْ لَمْ يَنْحَصِرِ الْمُسْتَحِقُّونَ

---

يمنع المدعى عليه من الحلف بعد نكوله أو ما في معناه، إذا لم يرض المستحق، فإن رضي فوجهان: أصحهما: له العود إليه؛ فإن الحق له لا يعدوه. وقول القاضي للمدعي: أحلف حكم بنكول المدعى عليه.

(<sup>١</sup>) اليمين المردود فيها قولان: الأول: تأخذ حكم البينة، لأن اليمين حجة في جانب المدعى عليه، ورُدت اليمين على المدعى. والقول الأطهر: أن اليمين المردودة كإقرار المدعى عليه، لأنه بنكوله توصل المدعى إلى حقه؛ فأشبهه إقرار المدعى عليه.

فِي الْبَلَدِ وَلَا رَدٌّ عَلَى السُّلْطَانِ وَالسَّاعِي (فَالْأَصَحُّ: أَنَّهَا تُؤْخَذُ مِنْهُ) لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِدَافِعٍ، وَالثَّانِي: لَا؛ إِذْ لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ حُجَّةٌ، وَإِنْ انْحَصَرَ الْمُسْتَحَقُّونَ فِي الْبَلَدِ وَمَنْعْنَا نَقْلَ الزَّكَاةِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ رُدَّتِ الْيَمِينُ عَلَيْهِمْ وَيَتَعَذَّرُ الرَّدُّ عَلَى السُّلْطَانِ وَالسَّاعِي، وَإِنْ قُلْنَا بِاسْتِحْبَابِ الْيَمِينِ وَهُوَ الْأَصَحُّ الْمُتَقَدِّمُ فِي بَابِ زَكَاةِ النَّبَاتِ لَمْ يُطَالَبْ بِشَيْءٍ<sup>(١)</sup>، (وَلَوْ ادَّعَى وَلِيُّ صَبِيٍّ دَيْنًا لَهُ) عَلَى شَخْصٍ (فَأُنْكَرَ وَنَكَلَ) عَنِ الْخَلْفِ (لَمْ يَخْلِفْ

---

(١) ومن طوّل بركة فادعى دفعها إلى ساع آخر أولم يدع دفعها، بل ادعى غلط خالص بعد التزامه القدر الواجب والزمناه اليمين فنكل وتعذر رد اليمين بأن لم ينحصر المستحقون في البلد ولا رد على السلطان والساعي، فالأصح: أنها تؤخذ منه؛ لأن مقتضى ملك النصاب ومضي الحول الوجوب، فإذا لم يأت بدافع أخذنا الزكاة، بمقتضى الأصل. والثاني: لا يطالب بشيء إذا لم يقدّم عليه حجة، فإن أحصر المستحقون، ومنع نقل الزكاة وهو الأظهر لم يتعذر رد اليمين. ومن وجبت عليه الزكاة وادعى مسقطاً لها أو اتهمه الساعي، فإنه يحلفه على ما يدعيه، وهل اليمين واجبة أو مستحبة؟ فإن كانت دعواه لا تخالف الظاهر كقوله: لم يحل الحول بعد فهي مستحبة، وإن خالفته كقوله: بعته ثم اشتريته ولم يحل الحول، فالأصح: استحبابهما أيضاً، فإن قلنا به فامتنع من اليمين فلا شيء عليه، وإن قلنا بوجوبها فنكل .. فهي مسألة الكتاب. وقوله: (وتعذر رد اليمين) أشار به إلى تفصيل، وهو أن المستحقين في البلد إن انحصروا ومنعنا النقل، ردت اليمين عليهم، وإلا فقد تعذر الرد على السلطان أو الساعي. وقوله: (فالأصح) يقابله أوجه: أحدها: لا يطالب بشيء إذا لم يقدّم حجة. والثاني: يحبس حتى يقر فيؤخذ منه أو يحلف فيترك. والثالث: إذا ادعى خلاف الظاهر بأن قال: ما تم الحول أو الذي بيدي لفلان المكاتب .. لم يؤخذ منه، وإن قال: أدبت في بلد آخر أو ساع آخر أخذت.

الْوَلِيِّ) لِأَنَّ إِبْثَاتِ الْحَقِّ لِغَيْرِ الْحَالِفِ بَعِيدٌ (وَقِيلَ: يَخْلِفُ) ؛ لِأَنَّهُ الْمُسْتَوْفِي (وَقِيلَ إِنَّ ادَّعَى مُبَاشَرَةً سَبَبِهِ خَلَفَ) وَإِلَّا فَلَا يَخْلِفُ<sup>(١)</sup>.

(فَصْلٌ) إِذَا (ادَّعَا) أَيُّ كُلِّ مِنْ اثْنَيْنِ (عَيْنًا فِي يَدِ ثَالِثٍ) أَنْكَرَهُمَا (وَأَقَامَ كُلَّ مِنْهُمَا بَيِّنَةً) بِهَا (سَقَطْنَا) فَيُصَارُ إِلَى التَّخْلِيفِ فَيَخْلِفُ لِكُلِّ مِنْهُمَا يَمِينًا، (وَفِي قَوْلٍ: تُسْتَعْمَلَانِ) فَتُنَزَّعُ الْعَيْنُ مِنْهُ، وَعَلَى هَذَا (فَفِي قَوْلٍ: تُقْسَمُ) بَيْنَهُمَا؛ أَيُّ يَكُونُ لِكُلِّ نَصْفُهَا (و) فِي (قَوْلٍ: يُقَرَّعُ بَيْنَهُمَا) فَيَأْخُذُهَا مَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ (و) فِي (قَوْلٍ: يُوقَفُ الْأَمْرُ حَتَّى يَبِينَ أَوْ

---

(١) ادعاء الولي أن لمن تحت ولايته ديناً عند آخر: في حلف الولي ثلاثة أوجه: الأول: وَلَوْ ادَّعَى وَلِيُّ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ، وَلَوْ وَصِيًّا أَوْ قَيْمًا دَيْنًا لَهُ عَلَى آخَرٍ، فَأَنْكَرَ وَنَكَلَ لَمْ يَخْلِفِ الْوَلِيُّ، لِأَنَّ إِبْثَاتِ الْحَقِّ لِلْإِنْسَانِ بِيَمِينِ غَيْرِهِ بَعِيدٌ، فَيَكْتَبُ الْقَاضِي مُحَضَرًا بِمَا جَرَى وَيُوقَفُ إِلَى بُلُوغِ الصَّبِيِّ وَإِفَاقَةِ الْمَجْنُونِ، وَقِيلَ: يَخْلِفُ لِأَنَّهُ الْمُسْتَوْفِي، وَالصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ لَيْسَ لِهَذَا أَهْلِيَّةُ الْيَمِينِ. وَقِيلَ: إِنَّ ادَّعَى مُبَاشَرَةً سَبَبِهِ أَيُّ: ثُبُوتُهُ بِمُبَاشَرَتِهِ لِسَبَبِهِ خَلَفَ؛ لِأَنَّ الْعَهْدَةَ تَتَعَلَّقُ بِهِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ؛ وَإِلَّا فَلَا يَخْلِفُ. وَتَجْرِي الْأَوْجُهَ فِيمَا لَوْ أَقَامَ شَاهِدًا هَلْ يَخْلِفُ مَعَهُ؟ وَفِيمَا لَوْ ادَّعَى عَلَى الْوَلِيِّ دَيْنًا فِي ذِمَّةِ الصَّبِيِّ هَلْ يَخْلِفُ الْوَلِيُّ إِذَا أَنْكَرَ؟ وَالْوَصِيُّ وَالْقَيْمُ كَالْوَلِيِّ، وَيجري في قِيمِ الْمَسْجِدِ وَالْوَقْفِ إِذَا نَكَلَ الْمَدْعَى عَلَيْهِ هَلْ يَخْلِفُ. وَمُلَخَّصُ هَذَا أَنَّ الْحَقَّ إِنْ كَانَ لِغَيْرِ مَعِينٍ كَالْمُسْلِمِينَ وَمَالٍ مِنْ لَا وَارِثَ لَهُ وَالْمَالِ الْمَوْصِي بِهِ لِلْفُقَرَاءِ، إِذَا ادَّعَاهُ مِنْ أَسْنَدَتْ تَفَرُّقَتُهُ إِلَيْهِ .. يَحْبِسُ الْمَدْعَى عَلَيْهِ حَتَّى يَخْلِفَ أَوْ يَدْفَعِ الْحَقَّ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْقَضَاءُ بِالنَّكُولِ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ، لِأَنَّ الْحَقَّوْقَ تَثْبُتُ بِالْإِقْرَارِ أَوْ الْبَيِّنَةِ، وَلَيْسَ النَّكُولُ وَاحِدًا مِنْهُمَا، وَلَا يُمْكِنُ رَدُّ الْيَمِينِ عَلَى مُسْتَحَقٍّ غَيْرِ مَعِينٍ، وَلَا يُمْكِنُ تَرْكُهُ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْكِ الْحَقِّ، فَتَعِينُ لِفَصْلِ الْخُصُومَةِ مَا قَلْنَاهُ. وَقِيلَ: يَقْضَى عَلَيْهِ بِالنَّكُولِ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ الْحَقُّ؛ لِلضَّرُورَةِ.



يَصْطَلِحًا) وَسَكَتَ فِي الرُّوضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ تَرْجِيحِ وَاحِدٍ مِنَ الثَّلَاثَةِ،  
(وَلَوْ كَانَتْ فِي يَدَيْهِمَا وَأَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ بَقِيَتْ) فِي يَدَيْهِمَا (كَمَا كَانَتْ) عَلَى  
قَوْلِ السُّقُوطِ، وَتُجْعَلُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَوْلِ الْقِسْمَةِ، وَلَا يَجِيءُ الْوُقُوفُ، وَفِي  
الْفُرْعَةِ وَجْهَانِ<sup>(١)</sup>، (وَلَوْ كَانَتْ بِيَدِهِ) وَحْدَهُ (فَأَقَامَ غَيْرُهُ بِهَا بَيِّنَةً وَهُوَ بَيِّنَةٌ

(١) العين المدعاة إما أن تكون في يدهما أو في يد ثالث: أولاً: إذا كانت في يد  
ثالث: إذا ادَّعَى شخصان عَيْنًا فِي يَدِ ثَالِثٍ مُنْكَرٍ لَهَا، وَأَقَامَ كُلُّ مِنْهُمَا بَيِّنَةً بِهَا  
مُطْلَقَتَيْنِ التَّارِيخِ، أَوْ مُتَقَاتِلَتَيْنِ، أَوْ إِحْدَاهُمَا مُطْلَقَةً وَالْأُخْرَى مُؤَرَّخَةً، سَقَطَتَا لِتَنَاقُصِ  
مُوجِبَتَيْهِمَا فَأَشْبَهَ الدَّلِيلَيْنِ إِذَا تَعَارَضَا وَلَا مُرَجَّحَ، فَعَلَى هَذَا كَانَ لَا بَيِّنَةَ وَيُصَارُ إِلَى  
التَّخَالُفِ فَيُخْلَفُ لِكُلِّ مِنْهُمَا يَمِينًا، فَإِنْ رَضِيََا بِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ فَلَا أَصْحَ: الْمَنْعُ كَمَا فِي  
الرُّوضَةِ خِلَافًا لِجَزْمِ الْإِمَامِ بِالْجَوَازِ، وَإِنْ رَجَحَهُ السُّبُكِيُّ وَفِي قَوْلِهِ: تُسْتَعْمَلَانِ الْبَيِّنَتَانِ  
صَيَانَةً لَهُمَا عَنِ الْإِلْغَاءِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ، فَعَلَى هَذَا تُنْزَعُ الْعَيْنُ مِمَّنْ هِيَ فِي يَدِهِ، لِاتِّفَاقِ  
الْبَيِّنَتَيْنِ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ لِوَاحِدٍ مُعَيَّنٍ، ثُمَّ مَا يُفْعَلُ بِهَا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ الْأَقْوَالِ الْآتِيَةِ:  
فَفِي قَوْلِهِ: يُقَسَمُ بَيْنَهُمَا: أَيُّ يَكُونُ لِكُلِّ نَصْفُهَا، وَفِي قَوْلِهِ: يُفْرَعُ بَيْنَهُمَا وَتُرْجَحُ مَنْ  
خَرَجَتْ فُرْعَتُهُ، وَفِي قَوْلِهِ: تُوقَفُ الْعَيْنُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَبِينَ الْأَمْرُ فِيهَا أَوْ يَصْطَلِحَا عَلَى  
شَيْءٍ؛ لِأَنَّهُ أَشْكَلُ الْحَالِ فِيمَا يُرْجَى انْكَشَافُهُ فَيُوقَفُ.

ثَانِيًا: إِذَا كَانَتْ فِي يَدَيْهِمَا: وَلَوْ كَانَتْ الْعَيْنُ الَّتِي ادَّعَاهَا الثَّانِي فِي يَدَيْهِمَا وَأَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ  
بَقِيَتْ فِي يَدَيْهِمَا كَمَا كَانَتْ أَوَّلًا تَقْرِيعًا عَلَى الصَّحِيحِ، وَهُوَ التَّسَاقُطُ، إِذْ أَنَّهُ لَيْسَ  
أَحَدُهُمَا أَوْلَى بِهَا مِنَ الْآخَرِ، وَيُجْعَلُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَوْلِ الْقِسْمَةِ، وَلَا يَجِيءُ الْوُقُوفُ إِذْ لَا  
مَعْنَى لَهُ.

ثَلَاثِيَةً: مَحَلُّ الْخِلَافِ أَنْ تَشْهَدَ كُلُّ بَيِّنَةٍ بِجَمِيعِ الْعَيْنِ. فَأَمَّا إِذَا شَهِدَ بِالنِّصْفِ الَّذِي هُوَ  
فِي يَدِ صَاحِبِهِ فَالْبَيِّنَتَانِ لَمْ يَتَوَارَدَا عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ، فَلَا تَجِيءُ أَقْوَالُ التَّعَارُضِ، فَيُخْتَلَمُ  
الْقَاضِي لِكُلِّ مِنْهُمَا بِمَا فِي يَدِهِ كَمَا كَانَ لَا بِجِهَةِ التَّسَاقُطِ وَلَا بِجِهَةِ التَّرْجِيحِ بِالْيَدِ،  
وَالَّذِي أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَوَّلًا يَخْتَارُ إِلَى إِعَادَتِهَا لِلنِّصْفِ الَّذِي بِيَدِهِ لِيَقَعَ بَعْدَ بَيِّنَةِ الْخَارِجِ، وَإِذَا

فُذِّمَ صَاحِبُ الْيَدِ) تَرْجِيحًا لِبَيِّنَتِهِ بِهَا (وَلَا تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ إِلَّا بَعْدَ بَيِّنَةِ الْمُدَّعِي)؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ إِقَامَتِهَا<sup>(١)</sup> (وَلَوْ أُزِيلَتْ يَدُهُ بِبَيِّنَةٍ ثُمَّ أَقَامَ بَيِّنَةً بِمَلِكِهِ مُسْتَنِدًّا إِلَى مَا قَبْلَ إِزَالَةِ يَدِهِ وَاعْتَدَرَ بِغَيْبَةِ شُهُودِهِ سُمِعَتْ وَقُدِّمَتْ) لِأَنَّهَا

---

لم توجد بينة تنبئ في يدهما أيضًا سواءً أخلَفَ كُلُّ مِنْهُمَا لِأَخَرٍ أَمْ نَكَلَ، وَلَوْ أُثْبِتَ أَوْ خَلَفَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ قَضَى لَهُ بِجَمِيعِهَا سَوَاءً أَشْهَدَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ.

(١) حكم وجود العين بيد شخص وادعاها آخر ولكل منهما بينة:

وَلَوْ كَانَتْ الْعَيْنُ بِيَدِهِ تَصَرُّفًا أَوْ إِمْسَاكًا فَأَقَامَ غَيْرُهُ بِمَلِكِهَا بَيِّنَةً وَ أَقَامَ هُوَ بِهَا بَيِّنَةً بَيَّنَتْ سَبَبَ مَلِكِهِ أَمْ لَا، أَوْ قَالَتْ: كُلُّ اشْتَرَاهَا أَوْ غَصَبَهَا مِنَ الْآخِرِ قُذِّمَ مَنْ غَيْرِ يَمِينِ صَاحِبِ الْيَدِ وَيُسَمَّى الدَّخِلُ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِذَلِكَ كَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ جَابِرٍ: "أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَاْعِيَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا، وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً، فَقَضَى بِهِ لِلَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ" وَلِأَنَّهُمَا اسْتَوِيَا فِي إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ، وَتَرَجَّحَتْ بَيِّنَتُهُ بِيَدِهِ فَقُدِّمَتْ؛ كَالْخَبَرَيْنِ مَعَ أَحَدِهِمَا قِيَاسًا، وَلِتَرْجَحَ بَيِّنَتُهُ وَإِنْ كَانَتْ شَاهِدًا وَيَمِينًا عَلَى الْآخَرَى وَإِنْ كَانَتْ شَاهِدَيْنِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي بِأَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْهُ أَوْ مِنْ بَائِعِهِ مَثَلًا أَوْ أَنَّ أَحَدَهُمَا غَصَبَهَا قُذِّمَ لِبُطْلَانِ الْيَدِ حِينَئِذٍ، وَلَا يَكْفِي قَوْلُهُمَا يَدُ الدَّخِلِ غَاصِبَةٌ كَمَا ذَكَرَهُ جَمْعٌ، فَإِنْ قَالَتْ: بَيِّنَتُهُ غَصَبَهَا مِنْهُ وَالثَّانِيَةُ اشْتَرَاهَا مِنْهُ قُدِّمَتْ لِأَنَّهَا تُثْبِتُ نَقْلًا صَحِيحًا، وَلَا يَشْتَرِطُ فِي سَمَاعِ بَيِّنَةِ الْيَدِ أَنْ يَبَيِّنَ سَبَبَ الْمَلِكِ؛ مِنْ شِرَاءٍ أَوْ إِرْثٍ وَنَحْوَهُمَا؛ كَبَيِّنَةِ الْخَارِجِ، وَأَنَّهُ لَا يَشْتَرِطُ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ بَيِّنَتِهِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ فِيهِمَا. وَلَا تَسْمَعُ بَيِّنَةُ الدَّخِلِ إِلَّا بَعْدَ سَمَاعِ بَيِّنَةِ الْمُدَّعِي وَهُوَ الْخَارِجِ، لِأَنَّ الْحُجَّةَ إِنَّمَا تَقَامُ عَلَى خَصْمٍ، وَلِأَنَّهُ وَقْتُ إِقَامَتِهَا وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي جَانِبِهِ الْيَمِينِ، فَلَا يَعْدَلُ عَنْهَا مَا دَامَتْ كَافِيَةً. وَقِيلَ: تَسْمَعُ بَيِّنَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَدْعِ عَلَيْهِ لَغَرَضِ التَّسْجِيلِ، قَالَ الزَّنْجَانِيُّ فِي "شَرْحِ الْوَجِيزِ": وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ فِي الْآفَاقِ، وَتَسْمَعُ بَيِّنَةُ الدَّخِلِ بَعْدَ بَيِّنَةِ الْخَارِجِ، وَإِنْ لَمْ تَعْدَلْ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لَتَعْرُضَ يَدُهُ لِلزَّوَالِ.

إِنَّمَا أُزِيلَتْ لِعَدَمِ الْحُجَّةِ وَقَدْ ظَهَرَتْ فَيُنْقَضُ الْقَضَاءُ، (وَقِيلَ: لَا) وَالْقَضَاءُ بِحَالِهِ<sup>(١)</sup>.

(وَلَوْ قَالَ الْخَارِجُ هُوَ مِلْكِي اشْتَرَيْتُهُ مِنْكَ فَقَالَ: بَلْ مِلْكِي وَأَقَامَا بَيْنَتَيْنِ) بِمَا قَالَاهُ، (قُدِّمَ الْخَارِجُ) لَزِيَادَةِ عِلْمِ بَيِّنَتِهِ بِالِانْتِقَالِ<sup>(٢)</sup>، (وَمَنْ أَقَرَّ لِغَيْرِهِ بِشَيْءٍ ثُمَّ ادَّعَاهُ لَمْ تُسْمَعْ) دَعْوَاهُ، (إِلَّا أَنْ يَذْكَرَ انْتِقَالًا) مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ مُوَآخِذٌ بِإِقْرَارِهِ وَيُسْتَصْحَبُ إِلَى الْإِنْتِقَالِ<sup>(٣)</sup> (وَمَنْ أَخَذَ مِنْهُ مَالٌ بِبَيِّنَةٍ ثُمَّ ادَّعَاهُ لَمْ

---

(١) ولو أزيلت يد الداخل عن العين التي بيده ببينة، ثم أقام بينة بملكه مستندًا إلى ما قبل إزالة يده، واعتذر بغيبة شهوده، سمعت وقدمت، لأن يده أزيلت؛ لعدم الحجة، فإذا ظهرت حكم بها. وقيل: لا تسمع، لأن تلك اليد قُضِيَ بزوالها، فلا ينقض القضاء. قال القاضي: وقد أشكلت عليَّ هذه المسألة نفيًا وعشرين سنة؛ لما فيها من نقض الاجتهاد بالاجتهاد [وتردد جوابي فيها ثم استقر على أنه لا ينقض. انتهى، والقائل بالأول يمنع كونه من باب نقض الاجتهاد بالاجتهاد] لأنه إنما قضى على تقدير ألا معارضة ولا حجة، فإذا ظهرت الحجة، حكم بها، وكأنه لما حكم استثنى هذه الحالة.

(٢) ولو قال الخارج: هو ملكي اشتريته منك، فقال: بل ملكي، وأقاما بينتين قدمت بينة الخارج؛ لزيادة علم بينته بالانتقال، ولو انعكس الحال فقال الداخل: هو ملكي اشتريته منك وأقام بينة، وأطلقت بينة الخارج للملك، قدمت بينة الداخل؛ لأنها تقدم عند الإطلاق فعند ذكر الانتقال أولى، لكن إذا كانت بينته حاضرة لا تزال يده قبل إقامتها على الصحيح. ووجه مقابله: أنه اعترف أنه كان له فيدفع إليه، فإذا ثبت ما ادَّعاه استردا، أما لو زعم أن بينته غائبة فإنه يؤمر بالتسليم في الحال، وإذا أثبت استرد.

(٣) ومن أقر لغيره بشيء ثم ادَّعاه لنفسه، لم تسمع دعواه به، إلا أن يذكر انتقال من المقر له؛ لأن المكلف مؤاخذ بإقراره في المستقبل، فيستصحب ما أقر به إلى أن

يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الْإِنْتِقَالِ فِي الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لَهُ بَيِّنَةٌ بِمَلَكِهِ فَتُرْجَحُ  
بِالْيَدِ السَّابِقَةِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَالثَّانِي: يُشْتَرَطُ كَالْإِقْرَارِ<sup>(١)</sup>.

(وَالْمَذْهَبُ أَنَّ زِيَادَةَ عَدَدِ شُهُودٍ أَحَدِهِمَا لَا تُرْجَحُ) لِكَمَالِ الْحُجَّةِ فِي  
الطَّرَفَيْنِ وَفِي قَوْلٍ مِنْ طَرِيقٍ: تُرْجَحُ؛ لِأَنَّ الْقَلْبَ إِلَى الرَّائِدِ أَمِيلٌ<sup>(٢)</sup>  
(وَكَذَا لَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا رَجُلَانِ وَلِلْآخَرِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ) لَا يُرْجَحُ  
الرَّجُلَانِ، وَفِي قَوْلٍ مِنْ طَرِيقٍ: يُرْجَحَانِ؛ لِزِيَادَةِ الْوُثُوقِ بِقَوْلِهِمَا، وَتَرْجِيحُ  
طَرِيقِ الْقَطْعِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ فِي أَصْلِ الرُّوْضَةِ (فَإِنْ كَانَ لِلْآخَرِ شَاهِدٌ  
وَيَمِينٌ رُجِحَ الشَّاهِدَانِ فِي الْأَظْهَرِ) لِأَنَّهُمَا حُجَّةٌ بِالْإِجْمَاعِ، وَفِي الشَّاهِدِ  
وَالْيَمِينِ خِلَافٌ، وَالثَّانِي: يَتَعَادَلَانِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا حُجَّةٌ كَافِيَةٌ فِي

---

يثبت الانتقال. المتلقي، فيحمل عليه؛ إذ من الممكن أن يكون المقر اشتراها بعد  
الإقرار من المقر له.

(١) من أخذ منه مال ببينة ثم ادعاه، لم يشترط ذكر الانتقال في الأصح؛ لأنه قد  
يكون له بينة بملكه فترجح اليد السابقة؛ وأنه لا خلاف أنه إذا أقام ببينة مطلقة،  
سمعت. والثاني: يشترط ذكر الانتقال؛ لأنه صار مؤاخذاً بالبينة كما لو أقر، وهذه  
من صور قوله قبل ذلك: (ولو أزيلت يده ببينة) فكان الأحسن أن يذكرها عقبها.

(٢) حكم زيادة الشهود لأحد المتنازعين: المذهب: أن زيادة عدد شهود أحدهما لا  
ترجح، بل يتعارضان؛ لما روى البيهقي عن علي أنه قال: (لا يرجح بكثرة العدد)،  
ولأن ما يتقدر بالشرع لا يختلف حكمه بالزيادة والنقصان كدية الحر، وهذا هو الجديد.  
وفي القديم قولان: أشبههما: نعم؛ لأن القلب إلى قول الأكثر أميل، وكذلك إذا كانت  
إحدهما أظهر عدالة أو فقهاً، أو معها شهادة أحد الخلفاء الأربعة.

الْمَالِ<sup>(١)</sup> (وَلَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ لِأَحَدِهِمَا بِمَلِكٍ مِنْ سَنَةٍ) إِلَى الْآنَ (وَ) بَيِّنَةٌ (لِلْآخَرِ) بِمَلِكٍ (مِنْ أَكْثَرِ) مِنْ سَنَةٍ إِلَى الْآنَ كَسَنَتَيْنِ وَالْعَيْنُ فِي يَدِ غَيْرِهِمَا، (فَالْأَظْهَرُ: تَرْجِيحُ الْأَكْثَرِ) ؛ لِأَنَّ الْأُخْرَى لَا تُعَارِضُهَا فِيهِ، وَالثَّانِي: لَا تَرْجِيحَ بِهِ؛ لِأَنَّ مَنَاطَ الشَّهَادَةِ الْمَلِكُ فِي الْحَالِ وَقَدْ اسْتَوَيَا فِيهِ<sup>(٢)</sup> ، (وَلِصَاحِبِهَا) أَيِ بَيِّنَةِ الْأَكْثَرِ عَلَى تَرْجِيحِهَا، (الْأَجْرَةُ وَالزِّيَادَةُ الْحَادِثَةُ مِنْ يَوْمِئِذٍ) أَيِ يَوْمِ مَلِكِهِ بِالشَّهَادَةِ، وَعَلَى الثَّانِي: فِيهِمَا،

---

(١) لو كان لأحدهما رجلان، وللآخر رجل وامرأتان، فلا ترجيح على المذهب؛ لقيام الحجة بكل منهما، وقيل: قولان. وإن كان للآخر شاهد ويمين، رجح الشاهدان في الأظهر، لأنها حجة مجمع عليها، ولأنها أبعد عن تهمة الكذب. والثاني: يتعادلان؛ لأن كلا منهما حجة كافية في المال. فعلى الأول: لو كان مع صاحب الشاهد واليمين يد فهل يرجح هو أو صاحب الشاهدين أو يتعادلان؟ أوجه: أصحها ثالثها.

(٢) في تعارض البينتين بسبق إحداهما على الأخرى: لو شهدت لأحدهما بملك من سنة وآخر من أكثر من سنة، فالأظهر: ترجيح الأكثر؛ لأنها انفردت بإثبات الملك في زمان لا تعارضها فيه الأخرى، فوجب وقف المتعارض، ولأن ثبوت ملك المتقدم يمنع أن يملكه المتأخر إلا عنه، ولم تتضمنه الشهادة له، فلم يحكم له بها. والثاني: يتعارضان، ورجحه ابن سريج وابن كج؛ لأن المقصود إثبات المالك في الحال، ولا تأثير للسبق؛ فإنه غير منازع فيه. وصورة المسألة: أن تكون العين في يدهما أو في يد ثالث، فإن كانت في يد متقدمة التاريخ رجح قطعاً، أو في يد متأخرة التاريخ فسيأتي، وصورها ابن الرفعة بما إذا شهدا مع ذلك بالملك في الحال، وهو مراد المصنف وغيره ممن أطلق المسألة؛ لما سيأتي في الشهادة بالملك القديم أنها لا تسمع، فضلاً عن أن ترجح.

كَالْأَصْلِ الْخِلَافُ السَّابِقُ فِي تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ أَيْ مِنَ الْقِسْمَةِ وَالْإِقْرَاعِ  
وَالْوُقُوفِ حَتَّى يُبَيَّنَ الْأَمْرُ أَوْ يَصْطَلِحَا<sup>(١)</sup>.

(وَلَوْ أُطْلِقَتْ بَيِّنَةٌ وَأُرِخَتْ بَيِّنَةٌ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُمَا سَوَاءٌ) وَقِيلَ: كَمَا فِي  
أَصْلِ الرُّوضَةِ: تُقَدَّمُ الْمُؤَرَّخَةُ؛ لِأَنَّهَا تَقْتَضِي الْمَلِكَ قَبْلَ الْحَالِ بِخِلَافِ  
الْمُطْلَقَةِ قَالَ الْأَوَّلُ: لَكِنَّهَا لَا تَنْفِيهِ، وَفِي الشَّرْحِ حِكَايَةُ طَرِيقَيْنِ طَارِدٍ  
لِلْقَوْلَيْنِ مِنَ الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ وَقَاطِعٌ بِالنِّسْبَةِ وَكَيْفَ فُرضَ فَالظَّاهِرُ  
النِّسْبَةُ انْتَهَى. (وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ لِصَاحِبِ مُتَأَخِّرَةِ التَّارِيخِ يَدٌ قَدِّمَ) عَلَى  
صَاحِبِ مُتَقَدِّمَةِ التَّارِيخِ، وَقِيلَ: الْعَكْسُ وَقِيلَ يَسَاوِيَانِ؛ لِأَنَّ لِكُلِّ جِهَةٍ  
تَرْجِيحَ ثَلَاثَةٌ أَوْجُهُ فِي الرُّوضَةِ كَأَصْلِهَا، وَلَوْ كَانَتْ الْيَدُ لِصَاحِبِ مُتَقَدِّمَةِ  
التَّارِيخِ قَدِّمَ قَطْعًا. (وَأَنَّهَا لَوْ شَهِدَتْ بِمُلْكِهِ أَمْسٍ وَلَمْ تَتَعَرَّضْ لِلْحَالِ لَمْ  
تُسْمَعْ حَتَّى يَقُولُوا وَلَمْ يَزَلْ مُلْكُهُ أَوْ لَا نَعْلَمُ مُزِيلًا لَهُ) وَفِي قَوْلٍ: تُسْمَعُ  
مِنْ غَيْرِ هَذَا الْقَوْلِ وَيَتَّبَعُ بِهَا الْمَلِكُ أَمْسٍ وَيُسْتَضَحَبُ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَطَعَ  
بِالْأَوَّلِ.

(وَتَجُوزُ الشَّهَادَةُ بِمُلْكِهِ الْآنَ اسْتِصْحَابًا لِمَا سَبَقَ مِنْ إِرْثٍ وَشِرَاءٍ  
وَعَيْرِهِمَا) وَإِنْ احْتَمَلَ زَوَالُهُ<sup>(٢)</sup> وَلَوْ صَرَّحَ فِي شَهَادَتِهِ بِاعْتِمَادِ

---

(١) ولصاحبها الأجرة والزيادة الحادثة من يومئذ يوم ملكه بالشهادة؛ لأنها نماء ملكه،  
وإن قلنا بمقابل الأظهر ففيه الخلاف السابق في تعارض البينتين. ولو أطلقت  
شهادتها عن تاريخ، وقيدت أخرى شهادتها بتاريخ، فالمذهب: أنهما سواء؛  
فيتعارضان؛ لأن المطلقة كالعامّة بالنسبة إلى الأزمان.

(٢) وقيل: تقدم المؤرخة؛ لأن معها زيادة علم، لأنها تثبت الملك من وقت معين،  
والأخرى لا تقتضي إلا الملك في الحال. لكن يستثنى: ما إذا شهدت بينة بالحق

الِاسْتِصْحَابِ فَوَجَّهَانِ، قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ: تُقْبَلُ؛ لِأَنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُ لَا مُسْتَنَدَ لَهُ سِوَاهُ، وَقَالَ الْعَزَلِيُّ: قَالَ الْأَصْحَابُ لَا تُقْبَلُ كَمَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الرِّضَاعِ عَلَى امْتِصَاصِ الثَّدْيِ وَحَرَكَةِ الحُلُقُومِ (وَلَوْ شَهِدَتْ) بَيِّنَةٌ (بِإِقْرَارِهِ) أَيِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (أَمْسٍ بِالْمَلِكِ لَهُ) أَيِ لِلْمُدَّعِي (أُسْتَدِيمِ) الْإِقْرَارُ وَإِنْ لَمْ تُصَرِّحْ الْبَيِّنَةُ بِالْمَلِكِ فِي الْحَالِ.

---

والأخرى بالإبراء، أو أطلقت إحداهما وأرخت الأخرى، فإن بينة البراءة أولى؛ لأن البراءة إنما تكون بعد الوجوب، والأصح: أنه لو كان لصاحب متأخرة التاريخ يد قدم؛ لتساقط البينتين فتبقى اليد، وهي أقوى من الشهادة على الملك ولهذا لا يزال بها اليد. والثاني: ترجيح السبق؛ لأن الترجيح من جهة البينة يقدم على الترجيح من جهة اليد. والثالث: أنهما يتساويان؛ لتعارض المعنيين. وحكى ابن الصياغ والفوراني طريقة قاطعة بالأول، وبه يتم في المسألة طريقان، ويصح عطف المسألة على التعبير ب (المذهب). واحترز بقوله: (متأخرة التاريخ) عما إذا كانت اليد لصاحبه مقدمة التاريخ، فإنها تقدم بلا خلاف، وهي تفهم من كلامه من باب أولى. والمذهب: أن البينة لو شهدت بملكه أمس ولم تتعرض للحال، لم تسمع حتى يقولوا: ولم يزل ملكه، أو لا نعلم مزيلاً له؛ لأن دعوى الملك السابق لا تسمع، فكذلك البينة عليه. والثاني: تسمع؛ لأنها أثبتت الملك له سابقاً والأصل دوامه. وتجوز الشهادة بملكه الآن استصحاباً لما سبق من إرث وشراء وغيرهما وإن كان يجوز زواله، لكن ترك ذلك اعتماداً على الاستصحاب لأجل الحاجة الداعية إليه؛ إذ لا يمكن استمرار الشاهد مع صاحبه دائماً لا يفارقه لحظة؛ لأنه متى فارقه أمكن زوال ملكه عنه فتعذر عليه الشهادة.

(وَلَوْ أَقَامَهَا بِمَلِكٍ دَابَّةٍ أَوْ شَجَرَةٍ لَمْ يَسْتَحِقَّ ثَمَرَهُ مَوْجُودَةً) عِنْدَ إِقَامَتِهَا الْمَسْبُوقَةِ بِالْمَلِكِ إِذْ يَكْفِي لِصَدَقِ النَّبِيِّ سَبْقُهُ بِلَحْظَةِ لَطِيفَةٍ (وَلَا وَلَدًا مُنْفَصِلًا وَيَسْتَحِقُّ حَمَلًا فِي الْأَصَحِّ) تَبَعًا لِلْأُمِّ، وَالثَّانِي: لَا يَسْتَحِقُّهُ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ لِعَبْدٍ مَالِكِ الْأُمِّ بِوَصِيَّةٍ.

(وَلَوْ اشْتَرَى شَيْئًا فَأَخَذَهُ مِنْهُ بِحُجَّةٍ مُطْلَقَةٍ رَجَعَ عَلَى بَائِعِهِ بِالشَّيْءِ وَقِيلَ: لَا يَرْجِعُ (إِلَّا إِذَا ادَّعَى فِي مَلِكٍ سَابِقٍ عَلَى الشِّرَاءِ) لِاحْتِمَالِ انْتِقَالِ الْمَلِكِ مِنَ الْمُشْتَرِي إِلَى الْمُدَّعِي، وَدُفِعَ بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ هَذَا الْإِحْتِمَالِ فَيَسْتَنَدُ الْمُشْهُودُ بِهِ إِلَى مَا قَبْلَ الشِّرَاءِ.

(وَلَوْ ادَّعَى مَلِكًا مُطْلَقًا فَشَهِدُوا لَهُ) بِهِ (مَعَ سَبَبِهِ لَمْ يَضُرَّ) مَا زَادُوهُ (وَإِنْ ذَكَرَ سَبَبًا وَهُمْ سَبَبًا آخَرَ ضَرَّ) ذَلِكَ لِلتَّنَاقُضِ بَيْنَ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرُوا السَّبَبَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ شَهِدُوا بِالْمَقْصُودِ وَلَا تَنَاقُضَ.

(فَصُلِّ) إِذَا (قَالَ أَجَرْتُكَ) هَذَا (النَّبِيَّتِ) شَهْرَ كَذَا (بِعَشْرَةٍ فَقَالَ: بَلْ) أَجَرْتَنِي (جَمِيعَ الدَّارِ) الْمُشْتَمَلَةِ عَلَيْهِ (بِالْعَشْرَةِ وَأَقَامَا بَيْنَتَيْنِ) بِمَا قَالَاهُ (تَعَارَضَتَا وَفِي قَوْلٍ: يَقْدَمُ الْمُسْتَأْجِرُ) لِمَا فِي بَيِّنَتِهِ مِنْ زِيَادَةِ غَيْرِ النَّبِيِّ، وَالْأَوَّلُ يَنْفِي التَّرْجِيحَ بِذَلِكَ وَيَقُولُ عَلَى قَوْلِ السُّقُوطِ: يَتَحَالَفَانِ ثُمَّ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ، أَوْ يَنْفَسِخُ عَلَى مَا سَبَقَ فِي الْبَيْعِ وَعَلَى الْمُسْتَأْجِرِ أَجْرُهُ مِثْلُ مَا



سَكَنَ فِي الْبَيْتِ أَوْ الدَّارِ وَتَجِيءُ الْقُرْعَةُ عَلَى الصَّحِيحِ عَلَى قَوْلِ  
الِاسْتِعْمَالِ دُونَ الْقِسْمَةِ وَالْوَقْفِ فَمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ عَمِلَ بِقَوْلِهِ<sup>(١)</sup>.

(وَلَوْ ادَّعَا) أَيُّ كُلِّ مِنْ اثْنَيْنِ (شَيْئًا فِي يَدِ ثَالِثٍ) أَنْكَرَهُمَا (وَأَقَامَ كُلُّ  
مِنْهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهُ اشْتَرَاهُ) مِنْهُ (وَوَزَنَ لَهُ ثَمَنَهُ فَإِنْ اخْتَلَفَ تَارِيخُ حُكْمِ  
لِلْأَسْبَقِ) تَارِيخًا<sup>(٢)</sup> (وَالَّا بِأَنْ اتَّحَدَ) التَّارِيخُ (تَعَارُضًا) فَعَلَى قَوْلِ  
السُّقُوطِ يَخْلِفُ لِكُلِّ مِنْهُمَا يَمِينًا أَنَّهُ مَا بَاعَهُ وَلَا تَعَارُضَ فِي التَّمْنَيْنِ

---

(١) إذا قال: أجرتك البيت بعشرة، فقال: بل أجرتني جميع الدار بالعشرة، وأقاما  
بينتين، تعارضتا فيتساقطان على الأصح: لتكاذبهما؛ لأن العقد واحد، وكل كيفية  
تتافي الأخرى، وعليه يتحالفان ثم يرجعان إلى فسخ العقد منهما أو أحدهما أو الحاكم.  
وفي قول: يقدم المستأجر، لاشتمال بينته على زيادة، وهي اكتراء جميع الدار؛ كما لو  
شهدت بينة بألف وبينة بألفين ثبت الألفان. وفرق الأول: بأن بينة الألف، وبينة  
الألفين لا يتنافيان؛ لأن التي شهدت بالألف لا تتافي الألفين، وههنا العقد واحد، وكل  
كيفية تتافي الكيفية الأخرى. وعلى القول بالفسخ: على المستأجر أجرة ما سكن في  
البيت أو في الدار. وعلى القول بالاستعمال: يقرع على الأصح، ولا تأتي القسمة، لأن  
التنازع هنا في العقد وهو لا يمكن أن يقسم بخلاف الملك، ولا الوقف أيضا؛ لأن  
المنافع تقوت في مدة التوقف.

(٢) إذا ادعى أكثر من شخص الشراء من ثالث ولكل منهما بينة إما أن يختلف  
التاريخ أو يتحد: أولا: إذا اختلف التاريخ: ولو ادعى شيئا في يد ثالث أنكرهما، وأقام  
كل منهما بينة، أنه اشتراه من ذلك الثالث ووزن له ثمنه، وطالب بتسليم ما اشتراه فإن  
اختلف تاريخ، كأن اشتراه أحدهما في عام والآخر في العام الذي يليه حكم للأسبق  
تاريخا، لأنه إذا باع من أحدهما، لم يتمكن من البيع من الثاني، ويطلبه الآخر  
بالتمن.

فَيُلْزَمَانِهِ، وَقِيلَ: نَعَمْ فَيُخْلَفُ عَلَيْهِمَا، وَعَلَى الْقُرْعَةِ مَنْ خَرَجَتْ لَهُ سَلَمٌ  
إِلَيْهِ الشَّيْءُ، وَاسْتَرَدَّ الْآخَرُ ثَمَنَهُ وَعَلَى الْقِسْمَةِ: لِكُلِّ مِنْهُمَا نِصْفُ الشَّيْءِ  
بِنِصْفِ الثَّمَنِ وَاسْتِرْدَادِ النِّصْفِ الْآخَرِ، وَعَلَى الْوَقْفِ يُنْتَزَعُ الشَّيْءُ  
وَالثَّمَنَانِ مِنَ الْخَصْمِ وَيُوقَفُ الْجَمِيعُ<sup>(١)</sup>.

(وَلَوْ قَالَ كُلُّ مِنْهُمَا بِعُتْكَهٖ بِكَذَا وَأَقَامَاهُمَا) أَيُّ الْبَيْنَتَيْنِ بِمَا قَالَاهُ وَطَالَبَا  
بِالثَّمَنَيْنِ (فَإِنْ اتَّحَدَ تَارِيخُهُمَا تَعَارَضَتَا) فَيُخْلَفُ عَلَى قَوْلِ السُّقُوطِ  
بِمِيزَانَيْنِ، وَلَا يُلْزَمُهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّمَنَيْنِ، وَعَلَى الْقُرْعَةِ مَنْ خَرَجَتْ لَهُ قُضِي  
لَهُ بِثَمَنِهِ وَلِلْآخَرِ تَخْلِيفُ الْخَصْمِ عَلَى ثَمَنِهِ، وَعَلَى الْقِسْمَةِ لِكُلِّ نِصْفُ  
ثَمَنِهِ وَكَأَنَّهُمَا بَاعَاهُ بِثَمَنَيْنِ مُتَّفَقَيْنِ أَوْ مُخْتَلَفَيْنِ، وَعَلَى الْوَقْفِ يُؤْخَذُ  
الْمَبِيعُ وَالثَّمَنَانِ عَلَى وَرَاقٍ مَا تَقَدَّمَ وَيُوقَفُ الْجَمِيعُ، (وَإِنْ اخْتَلَفَ)  
تَارِيخُهُمَا (لَزِمَهُ الثَّمَنَانِ) لِإِمْكَانِ الْجَمْعِ بِانْتِقَالِ الْمُدَّعِي مِنَ الْمُشْتَرِي إِلَى  
الْبَائِعِ الثَّانِي بِأَنْ يَسَعَهُ مَا بَيْنَ التَّارِيخَيْنِ. (وَكَذَا) يُلْزَمُهُ الثَّمَنَانِ (إِنْ  
أُطْلِقَتَا أَوْ) أُطْلِقَتْ (إِحْدَاهُمَا) وَأَرَحَّتْ الْآخَرَى (فِي الْأَصَحِّ) لِإِمْكَانِ  
الْجَمْعِ

---

(١) وَإِنْ اتَّحَدَ تَارِيخُهُمَا أَوْ أُطْلِقَا أَوْ أُطْلِقَ أَحَدُهُمَا تَعَارَضَتَا، فَعَلَى الصَّحِيحِ:  
يَتَسَاقُطَانِ، وَيُخْلَفُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، كَمَا لَوْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُ، وَيَرْجَعَانِ عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ؛  
لثَبُوتِهِ بِالْبَيِّنَةِ، هَذَا إِذَا لَمْ تَتَعَرَّضِ الْبَيِّنَةُ لِقَبْضِ الْمَبِيعِ، فَإِنْ فُرِضَ التَّعَرُّضُ لَهُ، فَلَا  
رَجُوعَ بِالثَّمَنِ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ قَدْ اسْتَقَرَّ بِالْقَبْضِ، وَلَيْسَ عَلَى الْبَائِعِ عَهْدَةٌ مَا يَحْدُثُ بَعْدَهُ.

وَالثَّانِي يَقُولُ بِتَعَارُضِهِمَا فَيُخْلِفُ عَلَى قَوْلِ السَّقُوطِ يَمِينِينَ وَلَا يُلْزِمُهُ شَيْءٌ مِنَ التَّمْنَيْنِ، وَعَلَى الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ مَا تَقَدَّمَ<sup>(١)</sup>.

---

(١) إذا ادعى أكثر من شخص البيع لثالث ولكل منهما بينة إما أن يختلف التاريخ أو يتحد:

أولاً: إذا اتحد التاريخ: ولو قال كل من المتداعيين لمن بيده ذلك الشيء بعته بكذا، وأقام كل منهما بينته؛ فإن اتحد تاريخهما، كأن أرختا بتاريخ واحد، تعارضتا، لامتناع كونه ملكاً في وقت واحد لهذا وحده، ولذا وحده، فعلى التساقط كأن لا بينة، ويحلف لكل منهما.

ثانياً: إذا اختلف التاريخ: وإن اختلف تاريخهما لزمه الثمنان، لجواز أن يكون اشتراه من أحدهما في التاريخ الأول ثم باعه، واشتراه من الآخر في التاريخ الثاني: نعم؛ يشترط في ذلك أن يكون الزمان متسعاً للعقد الأول، ثم الانتقال إلى البائع الثاني، ثم العقد الثاني؛ فإن لم يتسع لذلك لم يجب الثمنان. وكذا إن أطلقا أو إحداهما وأرخت الأخرى يلزمه أيضاً الثمنان في الأصح: لاحتمال أن يكونا في زمانين، وإذا أمكن الاستعمال لم يحكم بالإسقاط. والثاني: أنهما كمتحدي التاريخ؛ لأن الأصل براءة المشتري، فلا يؤاخذ إلا باليقين.